

eBook
2020

Coleção Carreiras Jurídicas

DIREITO EMPRESARIAL

Autor:
Daniel Carvalho

CP  IURIS



Organizado por CP Iuris

ISBN 978-85-5805-017-3

DIREITO EMPRESARIAL

1ª edição

Brasília

CP Iuris

2020

SOBRE O AUTOR

DANIEL PINHEIRO DE CARVALHO é Promotor de Justiça no MPDFT, aprovado em 1º lugar no 31º Concurso e Assessor Cível e de Controle de Constitucionalidade da Procuradora-Geral de Justiça do MPDFT. Anteriormente, foi assessor de Ministro do STF e Advogado da União (aprovado aos 23 anos, no mesmo ano de sua colação de grau). Ainda durante a graduação em Direito na Universidade de Brasília – UnB, obteve o 1º lugar no concurso para o cargo de Analista Judiciário do Superior Tribunal de Justiça (2008), e foi aprovado, entre outros, nos concursos para os cargos de Analista Processual do Ministério Público da União (2007) e Analista Judiciário do TJDF (2008). Coautor dos livros de questões comentadas #VouSerJuiz e #VouSerJuiz 2, da ed. CP Iuris, e do Exame da OAB – 1ª Fase, da editora Vestcon, de 2010. Autor de diversos artigos.

Capítulo 1 – Origem e Evolução Histórica do Direito Empresarial	24
1. Introdução	24
2. Origem do Direito Empresarial	24
2.1. 1ª fase – Direito Consuetudinário	25
2.1.1. Características da 1ª fase	25
2.1.2. Evolução Histórica	25
2.2. 2ª Fase – Teoria dos Atos de Comércio	26
2.2.1. Problemas da 2ª fase	26
2.2.2. Características da 2ª fase	27
2.3. 3ª Fase – Teoria da Empresa	27
2.3.1. Características da 3ª Fase	28
2.3.2. Evolução no Brasil	29
Capítulo 2 – Teoria Geral do Direito Comercial	30
1. Objeto do Direito Comercial	30
1.1. Teoria da Empresa	30
1.1.1. Perfis da empresa	31
1.1.2. Conceito de empresário	31
a) Profissionalismo	31
b) Atividade econômica	32
c) Atividade organizada.....	32
d) Produção ou circulação de bens ou serviços	32
1.1.3. Síntese dos elementos do conceito de empresa	33

1.1.4. Espécies de empresário	33
1.1.5. Impedimentos legais	34
a) Considerações gerais.....	34
b) Falido não reabilitado	35
c) Leiloeiro.....	35
d) Incapaz.....	35
e) Servidores, magistrados, membros do Ministério Público e Militares	36
1.1.6. Atividades econômicas civis	36
a) Profissional intelectual.....	36
b) Empresário rural	37
c) Cooperativas.....	37
d) Empresário individual	37
1.1.7. Prepostos do empresário	38
Capítulo 3 – Regime jurídico da livre iniciativa.....	39
1. Proteção da ordem econômica e da concorrência	39
1.1. Infração contra a ordem econômica	39
1.2. Concorrência desleal.....	40
1.3. Cláusula de não restabelecimento.....	40
1.4. Parasitismo	40
Capítulo 4 – Registro de empresa.....	42
1. Junta Comercial e Departamento de Registro Empresarial e Integração (DREI).....	44
1.1. Departamento de Registro Empresarial e Integração (DREI).....	44
1.2. Junta Comercial.....	44
1.3. Atos de registro de empresa	45

1.4. Registro das Cooperativas.....	45
1.5. Regras importantes (cobradas em provas).....	45
1.6. Processo decisório do registro de empresa	47
1.6.1. Decisão colegiada	47
1.6.2. Decisão singular	48
1.7. Inatividade da empresa	48
1.8. Empresário irregular	48
Capítulo 5 – Livros Comerciais e Balanços.....	49
1. Escrituração dos livros.....	49
1.1. Espécies de livros empresariais	49
1.2. Consequências na irregularidade da escrituração	50
1.3. Exibição judicial e eficácia probatória dos livros	50
2. Balanços anuais	50
Capítulo 6 – Estabelecimento empresarial.....	52
1. Conceito	52
2. Natureza Jurídica	52
3. Alienação de estabelecimento empresarial.....	53
4. Sucessão Empresarial.....	54
5. Cláusula de não-concorrência ou não-restabelecimento.....	55
6. Proteção ao ponto empresarial (locação empresarial).....	55
7. Proteção ao título de estabelecimento	57
8. Comércio eletrônico (internet)	57
Capítulo 7 — Nome empresarial	58
1. Conceito	58

2. Princípios do Nome Empresarial	59
3. Formação do nome empresarial	59
4. Quadro Esquemático (tipo de sociedade: Firma x Denominação)	60
5. Alteração do nome empresarial.....	61
6. Proteção ao nome empresarial.....	61
7. Nome empresarial x Marca	62
Capítulo 8 — O empresário e os direitos do consumidor	63
1. Introdução	63
2. Qualidade do produto ou do serviço	63
3. Publicidade	63
Capítulo 9 — Teoria geral do direito societário	65
1. Conceito de sociedade empresária	65
2. Personalização da sociedade empresária	65
3. Desconsideração da personalidade jurídica.....	66
3.1. Teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica.....	67
3.2. Teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica.....	68
3.2.1. Abuso subjetivo da personalidade jurídica	68
3.2.2. Abuso objetivo da personalidade jurídica	69
3.3. Efeitos da desconsideração da personalidade jurídica.....	69
3.4. Modalidades de desconsideração da personalidade jurídica	69
3.4.1. Desconsideração direta da personalidade jurídica.....	69
3.4.2. Desconsideração inversa da personalidade jurídica	69
3.4.3. Desconsideração indireta da personalidade jurídica	70
3.5. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica.....	70

4. Classificação das sociedades	71
4.1 Quanto à forma do exercício da atividade econômica	71
4.2. Quanto à responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais	72
4.3. Quanto ao regime de constituição e dissolução da sociedade	73
4.4. Quanto à composição (ou quanto às condições de alienação da participação societária)	73
4.5. Quanto à quantidade de sócios	74
4.6. Quanto à nacionalidade	74
5. Sociedade entre cônjuges	74
6. Sócio de serviço (ou sócio de indústria)	75
7. Um ou mais negócios	75
8. Sociedade irregular	75
Capítulo 10 — Constituição, transformação e dissolução das sociedades contratuais	77
1. Natureza do ato constitutivo da sociedade contratual	77
2. Requisitos do contrato social	77
3. Cláusulas contratuais	78
3.1. Cláusulas essenciais	78
3.2. Cláusulas não essenciais	79
4. Participação nos resultados	79
5. Forma do contrato social	79
6. Alteração do contrato social	80
7. Transformação do registro	80
8. Dissolução de sociedade contratual	80
8.1. Espécies de dissolução	80
8.1.1. Causas de dissolução total	81

8.1.2. Causas de dissolução parcial.....	81
8.2. Liquidação e apuração de haveres.....	82
Capítulo 11 — Sócio da sociedade contratual	83
1. Sócio remisso.....	83
2. Direitos dos sócios	83
3. Exclusão de sócio	84
Capítulo 12 — Tipos societários	85
1. Sociedade limitada.....	85
1.1. Limitação da responsabilidade dos sócios.....	85
1.2. Sociedade limitada unipessoal	85
1.3. Conselho Fiscal	85
1.4 Possibilidade de quota preferencial em sociedade limitada	86
1.5. Regência subsidiária e supletiva	86
1.6. Exclusão extrajudicial de sócio	87
1.7. Cessão de quotas.....	87
1.8. Aquisição de quotas pela própria sociedade	88
1.9. Administração da Sociedade Limitada	88
1.9.1 Designação do administrador	88
1.9.2. Responsabilidade por débitos enquadráveis como dívida ativa tributária ou não tributária	89
1.9.3. Da responsabilidade da sociedade pelos atos praticados pelo administrador.....	89
1.10. Deliberações Sociais	90
4.6. Sociedade limitada unipessoal	92
2. Sociedades contratuais menores	92

2.1. Introdução	92
2.2. Aspectos em comum da sociedade em nome coletivo e da sociedade em comandita simples.....	92
2.3. Sociedade em nome coletivo	93
2.4. Sociedade em comandita simples.....	93
2.5. Sociedade em conta de participação	93
3. Sociedade em comum	94
3.1. Prova da existência da sociedade em comum	95
3.2. Patrimônio da sociedade em comum	95
3.3. Responsabilidade dos sócios da sociedade em comum	96
4. Sociedades de grande porte	96
5. EIRELI.....	96
5.1. Natureza Jurídica da EIRELI	97
5.2. Capital “Social” da EIRELI	97
5.3. Nome empresarial da EIRELI	97
5.4. Quem pode constituir EIRELI	97
5.5. Aplicação Subsidiária das regras da sociedade limitada	98
6. Sociedade Anônima	98
6.1. Origem histórica	99
6.2. Classificação	99
6.3. Comissão de Valores Mobiliários.....	100
6.3.1. Mercado de valores mobiliários.....	100
a) Primário x Secundário	100
b) Bolsa de Valores x Mercado de balcão	100
6.4 Abertura de capital.....	101

6.5. Responsabilidade limitada do acionista.....	101
6.6. Constituição da sociedade anônima	102
6.6.1. Requisitos preliminares.....	102
6.6.2. Modalidades de Constituição	102
6.6.3. Providências complementares.....	103
6.6.4. Valores mobiliários	103
a) Ações e suas classificações	103
b) Partes Beneficiárias	105
c) Debêntures	106
d) Bônus de Subscrição	106
6.7. Órgãos societários	107
6.7.1. Assembleia-geral	107
a) Competências	107
b) Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária	108
c) Quórum de instalação	108
d) Quórum de deliberação	108
6.7.2. Conselho de administração	109
6.7.3. Diretoria	109
6.7.4. Conselho fiscal	110
6.8. Deveres dos administradores.....	110
6.8.1. Dever de diligência.....	110
6.8.2. Dever de lealdade	110
6.8.3. Dever de informação.....	111
6.9. Responsabilidade dos administradores	112

6.10. Acionista controlador	114
6.11. Acionista minoritário	116
6.12. Acordo de acionistas.....	116
6.13. Controle	117
6.14. Governança corporativa.....	118
6.15. Capital social da sociedade anônima	119
6.16. Acionista	120
6.17. Demonstrações financeiras	120
6.18. Lucros, reservas e dividendos	121
6.19. Dissolução e liquidação.....	121
6.19.1. Dissolução de pleno direito	121
6.19.2. Dissolução judicial.....	121
6.20. Transformação, incorporação, fusão e cisão	122
6.21. Grupos de sociedade e consórcio	122
6.22. Operações Societárias.....	123
6.22.1. Transformação	123
6.22.2. Incorporação.....	123
6.22.3. Fusão	124
6.22.4. Cisão.....	124
6.23. Sociedade de economia mista	125
7. Sociedade em comandita por ações	125
Capítulo 13 — Propriedade Industrial.....	126
1. Propriedade Intelectual.....	126
2. Diferenças entre o direito industrial e o direito autoral	126

3. Previsão Constitucional	126
4. Legislação específica	126
5. Objetos de proteção.....	127
6. Patentes	127
6.1. Requisitos de patenteabilidade	128
6.1.1. Novidade	128
6.1.2. Atividade inventiva	128
6.1.3. Aplicação industrial.....	129
6.1.4. Licitude.....	129
6.2. Titularidade da patente	130
6.3. Prazo de proteção das patentes de invenção e de modelo de utilidade	131
6.4. Licença da patente.....	132
6.4.1. Licença voluntária	132
6.4.2. Licença compulsória	132
7. Registros.....	133
7.1. Desenho industrial (design).....	133
7.1.1. Requisitos do desenho industrial	133
a) Novidade	133
b) Originalidade	134
c) Aplicação industrial	134
d) Licitude	134
7.1.2. Prazo de proteção do Desenho Industrial.....	134
7.2. Marca	135
7.2.1. Distintividade da marca.....	135

7.2.2. Espécies de marca	135
7.2.3. Âmbito de proteção da marca	136
a) Marca de alto renome.....	137
b) Marca notoriamente conhecida	137
7.2.4. Prazo de proteção do registro de marca.....	138
7.2.5. Requisitos para o registro da marca	138
7.2.6. Marca evocativa (marca fraca ou marca sugestiva)	139
7.2.7. Domínio eletrônico e marca	140
8. União de Paris.....	140
8.1. Indicações geográficas	140
8.1.2. Indicação de procedência	140
8.1.3. Denominação de origem	140
Capítulo 14 — Direito cambiário	142
1. Desenvolvimento histórico (fases do Direito Cambiário)	142
1.1. Período Italiano.....	142
1.2. Período francês	142
1.3. Período alemão	143
1.4. Período Uniforme	143
2. Conceito de título de crédito	143
3. Princípios gerais do Direito Cambiário	143
4. Classificação dos títulos de crédito	144
4.1. Quanto ao modelo.....	144
4.2. Quanto à estrutura	144
4.3. Quanto às hipóteses de emissão	145

4.4. Quanto à circulação	145
5. Endosso	146
5.1. Endosso.....	147
5.1.1. Endosso em branco/geral	148
5.1.2. Endosso em preto/especial	148
5.1.3. Endosso translativo/próprio	148
5.1.4. Endosso impróprio	148
a) Endosso-mandato/procuração	149
b) Endosso-caução/penhor/pignoratício.....	149
c) Endosso-fiduciário.....	149
d) Endosso póstumo/tardio.....	150
6. Aval	150
6.1. Aval em branco e em preto	151
6.2. Avais simultâneos x avais sucessivos	151
6.3. Aval x fiança	151
6.4. Necessidade de outorga conjugal	152
7. Exigibilidade do crédito cambiário	152
8. Protesto.....	153
9. Letra de Câmbio	154
9.1. Saque	154
9.2. Aceite.....	154
9.3 Vencimento e Pagamento.....	155
9.4. Ação cambial.....	156
10. Nota promissória.....	156

11. Cheque	156
11.1. Considerações gerais	156
11.2. Modalidades de cheque	157
11.3. Requisitos legais	157
11.4. Endosso no cheque	158
11.5. Aval no cheque	158
11.6. Prazos para pagamento/cobrança do cheque	158
11.7. Sustação do cheque	159
11.8. Papel de curso não forçado	160
11.9. Cheque sem fundos	160
11.9. Juros e correção monetária	160
12. Duplicata	161
12.1. Conceito	161
12.2. Requisitos da duplicata	161
12.3. Aceite na duplicata	162
12.4. Protesto da duplicata	162
12.5. Duplicata virtual (duplicata eletrônica ou sob forma escritural)	163
12.6. Prazos para cobrança da duplicata	164
12.7. Duplicatas de prestação de serviços	164
12.8. Duplicata por conta de serviços	164
13. Títulos de créditos impróprios	165
13.1. Título de legitimação	165
13.2. Título representativo	165
13.3. Títulos de financiamento	166

13.4. Títulos de investimentos	166
Capítulo 15 — Direito falimentar e recuperacional	167
1. Principais inovações da Lei nº 11.101/2005:.....	167
2. Incidência subjetiva da Lei nº 11.101/2005	167
3. Foro competente	169
4. Participação do MP	169
5. Aplicação subsidiária do CPC	170
6. Cabimento de agravo de instrumento nos procedimentos falimentares e recuperacionais	170
7. Administrador judicial	171
8. Recuperação Judicial	171
8.1. Introdução e diferenças entre a recuperação e a concordata	171
8.2. Requisitos para que o devedor possa pedir recuperação	172
8.3. Processo de recuperação judicial.....	173
8.3.1. Fase postulatória	173
8.3.2. Fase de deliberação (plano de recuperação)	175
a) Requisitos do plano de recuperação judicial	175
b) Meios de recuperação judicial	175
c) Análise e deliberação sobre o plano.....	176
d) <i>Cram down</i>	177
e) Soberania da AGC e controle exercido pelo magistrado.....	178
8.3.3. Fase de execução	179
a) Aprovação do plano e retirada do nome da devedora dos cadastros de inadimplentes ..	179
b) Novação <i>sui generis</i> e Súmula 581 do STJ	179
c) Dispensa de garantias.....	180

d) Prazo de duração da recuperação judicial	180
8.4. Créditos sujeitos à recuperação judicial e <i>Stay period</i>	180
8.4.1. Créditos sujeitos à recuperação judicial	180
8.4.2. <i>Stay period</i>	181
8.5. Habilitação dos créditos, divergências e impugnações	182
8.6. Cessão fiduciária de créditos	184
8.7. Sócio solidário	184
8.8. Órgãos da recuperação judicial	185
8.8.1. Assembleia-geral	185
a) Convocação da assembleia	185
b) Competências da assembleia	185
8.8.2. Comitê de credores	186
a) Competências do comitê	186
8.8.3. Administrador judicial	186
a) Funções do administrador	186
8.9. Certidões Negativas de Débitos Tributários	187
8.10. Recuperação judicial especial para ME/EPP	188
8.11. Convolução em falência	188
9. Falência	189
9.1. Introdução	189
9.2. Etapas do processo falimentar	189
9.3. Juízo da falência	190
9.4. Legitimados a pedir falência.....	190
9.5. Fundamentos do pedido de falência (insolvência jurídica)	191

9.5.1. Impontualidade injustificada	191
9.5.2. Execução frustrada.....	192
9.5.3. Prática de atos de falência.....	193
9.6. Defesas do Devedor.....	193
9.7. Sentença declaratória da falência.....	194
9.7. Suspensão das execuções individuais	194
9.8. Termo legal da falência	195
9.9. Recurso contra decisão de falência.....	195
9.10. Requerimento doloso ou culposo do pedido de falência	195
9.11. Presidente da falência.....	196
9.12. Órgãos da falência	196
9.12.1. Administrador judicial	196
9.12.2. Assembleia de credores na falência	197
9.12.3. Comitê de credores	197
9.13. Pessoa e bens do falido.....	197
9.13.1. Restrições pessoais	197
9.13.2. Continuação provisória da empresa do falido.....	198
9.14. Atos ineficazes.....	198
9.14.1. Atos ineficazes em sentido estrito	198
9.14.2. Atos revogáveis.....	199
9.14.3. Declaração judicial da ineficácia	200
9.15. Regime jurídico dos contratos do falido.....	200
9.16. Regime jurídico dos credores do falido	201
9.16.1. Direitos do credor no processo falimentar	201

9.16.2. Efeitos da falência quanto aos credores	201
a) Massa falida subjetiva	201
b) Suspensão das ações individuais contra o falido	201
c) Vencimento antecipado das dívidas	202
d) Suspensão da fluência dos juros	202
9.17. Habilitação dos créditos, divergências e impugnações	202
9.18. Arrecadação dos bens	202
9.19. Realização do ativo	203
9.20. Pedido de restituição, embargos de terceiro e patrimônio separado	204
9.20.1. Pedido de restituição	204
9.20.2. Embargos de terceiro	205
9.20.3. Patrimônio separado	205
9.21. Princípio <i>par conditio creditorum</i>	205
9.22. Classificação dos créditos	205
9.23.1. Créditos pagáveis com a disponibilidade de caixa	205
9.23.2. Créditos extraconcursais	206
9.23.3. Créditos concursais	206
a) Crédito por acidente de trabalho e crédito trabalhista	207
b) Crédito com garantia real	208
c) Créditos tributários	208
d) Créditos com privilégio especial	208
e) Créditos com privilégio geral	208
f) Créditos quirografários	209
g) Multas	209

h) Créditos subordinados	209
9.23. Encerramento.....	209
9.23. Reabilitação do falido	209
10. Recuperação extrajudicial	210
10.1. Requisitos para homologação do plano de recuperação extrajudicial	210
10.1.1. Requisitos subjetivos.....	210
10.1.2. Requisitos objetivos	210
10.1.3. Homologação do plano.....	211
10.2. Os credores na recuperação extrajudicial	211
11. Liquidação extrajudicial de instituições financeiras	211
11.1. Introdução.....	211
11.2. Reorganização da instituição financeira.....	212
11.2.1. Intervenção.....	212
11.2.2. Regime de administração especial temporária (RAET)	213
Capítulo 16 — Contratos empresariais	214
1. Introdução.....	214
2. Princípios dos contratos empresariais.....	215
3. Teoria da aparência.....	216
4. Teoria da imprevisão (cláusula <i>rebus sic stantibus</i>) e <i>pacta sunt servanda</i>	216
5. <i>Exceptio non adimpleti contractus</i> e <i>pacta sunt servanda</i>	217
6. Compra e venda mercantil	217
6.1. Contrato de partida	218
6.2. Contrato de transporte principal não pago	218
6.3. Contrato de transporte principal pago.....	219

6.4. Contrato de chegada	220
7. Contratos de colaboração.....	221
7.1. Espécies de colaboração empresarial	221
7.2. Contrato de comissão mercantil.....	221
7.3. Contrato de representação comercial.....	222
7.4. Contrato de concessão mercantil	225
7.5. Franquias	225
7.6. Contrato de distribuição	229
7.6.1 Contrato de distribuição por aproximação	229
7.6.2 Contrato de distribuição por intermediação.....	230
Capítulo 17 — Contratos bancários	231
1. Introdução.....	231
2. Requisitos dos contratos bancários.....	231
3. Atividades bancárias	231
3.1. Operações passivas	231
3.1.1. Contrato de depósito bancário	232
3.1.2. Contrato de conta corrente	232
3.1.3. Contrato de aplicação financeira	232
3.2. Operações ativas	233
3.2.1. Contrato de mútuo bancário	233
3.2.2. Contrato de desconto bancário.....	234
3.2.3. Contrato de abertura de crédito	234
3.2.4. Contrato de crédito documentário.....	234
4. Contratos bancários impróprios.....	235

4.1. Alienação fiduciária em garantia	235
4.2. Faturização (<i>Factoring</i>)	236
4.3. Arrendamento mercantil	237
Capítulo 18 — Contratos intelectuais	239
1. Introdução	239
2. Cessão de direito industrial	239
2.1. Cessão da patente	239
2.2. Cessão do registro industrial	239
3. Licença de uso de direito industrial	239
3.1. <i>Merchandising</i>	240
4. Transferência de tecnologia	240
5. Comercialização de <i>software</i>	240
Capítulo 19 — Contratos de seguro	242
1. Conceito	242
2. Sistema Nacional de Seguros Privados	242
3. Natureza do contrato de seguro	242
4. Obrigação das partes	243
5. Espécies de seguro	243
5.1. Seguro de dano	243
5.2. Seguro de pessoas	243
5.3. Seguro-saúde	244
6. Capitalização	244
Referências Bibliográficas	245

CAPÍTULO 1 – ORIGEM E EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DIREITO EMPRESARIAL

1. Introdução

No estudo do Direito Empresarial, faz-se necessário o aprendizado da parte histórica em razão da incidência de tal matéria nas provas de concurso público. Mostra-se, ainda, fundamental abordar a origem histórica do Direito Empresarial e como ele evoluiu ao longo do tempo, a fim de se entender o que aconteceu com o Direito Empresarial brasileiro no ano de 2002, quando foi editado o Código Civil.

2. Origem do Direito Empresarial

É consenso, na doutrina, que o Direito Empresarial, ou Direito Comercial, como era chamado antes, surgiu depois da aparição do fenômeno que ele regula, ou seja, a atividade econômica. A atividade mercantil (comércio), em especial, existe há muito mais tempo do que o Direito Comercial, e durante séculos as regras que disciplinavam a atividade econômica faziam parte do direito comum (Direito Civil), isto é, não havia distinção entre Direito Civil e Direito Empresarial (Comercial), tudo fazia parte do direito comum/privado.

A partir de determinado momento é que houve uma divisão, passando-se a existir dois regimes jurídicos para a disciplina das atividades privadas: o regime jurídico civil e o regime jurídico comercial.

O comércio existe desde a Idade Antiga, mas nesse período histórico ainda não se pode falar na existência de um Direito Comercial, entendido esse como um conjunto orgânico e minimamente sistematizado, com regras e princípios próprios, para a ordenação da atividade econômica.

Embora existisse desde o início da civilização a atividade econômica exercida por meio da troca de bens, as normas jurídicas reguladoras dessa atividade eram esparsas e difusas. Sempre houve comércio e pessoas que o praticavam em caráter profissional, porém, na Antiguidade, inexistiu um corpo específico e orgânico de normas relativas ao comércio (BARRETO FILHO, 1973) capazes de constituir um efetivo ramo autônomo do Direito.

Nas palavras de André Santa Cruz:

Normas particulares à matéria comercial sempre existiram e os eruditos as assinalam desde o Código de Hamurabi. Mas um sistema de Direito Comercial, ou seja, uma série de normas coordenadas a partir de princípios comuns, só começa a aparecer com a civilização comunal italiana, tão excepcionalmente rica de inspirações e impulsos de toda ordem. (CRUZ, 2019)

A origem do Direito Comercial (hoje Direito Empresarial) está intrinsecamente relacionada às mudanças econômicas, sociais, políticas e culturais vivenciadas no início do período de transição da baixa Idade Média para a Idade Moderna (séculos XII a XVI), o período do Renascimento, com destaque para a gradativa substituição do feudalismo por uma economia pré-capitalista, para a ascensão social da burguesia e para o deslocamento da sociedade do campo para a cidade.

No período de decadência do regime feudal começam a ressurgir, por assim dizer, as cidades, os burgos, na periferia dos feudos. As feiras medievais fazem com que o comércio também renasça (há o período do renascimento mercantil), e, com isso, uma classe social importante se organiza e se desenvolve: a burguesia mercadora, os comerciantes burgueses, que eram aqueles que habitavam os burgos e se dedicavam a uma atividade econômica.



2.1. 1ª fase – Direito Consuetudinário

Esse ainda é um período de descentralização política, isto é, cada feudo tinha suas leis, ordálias e leis consuetudinárias. A construção dos estados nacionais modernos é um fenômeno posterior.

Com isso, os comerciantes (os mercadores, aqueles que se dedicavam à atividade econômica) puderam se organizar em associações privadas (famosas corporações de ofício), criando as próprias regras que regulariam as atividades que exerciam. Assim nasceu o Direito Comercial.

As corporações criavam suas próprias regras e seus próprios institutos com base nas práticas usuais do mercado e compilavam tais regras e institutos em seus estatutos (Direito Estatutário – por isso, essa época é conhecida como “época do Direito Estatutário italiano”), aplicando-os aos seus respectivos membros, quando necessário, por meio de uma jurisdição própria (juízos ou tribunais consulares).

Não havia participação do Estado nem na produção nem na aplicação desse Direito, porque as regras eram os usos e costumes de cada localidade, além de serem aplicadas por juízos ou tribunais consulares, praticamente juízos arbitrais, pessoas escolhidas pelos próprios comerciantes, como cônsules e árbitros.

Ausente um poder central forte destinado a assegurar a paz pública e a ordem jurídica, aqueles que exerciam o mesmo ofício se reuniam em associações ou corporações como forma de prover a defesa de seus interesses. Como nos traz Mello Franco, o regulamento básico dessas corporações estava consubstanciado em estatutos, nos quais foram transcritos e fixados os costumes decorrentes da prática mercantil.

2.1.1. Características da 1ª fase

- Idade Média: descentralização política;
- Burgos e renascimento do comércio;
- Usos e costumes mercantis;
- Corporações de Ofício;
- Subjetivismo – o Direito Comercial era o direito produzido e aplicado por uma classe, e o que determinava a aplicação dessas regras era o sujeito da relação jurídica. Se aquela relação jurídica era travada entre membros das corporações de ofício, isso iria atrair aquela legislação específica, bem como a competência dos respectivos tribunais;
- Autonomia: características e institutos típicos – somente nesse ponto é possível identificar a existência de um Direito Comercial, pois, até então, as regras eram esparsas, não compunham um sistema normativo próprio;
- Doutrina empresarialista – famoso *Tractatus de Mercatura*, de Benvenuto Stracha, publicado em 1553, os primeiros manuais práticos que auxiliavam os comerciantes no exercício de suas atividades.

2.1.2. Evolução Histórica

Depois desse período, o Direito Comercial evolui e entra na era das codificações. É assim que o Direito Comercial atinge sua “maioridade”, separando-se claramente do Direito Civil, ao ponto de cada um ter seu próprio diploma legislativo.

Nessa mesma época, destaca-se a formulação da Teoria dos Atos de Comércio, formulada para delimitar a abrangência dessas regras especiais que compõem o Direito Comercial.

Após o seu período inaugural de afirmação como um direito específico, ou como um regime jurídico autônomo, distinto e separado do direito comum, o Direito Empresarial iniciou



um intenso processo evolutivo, adotando, ao longo dele, basicamente dois sistemas para a disciplina da atividade econômica: o francês, conhecido como Teoria dos Atos de Comércio – em sua segunda fase, já no período das codificações; e o italiano, conhecido como Teoria da Empresa – em sua terceira fase, que se inicia com a edição do Código Civil italiano de 1942.

2.2. 2ª Fase – Teoria dos Atos de Comércio

O marco histórico que inaugura a 2ª fase evolutiva do Direito Comercial é a Codificação Napoleônica.

Conforme Fábio Ulhoa:

No início do século XIX, na França, Napoleão, com a ambição de regular a totalidade das relações sociais, patrocina a edição de dois monumentais diplomas jurídicos: o Código Civil (1804) e o Comercial (1808). Inaugura-se, então, um sistema para disciplinar as atividades dos cidadãos, que repercutirá em todos os países de tradição romana, inclusive no Brasil. De acordo com esse sistema, classificam-se as relações que hoje em dia são chamadas de direito privado em civis e comerciais. Para cada regime, estabelecem-se regras diferentes sobre contratos, obrigações, prescrição, prerrogativas, prova judiciária e foros. A delimitação do campo de incidência do Código Comercial é feita, no sistema francês, pela Teoria dos Atos de Comércio. (COELHO, 2003)

Em virtude da **Teoria dos Atos de Comércio**, nessa segunda fase do Direito Comercial, podemos perceber uma importante mudança quanto à mercantilidade, que antes era definida pela qualidade dos sujeitos da relação jurídica (o Direito Comercial era o direito aplicável aos membros das Corporações de Ofício), e passa a ser definida pelo seu objeto (os atos de comércio). Em outras palavras, o que importa agora não é quem são os atores da relação jurídica, mas qual é o objeto dessa relação. Se o objeto é um ato de comércio, assim definido em lei, essa relação jurídica é uma relação comercial, e, portanto, será regida pelas regras do Direito Comercial, que estão em um código próprio de normas: o Código Comercial.

É uma importante mudança que surge no Direito Comercial. A mercantilidade deixa de ser definida pelo sujeito e passa a ser definida pelo objeto. Por essa razão, afirma-se que nessa época houve uma objetificação do Direito Comercial:

Com a codificação francesa de princípios do século XIX, o Direito Comercial abandonava o sistema subjectivo – segundo o qual este direito se aplicava apenas a quem estivesse inscrito como comerciante no correspondente registro –, adaptando o sistema objectivo: o Direito Comercial aplica-se a todos os actos de comércio, praticados por quem quer que seja, ainda que ocasionalmente; ao passo que a prática habitual de actos de comércio e a conseqüente aquisição da qualidade de comerciante seria pressuposto para a aplicação de normas específicas, como as relativas à obrigação de manter escrituração mercantil e as relativas à falência. (GALGANO, 1990)

Alguns países optaram por dar uma definição genérica de atos de comércio, ou seja, todas as relações jurídicas que se enquadrassem naquela definição seriam consideradas atos de comércio. Outros ordenamentos jurídicos, como o Brasil, por exemplo, optaram por estabelecer um rol de atividades que eram consideradas atos de comércio (Regulamento 737, de 1950).

2.2.1. Problemas da 2ª fase

A Teoria dos Atos de Comércio restringia muito a abrangência do regime jurídico comercial, porque por mais abrangente que fosse a definição de atos de comércio adotada, por



mais extensa que fosse a lista de atos de comércio criada, algumas atividades acabavam ficando de fora, gerando uma disciplina anti-isonômica do mercado, uma vez que alguns agentes econômicos seriam caracterizados comerciantes, e, portanto se sujeitariam a todas as regras do regime jurídico comercial, enquanto outros agentes econômicos, que praticavam atividades que não se enquadravam no conceito de atos de comércio, ou não estavam na lista de atos de comércio, não seriam considerados comerciantes, e, portanto, ficariam fora desse regime jurídico.

Exemplos da situação acima descrita: (a) a prestação de serviços inicialmente não era caracterizada como ato de comércio; (b) a negociação de bens imóveis não era considerada mercantil, só era considerada mercantil a negociação de bens móveis e semoventes; (c) as atividades rurais historicamente foram excluídas dos atos de comércio; (d) os atos mistos às vezes eram atos de comércio para uma das partes e não eram para a outra.

Havia, portanto, necessidade de se estabelecer outro critério, uma nova teoria, que desse abrangência ao Direito Comercial, que englobasse todas as atividades econômicas, e não apenas aquelas atividades comerciais, mercantis, porque, com o passar do tempo e a complexidade da economia, percebeu-se que o comércio propriamente dito deixou de ser a atividade mais importante, ou a única atividade econômica relevante.

2.2.2. Características da 2ª fase

- Formação dos Estados Nacionais – monopólio da jurisdição por parte do Estado, tribunais e juízes consulares perdem força, as corporações de ofício vão perdendo gradativamente o poder político;
- Monopólio estatal da jurisdição;
- Codificações legais – o Direito Comercial deixa de ser um direito consuetudinário, passa a ser um direito posto e aplicado pelo Estado, por meio das grandes legislações;
- Desenvolvimento da Teoria dos Atos de Comércio como critério delimitador da abrangência do Direito Comercial;
- Objetivação do Direito Empresarial – o que importa é o objeto da relação jurídica, e não o seu sujeito.

2.3. 3ª Fase – Teoria da Empresa

A noção do Direito Comercial fundada exclusiva ou preponderantemente na figura dos atos de comércio, com o passar do tempo, mostrou-se totalmente ultrapassada, já que a efervescência do mercado, sobretudo após a Revolução Industrial, acarretou o surgimento de diversas atividades econômicas relevantes, e muitas delas não estavam compreendidas no conceito de ato de comércio ou de mercancia.

Em 1942, ou seja, mais de um século após a edição da codificação napoleônica, a Itália editou um novo Código Civil, trazendo, enfim, um novo sistema delimitador da incidência do regime jurídico comercial: **a Teoria da Empresa**.

Embora o Código Civil italiano de 1942 tenha adotado a chamada Teoria da Empresa, não definiu o conceito jurídico de empresa, que acabou sendo uma tarefa atribuída à doutrina. Na formulação desse conceito, merece destaque a contribuição doutrinária de Alberto Asquini, jurista italiano que analisou a empresa como um fenômeno jurídico *poliédrico* (cobrado em diversos concursos como “teoria poliédrica da empresa” ou “teoria dos perfis da empresa”), que apresentava variados perfis, assim explanados por Santa Cruz:

- a) o perfil subjetivo, pelo qual a empresa seria uma pessoa (física ou jurídica), ou seja, o empresário;



- b) o perfil funcional, pelo qual a empresa seria uma “particular força em movimento que é a atividade empresarial dirigida a um determinado escopo produtivo”, ou seja, uma atividade econômica organizada;
- c) o perfil objetivo (ou patrimonial), pelo qual a empresa seria um conjunto de bens afetados ao exercício da atividade econômica desempenhada, ou seja, o estabelecimento empresarial; e
- d) o perfil corporativo, pelo qual a empresa seria uma comunidade laboral, uma instituição que reúne o empresário e seus auxiliares ou colaboradores, ou seja, “um núcleo social organizado em função de um fim econômico comum”. (CRUZ, 2019).

Santa Cruz afirma que o perfil corporativo estaria ultrapassado “pois só se sustentava a partir da ideologia fascista que predominava na Itália quando da edição do Código Civil de 1942” (CRUZ, 2019). Mas já caiu em prova a afirmação de Bugarelli no sentido de que o aspecto corporativo, no Brasil, se submete ao regramento da legislação trabalhista.

De qualquer modo, é possível constatar que os demais perfis guardam correlação com importantes focos de estudo do direito empresarial: o empresário (perfil subjetivo); o estabelecimento (perfil objetivo); e a atividade empresarial (perfil funcional).

O Código Civil italiano também promoveu uma *unificação formal* do direito privado, disciplinando as relações civis e comerciais em um único diploma legislativo. Essa unificação foi meramente formal, porque a partir de agora tudo estava em um único diploma legislativo, mas materialmente/substancialmente, Direito Civil e Direito Comercial continuaram a ser ramos distintos.

O nosso atual Código Civil se inspira fortemente na codificação italiana.

Como destaca Fábio Ulhoa:

O mais importante, todavia, com a edição do Código Civil italiano e a formulação da Teoria da Empresa, é que o Direito Comercial deixou de ser, como tradicionalmente o foi, um direito do comerciante (período subjetivo das corporações de ofício) ou dos atos de comércio (período objetivo da codificação napoleônica), para ser o direito da empresa, isto é, “para alcançar limites muito mais largos, acomodando-se à plasticidade da economia política”. (SOUZA, 1959).

Isso porque o conceito de empresa, como atividade econômica organizada, é muito mais abrangente do que o conceito de ato de comércio, que está preso à atividade mercantil de troca, o comércio propriamente dito. Por outro lado, a empresa é toda e qualquer atividade econômica, comércio, prestação de serviço, indústria, etc.

É em torno da *atividade econômica organizada*, ou seja, da *empresa*, que gravitarão todos os demais conceitos fundamentais do Direito Empresarial, sobretudo os conceitos de empresário (aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada, isto é, exerce empresa) e de estabelecimento empresarial (complexo de bens usado para o exercício de uma atividade econômica organizada, isto é, para o exercício de uma empresa). (CRUZ, 2019)

Então, a partir do Código Civil Italiano, o conceito de *empresa* é que passa a orientar todo o regime jurídico empresarial. Por isso que o nome mudou de Direito Comercial para Direito Empresarial, porque se abandona a Teoria dos Atos de Comércio e se passa para a Teoria da Empresa.

2.3.1. Características da 3ª Fase

- Revolução Industrial – o mercado ganha uma complexidade tal que o comércio deixa de ser a atividade econômica mais relevante para ser apenas mais uma das atividades econômicas praticadas no mercado;



- Código Civil italiano de 1942 – rompe-se com a tradição das codificações de separar o direito privado em diplomas legislativos;
- Unificação do Direito Privado – não significa que o Direito Empresarial perdeu sua autonomia. Materialmente, Direito Civil e Direito Empresarial continuam sendo direitos distintos e autônomos, mas as regras nucleares estão no mesmo diploma legislativo, no Código Civil.
- Teoria da Empresa – Substituição da Teoria dos Atos de Comércio.

2.3.2. Evolução no Brasil

Antes da chegada da família real ao Brasil, as leis que vigoravam aqui eram as leis de Portugal, as Ordenações do Reino (antes tivemos as Ordenações Manuelinas, Afonsinas, Filipinas).

Com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, dão-se os primeiros passos para o advento de um Direito Comercial propriamente brasileiro, porque começa a existir um amplo movimento reivindicatório da criação de leis nacionais, que viria a culminar na edição do Código Comercial de 1850.

O Código Comercial brasileiro, inspirando-se no Código Comercial Napoleônico, adota a Teoria dos Atos de Comércio. O Brasil opta por estabelecer um rol de atividades caracterizadas como atos de comércio.

Os mesmos problemas apontados para a Teoria de Atos de Comércio no mundo aconteciam também no Brasil, o que perdurou até há pouco tempo, porque nossa transição da Teoria dos Atos de Comércio para a Teoria da Empresa apenas se deu em 2002, com o atual Código Civil.

Mas a partir da edição do Código Civil Italiano de 1942 e da importação para o Brasil das ideias da Teoria da Empresa, o cenário já havia começado a mudar. Nas décadas de 50 e 60, a doutrina brasileira começa a falar da Teoria da Empresa e a abordar com mais ênfase as vicissitudes da Teoria dos Atos de Comércio. Ademais, prolatam-se decisões judiciais inspiradas na Teoria da Empresa e há a edição de leis inspiradas na Teoria da Empresa (por exemplo, o conceito de fornecedor no Código de Defesa do Consumidor, muito mais abrangente que no Código Comercial). Esse movimento culmina, por fim, com a edição do Código Civil de 2002, que completa a transição da Teoria dos Atos de Comércio para a Teoria da Empresa no ordenamento jurídico brasileiro.

O CC de 2002 adota, então, a Teoria da Empresa, abandona a Teoria dos Atos de Comércio e tenta a unificação formal do direito privado (sob um código apenas, embora preservando a autonomia das disciplinas). Como o Brasil demorou muito para fazer essa transição, quando o CC de 2002 foi editado, vivia-se a era dos microssistemas legislativos, e essa ideia de codificação é oitocentista, presunçosa de que seria possível esgotar o tratamento legislativo de uma matéria em um único diploma legislativo. A ideia atual é oposta, dada a complexidade do mercado e da relação econômica e social. A unificação seria ruim, inclusive, porque engessaria esse ramo do direito.

Embora o CC de 2002 tenha trazido essa intenção de unificação formal do direito privado, acaba cuidando muito pouco do Direito Empresarial, pois existem diversas leis específicas que tratam da matéria.

Há alguns anos, tramita no Congresso Nacional, projeto de Código Comercial que tenta revogar a parte do Código Civil que trata do Direito Empresarial, retornando-se à existência de um Código Comercial autônomo.

O Código Comercial de 1850 está em vigor apenas na parte segunda, de comércio marítimo. Era dividido em três partes. A parte terceira, de quebras (falência), foi revogada há mais de 100 anos. A parte primeira, Teoria Geral do Direito Empresarial, foi revogada pelo CC de 2002.



CAPÍTULO 2 – TEORIA GERAL DO DIREITO COMERCIAL

1. Objeto do Direito Comercial

O objeto do direito comercial é a atividade do empresário.

O empresário articula os fatores de produção (CMIT):

- **capital;**
- **mão de obra;**
- **insumos;**
- **tecnologia.**

Para uma parte da doutrina (ex: Fábio Ulhoa), se não houver algum desses fatores, não haverá falar em empresário. Por exemplo, João vende 20 mil reais por dia nas ruas, pois tem máquina que faz panetone (tecnologia), tendo os ingredientes para fabricá-lo (insumos), bem como recebe quantia para investir no seu negócio (capital). Todavia, não tem mão de obra. Assim, ausente um dos fatores de produção, não seria empresário. Outra parte (ex: André Santa Cruz), porém, discorda, afirmando que

essa ideia fechada de que a organização dos fatores de produção é absolutamente imprescindível para a caracterização do empresário vem perdendo força no atual contexto da economia capitalista. Com efeito, basta citar o caso dos microempresários, os quais, não raro, exercem atividade empresarial única ou preponderantemente com trabalho próprio. Pode-se citar também o caso dos *empresários virtuais*, que muitas vezes atuam completamente sozinhos, resumindo-se sua atividade à intermediação de produtos ou serviços por meio da *internet*. (CRUZ, 2019)

O Direito Comercial cuida do exercício dessa atividade econômica organizada pelo empresário. Portanto, atividade econômica organizada para fornecimento de bens e serviços é denominada de **empresa**. Empresa, em sentido técnico, é a atividade exercida pela pessoa física ou jurídica!

1.1. Teoria da Empresa

Com a queda da Teoria dos Atos de Comércio e adoção da Teoria da Empresa pelo Código Civil de 2002, o Direito Comercial deixa de cuidar de determinadas atividades previamente definidas como de mercancia e passa a disciplinar uma forma específica de circulação de bens ou serviços: a forma empresarial.

No Brasil, pelo Código Comercial de 1850, que adotava a Teoria dos Atos de Comércio, só eram consideradas atividades de mercancia:

- compra e venda de bens móveis semoventes, no atacado ou no varejo;
- indústrias;
- bancos;
- logísticas;
- armação e expedição de navios.

Perceba que o Código deixava de lado atividades como negociação de imóveis, atividades rurais e principalmente prestação de serviços, que não era uma atividade comercial para a época.

O Direito Comercial vem do desenvolvimento com a burguesia, a qual rompeu com o feudo, criando uma regulamentação que acabasse por proteger as suas atividades. Por isso, deixaram-se de lado as demais atividades dos feudos, que eram tipicamente rurais, não exercidas pela burguesia de então.



Até hoje a inserção da atividade rural como empresarial depende de uma opção nesse sentido pelo produtor rural.

1.1.1. Perfis da empresa

Ricardo Negrão, ao tratar sobre os perfis da empresa, leciona que o conceito poliédrico **desenvolvido por Alberto Asquini** concebe quatro perfis à empresa, visualizando-a, como objeto de estudos, por quatro aspectos distintos, a saber:

- **perfil subjetivo:** consiste no estudo da **pessoa** que exerce a empresa, ou seja, a pessoa natural (empresário individual) ou a pessoa jurídica (sociedade empresária) que exerce atividade empresarial;
- **perfil objetivo:** foca-se nas **coisas utilizadas** pelo empresário individual ou sociedade empresária no exercício de sua atividade. São os bens corpóreos e incorpóreos que instrumentalizam a vida negocial. Em suma, consiste no **estudo da teoria do estabelecimento** empresarial;
- **perfil funcional:** refere-se à **dinâmica empresarial**, isto é, a atividade própria do empresário ou da sociedade empresária, em seu cotidiano negocial. Nesse aspecto, empresa é entendida como exercício da atividade (complexo de atos que compõem a vida empresarial);
- **perfil corporativo ou institucional:** estuda os **colaboradores da empresa**, empregados que, com o empresário, envidam esforços à consecução dos objetivos empresariais.

Pelo fato do aspecto corporativo se submeter às regras da legislação laboral no direito brasileiro, Waldírio Bulgarelli prefere dizer que, **no Brasil, a Teoria Poliédrica da Empresa foi reduzida à Teoria Triédrica da Empresa**, abrangendo tão-somente os **perfis subjetivo, objetivo e funcional**, que interessam à legislação civil. **Ressalte-se que essa afirmação já foi objeto de cobrança em diversos concursos.**

Partindo desses elementos, Waldírio Bulgarelli define empresa como atividade econômica organizada de produção e circulação de bens e serviços para o mercado, exercida pelo empresário, em caráter profissional, por meio de um complexo de bens.

1.1.2. Conceito de empresário

O conceito de empresário é um **conceito legal**, estabelecido no art. 966 do Código Civil, cuja literalidade já foi objeto de cobrança em diversos concursos públicos para carreiras de Estado! Segundo o dispositivo, considera-se **empresário aquele que exerce atividade empresária**. Essa atividade empresária deverá ser:

- exercida de forma profissional (não habitual);
- econômica (intuito lucrativo);
- organizada;
- voltada para a produção ou a circulação de bens ou serviços.

a) Profissionalismo

Esse profissionalismo requer que estejam presentes três características:

- **Habitualidade:** o exercício esporádico ou a organização esporádica não configura atividade empresária;
- **Pessoalidade:** necessidade de o empresário exercer pessoalmente a atividade empresarial, o que não afasta a possibilidade de contratação de empregados e prepostos necessários à realização da atividade;



- **Monopólio das informações:** a ideia é de presunção de que o titular da sociedade empresária detenha as informações dos bens e serviços que ela produz ou que ela faz circular. Em outras palavras, ela sabe sobre os insumos que aplicou, se há a possibilidade de um defeito de fabricação, etc., quais são os riscos dos bens, etc. Isso se consolida como monopólio das informações.

b) Atividade econômica

Por atividade econômica quer-se dizer que o sujeito visa à obtenção de lucro. Empresa é o sinônimo de empreendimento. Não se pode dizer que o sócio da empresa é empresário, pois **empresário é quem exerce a atividade**. Em outras palavras, no caso de uma sociedade, **quem exerce a atividade empresária é a própria sociedade**. O sócio poderá até mesmo ser um empreendedor, ou um investidor, mas quem exerce a atividade é a empresa, ou seja, a sociedade empresária.

A atividade empresarial é econômica pois busca obter lucro para quem a explora.

A FGV não tem fins lucrativos, mas isto não se confunde com o fato de não ter lucro. O que distingue a sociedade empresária da sociedade não empresária é a finalidade. Isso porque **a sociedade empresária visa a obter lucro, ainda que não o tenha, enquanto a sociedade não empresária não tem a finalidade de lucro, ainda que o obtenha**.

c) Atividade organizada

A atividade é organizada, pois o empresário faz a junção dos quatro fatores de produção (CMIT):

- capital;
- mão de obra;
- insumo;
- tecnologia.

d) Produção ou circulação de bens ou serviços

A atividade, para ser empresarial, deve ser voltada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.

A distinção entre bens e serviços perdeu a razão de ser, visto que antes bens teriam natureza corpórea e os serviços seriam de natureza incorpórea. Todavia, com a internet, essa distinção não mais se sustenta, pois é possível adquirir um jornal virtual, sendo esse um produto.

O CC não define *empresa*, mas o conceito de empresa está implícito no conceito de *empresário*. Diz-se que se considera empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para produção e circulação de bens e serviços. Logo, empresa é justamente isso: atividade econômica profissional organizada para produção e circulação de bens e serviços.

Ao contrário do conceito de atos de comércio, a empresa engloba toda e qualquer atividade econômica que preencha os demais requisitos previstos no art. 966 do Código Civil e não esteja contemplada entre as exceções de seu parágrafo único.

Refere-se, esse conceito, tanto ao empresário pessoa física, que é o empresário individual, quanto à pessoa jurídica, que é a sociedade empresária ou, excepcionalmente, a EIRELI.

Cuidado: para o Direito, empresa é uma atividade. Atente-se para a incorreção das noções vulgares de empresa, tais como o local físico onde se exerce atividade ou a própria sociedade empresária.



1.1.3. Síntese dos elementos do conceito de empresa

- a) **profissionalismo**: atividade habitual, exercida com assunção dos riscos;
- b) **atividade econômica**: atividade exercida com fins lucrativos;
- c) **organização**: atividade exercida com articulação dos fatores de produção: capital, insumos, mão-de-obra e tecnologia;
- d) **produção/circulação de bens/serviços**: abrangência da Teoria da Empresa.

1.1.4. Espécies de empresário

Empresário individual: pessoa natural que exerce empresa profissionalmente, respondendo direta e ilimitadamente pelas obrigações empresariais.

Cuidado: empresário individual é pessoa natural, é pessoa física. Não confunda com a existência de CNPJ, que é o Cadastro Fiscal do Ministério da Fazenda. Quem diz o que é pessoa jurídica não é o CNPJ, é o Código Civil – Sociedade, associação, fundação, partido político, organização religiosa e EIRELI.

Porém, pode ser equiparado à pessoa jurídica para fins tributários.

Sociedade Empresária: pessoa jurídica constituída sob a forma de sociedade, cujo objeto social é o exercício de empresa. Atenção para a atual possibilidade de Sociedade Limitada com sócio único (art. 1052, § 1º, do CC, com a redação dada pela Lei da Liberdade Econômica).

EIRELI (empresa individual de responsabilidade limitada): nova pessoa jurídica criada pela Lei nº 12.441/11, que tem um único titular.

Cuidado com o parágrafo único do artigo 966, CC, pois a Teoria da Empresa deu uma abrangência maior ao Direito Empresarial, mas não significa que o CC não tenha excluído certas atividades do regime jurídico empresarial, o que faz com que receba críticas, pois essa dualidade de regimes traz complicações, quando na verdade a atividade econômica deveria ser considerada igual, para todos os efeitos.

O CC faz uma ressalva, estabelecendo que certas atividades econômicas não configuram empresa, portanto seus exercentes não são considerados empresários, a exemplo dos **profissionais liberais/intelectuais**, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa.

Enquanto o profissional liberal exerce sua atividade sozinho ou mesmo em sociedade ou ainda que tenha contratado colaboradores ou auxiliares, enquanto o exercício da profissão for a atividade preponderante, não será considerado empresário. No entanto, se esse profissional dá uma organização tal à atividade, de modo que o exercício da profissão intelectual passa a ser um mero elemento de uma atividade empresarial mais complexa ali desenvolvida, passará a ser considerado empresário.

O que importa é observar se a organização dos fatores de produção é mais importante que o trabalho pessoal.

Exemplo 1: médico que atende pacientes em consultório, ainda que com a existência de secretários, auxiliar contábil e copeiro para auxiliá-lo não é empresário.

Exemplo 2: médico proprietário de um hospital, onde se atendem diversas especialidades, com quadro próprio de enfermagem, setor de almoxarifado, setor de atendimento e triagem, rede de laboratórios. Neste caso, ainda que o médico continue a exercer a medicina no âmbito do hospital, o exercício dessa profissão foi absorvido pela organização empresarial e passou a ser mero elemento de empresa.

A partir do momento em que o profissional intelectual dá uma forma empresarial ao exercício de suas atividades, passando a ostentar mais a característica de organizador da atividade desenvolvida, será considerado empresário e passará a ser regido pelas normas do Direito Empresarial.



Sobre o tema, são também importantes os Enunciados 193, 194 e 195 do Conselho da Justiça Federal, aprovados na III Jornada de Direito Civil, segundo os quais: “o exercício das atividades de natureza exclusivamente intelectual está excluído do conceito de empresa”; “os profissionais liberais não são considerados empresários, salvo se a organização dos fatores de produção for mais importante que a atividade pessoal desenvolvida”; e “a expressão elemento de empresa demanda interpretação econômica, devendo ser analisada sob a égide da absorção da atividade intelectual, de natureza científica, literária ou artística, como um dos fatores da organização empresarial”.

De acordo com o Código Civil, **o empresário deve se inscrever perante o Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede (Junta Comercial) antes do início de sua atividade.** Caso inicie a atividade antes do registro, ainda assim será considerado empresário, embora irregular, aplicando-se-lhe os ônus típicos de um empresário, mas não alguns bônus em relação aos quais a lei exige regularidade empresarial (ex: não poderá requerer a falência de um devedor nem pleitear recuperação judicial) (Enunciado 198 das Jornadas de Direito Civil do CJF). **Nesse caso, portanto, o registro a posteriori perante a Junta Comercial é declaratório,** ou seja, empresário ele já é, mas o registro é necessário para que ele seja considerado regular.

Empresário Rural: No caso dos empresários rurais, o registro é facultativo e pode ser desempenhado após o exercício efetivo de suas atividades. Assim, **a inscrição do empresário rural possuirá natureza constitutiva,** equiparando-o, para todos os efeitos, às demais classes empresariais.

Dito de outro modo, o registro transfere quem desempenha a atividade econômica rural para o regime empresarial. Sendo o registro facultativo, a regularidade no exercício da atividade rural existe independentemente do registro. Para o empresário rural “é o registro que faz o empresário”. Caso opte por não se registrar, não será considerado empresário irregular, apenas não será tratado como empresário. Isso vale tanto para o empresário rural quanto para a sociedade rural (arts. 971 e 984 do CC).

Inclusive, recentemente, o STJ firmou o entendimento de que para cumprir os 2 anos exigidos por lei (art. 48 da Lei nº 11.101/2005) para que um devedor possa requerer a recuperação judicial, o produtor rural pode aproveitar o período anterior ao registro, pois se considera atividade empresarial regular esse período anterior ao registro (STJ. 4ª Turma. REsp 1.800.032-MT, julgado em 05/11/2019).

1.1.5. Impedimentos legais

a) Considerações gerais

Há uma série de impedimentos para o exercício da atividade empresarial. O próprio CC, no artigo 1.011, § 1º, traz alguns impedimentos à atuação como administrador de sociedades, que, de acordo com alguns autores, se aplicariam também ao exercício de empresa na condição de empresário individual (CRUZ, 2014).

De qualquer modo, em prol do princípio da aparência, as obrigações contraídas por um “empresário” impedido não são nulas perante terceiros de boa-fé que com ele contratarem.

É preciso se atentar para o fato de que a proibição é para o exercício de empresa, não sendo vedado, pois, que alguns impedidos sejam sócios de sociedades empresárias, uma vez que, nesse caso, quem exerce a atividade empresarial é a própria pessoa jurídica, e não seus sócios. Em suma: os impedimentos se dirigem aos empresários individuais, e não aos sócios de sociedades empresárias. (CRUZ, 2014)

Nesse sentido, pode-se afirmar, então, que os impedidos não podem se registrar na Junta Comercial como empresários individuais (pessoas físicas que exercem atividade empresarial), não significando, em princípio, que eles não possam participar de uma sociedade



empresária como quotistas ou acionistas, por exemplo. No entanto, a possibilidade de os impedidos participarem de sociedades empresárias não é absoluta, somente podendo ocorrer se forem sócios de responsabilidade limitada e, ainda assim, se não exercerem funções de gerência ou administração.

Esmiuçando: o artigo 972 se dirige aos empresários individuais. Quando se trata de sociedade, quem vai exercer a atividade é a própria sociedade, a própria pessoa jurídica. Em uma sociedade empresária, o empresário é a sociedade, os sócios não são empresários. O impedido não pode ser empresário individual, o que não significa dizer que não pode ser sócio de uma sociedade empresária.

Porém, atente-se aos requisitos: para que um impedido seja sócio de uma sociedade empresária, o tipo societário deve consagrar a responsabilidade limitada e não pode ter poderes de administração.

b) Falido não reabilitado

São vários aqueles que estão proibidos de exercer empresa. Porém, o principal caso é o **falido não reabilitado**.

Quando a falência não é fraudulenta, ou seja, não houve crime falimentar, haverá, oportunamente (veremos em tópico próprio), a declaração de extinção das obrigações, nesse caso, o sujeito já seria considerado reabilitado, podendo exercer atividade empresária.

Contudo, **se houve crime falimentar**, e, portanto, a sua falência foi fraudulenta, nesse caso, **estará o sujeito vedado do exercício de sua atividade**, pois é não reabilitado. Então, **serão declaradas extintas as suas obrigações, e só poderá exercer atividade empresária quando o sujeito obtiver a reabilitação penal também**.

c) Leiloeiro

Quando a lei diz que o incapaz não pode ser empresário, a lei quer proteger o incapaz. Todavia, quando a lei diz que o falido ou o leiloeiro não pode ser empresário, estaria protegendo a sociedade, o Estado, bem como as pessoas que tratam com o leiloeiro.

d) Incapaz

O incapaz não pode ser empresário individual, salvo no caso do art. 974 do CC, quando a incapacidade for superveniente ou quando ele herdar o exercício de uma atividade empresarial. **Sobre o tema, também muito explorado em provas, é importante atentar para o verbo continuar**. O incapaz só pode ser autorizado a **continuar** o exercício de empresa que já era exercido por si mesmo ou por alguém (seus pais ou autor da herança). Nesse caso, atuará por meio de representante ou assistente. Em hipótese alguma poderá ser autorizado a iniciar o exercício de uma atividade empresarial. Nesse sentido, vide o Enunciado 203 do CJF, aprovado na III Jornada de Direito Civil: “o exercício de empresa por empresário incapaz, representado ou assistido, somente é possível nos casos de incapacidade superveniente ou incapacidade do sucessor na sucessão por morte”.

Em primeiro lugar, destaque-se que o art. 974 do Código Civil se refere ao exercício individual de empresa. Trata-se, pois, de casos em que o incapaz será autorizado a explorar atividade empresarial individualmente, ou seja, na qualidade de empresário individual (pessoa física). A possibilidade de o incapaz ser sócio de uma sociedade empresária configura situação totalmente distinta, já que o sócio de uma sociedade não é empresário.

É direito do incapaz continuar a atividade? Não. Deve haver autorização judicial, consoante § 1º do artigo 974, CC:



Art. 974 (...) § 1º Nos casos deste artigo, precederá autorização judicial, após exame das circunstâncias e dos riscos da empresa, bem como da conveniência em continuá-la, podendo a autorização ser revogada pelo juiz, ouvidos os pais, tutores ou representantes legais do menor ou do interdito, sem prejuízo dos direitos adquiridos por terceiros.

Referida pedido de autorização correrá, via de regra, em procedimento de jurisdição voluntária, devendo ainda ser ouvido o Ministério Público, nos termos do art. 178, II, e 721 do CPC.

Importante: *§ 2º Não ficam sujeitos ao resultado da empresa os bens que o incapaz já possuía, ao tempo da sucessão ou da interdição, desde que estranhos ao acervo daquela, devendo tais fatos constar do alvará que conceder a autorização.*

Em outras palavras, o juiz irá verificar quais os bens que o incapaz já possuía ao tempo da interdição, e que eram estranhos ao acervo da empresa, e destacará esses bens no alvará que conceder a autorização, porque, a partir de então, as obrigações assumidas pelo incapaz (que atuará por meio de representante), não poderão ser executadas nos bens destacados.

Quando o incapaz vai ser sócio de uma sociedade empresária, não é necessária a obediência ao artigo 974 e §§ 1º e 2º. A regra que se aplica ao sócio incapaz é a do § 3º, acrescentado anos após a edição do Código, porque os cartórios de registro estavam confundindo as regras.

e) Servidores, magistrados, membros do Ministério Público e Militares

Servidores públicos em geral, membros do Ministério Público, magistrados etc, tampouco podem se dedicar a atividades empresariais.

1.1.6. Atividades econômicas civis

A Teoria da Empresa, apesar de ampliar o conceito de empresa, não supera nem pretende superar a dicotomia do regime jurídico civil e do regime jurídico empresarial. Existem determinadas sociedades (com intuito econômico/lucrativo) que não estão submetidas ao regime jurídico de direito comercial, tais como:

- sujeito que não se enquadra na definição legal de empresário;
- profissionais intelectuais;
- empresários rurais não inscritos como empresários;
- cooperativas.

a) Profissional intelectual

O art. 966, p.u., afirma que não se considera empresário quem **exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística**, mesmo que contrate empregados para auxiliar no seu trabalho.

Todavia, a própria lei traz uma **exceção**, pois **quando o exercício da profissão constituir elemento de empresa se tornará empresário, conforme já visto acima.**

Ex.: dois escritórios de advocacia. Um deles, João abriu com o seu irmão, contratando uma secretária. Não será empresário. Outra situação será a hipótese do escritório com mais de mil advogados, e diversos departamentos. Esse segundo é empresa.



b) Empresário rural

As atividades rurais do Brasil são exploradas em duas linhas radicalmente distintas. Uma delas é baseada na agricultura familiar, e a outra é a agroindústria.

Para ser empresário rural, basta que o indivíduo se registre na Junta Comercial.

A ideia é que o sujeito que pratica agricultura familiar não faça a inscrição.

O legislador reserva um tratamento específico ao empresário rural.

c) Cooperativas

Nos termos do art. 982, p.u., do CC, muito explorado em provas, a sociedade anônima será sempre empresária, enquanto a cooperativa **nunca será sociedade empresária, sendo sempre sociedade simples.**

Portanto, **ainda que as cooperativas preencham todos os requisitos da definição legal de empresário, não serão sociedades empresárias.**

d) Empresário individual

O empresário pode ser **pessoa física** ou **jurídica**.

Sendo **pessoa física, será denominado de empresário individual**. Sendo **pessoa jurídica, será denominada de sociedade empresária**. O sócio não é empresário. O sócio é empreendedor ou investidor.

Para ser empresário individual, **a pessoa deve estar no pleno gozo de suas capacidades civis**. Não têm capacidade para serem empresários:

- menor de 18 anos, salvo emancipado;
- ébrio habitual;
- viciados em tóxicos;
- aqueles que não puderem exprimir suas vontades;
- pródigo;
- indígenas, nos termos da sua lei.

Perceba que **essas pessoas não poderão ser empresários individuais**. Sócio, por sua vez, **poderão ser**.

Excepcionalmente, poderá ser empresário o incapaz, desde que tenha autorização judicial, conforme visto no tópico anterior.

Vale lembrar que o empresário casado pode, **sem necessidade de outorga conjugal**, qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real.

No entanto, os Enunciados da Jornada de Direito Empresarial vem impondo certos requisitos para a afetação dos imóveis ao patrimônio da empresa. Para tanto, **será necessário que exista**:

- **prévia averbação da autorização conjugal à conferência do imóvel ao patrimônio empresarial no cartório de registro de imóveis; e**
- **averbação do ato à margem de sua inscrição no registro público de empresas mercantis.**

Esses requisitos já foram chancelados também pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Para fins de prova, porém, tome muito cuidado, pois pode ser cobrada tanto a literalidade do artigo 978 do CC (que se refere ao imóvel que já está afetado à atividade empresarial) quanto a jurisprudência do STJ, amparada no enunciado 58 do CJF, da II Jornada de Direito Comercial (que se referem aos requisitos para a afetação do bem à atividade empresarial).



1.1.7. Prepostos do empresário

O empresário articula os quatro fatores de produção (CMIT):

- capital;
- mão de obra;
- insumos;
- tecnologia.

Em relação à mão de obra, precisa-se contratar pessoa, seja como empregado, representante etc. Nesse caso, o trabalhador que atua no exercício da atividade será considerado preposto do empresário, independentemente do vínculo.

Os atos dos prepostos obrigam o empresário. Se o preposto agiu com culpa, deverá indenizar por regresso. Caso haja **com dolo, responderá o preponente solidariamente com o empresário** pelos seus atos.

Caso o empresário pague a conta, poderá buscar em ação de regresso contra o preposto pelo prejuízo. Em relação ao preposto, **esse é proibido de concorrer com o preponente**. Caso o faça, responderá por perdas e danos. A depender do que faz, poderá responder pelo crime de concorrência desleal, como no caso de utilização de sigilo comercial.

O **gerente** é o funcionário que faz a organização do trabalho na sede ou na filial.

O **contabilista** é quem faz a escrituração dos livros do empresário.

CAPÍTULO 3 – REGIME JURÍDICO DA LIVRE INICIATIVA

1. Proteção da ordem econômica e da concorrência

Sempre devemos fazer uma leitura constitucional do Direito Comercial, facilitando o entendimento. A ideia é proteger a ordem econômica e a concorrência, visto que a CF garante a livre iniciativa.

A partir daí, o legislador estabelece mecanismos para proteger a liberdade de competição e de livre iniciativa. Esses mecanismos criados podem ser agrupados em duas categorias:

- infração à ordem econômica;
- concorrência desleal.

Trata-se de temas com estudo aprofundado no âmbito do Direito Econômico, não propriamente no âmbito do Direito Empresarial, mas ainda assim serão dedicadas algumas linhas para uma exposição geral.

1.1. Infração contra a ordem econômica

O conceito de infração contra a ordem econômica está previsto no art. 36 da Lei nº 12.529/2011, que assim dispõe:

Art. 36. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados:

- I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa;
- II - dominar mercado relevante de bens ou serviços;
- III - aumentar arbitrariamente os lucros; e
- IV - exercer de forma abusiva posição dominante.

Para que se considere uma infração contra a ordem econômica, portanto, basta a prova de que a prática adotada pelo empresário trouxe um efeito lesivo ou que poderia trazer uma lesão à estrutura livre do mercado.

A ideia, como se vê, é a de que, ainda que não se tenha esse objetivo e independentemente de culpa, **caso a prática comercial acabe trazendo prejuízos à livre iniciativa, à livre concorrência, implique em dominação do mercado relevante ou aumento arbitrário dos lucros, ou ainda exercício de forma abusiva de posição dominante, estará configurada uma infração contra a ordem econômica!**

Havendo uma infração contra a ordem econômica, ganha destaque a atuação do **Conselho Administrativo de Defesa Econômica**. Trata-se de uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Justiça e profere decisões de caráter repressivo, a qual tem força de **título executivo extrajudicial**. No âmbito do CADE, funcionam o Tribunal Administrativo de Defesa Econômica, a Superintendência-Geral e o Departamento de Estudos Econômicos.

As **sanções** que aquele que praticar infração contra a ordem econômica estão previstas nos artigos 37 e seguintes da Lei nº 12.529/2011, com destaque para as seguintes:

- multa, que varia de acordo com os critérios previstos na lei;
- publicação na imprensa do extrato da sentença condenatória;
- proibição de contratar com o poder público.
- inscrição do infrator no Cadastro de Defesa do Consumidor;
- proibição de exercer o comércio em nome próprio ou como representante de pessoa jurídica, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;



O CADE não atua somente na esfera repressiva, atuando também preventivamente. Algumas operações, como fusões ou incorporações que se enquadrem em determinados critérios legais, **não são eficazes caso não sejam aprovadas pelo CADE**. Ex.: uma empresa compra a outra, dominando 50% do mercado. Em tese, não há problema, mas o CADE pode colocar condições para aprovar. Se a marca João, que detém 25% do mercado, se unir à marca Maria, que detém outros 25% do mercado, o CADE poderá exigir que uma dessas marcas não mais seja usada ou então continuem ambas em uso, com contabilidade própria, por exemplo. Tudo isso para proibir, ou prevenir, a prática de uma infração contra a ordem econômica.

1.2. Concorrência desleal

Inicialmente, é importante destacar a distinção entre concorrência desleal e infração concorrencial: aquela é reprimida civil (art. 209 da Lei de Propriedade Industrial – LPI) e criminalmente (art. 195 da LPI) e trata de condutas que atingem um concorrente *in concreto* (venda de produto pirata, por exemplo); esta é reprimida administrativamente pelo CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) nos termos da Lei Antitruste (Lei 12.529/2011) e se refere às chamadas infrações contra a ordem econômica, condutas que atingem à concorrência *in abstracto* (cartelização, por exemplo). Essa repressão poderá se dar por fundamento contratual ou extracontratual.

1.3. Cláusula de não restabelecimento

Em caso de alienação de um estabelecimento empresarial, por meio do trespasse, estabelece o art. 1.147 do CC estabelece que o alienante não poderá se restabelecer no mesmo ramo e local pelo prazo de 5 anos, salvo diante de autorização expressa. Na omissão do contrato sobre o tema, será uma cláusula não concorrencial **implícita**. Isto é, há uma cláusula decorrente da própria lei que determina não ser possível haver concorrência entre o alienante do estabelecimento por esse prazo.

Quanto a isso, é preciso atentar que essa cláusula implícita traz duas limitações:

- **ordem espacial:** não pode o alienante se restabelecer no mesmo local;
- **ordem temporal:** não pode se restabelecer no prazo de 5 anos.

Isso significa dizer que se o indivíduo vender uma pequena loja de sapatos em uma cidade, não impede que o sujeito abra uma loja de sapatos em outra no dia seguinte, visto que não haverá concorrência à antiga loja.

Atente-se que a limitação temporal poderá ser para mais ou para menos, ou seja, poderá limitar para o prazo de 1 ano, assim como poderá limitar a 10 anos ou mais. **O que não poderá é vedar a concorrência por prazo indeterminado**, conforme entendeu o STJ. Isso porque atingiria o núcleo duro da livre iniciativa, que é a liberdade.

A validade da limitação temporal e espacial, a seu turno, deverão ser analisadas também de acordo com o critério material (ramo de atividade e porte do estabelecimento alienado). Com efeito, no mesmo exemplo acima, das lojas de sapato, se estivermos diante de uma rede com abrangência regional, a vedação de restabelecimento observaria os limites da região. Se o vulto do aporte financeiro for significativo, implicando retorno do investimento em um longo prazo, eventual limitação do não restabelecimento por mais anos poderá ser justificável. O que deve haver é razoabilidade na definição espacial e temporal.

1.4. Parasitismo

Esse é um dos temas mais atuais acerca da matéria concorrência desleal. Há certa polêmica dentro do tema, porque não há unanimidade da doutrina sobre a própria



nomenclatura, tampouco quanto à definição de quais condutas seriam legítimas e quais seriam ilegais.

De forma simplista, é a conduta do empresário que se utiliza **sutilmente** de ativos intangíveis de outro empresário, tentando pegar carona no sucesso deste (*free riding*).

Há autores que subdividem o parasitismo em (i) **concorrência desleal parasitária** e (ii) mero **aproveitamento parasitário**. Para eles, a diferença estaria no fato de que, na primeira, a apropriação intelectual alheia tem o potencial de causar confusão entre os consumidores e/ou desviar clientela. Em contrapartida, na segunda, não há desvio de clientela nem possibilidade de confusão entre os consumidores.

Geralmente, os Tribunais, principalmente o STJ, preocupam-se quanto à questão da confusão dos consumidores. Havendo confusão aos consumidores, o STJ reprime a conduta.

Como há uma imitação sutil de ativos intangíveis, pode ser que não haja cópia da marca, mas do modelo de negócio. Dessa forma, vem surgindo discussões acerca do conjunto imagem do produto, ou *trade dress*. Não há cópia do negócio, mas do modelo do negócio.

Sobre o tema, decidiu o STJ o seguinte:

(...) 1. O conjunto-imagem (*trade dress*) é a soma de elementos visuais e sensitivos que traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva de apresentação do bem no mercado consumidor. Não se confunde com a patente, o desenho industrial ou a marca, apesar de poder ser constituído por elementos passíveis de registro, a exemplo da composição de embalagens por marca e desenho industrial. Embora não disciplinado na Lei n. 9.279/1996, o conjunto-imagem de bens e produtos é passível de proteção judicial quando a utilização de conjunto similar resulte em ato de concorrência desleal, em razão de confusão ou associação com bens e produtos concorrentes (art. 209 da LPI). (...) (REsp 1591294/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018)



CAPÍTULO 4 – REGISTRO DE EMPRESA

Regra: para os empresários em geral, o registro é obrigatório, mas tem efeito declaratório. Todo empresário deve se registrar antes de iniciar suas atividades, sob pena de exercer a atividade de forma irregular. Quanto às sociedades, o art. 998 concede o prazo de trinta dias subsequentes à sua constituição para que requeira sua inscrição.

Lembre-se: o registro não é o que caracteriza alguém como empresário, apenas determina se o exercício da atividade empresarial está ocorrendo de forma regular. O exercício da atividade empresarial sem registro não significa que o exercente não é empresário, mas que está exercendo a atividade de forma irregular.

Exceção: para quem exerce atividade rural, o registro é facultativo e tem efeito constitutivo (regra específica do artigo 971 do CC).

O registro empresarial tem algumas regras no Código Civil (Artigo 1.150 ao artigo 1.154), mas é matéria objeto de lei específica, Lei nº 8.934/94.

Essa lei criou o Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis – SINREM, que é estruturado da seguinte forma: um órgão central, chamado de DNRC – Departamento Nacional de Registro do Comércio, que, embora ainda conste da lei, foi extinto por um decreto e substituído pelo DREI – Departamento de Registro Empresarial e Integração.

Atente-se: quando a lei mencionar DNRC, deve-se ler DREI.

O DREI é, portanto, o órgão central, federal, que integra a estrutura administrativa da União e exerce, basicamente, funções gerais, de supervisão, de orientação e etc., mas, principalmente, de normatização do registro de empresas no Brasil.

Esse sistema também é composto por órgãos locais, que são as Juntas Comerciais, e por órgãos estaduais, que integram a estrutura administrativa dos estados.

“Art. 6º da Lei nº 8.934/1994: As juntas comerciais subordinam-se administrativamente ao governo da unidade federativa de sua jurisdição e, tecnicamente, ao DREI, nos termos desta lei.”

O artigo 6º, supramencionado, demonstra que as Juntas Comerciais possuem subordinação híbrida: administrativamente, estão subordinadas aos estados e ao Distrito Federal, tecnicamente, estão subordinadas ao DREI, por exemplo, no momento do exercício de sua atividade fim (proceder ao registro dos empresários), obedecem às regras baixadas pelo DREI.

Não cabe ao estado, por exemplo, baixar uma lei regulamentando os requisitos que a Junta Comercial deve atender para registrar o contrato social de uma sociedade limitada. Do mesmo modo, não cabe ao DREI determinar como a Junta Comercial deve ser administrada.

Situação *sui generis*: a Junta Comercial do Distrito Federal, até o advento da Lei nº 13.833/2019, era submetida tanto técnica quanto administrativamente ao DREI (era um órgão federal). Todavia, a partir do advento da tal lei (em verdade, desde a medida provisória posteriormente convertida na citada lei), passou a ser órgão administrativo do Distrito Federal.

Em virtude da subordinação híbrida das Juntas Comerciais existe uma jurisprudência do STJ que merece atenção:

Conflito de competência. Registro de comércio. As juntas comerciais estão, administrativamente, subordinadas aos Estados, mas as funções por elas exercidas são de natureza federal. **Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Federal da 3ª Vara de Londrina – SJ/SP. (STJ, 2.ª Seção, CC 43.225/PR, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 26.10.2005, DJ 01.02.2006, p. 425).**

Conflito de competência. Mandado de segurança. Junta comercial. Os serviços prestados pelas juntas comerciais, apesar de criadas e mantidas pelos estados são de natureza federal. **Para julgamento de ato, que se compreenda nos serviços do**



registro de comércio, a competência da justiça federal. (STJ, CC 15.575/BA, Rel. Min. Cláudio Santos, j. 14.02.1996, DJ 22.04.1996).

Competência. Conflito. Justiça estadual e Justiça federal. Mandado de segurança contra ato do presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Competência *ratione personae*. Precedentes. Conflito procedente. I – Em se cuidando de mandado de segurança, a competência se define em razão da qualidade de quem ocupa o polo passivo da relação processual. **II – As Juntas Comerciais efetuam o registro do comércio por delegação federal, sendo da competência da Justiça Federal, a teor do artigo 109VIII, da Constituição, o julgamento de mandado de segurança contra ato do Presidente daquele órgão.** III – Consoante o art. 32, I, da Lei 8.934/1994, o registro do comércio compreende “a matrícula e seu cancelamento: dos leiloeiros, tradutores públicos e intérpretes comerciais, trapicheiros e administradores de armazéns-gerais”. (STJ, CC 31.357/MG, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 14.04.2003, p. 174).

Juntas Comerciais. Órgãos administrativamente subordinados ao Estado, mas tecnicamente à autoridade federal, como elementos do Sistema Nacional dos Serviços de Registro do Comércio. Consequente **competência da Justiça Federal para o julgamento de mandado de segurança contra ato do Presidente da Junta, compreendido em sua atividade fim.** (STF, RE 199.793/RS, Rel. Min. Octavio Gallotti, DJ 18.08.2000, p. 93).

Em outras palavras, nas ações propostas contra a Junta Comercial a competência será da Justiça Federal quando se tratar de matéria técnica, referente ao registro de empresa, porém, será da Justiça Estadual quando se tratar de matéria administrativa.

CUIDADO!

Diante de várias ações que tratavam subsidiariamente ou superficialmente de matéria relacionada ao registro de empresa, propostas contra Juntas Comerciais perante a Justiça Federal, o STJ fez uma reinterpretação da jurisprudência supramencionada, esclarecendo que apenas quando a matéria questionar a lisura de ato praticado pela Junta Comercial, ou no caso de Mandado de Segurança contra presidente da Junta Comercial, é que se proporá a ação perante a Justiça Federal.

Portanto, quando se tratar de demanda que envolve apenas questões particulares, como conflitos societários, a competência será da Justiça Estadual, ainda que no processo esteja sendo discutido um ato ou registro praticado pela Junta Comercial. Confira-se:

Recurso especial. Litígio entre sócios. Anulação de registro perante a junta comercial. Contrato social. Interesse da administração federal. Inexistência. Ação de procedimento ordinário. Competência da justiça estadual. Precedentes da segunda seção. 1. **A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem decidido pela competência da Justiça Federal, nos processos em que figuram como parte a Junta Comercial do Estado, somente nos casos em que se discute a lisura do ato praticado pelo órgão, bem como nos mandados de segurança impetrados contra seu presidente,** por aplicação do artigo 109, VIII, da Constituição Federal, em razão de sua atuação delegada. 2. **Em casos em que particulares litigam acerca de registros de alterações societárias perante a Junta Comercial, esta Corte vem reconhecendo a competência da justiça comum estadual,** posto que uma eventual decisão judicial de anulação dos registros societários, almejada pelos sócios litigantes, produziria apenas efeitos secundários para a Junta Comercial do Estado, fato que obviamente não revela questão afeta à validade do ato administrativo e que, portanto, afastaria o interesse da Administração e, consequentemente, a competência da Justiça Federal para julgamento da causa. Precedentes. Recurso especial não conhecido (REsp 678.405/RJ, 3.ª Turma, Rel. Min. Castro Filho, j. 16.03.2006, DJ 10.04.2006, p. 179).

Conflito de competência. Junta Comercial. Anulação de alteração contratual. Ato fraudulento. Terceiros. Indevido registro de empresa. 1. **Compete à Justiça Comum**



processar e julgar ação ordinária pleiteando anulação de registro de alteração contratual efetivado perante a Junta Comercial, ao fundamento de que, por suposto uso indevido do nome do autor e de seu CPF, foi constituída, de forma irregular, sociedade empresária, na qual o mesmo figura como sócio. Nesse contexto, não se questiona a lisura da atividade federal exercida pela Junta Comercial, mas atos antecedentes que lhe renderam ensejo. 2. Conflito conhecido para declarar competente o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, o suscitado. (CC 90.338/RO, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 2.ª Seção, j. 12.11.2008, DJe 21.11.2008).

Enfim, a competência só será da Justiça Federal quando a Junta Comercial estiver agindo no exercício de delegação de função pública federal, referente aos atos de registro previstos na Lei nº 8.934/1994.

1. Junta Comercial e Departamento de Registro Empresarial e Integração (DREI)

Uma das obrigações basilares do empresário é fazer o registro da empresa na **Junta Comercial**. Esse registro **deverá ser feito antes de suas atividades**.

O registro das empresas na Junta Comercial constitui um sistema integrado por órgãos, que vão além da Junta Comercial.

Quando se fala em registro de empresas, haverá dois órgãos:

- Junta Comercial;
- Departamento de Registro Empresarial e Integração (DREI).

1.1. Departamento de Registro Empresarial e Integração (DREI)

É o órgão máximo do ponto de vista técnico, responsável por supervisionar o registro das empresas feito pelas Juntas Comerciais, expedir normas com relação a como elas deverão atuar, bem como fiscalizar a atuação das Juntas.

Caso as Juntas não cumpram com as suas determinações, **não poderá** o DREI atuar diretamente nelas, visto que se trata de um órgão federal, e a Junta Comercial é um órgão estadual ou distrital. Diante disso, deverá representar ao secretário da fazenda do Estado ou do Distrito Federal ou mesmo ao Governador.

Compete ao DREI organizar e manter o cadastro nacional das empresas mercantis. É um banco de dados, não substituindo o registro da empresa na junta comercial.

1.2. Junta Comercial

A junta comercial é um órgão estadual ou distrital, ao qual cabe a execução do registro da empresa.

Além das funções previstas no art. 32 da Lei nº 8.934/94, atinentes à matrícula, ao arquivamento e autenticações de documentos empresariais, há outras de competência das Juntas Comerciais, a exemplo das previstas no art. 8º da mesma lei, entre as quais:

- **fazer o assentamento dos usos e práticas mercantis:** é uma herança da ideia de que no âmbito mercantil há uma força do direito consuetudinário das práticas mercantis;
- **habilitação e a nomeação de tradutor público e intérprete comercial:** o tradutor público e o intérprete comercial compõem uma categoria paracomercial, uma vez que está ao lado do comércio e da empresa, apesar de ser sua nomeação feita pela junta comercial.

A subordinação da junta comercial é **híbrida**, visto que:

- **matéria técnica:** deve se submeter às orientações do DREI;



- **matéria administrativa e financeira:** deve se submeter ao Poder Executivo Estadual ou Distrital.

A Junta Comercial, quando analisa os documentos, **está adstrita aos aspectos formais** dos documentos, não sendo necessário se preocupar se o documento é materialmente verdadeiro, bastando que seja formalmente verdadeiro.

1.3. Atos de registro de empresa

Ao contrário do DREI, que tem principalmente a função de normatização dos registros de empresa, as Juntas Comerciais têm funções mais específicas, pois são elas que efetuam e administram os atos e serviços de registro dos empresários.

São três os atos de registro praticados pelas Juntas Comerciais: arquivamento, matrícula e autenticação.

Arquivamento: dos atos constitutivos da sociedade empresária e do empresário individual e seus respectivos atos consecutórios. Além do contrato social, por exemplo, serão arquivadas na Junta Comercial todas as alterações contratuais.

Matrícula: refere-se a alguns profissionais específicos, os auxiliares de comércio (tradutores, leiloeiros, administradores de armazéns-gerais). Para que possam exercer suas atividades, devem estar devidamente matriculados na Junta Comercial. A Junta atua como se fosse um órgão regulamentador da profissão (comparação grosseira apenas para fins de memorização).

Autenticação: não deve ser confundida com a autenticação de documentos efetivada em cartório. Trata-se da autenticação dos documentos de escrituração contábil do empresário, dos livros empresariais. A Junta irá verificar se os livros estão em conformidade com os requisitos intrínsecos e extrínsecos de contabilidade, procedendo à sua autenticação em caso positivo, pois tais livros podem, inclusive, ser instrumentos de prova em litígios.

1.4. Registro das Cooperativas

As cooperativas são um tipo societário *sui generis*, consideradas sociedades simples por determinação legal, consoante parágrafo único do artigo 982 do Código Civil: “independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações; e, simples, a cooperativa”, submetendo-se, em tese, ao registro no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, não nas Juntas Comerciais.

CC, Art. 1.150. O empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao Registro Público de Empresas Mercantis a cargo das Juntas Comerciais, e a sociedade simples ao Registro Civil das Pessoas Jurídicas, o qual deverá obedecer às normas fixadas para aquele registro, se a sociedade simples adotar um dos tipos de sociedade empresária.

Todavia, o art. 18 da Lei nº 5.764/1971 (Lei do Cooperativismo) e o art. 32, II, “a” da Lei nº 8.934/1994 preveem que as cooperativas devem ser registradas nas Juntas Comerciais.

Enunciado 69 das Jornadas de Direito Civil: “as sociedades cooperativas são sociedades simples sujeitas à inscrição nas Juntas Comerciais”.

1.5. Regras importantes (cobradas em provas)

Publicidade:



@cpiuris



www.cpiuris.com.br



contato@cpiuris.com.br



Art. 29. Qualquer pessoa, sem necessidade de provar interesse, poderá consultar os assentamentos existentes nas juntas comerciais e obter certidões, mediante pagamento do preço devido.

Prazo para realização:

Art. 36. Os documentos referidos no inciso II do art. 32 deverão ser apresentados a arquivamento na junta, dentro de 30 (trinta) dias contados de sua assinatura, a cuja data retroagirão os efeitos do arquivamento; fora desse prazo, o arquivamento só terá eficácia a partir do despacho que o conceder.

Atente-se: se dentro dos 30 dias os efeitos serão *ex tunc*, ultrapassado esse prazo, os efeitos serão *ex nunc*.

Análise feita pela Junta (forma x mérito):

Art. 40. Todo ato, documento ou instrumento apresentado a arquivamento será objeto de exame do **cumprimento das formalidades legais pela junta comercial**. § 1º. Verificada a existência de vício insanável, o requerimento será indeferido; quando for sanável, o processo será colocado em exigência.

Decisão colegiada x decisão singular:

Art. 41. Estão sujeitos ao regime de decisão colegiada pelas juntas comerciais, na forma desta lei: I - o arquivamento: a) dos atos de constituição de sociedades anônimas, bem como das atas de assembléias gerais e demais atos, relativos a essas sociedades, sujeitos ao Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins; b) dos atos referentes à transformação, incorporação, fusão e cisão de empresas mercantis; c) dos atos de constituição e alterações de consórcio e de grupo de sociedades, conforme previsto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976; II - o julgamento do recurso previsto nesta lei.

Art. 42. Os atos próprios do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, não previstos no artigo anterior, serão objeto de decisão singular proferida pelo presidente da junta comercial, por vogal ou servidor que possua comprovados conhecimentos de Direito Comercial e de Registro de Empresas Mercantis.

Esses artigos explicam como são tomadas as decisões em uma Junta Comercial.

As Juntas Comerciais têm estrutura administrativa, e os membros das Juntas Comerciais que analisam os atos são chamados de **vogais**, três vogais formam **turmas**, que se reúnem, eventualmente, em plenário.

Alguns atos podem ser objeto de decisão monocrática e outros devem ser objeto de decisão colegiada, sendo essas as quatro hipóteses elencadas no artigo 41 supratranscrito.

As Juntas Comerciais não podem criar exigências não previstas na lei como condição para registro do ato. Algumas Juntas, por exemplo, exigem certidão de regularidade fiscal para o registro de alteração contratual, mas o STJ tem entendido que tal exigência é ilegítima, porque não está prevista na lei de regência (Lei nº 8.934/1994) nem em seu decreto federal regulamentar (Decreto 1.800/1996).

Junta comercial. Exigência de regularidade fiscal estadual para registro de atos constitutivos e suas respectivas alterações. Ilegalidade. 1. **A exigência de certidão de regularidade fiscal estadual para o registro de alteração contratual perante a Junta Comercial não está prevista na lei de regência (Lei n. 8.934/1994), nem no decreto federal que a regulamentou (Decreto n. 1.800/1996), mas em decreto estadual, razão pela qual se mostra ilegítima.** 2. Recurso especial conhecido, mas não provido.



(REsp 724.015/PE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 15.05.2012, DJe 22.05.2012).

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUNTA COMERCIAL. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL PREVISTA EM DECRETO ESTADUAL. PRECEDENTES DA CORTE. 1. **Não é possível a exigência de apresentação de certidão de regularidade fiscal como condição para arquivamento de alteração contratual por decreto estadual, pois não preenche o requisito do art. 34 do Decreto n. 1800, que regulamentou a Lei Federal n. 8.934/94. Precedente da Segunda Seção.** 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1256469/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe 05/10/2016)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. JUNTA COMERCIAL. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA TRIBUTÁRIA. ANTINOMIA JURÍDICA DE SEGUNDO GRAU. CONFLITO ENTRE O CRITÉRIO CRONOLÓGICO E O DA ESPECIALIDADE. HIPÓTESE DE PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO CRONOLÓGICO. PREVALÊNCIA DA LIVRE INICIATIVA. 1. Exigência, por Junta Comercial, de certidões negativas tributárias como condição para o arquivamento de ato de transformação de sociedade simples em sociedade empresária. 2. Antinomia jurídica entre a Lei 8.934/94, ao regular o registro público de empresas mercantis e atividades afins, e leis tributárias específicas anteriores. 3. Possibilidade de aplicação do critério cronológico ou do critério da especialidade, caracterizando um conflito qualificado como "antinomia de segundo grau". 4. Prevalência excepcional do critério cronológico. Precedente da Terceira Turma. 5. Derrogação tácita dos dispositivos de leis tributárias anteriores que condicionavam o ato de arquivamento na Junta Comercial à apresentação de certidão negativa de débitos. 6. Interpretação condizente com o princípio constitucional da livre iniciativa. (REsp 1393724/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2015, DJe 04/12/2015)

1.6. Processo decisório do registro de empresa

Existem dois regimes de execução do registro de empresa:

- decisão colegiada;
- decisão singular.

1.6.1. Decisão colegiada

A decisão colegiada está ligada ao arquivamento de atos relativos à sociedade anônima, que são atos mais complexos e que dependem de decisão colegiada.

Esse regime decisório será de forma colegiada quando for arquivamento de transformação, incorporação, fusão, cisão de sociedade empresária de qualquer tipo. Essa decisão está ligada a algo complexo.

A Junta Comercial possui **dois órgãos colegiados**:

- **Plenário;**
- **Turmas.**

Há no mínimo 11 vogais e no máximo 23 vogais.

Sendo 11 os vogais, haverá a **exclusão do presidente e do vice-presidente**, visto que não compõem as turmas. Nesse caso, haverá 3 turmas com 3 membros cada.

As decisões colegiadas **competem às Turmas**.



1.6.2. Decisão singular

Geralmente, as decisões singulares compreendem matrícula, autenticação e todos os demais arquivamentos.

Quem determina a prática do ato de registro é o presidente da turma, ou um vogal que seja por ele designado. A lei ainda permite que um **funcionário da Junta Comercial tenha a designação dada pelo presidente da turma para promover o arquivamento.**

O julgamento do recurso praticado pela Junta sempre se faz pelo regime da decisão colegiada, e a instância é o Plenário. Ainda que a decisão seja singular, **se houver recurso, a decisão será colegiada, devendo a instância competente ser o Plenário (art. 46 da Lei nº 8.934/94).**

1.7. Inatividade da empresa

Se o empresário **não proceder qualquer arquivamento no período de 10 anos**, deverá comunicar a Junta Comercial de que está em atividade. Caso contrário, cria-se uma presunção de que esteja inativo. Com isso, **a Junta fica autorizada a considerá-lo como inativo.**

A inatividade autoriza o cancelamento do registro e conseqüentemente perda da proteção do nome empresarial, podendo outro interessado registrar sociedade com o mesmo nome empresarial.

1.8. Empresário irregular

Quando se fala em empresário irregular, quer-se dizer que não está atuando regularmente, mas **não deixa de ser empresário.**

O empresário não registrado é considerado empresário irregular. Pelo fato de não estar em uma situação regularizada, sofrerá algumas restrições legais, entre as quais:

- **não pode requerer a falência de um devedor**, mas **pode pedir a sua autofalência**, e outro **credor também poderá pedir a sua falência**;
- **não tem legitimidade para requerer recuperação judicial**, pois um dos requisitos para que seja admitida é que esteja no exercício **regular** da atividade por dois anos;
- **não consegue ter livros autenticados na Junta Comercial.** A consequência da autenticação é a de que os livros tenham eficácia probatória, motivo pelo qual não poderá se utilizar do livro como meio de prova. Se a falência for decretada, será considerada fraudulenta, incorrendo em crime falimentar;
- **se o caso é de sociedade empresária, e ela está em situação irregular, pelas responsabilidades sociais, o sócio responderá solidária e ilimitadamente, além de que aquele que administra a sociedade responderá diretamente, não se valendo do benefício de ordem previsto no art. 1.024 do Código Civil.**



CAPÍTULO 5 – LIVROS COMERCIAIS E BALANÇOS

Todos os empresários estão sujeitos, entre outras, às seguintes obrigações:

- registrar-se na Junta Comercial antes de iniciar as atividades;
- escriturar os livros obrigatórios;
- fazer anualmente balanço patrimonial e de resultados econômicos.

1. Escrituração dos livros

Existem duas categorias de empresários que **estão desobrigados de escriturar os livros**:

- microempresários e empresários de pequeno porte;
- microempreendedor individual.

Os microempresários e empresários de pequeno porte que, sendo optantes do Simples Nacional, não terão essa obrigação. Se os microempresários e empresários de pequeno porte não forem optantes do Simples Nacional, eles ficarão sujeitos a um regime especial que é o livro obrigatório denominado de livro caixa. Todavia, **se optar pelo Simples Nacional, não terá obrigação de escriturar qualquer livro**.

1.1. Espécies de livros empresariais

Existem duas espécies:

- obrigatório;
- facultativo.

Quanto aos obrigatórios, há uma subdivisão em:

- **Livro obrigatório comum:** toda sociedade empresária ou empresário deverá ter esse livro. Atualmente, fala-se no **livro-diário** como sendo o livro obrigatório comum a todas as sociedades empresárias ou empresário.
- **Livros obrigatórios especiais:** não são todas as sociedades que deverão ter esses livros, mas sim determinadas categorias que exercem certas atividades. Em relação a livros especiais, existe o livro de registro de duplicatas, por exemplo, que deverá ter todo o empresário que emite duplicata. O livro de entrada e saída de mercadoria para o empresário que exerce atividade com armazéns gerais. O livro de escrituração para as sociedades por ações. Trata-se de **livros obrigatórios, mas especiais**, só sendo necessário para determinadas atividades. Em outras palavras, sendo integrante de determinadas atividades, esses livros especiais serão obrigatórios.

O livro empresarial deverá atender a dois requisitos:

- **Requisitos intrínsecos:** são ligados à contabilidade, tendo relação com a técnica contábil, estando escriturados por ordem cronológica, etc.
- **Requisitos extrínsecos:** são dois:
 - **Termo de encerramento de abertura do livro;** e
 - **Autenticação pela junta comercial:** não sendo autenticado, perderá a eficácia probatória.

Atualmente, a escrituração é feita basicamente por meio eletrônico, mantido em um ambiente da internet pela Receita Federal. **Para fins penais, os livros mercantis se equiparam a documentos públicos.**



1.2. Consequências na irregularidade da escrituração

Havendo irregularidade intrínseca ou extrínseca, **não haverá mais eficácia probatória** concedida legalmente aos livros empresariais.

Caso seja **requerida a exibição de um livro obrigatório** contra o empresário, e no caso de ele não possuir esse livro, ou possuí-lo, mas não estando esse regular, ou seja, **não autenticado ou não preenchendo os requisitos, a lei presumirá verdadeiros os fatos relatados pelo requerente (presunção relativa)**.

No **campo penal**, haverá uma consequência grave, pois **se não há autenticação dos livros empresariais, em caso de falência, haverá crime falimentar**, que é a conduta de deixar de autenticar os livros de escrituração contábil obrigatórios, antes ou depois da sentença que decreta falência, ou concede recuperação judicial, ou homologa o plano de recuperação. **A falência é necessariamente fraudulenta nesse caso.**

Os livros empresariais **deverão ser mantidos até que haja a prescrição** das obrigações neles contidas.

1.3. Exibição judicial e eficácia probatória dos livros

Os livros comerciais podem ser utilizados como meios de prova. Em tese, os livros deverão observar o **princípio do sigilo**, pois há que se proteger a concorrência.

A exibição total dos livros só pode ser determinada pelo juiz, e em algumas ações, devendo haver **requerimento da parte**, como nos casos de:

- sucessão;
- ingresso na sociedade;
- retirada da sociedade.

O Código Civil autoriza que o juiz exiba integralmente os livros e papéis de escrituração quando necessário para resolver questões relativas à sucessão, à comunhão ou sociedade, à administração ou gestão à conta de outrem, ou em caso de falência.

A exibição parcial dos livros poderá ser determinada pelo juiz, inclusive de ofício, e em qualquer ação. Já a **exibição total** do livro somente irá ocorrer quando se mostrar **imprescindível, não podendo o juiz decretar de ofício.**

Atente-se que **somente na falência é que o juiz poderá de ofício determinar a exibição total dos livros.**

O livro empresarial vai provar contra o seu titular, pois, conforme art. 417 do CPC, os livros empresariais provam contra seu titular, **sendo permitido ao empresário, todavia, demonstrar, por todos os meios, que os lançamentos não correspondem à verdade dos fatos.** Por outro lado, o art. 418 estabelece que **os livros empresariais provam a favor de seu autor no litígio entre empresários**, mas é preciso que **o livro preencha os requisitos intrínsecos e extrínsecos.**

Em outras palavras, se for para prejudicar quem não se mostrou prudente, não precisará preencher os requisitos intrínsecos e extrínsecos. Porém, **se for para beneficiar quem está apresentando o livro, deverá ele estar absolutamente regular.**

O princípio do sigilo, na verdade, **não exime o titular de exibir esse livro para determinadas autoridades administrativas**, como a **autoridade fiscal**, e para a **fiscalização da seguridade social.**

2. Balanços anuais

Em relação aos balanços anuais, o balanço patrimonial consiste na demonstração da situação real da empresa, por meio da indicação de seu ativo e de seu passivo (art. 1.188 do CC).



Já o balanço de resultado econômico serve para apontar os lucros e as perdas do ano (art. 1.189 do CC).

Registre-se, porém, que as **instituições financeiras deverão fazer esses balanços semestralmente**.

Sendo decretada a falência, será considerado crime falimentar a inexistência desses documentos de escrituração contábil obrigatório: balanço patrimonial e balanço de resultado econômico.



CAPÍTULO 6 – ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL

1. Conceito

Estabelecimento é todo conjunto de bens organizado pelo empresário para exercício da empresa.

É comum associar a expressão estabelecimento empresarial, num primeiro momento, ao local onde é exercida a atividade econômica, mas o conceito jurídico de estabelecimento empresarial é mais complexo. De acordo com o art. 1.142 do Código Civil, “considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária”. Assim, o estabelecimento é, na verdade, um conjunto de bens, **materiais ou imateriais**, que o empresário organiza e utiliza no exercício da sua atividade.

Conforme já decidiu o STJ,

o estabelecimento comercial é composto por patrimônio material e imaterial, constituindo exemplos do primeiro os bens corpóreos essenciais à exploração comercial, como mobiliários, utensílios e automóveis, e, do segundo, os bens e direitos industriais, como patente, nome empresarial, marca registrada, desenho industrial e o ponto (REsp 633.179/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02.12.2010, DJe 01.02.2011).

O “ponto” é o local onde se exerce a atividade, qualificado pelo fato de ali se exercer uma atividade econômica. Bem imaterial importante, quando analisado sob a ótica da Lei de Locações, por exemplo.

Quando se trata de locação empresarial, o empresário tem direito à renovação do contrato de aluguel, quando presentes certos requisitos previstos no art. 51 da Lei de Locações de Imóveis Urbanos (Lei nº 8.245/91). São eles:

Art. 51. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito a renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente:

- I - o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado;
- II - o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos;
- III - o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos.

Ainda que não consiga a renovação do contrato de aluguel, em virtude de uma das exceções legais (art. 52), eventualmente o locatário poderá ser indenizado pela perda do ponto (§ 3º do art. 52 da Lei nº 8.245/91).

2. Natureza Jurídica

Atenção: tema recentemente cobrado em prova de magistratura.

Todos os professores e doutrinadores dizem que o estabelecimento comercial tem natureza jurídica de uma **universalidade de fato**, porém, na prova supracitada, o examinador entendeu como correto aferir ao estabelecimento comercial a natureza jurídica de universalidade de direito. Opinião minoritária.

Prevalecem, na doutrina, as teorias universalistas sobre a natureza jurídica do estabelecimento empresarial. Assim, considera-se o estabelecimento empresarial uma **universalidade de bens**.



As universalidades de bens são conjuntos de bens aos quais se dá uma destinação específica, passando a serem vistos como “uma coisa só”, como uma universalidade, deixando de serem considerados de forma individual.

As universalidades podem ser de fato ou de direito. De acordo com o art. 90 do Código Civil, “constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que, pertinentes à mesma pessoa, tenham destinação unitária”. O art. 91, por sua vez, prevê que “constitui universalidade de direito o complexo de relações jurídicas, de uma pessoa, dotadas de valor econômico”.

Majoritariamente, os juristas consideram o estabelecimento empresarial como uma universalidade de fato, seguindo o entendimento de Oscar Barreto Filho, autor de obra clássica sobre o tema (vide CRUZ, 2014). Com efeito, a definição de estabelecimento prevista no art. 1.142 do Código Civil deixa claro que ele é uma pluralidade de bens singulares (conjunto organizado de bens materiais e/ou imateriais), que pertence a uma mesma pessoa (o empresário, a EIRELI ou a sociedade empresária) e que possui destinação específica (exercício de uma atividade empresarial).

Há, também, uma classificação doutrinária que diz que o que diferencia a universalidade de fato ou de direito é que, na universalidade de fato, a reunião dos bens se dá por ato de vontade, e na universalidade de direito, a reunião dos bens se dá por determinação legal, por exemplo, o espólio e a massa falida.

3. Alienação de estabelecimento empresarial

O contrato que envolve a alienação, a transferência, a negociação do estabelecimento comercial é chamado de trespasse, tratando-se de um contrato solene, que exige o cumprimento de algumas formalidades específicas.

Art. 1.144 do CC. O contrato que tenha por objeto a alienação, o usufruto ou arrendamento do estabelecimento, só produzirá efeitos quanto a terceiros depois de averbado à margem da inscrição do empresário, ou da sociedade empresária, no Registro Público de Empresas Mercantis, e de publicado na imprensa oficial.

Portanto, deverá ser celebrado por escrito, pois será registrado na Junta Comercial e só produzirá efeitos perante terceiros após a averbação à margem da inscrição do empresário (que está vendendo), e publicado na imprensa oficial.

Cuidado: esse não é um requisito de validade do contrato, mas condição de eficácia perante terceiros (incidência de pegadinha em provas).

Art. 1.145 do CC. Se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores, ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, em trinta dias a partir de sua notificação.

Esse artigo estabelece que se o empresário quiser vender seu estabelecimento comercial para outrem, deve tomar o cuidado de guardar bens suficientes de seu patrimônio para garantia dos credores, ou deverá obter o consentimento desses, por meio de notificação da intenção de venda. A anuência dos credores poderá ser **expressa ou tácita**, ocorrendo essa última quando os credores forem notificados e permanecerem silentes **após o prazo de 30 dias**.

Se restar **no patrimônio do alienante bens suficientes para solver a sua dívida** perante os credores, dispensa-se sua anuência.

Se o empresário não observa a cautela de requerer a anuência dos credores, **poderá ter sua falência decretada**, hipótese na qual o trespasse será considerado ineficaz perante os credores.



4. Sucessão Empresarial

O art. 1.146 do Código Civil trata da sucessão empresarial, estabelecendo que

Art. 1.146. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação*, e, quanto aos outros, da data do vencimento.

Atente-se: esse tema é muito cobrado em prova.

Somente as dívidas contabilizadas – isto é, constantes da escrituração regular do empresário alienante – são assumidas pelo empresário adquirente, mas aquele não se livra de tais dívidas de imediato, já que permanece solidariamente responsável por elas durante o **prazo de um ano**. Tal prazo será contado de maneiras distintas, a depender do vencimento da dívida em questão: tratando-se de dívida já vencida, conta-se um ano a partir da publicação do contrato de trespasse na imprensa oficial; tratando-se, em contrapartida, de dívida vincenda, conta-se um ano a partir do dia de seu vencimento. Em outras palavras, se a alienação ocorreu em janeiro, mas a dívida (contraída pelo alienante antes da alienação) apenas venceu em abril, o alienante ficará responsável até abril do ano subsequente.

O adquirente não vai responder pelas obrigações do alienante no caso de compra do estabelecimento empresarial no caso de recuperação judicial ou falência. Isso porque a lei de falência exime o adquirente, como modo de se tornar atraente a aquisição da empresa e, com isso, prestigiar-se o princípio da preservação da empresa.

IMPORTANTE: essa sistemática de sucessão obrigacional prevista no art. 1.146 do Código Civil só se aplica às dívidas negociais do empresário (por exemplo, dívidas com fornecedores ou financiamentos bancários). Em se tratando, todavia, de dívidas tributárias ou dívidas trabalhistas, aplicam-se os regimes próprios de sucessão previstos na legislação específica (arts. 133 do CTN e art. 448 da CLT, respectivamente)

Em relação ao **credor tributário**, ficará sujeito a algumas proteções específicas. Isso porque o adquirente terá, nesse caso, uma responsabilidade subsidiária ou responsabilidade integral frente ao credor tributário:

- **Responsabilidade subsidiária:** ocorrerá quando o alienante continuar exercendo atividade;
- **Responsabilidade integral:** ocorrerá quando o alienante deixar de exercer a atividade.

Ainda sobre o trespasse e seus efeitos obrigacionais, o art. 1.148 do Código Civil determina que,

salvo disposição em contrário, a transferência [do estabelecimento empresarial] importa a sub-rogação do adquirente nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento, **se não tiverem caráter pessoal**, podendo os terceiros rescindir o contrato em noventa dias a contar da publicação da transferência, se ocorrer justa causa, ressalvada, neste caso, a responsabilidade do alienante.

Assim, todos os contratos relacionados à exploração da atividade empresarial que o empresário alienante mantinha serão continuados pelo empresário adquirente, salvo aqueles que possuem caráter pessoal (*intuitu personae*).

IMPORTANTE: existe uma discussão a respeito da aplicação dessa regra ao contrato de locação, em virtude de haver divergência sobre a natureza pessoal dessa espécie contratual. O entendimento que tem **prevalecido** na doutrina, porém, é pela **interpretação extensiva do art. 1.148 do Código Civil**, afirmando-se que em eventual contrato de locação firmado pelo



empresário alienante haverá, sim, a sub-rogação do empresário adquirente. Nesse sentido, confira-se o teor do enunciado 8 das Jornadas de Direito Comercial do CJF: “a sub-rogação do adquirente nos contratos de exploração atinentes ao estabelecimento adquirido, desde que não possuam caráter pessoal, é a regra geral, incluindo o contrato de locação”.

Ainda sobre o trespasse e seus efeitos obrigacionais, o art. 1.149 do Código Civil prevê que “a cessão dos créditos referentes ao estabelecimento transferido produzirá efeito em relação aos respectivos devedores, desde o momento da publicação da transferência, mas o devedor ficará exonerado se de boa-fé pagar ao cedente”.

Assim, da mesma forma que o empresário adquirente assume as dívidas contabilizadas do empresário alienante, ele assume também todo o ativo contabilizado. Sendo assim, efetuada a transferência, a partir do registro na Junta Comercial, cabe aos devedores pagarem ao empresário adquirente do estabelecimento. Caso, entretanto, esses devedores paguem, de boa-fé, ao antigo titular do estabelecimento – ou seja, ao empresário alienante – ficarão livres de responsabilidade pela dívida, cabendo ao adquirente, nesse caso, cobrar do alienante, que recebeu os valores de forma indevida, uma vez que já havia transferido seus créditos quando da efetivação do trespasse.

5. Cláusula de não-concorrência ou não-restabelecimento

É comum que nos contratos de trespasse as partes pactuem expressamente uma cláusula de não concorrência, na qual se estabelece a obrigação do empresário alienante de não concorrer com o empresário adquirente por certo período.

O objetivo dessa cláusula é **evitar o desvio de clientela**. Com efeito, o **empresário adquirente** do estabelecimento empresarial **espera “herdar” a clientela do empresário alienante**, e o restabelecimento deste – em igual ramo de atividade, na mesma área geográfica e num curto espaço de tempo – pode frustrar essa legítima expectativa.

Mesmo que essa cláusula não seja pactuada, porém, a obrigação do empresário alienante de não concorrer com o empresário adquirente existirá, nos termos art. 1.147 do Código Civil, que assim dispõe: “não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente, nos cinco anos subsequentes à transferência”.

Portanto, considera-se implícita a cláusula de não concorrência nos contratos de trespasse, ressalvando-se, porém, a possibilidade de as partes pactuarem essa questão em outros termos. Assim, é possível que se permita o imediato restabelecimento do empresário alienante ou que, em sentido oposto, determine-se que a obrigação de não concorrência se estenda por mais de cinco anos.

Cuidado: O STJ já disse que é possível controlar a validade dessa cláusula caso seja pactuado um prazo muito longo ou indeterminado, podendo configurar cláusula ilegal. Autoriza-se prazo superior a cinco anos, desde que estipulado dentro de limites razoáveis, à luz de critérios espaciais, temporais e materiais, conforme visto no capítulo 3, item 1.3, desta obra.

6. Proteção ao ponto empresarial (locação empresarial)

A proteção ao ponto trata da denominada locação empresarial.

Primeiramente, o lugar onde o empresário está é relevante para o sucesso ou fracasso da empresa. A lei enxerga que o valor do estabelecimento está relacionado ao local em que o estabelecimento está, devendo ser protegida a pessoa que faz a locação empresarial.

No direito brasileiro, há duas espécies de locação: a residencial e a não residencial.

Se a **locação não residencial** atender a determinados requisitos, será classificada como **locação empresarial** (por empresário: ficam excluídos o profissional liberal, associação,



fundação, sindicato, etc.). Sendo assim classificada, para proteger o empresário, a lei assegura a denominada **renovação compulsória do contrato de locação**.

Os requisitos para a renovação compulsória são:

- **Contrato escrito e por prazo determinado;**
- **Prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos:** é admitida a soma de prazos de contratos renovados sucessivamente, desde que haja esta renovação por acordo. Admite-se que neste prazo se contabilize o prazo em que o sucedido estava lá, situação na qual o sucessor acrescentará o prazo para fins de renovação. A súmula 482 do STF diz que o locatário, que não for sucessor ou cessionário do que o precedeu na locação, não pode somar os prazos concedidos a esse, para pedir a renovação do contrato, nos termos do Decreto nº 24.150. Por sua vez, o STJ já entendeu que pequenos lapsos temporais entre o fim de um contrato anual e o contrato subsequente entre as mesmas partes, necessários para a formalização dos ajustes da renovação do contrato, não afastam a caracterização do prazo mínimo de 5 anos ininterruptos exigidos pela lei.
- **locatário deverá estar explorando o mesmo ramo de atuação pelo prazo mínimo de 3 anos na data de propositura da ação renovatória.**

A ação em que se busca a renovação compulsória deverá ser proposta no último ano de vigência do contrato até o prazo de 6 meses antes do vencimento do contrato. Então deverá ser proposta no prazo de 1 ano a 6 meses antes do término do contrato que se pretende renovar. Caso a ação não seja proposta no prazo, haverá a decadência da renovação do direito.

Existem casos em que essa renovação compulsória, apesar de cumpridos esses requisitos, não ocorrerá. Nesse caso, a atividade da empresa, livre iniciativa e proteção da empresa, não vai se sobrepor ao direito de propriedade.

Vale lembrar que **não é necessária a citação do fiador** para a renovação compulsória, visto que a própria lei não exige.

Com base nesta ideia, **é possível entender as exceções legais que desautorizam a renovação compulsória, apesar de preenchidos seus requisitos:**

- **Insuficiência da proposta de renovação apresentada pelo locatário**
- **Se houver uma proposta melhor de terceiro**
- **Reforma substancial no prédio:** a reforma poderá ser por vontade do locador ou do poder público e deverá ser substancial. **Caso se passem 3 meses sem que iniciem as obras, a lei determina que é cabível uma indenização ao locatário.**
- **Para uso próprio:** é possível que se obste a renovação compulsória quando houver o interesse do bem para uso próprio, desde que não seja no mesmo ramo de atividade do locatário, salvo se a locação também envolvia fundo de comércio. que realizava o locatário. Fabio Ulhoa Coelho admite que seja obstada a renovação nesse caso. A lei estabelece que para uso da mesma atividade não caberia a retomada, mas **se se tratar de um caso de locação-gerência, haveria a possibilidade de retomada do bem.** A locação-gerência ocorre nos casos em que a locação compreende não só o imóvel, mas o estabelecimento lá instalado. Isto é, se o indivíduo aluga um galpão e monta um restaurante, o locador não poderá mandar embora o locatário para montar outro restaurante. Todavia, se alugou para o indivíduo o próprio restaurante, não há dúvidas de que o locador poderá mandar embora o locatário para gerenciar o restaurante.
- **Transferência do estabelecimento empresarial que existe há mais de um ano, sendo titularizado por descendente, ascendente ou cônjuge do locador, ou por uma sociedade que eles integrem, e desde que este estabelecimento seja de ramo diverso do locatário:** por exemplo, a mulher do locador, que tem loja no bairro X, quer transferir-se para o bairro Y, onde está a locação do locatário. O locatário, neste



caso, terá direito a uma indenização, se o novo usuário acabar exercendo a mesma atividade que a anterior.

Atente-se que, em se tratando de sublocação total do imóvel, **o direito a renovação somente poderá ser exercido pelo sublocatário.**

Em se tratando de locação empresarial em Shopping Center, a situação muda de contexto. Com efeito, em um Shopping Center, há o **tenant mix**, sendo o espaço em que há uma distribuição de produtos e serviços que tornem o complexo atraente ao cliente. Não há como pensar em shopping center com 20 farmácias, razão pela qual há uma preocupação com o *tenant mix*, ou seja, preocupação com a oferta e variedade para o cliente.

A lei reconhece o direito de interesse do locatário, mas em determinadas situações esta renovação compulsória não se sustenta. Isso porque, se for garantida a renovação compulsória para o locatário que preenche os requisitos legais, poderá haver o prejuízo e impedimento de desenvolvimento daquele complexo.

Então, Fabio Ulhoa diz que o direito do lojista não pode esvaziar o direito de propriedade do empreendedor do shopping center. Em outras palavras, **se o locador do shopping center não conseguir realizar devidamente o tenant mix com aquele locatário, deverá haver uma rejeição ou não acolhimento da ação de renovação compulsória.**

7. Proteção ao título de estabelecimento

O elemento de **identificação do estabelecimento empresarial é o seu título**, que é diferente do seu nome empresarial, que é o nome do sujeito-empresário, sendo também diferente da marca, que é a identidade do produto.

Para proteção do estabelecimento empresarial, haverá os casos de responsabilidade civil e de responsabilidade penal, se o título empresarial causou um efetivo desvio de clientela, razão pela qual teria havido uma infração de concorrência desleal.

A partir de então, se o sujeito não observa a concorrência leal, colocando o mesmo título de um outro estabelecimento, é plenamente possível que se busque, além da responsabilidade civil, a responsabilidade penal, com base no art. 195, III, da LPI.

8. Comércio eletrônico (internet)

Os canais de venda na internet têm um endereço eletrônico. Por exemplo: cpiuris.com.br. Esses canais eletrônicos possuem o seu nome de domínio.

O nome de domínio possui uma função de **identificação do canal de venda de determinado empresário na rede mundial de computadores**. Então, o nome de domínio acaba cumprindo a mesma função da do título de estabelecimento, com relação ao ponto comercial. Isso porque o nome de domínio faz o mesmo papel do título do estabelecimento.

Por exemplo, se alguém pegasse o nome da “Saraiva” e fizesse uma livraria virtual, de fundo amarelo, incidiria em desvio da clientela.

Por conta disso, é necessário que haja a proteção ao nome empresarial, mas também do título do estabelecimento comercial, uma vez que esse é um dos canais de identificação da clientela.

Se esta proteção não é observada, poderá haver a concorrência desleal, com a responsabilidade civil e penal.

Todavia, no caso do domínio na internet, haverá o registro no Brasil por meio do “**nick.br**”, que é um núcleo de informação e coordenação do “.br”. Trata-se de uma associação de direito privado, voltada para o registro dos domínios no Brasil.



CAPÍTULO 7 — NOME EMPRESARIAL

O nome é um direito da personalidade, mas o **nome empresarial é um elemento do patrimônio do empresário**, sendo um bem incorpóreo. Assim como a pessoa natural possui um nome civil, capaz de identificá-la como sujeito de direitos, os empresários (empresário individual, EIRELI ou sociedade empresária) devem possuir um nome empresarial, que consiste na expressão que os identifica como sujeitos de direitos.

1. Conceito

“Nome empresarial é aquele sob o qual o empresário individual, empresa individual de responsabilidade Ltda. – EIRELI, as sociedades empresárias, as cooperativas exercem suas atividades e se obrigam nos atos a elas pertinentes” (art. 1.º, caput, da IN/DREI 15/2013).

É o **elemento de identificação** do empresário.

Há basicamente duas espécies de nome empresarial:

- **Firma:** deve ter por base um nome civil (do empresário individual ou dos sócios da sociedade empresária), completo ou abreviado acompanhado ou não de designação mais precisa de sua identidade ou ao gênero da atividade (art. 1.156). A firma acaba sendo a sua assinatura, pois quando se faz um contrato social, na assinatura, deverá o empresário assinar, por exemplo, “João da Silva Livros Ltda.”. Essa será a assinatura da sociedade.
- **Denominação:** o mais importante não é o nome dos sócios, visto que a relevância está na descrição do objeto da empresa, esta sim obrigatória na denominação. Poderá haver o acréscimo de eventual nome civil ou de qualquer outra expressão linguística, denominado de elemento fantasia. No caso da denominação, o nome empresarial servirá exclusivamente para elemento de identificação. Ex.: CP Iuris Cursos e Editora Ltda. Eventuais contratos serão assinados com o nome do administrador da sociedade. Ou seja, a denominação, ao contrário da firma, não vale como assinatura.

Atente-se para não confundir o nome empresarial com outros elementos de identificação do empresário:

Nome empresarial: expressão que identifica o empresário como sujeito de direitos. Ex.: CP Iuris Cursos e Editora Ltda.

Nome de fantasia: expressão que identifica o título do estabelecimento. Ex.: CP Iuris.

Marca: expressão que identifica produtos ou serviços do empresário (Um dos direitos de propriedade industrial a ser estudado **posteriormente**). Ex.: o logotipo do CP Iuris, composto por elementos visuais e linguísticos, é uma marca devidamente registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

Nome de domínio: endereço eletrônico dos sites dos empresários na internet.

O que muitas vezes pode gerar confusão é que uma mesma expressão pode ser usada na formação do nome empresarial, nome fantasia, marca e, também, no nome de domínio, como no caso do CP Iuris, porém, ainda assim, são de naturezas distintas, submetendo-se a registros e regimes jurídicos diferentes.

Destaca-se, acerca do nome de domínio, jurisprudência do STJ, que se consolidou:

(...) 1. A anterioridade do registro no nome empresarial no órgão competente não assegura, por si só, ao seu titular o direito de exigir a abstenção de uso do nome de domínio na rede mundial de computadores (internet) registrado por estabelecimento empresarial que também ostenta direitos acerca do mesmo signo distintivo. 2. No Brasil, o registro de nomes de domínio na internet é regido pelo princípio “First Come, First Served”, segundo o qual é concedido o domínio ao primeiro requerente que satisfizer as exigências para o registro. 3. A legitimidade do



registro do nome do domínio obtido pelo primeiro requerente pode ser contestada pelo titular de signo distintivo similar ou idêntico anteriormente registrado – seja nome empresarial, seja marca. 4. Tal pleito, contudo, não pode prescindir da demonstração de má-fé, a ser aferida caso a caso, podendo, se configurada, ensejar inclusive o cancelamento ou a transferência do domínio e a responsabilidade por eventuais prejuízos. (...) (REsp 594404/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 05.09.2013, DJe 11.09.2013).

Assim, o fato de o empresário ter uma marca registrada há muitos anos, não significa ter o direito de domínio sobre a expressão. Se a mesma expressão já havia sido registrada por outrem, o direito a ele assiste, porque o direito de domínio se rege pelo princípio *first come, first served*, ou seja, domínio concedido ao primeiro requerente que satisfizer as exigências para o registro, salvo comprovação de má-fé, que será analisada caso a caso.

2. Princípios do Nome Empresarial

Princípio da veracidade: O nome empresarial não pode conter nenhuma informação falsa, deve identificar de forma fidedigna o empresário.

Exemplo 1: Se atua no ramo de atividade X, este é o ramo que deve constar no nome.

Exemplo 2: Se sócio que constava no nome da empresa vier a falecer, for excluído, ou se retirar, este nome deve ser excluído.

Princípio da Novidade: O nome empresarial deve ser diferente de qualquer outro nome empresarial registrado no mesmo órgão de registro, a fim de se evitar abalo de crédito indevido, confusão entre consumidores, etc.

Assim, o nome fica protegido dentro do Estado em que registrado, uma vez que o órgão competente para o registro é a Junta Comercial, salvo se houve pedido de proteção em todo o território nacional, por meio do registro do nome empresarial nas demais juntas comerciais.

A marca, por sua vez, é protegida em todo território nacional, mas se submete ao princípio da especificidade (apenas no ramo da atividade, exceto se de alto renome), como será visto em momento posterior.

3. Formação do nome empresarial

O **empresário individual** só está autorizado a adotar a **firma**. Caso deseje, poderá colocar em frente ao seu nome ou após o seu nome a atividade que se dedica.

A **sociedade em nome coletivo** também só poderá adotar **firma**. Nesse caso, poderá ter o nome de todos os sócios da sociedade, ou o nome de alguns. Nesse último caso, é preciso que seja acrescida a partícula “e Cia.”. Ex.: Fabiana Perillo, Samer Agi e Daniel Carvalho são os sócios da sociedade, mas caso o nome empresarial conste de apenas um deles deverá ter a partícula “e Cia.”: Samer Agi e Cia. Na sociedade em nome coletivo, é possível que conste a atividade da sociedade.

Na **sociedade em comandita simples**, também só é possível a **firma**. Diante disso, o nome empresarial deverá ter o **nome civil do sócio ou dos sócios comanditados**. Essa sociedade faz uma diferenciação entre sócios comanditados e sócios comanditários. Os comanditados assumem uma responsabilidade administrativa, respondendo pelas dívidas da sociedade, razão pela qual deverá ter o nome do sócio com a partícula “e Cia.” para os demais sócios comanditados. **Os sócios comanditários não podem ter seus nomes aproveitados na firma social**, visto que não detêm responsabilidade ilimitada pelas obrigações da companhia e tampouco podem praticar atos de gestão da sociedade. Também poderá agregar o ramo do negócio no nome empresarial.

Atente-se que a **sociedade em conta de participação** é uma sociedade **despersonalizada**, razão pela qual **não adota nome empresarial**.



A sociedade limitada poderá adotar firma ou denominação. Porém, em qualquer das hipóteses, o nome empresarial não poderá deixar de contemplar a partícula “Ltda.”. Isso porque é preciso informar (princípio da veracidade) que os sócios detêm responsabilidade limitada. Caso não haja a cláusula ou expressão “limitada”, os sócios administradores responderão ilimitadamente.

A empresa individual de responsabilidade limitada poderá adotar firma ou denominação. Todavia, deverá constar ao final a sigla “EIRELI”.

A sociedade anônima só poderá adotar denominação. É obrigatória a identificação do tipo societário de uma S.A. E essa identificação deverá trazer a expressão “S.A.” ou a palavra “Companhia”, devendo esta vir na frente ou no meio da denominação. Ex.: Companhia Vale do Rio Doce; Cantareira Companhia de Fertilizantes. Esta expressão “companhia” não poderá vir ao final, pois poderia confundir com a firma, caso alguns dos sócios não sejam citados. Na sociedade anônima, é possível colocar nome de pessoas que fundaram a companhia, ou que concorrem para o seu bom êxito.

A sociedade em comandita por ações, que também é sociedade estatutária, poderá adotar tanto a firma como a denominação. No caso de firma, adotará apenas os nomes daqueles sócios-diretores ou administradores, visto que esses vão responder ilimitadamente pelas obrigações sociais. Também é obrigatória a inserção do tipo societário no nome empresarial, por meio da expressão “C/A”. Ex.: Transparência C/A. Caso seja fundado no nome civil, é obrigatória a locução “e Cia.” Isso porque assim como na sociedade em comandita simples há um sócio comanditado e um sócio comanditário, há na sociedade em comandita por ações um sócio-diretor que exerce atividade administrativa e um sócio acionista. O sócio-diretor responde ilimitadamente, mas o acionista não poderá constar do nome empresarial. Por conta disso, como parte dos sócios não estará no nome empresarial, é preciso que haja a expressão “e Cia.”, instruindo o contratante para informar que existem outros sócios naquela sociedade.

A sociedade empresária, em recuperação judicial, deverá ainda acrescer ao seu nome, em qualquer ato que ela pratique, a expressão “em recuperação judicial”. Ex.: Beleza cosméticos Ltda. em recuperação judicial.

O microempresário e o empresário de pequeno porte deverão acrescer ao seu nome a locução “ME ou EPP”.

4. Quadro Esquemático (tipo de sociedade: Firma x Denominação)

	FIRMA	DENOMINAÇÃO
Empresário Individual	X	
Em Nome Coletivo	X	
Em Comandita Simples	X	
Anônima		X
Cooperativa		X
Limitada	X	X
Comandita por Ações	X	X
EIRELI	X	X
Em Conta de Participação		

5. Alteração do nome empresarial

O nome empresarial poderá ser alterado. Diferentemente do nome da pessoa física, a pessoa jurídica poderá mudar o nome com a simples vontade do empresário.

No entanto, **existem hipóteses em que a alteração do nome empresarial é obrigatória:**

- **Saída, retirada ou exclusão de um sócio que constava da firma social:** isto se fundamenta no princípio da veracidade, devendo ser obrigatória neste caso.
- **Alteração da categoria do sócio quanto às obrigações sociais:** o sócio que era comanditado e passou a ser comanditário, ou seja, deixou de responder ilimitadamente, não poderá figurar no nome empresarial, sob pena de permanecer a sua responsabilidade ilimitada no caráter subsidiário.
- **Alienação do estabelecimento:** se for previsto em contrato, é possível que o adquirente use o nome do alienante precedido do seu. Neste caso, deverá colocar a qualificação “sucessor de”. Ex.: J Silva Cia. Ltda. Alguém adquiriu este estabelecimento e quer manter o nome, deverá colocar o seu nome na frente: Carlos Antonio Queiroz sucessor de J Silva e Companhia Ltda. O nome empresarial é inalienável, mas o estabelecimento poderá ser alienado.
- **Alteração do tipo societário (transformação):** seja para firma ou para denominação, uma sociedade limitada que se torna sociedade anônima não poderá mais se chamar de sociedade limitada, devendo ser denominada S.A., da mesma forma o contrário. Enfim, em caso de alteração do tipo societário deverá se submeter a uma modificação do nome empresarial de forma obrigatória.
- **Houver lesão a direito de outro empresário:** no caso de concorrência desleal, será feita a alteração pelo empresário que registrou este nome posteriormente, sob pena de a alteração ser coercitiva, sem prejuízo das responsabilidades por perdas e danos.

6. Proteção ao nome empresarial

É necessário proteger o nome empresarial, para se evitar eventual **desvio de clientela**. Por exemplo, abrir uma livraria “Saraivinha” poderia gerar a ideia de que seria uma livraria para livros infantis do mesmo grupo empresarial da livraria Saraiva.

Também é necessário proteger o nome empresarial em razão da **proteção do crédito**. Isso porque se outro empresário sai com nome semelhante e passa a ter títulos protestados, bem como ser impontual com os fornecedores, acabará por comprometer a boa fama da empresa que tem o nome parecido com o dela, apesar de honrar seus compromissos.

Em suma, são dois os fundamentos de proteção do nome empresarial:

- proteger do desvio da clientela;
- proteger o crédito.

No caso de identidade ou de semelhança de nomes, o empresário que anteriormente tenha feito o uso deste nome empresarial terá direito a que se determine ao outro empresário que acresça ao seu nome alguma distinção suficiente. E caso ainda não seja suficiente, poderá mudar o nome completamente.

Segundo o art. 1.163, o nome de empresário deve se distinguir de qualquer outro já inscrito no mesmo registro. Caso o empresário tenha nome idêntico ao de outros já inscritos, deverá acrescentar designação que o distinga.

A lei não diz o que é ser um nome empresarial semelhante ou idêntico, passando este papel a ser exercido pela doutrina. Portanto, considera-se idêntico ou muito semelhante a partir do **núcleo do nome empresarial**.

Se João monta uma sociedade com Carlos chamada de “Primavera Tecidos Ltda.” e outro indivíduo abre outra sociedade chamada de “Companhia Primavera de Tecelagem S.A.”, apesar



de os nomes não serem os mesmos, o núcleo do nome empresarial é o mesmo, uma vez que as pessoas irão dizer que se trata da empresa primavera.

No campo do Direito Penal, haverá sanção no caso de **usurpação do nome empresarial**, configurando crime de concorrência desleal.

7. Nome empresarial x Marca

As formas de proteção ao nome empresarial e à marca comercial não se confundem.

A **tutela do nome empresarial se circunscreve à unidade federativa de competência da Junta Comercial** em que registrados os atos constitutivos da empresa, **podendo ser estendida a todo o território nacional, desde que feito pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas Comerciais.**

Por sua vez, a **proteção à marca obedece ao sistema atributivo, sendo adquirida pelo registro validamente expedido pelo INPI**, que assegura ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, nos termos do art. 129, caput e § 1º, da Lei 9.279/1996 (LPI).

Segundo o STJ, **para que a reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciado de nome empresarial de terceiros constitua óbice ao registro de marca**, a qual que possui proteção nacional, será necessário, nessa ordem:

- proteção ao nome empresarial seja tutelada em todos os Estados da federação;
- reprodução ou imitação seja 'susceptível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos'.

Não havendo esses requisitos, é plenamente possível a convivência entre o nome empresarial e a marca cuja colidência for suscitada.



CAPÍTULO 8 — O EMPRESÁRIO E OS DIREITOS DO CONSUMIDOR

1. Introdução

O presente capítulo tangencia tema que é mais bem aprofundado e cobrado em provas dentro da Disciplina de Direito do Consumidor. Aqui, serão apresentadas apenas noções gerais sobre qualidade do produto ou do serviço e sobre publicidade, remetendo-se o leitor à citada disciplina para estudo completo das questões abaixo ventiladas e outras correlatas.

O conceito de empresário está contido no conceito de fornecedor. Isso significa que todo o empresário é fornecedor, mas nem todo fornecedor é empresário.

2. Qualidade do produto ou do serviço

Quando o CDC trata da qualidade do produto ou do serviço, afirma que, quando o produto peca em sua qualidade, está-se diante de um produto ou serviço perigoso, defeituoso ou viciado. Portanto, são três as hipóteses de fornecimento com qualidade inadequada:

- **fornecimento perigoso:** quando há a utilização de produtos ou serviços que gerem dano em razão das informações prestadas pelo fornecedor. O produto em si não apresenta vício ou defeito, mas o fornecedor não observa o seu dever de informar. Ele deverá informar os riscos do produto, mas não será obrigado a informar sobre os produtos amplamente conhecidos. Ex.: não precisa informar que a faca tem um risco letal, se manuseada no pescoço de alguém;
- **fornecimento defeituoso:** o produto ou serviço apresenta uma impropriedade danosa ao consumidor. Trata-se de um problema intrínseco ao fornecimento. O produto tem um problema. Ex.: ao envazar o refrigerante colocaram mais gás do que o previsto, o que ensejou a quebra da garrafa na mão do consumidor;
- **fornecimento viciado:** o produto ou serviço apresenta uma impropriedade que o torna inócuo. Porém, esta impropriedade não atinge o consumidor, isto é, não causa danos a ele. Em não sendo sanado o vício no prazo máximo de trinta dias, o consumidor poderá adotar uma destas três alternativas (art. 18, §1º, do CDC):
 - **desfazimento do negócio: ação redibitória;**
 - **redução proporcional do preço: ação estimatória.** Ex.: ar condicionado do carro não funciona;
 - **requerer a substituição do produto por outro da mesma espécie: ação executória específica.**

3. Publicidade

Há três formas de publicidades que são consideradas ilícitas:

- **publicidade simulada:** na simulação, procura-se ocultar o caráter de propaganda. A lei deixa clara que a propaganda tenha cara de propaganda. Aqui, coloca-se como se fosse uma notícia no jornal aquilo que seria uma propaganda;
- **publicidade enganosa:** induz o consumidor em erro. Faz com que ele adote um comportamento em razão de uma enganação por conta da propaganda;
- **publicidade abusiva:** agride os valores sociais. É a propaganda racista, discriminatória, lesiva ao meio ambiente, etc.

As informações precisas que o empresário veicula por meio da publicidade integram o contrato que ele vier a celebrar com o consumidor, obrigando o empresário.

Outra espécie de publicidade que foi questionada judicialmente foi a **publicidade comparativa**. Nesse modelo de publicidade, faz-se referência a produto de marca concorrente.



No julgamento do caso, o STJ destacou que tal prática está normatizada na Resolução 126 do Mercosul, embora não haja previsão normativa interna expressa. Há, apenas, menção sobre sua possibilidade no Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária (apesar da nomenclatura, não tem força de lei, é oriundo de entidade privada).

Deve-se observar, todavia, algumas balizas para sua válida aplicação. Devem ser utilizados apenas esclarecimentos objetivos, que informem o consumidor sobre as diferenças dos produtos comparados, sem que se denigre a marca concorrente. Em outras palavras, a publicidade comparativa deve obedecer ao princípio da veracidade das informações, ser objetiva e não abusiva.

Ademais, para que se viole o direito marcário do concorrente, “as marcas devem ser passíveis de confusão ou a referência da marca deve estar cumulada com ato depreciativo da imagem de seu produto/serviço, acarretando a degenerescência e o consequente desvio da clientela” (STJ, REsp 1.377.911).



CAPÍTULO 9 — TEORIA GERAL DO DIREITO SOCIETÁRIO

1. Conceito de sociedade empresária

A sociedade empresária pode ser conceituada, segundo COELHO (2003), como sendo uma pessoa jurídica de direito privado, não estatal, que explora empresarialmente o seu objeto social ou adota a forma de sociedade por ações.

A sociedade empresária é:

- **pessoa jurídica de direito privado**
- **pessoa jurídica não estatal:** se fosse estatal, as regras seriam diferentes. Portanto, mesmo que se trate de uma empresa estatal, a ela não são aplicadas todas as regras, pois há por detrás o princípio do interesse público e a incidência de outras normas específicas, a exemplo do Estatuto das Empresas Estatais (Lei nº 13.303/2016);
- **pessoa jurídica que explora empresarialmente o seu objeto social:** é possível que uma pessoa jurídica não estatal explore o seu objeto social de forma não empresarial, como é o caso de uma clínica formada por dois médicos e uma secretária;
- **pessoa jurídica que adota a forma de sociedade por ações:** toda sociedade por ações é uma sociedade empresária, independentemente de seu objeto.

2. Personalização da sociedade empresária

A sociedade empresária é uma pessoa (jurídica) e tem sócios com personalidade (natural ou jurídica) distinta da sociedade. Em outras palavras, a sociedade é um **sujeito de direito personalizado**.

A partir do momento em que tem personalidade jurídica, poderá praticar todo e qualquer ato ou negócio jurídico, desde que não exista proibição nesse sentido.

EIRELI também é uma pessoa jurídica, mas não se enquadra no conceito de sociedade empresária, tratando-se de novo ente jurídico personalizado (Enunciado 469 das Jornadas de Direito Comercial do CJF). Ele também terá personalidade jurídica distinta.

A personalização das sociedades empresárias gera **consequências**:

- **titularidade negocial:** é a sociedade que assume um dos polos da relação negocial, ainda que o ato ou contrato seja assinado por (re)presentante;
- **titularidade processual:** tem capacidade de ser parte em uma relação processual;
- **autonomia patrimonial:** sociedade empresária tem um patrimônio próprio, distinto do patrimônio de seus sócios;
- **fim da personalidade:** o fim da personalidade da sociedade se dá por meio de um processo denominado de dissolução da sociedade. É uma dissolução em sentido amplo, sendo que o ato de dissolução em sentido estrito será o ato de desfazimento, o qual dará início à liquidação que vai apurar o ativo e pagar o passivo. Por último, se sobrar, haverá a partilha, em que os sócios irão participar do acervo da sociedade. Há outros modos de se extinguir a sociedade, diferentes da dissolução, a exemplo da incorporação, da fusão, da cisão e da falência.

Ao contrário do que ocorre com as pessoas naturais, cujo reconhecimento da personalidade independe de registro, já que “a personalidade civil começa do nascimento com vida” (art. 3º do Código Civil), **as sociedades só adquirem personalidade a partir do registro no órgão competente** (Registro Civil de Pessoas Jurídicas, se for uma sociedade simples, ou Junta Comercial/Registro Público de Empresas Mercantis, se for uma sociedade empresária), conforme previsão do art. 985 do Código Civil: “a sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição, no registro próprio e na forma da lei, dos seus atos constitutivos”.



O Brasil adotou um critério objetivo: apenas o registro confere personalidade jurídica. Assim, constituída uma sociedade sem que se efetue o registro, esta não terá personalidade jurídica, sendo tratada como uma sociedade em comum, que é uma sociedade não personificada. (Assunto que será estudado mais adiante).

IMPORTANTE: as **sociedades de advogados** são sociedades simples, mas seu registro não é feito em Cartório, e sim no Conselho Seccional da OAB em cuja base territorial tiver sede (art. 15, § 1º da Lei nº 8.906/1994). Já as **sociedades cooperativas** são sociedades simples, independentemente do objeto social, mas se registram na Junta Comercial (art. 32, inciso II, alínea 'a' da Lei nº 8.934/1994 e art. 18 da Lei nº 5.764/1971).

Para memorizar: a regra é que a sociedade simples se registre no cartório e sociedade empresária se registre na junta, mas existem exceções — a sociedade de advogados, que é uma sociedade simples, mas se registra na própria OAB, e a cooperativa, que é uma sociedade simples, independentemente do objeto, mas se registra na junta comercial.

3. Desconsideração da personalidade jurídica

De acordo com o art. 1.024 do Código Civil, “os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas da sociedade, senão depois de executados os bens sociais.” Essa regra trata da autonomia patrimonial das sociedades, estabelecendo a responsabilidade subsidiária dos sócios pelas obrigações sociais, responsabilidade essa que pode também ser limitada ao próprio valor da quota do sócio, a depender do tipo societário.

Portanto, enquanto a sociedade possuir bens, são esses bens que devem responder pelas dívidas sociais, o que assegura aos sócios o conhecido **benefício de ordem**. Caso, entretanto, a sociedade não possua mais bens, deve-se verificar o tipo de responsabilidade dos sócios: se for ilimitada (como ocorre na sociedade em nome coletivo, por exemplo), seus bens particulares poderão ser executados; se for limitada (como ocorre na sociedade limitada e na sociedade anônima, por exemplo), seus bens particulares não poderão, em princípio, ser executados.

A situação muda, no entanto, caso se verifique o uso abusivo da personalidade jurídica da sociedade em detrimento dos credores. Configurada essa hipótese, poderá ser determinada a desconsideração da personalidade jurídica, o que permitirá a execução dos bens pessoais dos sócios mesmo que se trate de uma sociedade limitada, por exemplo.

Resumo: em todas as sociedades, a responsabilidade do sócio é, via de regra, subsidiária: enquanto a sociedade tem bens quem responde é a própria sociedade. Em algumas sociedades, a responsabilidade, embora seja subsidiária, é ilimitada, quando a sociedade não tem mais bens, executa-se o sócio. Porém, nas sociedades em que o sócio responde de forma limitada, quando a sociedade não tem mais bens, em princípio não se pode executar os bens dos sócios, salvo se o capital não estiver integralizado, hipótese em que poderá ser executado até o limite da integralização, ou se estiver presente alguma circunstância que admita a desconsideração da personalidade jurídica, hipótese em que será responsabilizado em virtude dessa desconsideração.

A teoria da desconsideração da personalidade jurídica (*disregard doctrine*) já é conhecida há bastante tempo, mas só foi positivada em nosso ordenamento jurídico em 1990, com a edição do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), cujo art. 28 tem a seguinte redação:

Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica **provocados por má administração**.



(...)

§ 5º Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

Há muita crítica em relação a esse dispositivo, no sentido de que o § 5º invalida o *caput*, em razão, principalmente, da expressão “de alguma forma”.

Posteriormente, outros diplomas legislativos específicos também trataram do tema (Lei Antitruste e Lei de Crimes Ambientais), praticamente repetindo a redação do *caput* e do § 5º do art. 28 do CDC. Faltava, porém, uma regra geral sobre o assunto.

Essa regra geral acabou sendo prevista no art. 50 do Código Civil, que tem o seguinte teor original:

Art. 50 em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela **confusão patrimonial**, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.

Em 2019, porém, houve significativa alteração nesse dispositivo pela Lei de Liberdade Econômica, que serão exploradas adiante, quando tratarmos da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica.

3.1. Teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica

Costuma-se usar a expressão teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica para os casos em que se admite a desconsideração quando há o mero prejuízo do credor, ou seja, a simples insolvência da pessoa jurídica.

É o que ocorre, por exemplo, nas relações de consumo, por aplicação da regra específica do art. 28, § 5º do CDC.

Nesse sentido, o STJ já decidiu que

é possível a desconsideração da personalidade jurídica com base no artigo 28, § 5º, do CDC, na hipótese em que comprovada a insolvência da empresa, pois tal providência dispensa a presença dos requisitos contidos no *caput* do artigo 28, isto é, abuso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica, sendo aplicável a teoria menor da desconsideração, subordinada apenas à prova de que a mera existência da pessoa jurídica pode causar, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores (AgRg no Ag 1.342.443/PR).

Enfim, “tratando-se de **relação consumerista**, é possível a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária ante sua insolvência para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial” (AgRg no AREsp 511.744/SP; no mesmo sentido: AgRg no REsp 1.106.072/MS e REsp 737.000/MG).

Norma semelhante se encontra no art. 4º da Lei nº 9.605/98: “Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente”.



3.2. Teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica

Costuma-se usar a expressão teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica para os casos em que só se admite a desconsideração quando há abuso no uso da pessoa jurídica, o qual pode ser caracterizado pelo desvio de finalidade (abuso subjetivo) ou pela confusão patrimonial (abuso objetivo).

Tem-se, aqui, aplicação da regra geral do art. 50 do Código Civil, que tem incidência, predominantemente, no âmbito das relações civis e empresariais, em que as regras de responsabilidade subsidiária e limitada dos sócios devem ser respeitadas, sendo desconsideradas apenas em situações excepcionais. Também é a adotada no art. 14 da Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013).

Assim, quando

se trata de relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas) (AgInt no AREsp 589.840/RS).

Em suma,

conforme entendimento reiterado pelas Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, acerca dos pressupostos para a desconsideração de pessoa jurídica, a partir da interpretação do art. 50 do CC/02, deve ser adotada a teoria maior da desconsideração. Assim, exige-se a demonstração de desvio de finalidade, demonstração de confusão patrimonial, ou a configuração do abuso de personalidade jurídica. (...) A mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações (...) não constitui motivo suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica (REsp 1635630/MG).

Como citado acima, a Lei de Liberdade Econômica promoveu alterações normativas importantes sobre o tema. Em primeiro lugar, passou a constar do caput do art. 50 do CC que a extensão das obrigações sociais deverá recair sobre os administradores ou sócios **“beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”**. Esse já era o entendimento da doutrina e da jurisprudência do STJ, mas agora passou a estar positivado.

Ademais, houve a inclusão de diversos parágrafos que delineiam os contornos das expressões previstas no caput do art. 50 e que regulam as espécies de abuso da personalidade.

3.2.1. Abuso subjetivo da personalidade jurídica

É caracterizado pelo desvio de finalidade.

O novo § 1º do art. 50 deixou claro que “desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza”.

O novo § 5º do mesmo artigo, por sua vez, estabelece que “não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica”.



3.2.2. Abuso objetivo da personalidade jurídica

Caracteriza-se pela confusão patrimonial. Inicialmente sem delineamento normativo, o novo § 2º do art. 50 passou a regulamentar a questão, estabelecendo o seguinte:

Art. 50 (...) § 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

3.3. Efeitos da desconsideração da personalidade jurídica

Outro ponto importante a ser destacado no estudo da *disregard doctrine* é o relativo a seus efeitos. A desconsideração da personalidade jurídica, ao contrário do que se possa imaginar, não acarreta o fim da pessoa jurídica, ou seja, esta não será dissolvida nem liquidada.

Assim, a desconsideração da personalidade jurídica tem os seus **efeitos adstritos ao caso concreto** em que foi requerida, continuando a sociedade – ainda que “desconsiderada” naquele caso – a existir normalmente e a ter os efeitos da sua personalização respeitados em todas as demais relações jurídicas em que figurar. Nesse sentido, já decidiu o STJ que “a desconsideração não importa em dissolução da pessoa jurídica, mas se constitui apenas em um ato de efeito provisório, decretado para determinado caso concreto e objetivo, dispondo, ainda, os sócios incluídos no polo passivo da demanda, de meios processuais para impugná-la” (REsp 1.169.175/DF).

Da mesma forma, a aplicação da teoria da desconsideração não significa a possibilidade de execução de todos os sócios e/ou administradores da sociedade, indistintamente. **Somente serão atingidos aqueles sócios que se beneficiaram do uso abusivo da pessoa jurídica.** Nesse sentido, também já decidiu o STJ que, “nos termos do art. 50 do CC, o decreto de desconsideração da personalidade jurídica de uma sociedade somente pode atingir o patrimônio dos sócios e administradores que dela se utilizaram indevidamente, por meio de desvio de finalidade ou confusão patrimonial” (REsp 1.412.997/SP; no mesmo sentido: AgRg no AREsp 621.926/RJ).

3.4. Modalidades de desconsideração da personalidade jurídica

3.4.1. Desconsideração direta da personalidade jurídica

A teoria da desconsideração surgiu e foi aplicada, historicamente, com a finalidade de permitir a execução de bens particulares dos sócios e/ou administradores por dívidas da sociedade. Essa é a desconsideração direta da personalidade jurídica.

3.4.2. Desconsideração inversa da personalidade jurídica

Pode-se também fazer o caminho inverso: desconsiderar a pessoa jurídica para executar bens sociais por dívidas pessoais de um de seus sócios.

A desconsideração inversa consiste, pois, em aplicar os fundamentos da *disregard doctrine* para permitir que a pessoa jurídica responda por obrigações pessoais de um ou mais sócios, conforme já decidiu o STJ:



considerando-se que a finalidade da *disregard doctrine* é combater a utilização indevida do ente societário por seus sócios, o que pode ocorrer também nos casos em que o sócio controlador esvazia o seu patrimônio pessoal e o integraliza na pessoa jurídica, conclui-se, de uma interpretação teleológica do art. 50 do CC/2002, ser possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica, de modo a atingir bens da sociedade em razão de dívidas contraídas pelo sócio controlador, conquanto preenchidos os requisitos previstos na norma (STJ, REsp 948.117/MS).

É comum a aplicação da desconsideração inversa em questões relativas ao direito de família, quando se constata que um dos cônjuges, por exemplo, cria uma pessoa jurídica para **ocultação de patrimônio**, a fim de afastá-los da partilha ou frustrar a cobrança de pensão alimentícia. Sobre o assunto, o STJ já decidiu o seguinte:

é possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica sempre que o cônjuge ou companheiro empresário valer-se de pessoa jurídica por ele controlada, ou de interposta pessoa física, a fim de subtrair do outro cônjuge ou companheiro direitos oriundos da sociedade afetiva (REsp 1.236.916/RS).

Ainda sobre o assunto, confira-se o **enunciado 283 das Jornadas de Direito Civil do CJF**: “é cabível a desconsideração da personalidade jurídica denominada ‘inversa’ para alcançar bens de sócio que se valeu da pessoa jurídica para ocultar ou desviar bens pessoais, com prejuízo a terceiros”.

Inicialmente sem previsão legal, passou a constar expressa referência a essa modalidade de desconsideração no art. 133, § 2º, do CPC e atualmente também no art. 50, § 3º, do CC, que, aliás, determina também a aplicação dos conceitos de desvio de finalidade e de confusão patrimonial atualmente presentes nos §§1º e 2º do art. 50 do CC à desconsideração inversa da personalidade jurídica.

3.4.3. Desconsideração indireta da personalidade jurídica

Deve-se tomar muito cuidado para não confundir a desconsideração inversa com a indireta. Embora o nome possa fazer supor que se trata do contrário da desconsideração direta, em verdade nenhuma relação guarda com aquela.

Trata-se da desconsideração que ocorre no contexto de grupos econômicos/empresariais.

O novo § 4º do art. 50 do CC também determina a observância dos requisitos previstos nesse artigo à desconsideração indireta. Confira-se: “Art. 50. (...) § 4º A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.”

3.5. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica

O art. 50 do Código Civil trata dos requisitos materiais para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, mas nada dispõe sobre seu procedimento, afirmando apenas que ela deve ser requerida pela parte ou pelo Ministério Público (o que afasta, em princípio, sua aplicação de ofício pelo juiz).

O procedimento a ser seguido está previsto nos arts. 133 a 137 do novo CPC, que disciplinam o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Não é um procedimento especial, trata-se de um mero incidente processual, o que já era entendimento do STJ antes do Código de Processo Civil de 2015. Referido incidente é cabível “em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial” (art. 134 do CPC) e, via de regra, suspende o processo.



Se for pleiteada a desconsideração da personalidade jurídica já na petição inicial, ficam dispensadas a instauração do incidente e a suspensão do processo.

De acordo com o art. 133,

Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo.

§ 1º O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.

§ 2º Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Perceba-se que o novo CPC não criou hipótese de desconsideração, mas apenas disciplinou o seu procedimento. Em caso de litígios empresariais, os “pressupostos previstos em lei” a que se refere o art. 133, § 1º, são aqueles do art. 50 do CC e seus parágrafos. Em litígios consumeristas, “os pressupostos previstos em lei” serão os do art. 28 do CDC, nas ações por danos ambientais, os do art. 4º da Lei nº 9.605/98, e assim por diante.

Antes do novo CPC, o STJ entendia que a desconsideração podia ser decretada nos próprios autos, sem necessidade de citação, de modo que o sócio atingido pela medida só podia defender-se após já realizada a constrição de seus bens pessoais (nesse sentido: REsp 1.096.604/DF e AgRg no REsp 1.459.784/MS).

A partir da vigência do novo CPC, porém, parece-nos que essa jurisprudência terá de ser revista, uma vez que será preciso instaurar um incidente processual específico, com a imprescindível citação do sócio ou da pessoa jurídica. Confira-se, a propósito, o que diz o art. 135: *instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.*

4. Classificação das sociedades

4.1 Quanto à forma do exercício da atividade econômica

Em relação à forma do exercício da atividade econômica, há as sociedades simples e as sociedades empresárias. Ambas visam ao lucro (finalidade econômica), mas aquelas exercem a atividade econômica de modo não empresarial.

De acordo com o art. 983 do Código Civil, “a sociedade empresária **deve** constituir-se segundo um dos tipos regulados nos arts. 1.039 a 1.092; a sociedade simples **pode** constituir-se de conformidade com um desses tipos, e, não o fazendo, subordina-se às normas que lhe são próprias.”

Para as sociedades empresárias, o legislador criou cinco tipos societários específicos, cada qual com seu regime jurídico próprio:

- (i) sociedade em nome coletivo (arts. 1.039 a 1.044 do Código Civil);
- (ii) sociedade em comandita simples (arts. 1.045 a 1.051 do Código Civil);
- (iii) sociedade limitada (art. 1.052 a 1.087 do Código Civil);
- (iv) sociedade anônima (arts. 1.088 e 1.089 do Código Civil e Lei 6.404/1976); e
- (v) sociedade em comandita por ações (arts. 1.090 a 1.092 do Código Civil e Lei 6.404/1976).

Para se constituir uma sociedade há de ser escolhido um dos cinco tipos, não havendo possibilidade de se criar uma sociedade empresária atípica.

Para as sociedades simples, o legislador fez o oposto: não criou nenhum tipo societário específico, permitindo a constituição de uma sociedade simples atípica (arts. 997 a 1.038 do Código Civil), que a praxe empresarial costuma chamar de **sociedade simples “pura”** (sociedade simples que não adota um tipo societário específico). Entretanto, o legislador permitiu também



que a sociedade simples use por empréstimo um dos tipos societários previstos para as sociedades empresárias (com exceção das sociedades por ações, já que estas são sempre empresárias, nos termos do art. 982, parágrafo único, Código Civil).

O parágrafo único do art. 983 do Código Civil ressalva os casos da **sociedade em conta de participação** (que, em verdade, não é uma sociedade, mas um contrato especial de investimento), da sociedade cooperativa (que é uma sociedade simples, independentemente do objeto social, e é regida por lei própria, a Lei nº 5.764/1971) e das sociedades que devem adotar um determinado tipo societário por **determinação legal** (caso das instituições financeiras, por exemplo, que devem adotar a forma de sociedade anônima, nos termos do art. 25 da Lei nº 4.595/1964).

Quanto às sociedades rurais, o art. 984 do Código Civil prevê o seguinte:

Art. 984. A sociedade que tenha por objeto o exercício de atividade própria de empresário rural e seja constituída, ou transformada, de acordo com um dos tipos de sociedade empresária, pode, com as formalidades do art. 968, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da sua sede, caso em que, depois de inscrita, ficará equiparada, para todos os efeitos, à sociedade empresária.

Essa regra está para as sociedades rurais assim como a regra do art. 971 do Código Civil está para os empresários rurais individuais: se o objeto da sociedade for o exercício de atividade rural, ela tem a faculdade de se registrar na Junta Comercial, só sendo considerada uma sociedade empresária, para os efeitos legais, se optar por esse registro. Registre-se, porém, que o STJ firmou o entendimento de que para cumprir os 2 anos exigidos por lei (art. 48 da Lei nº 11.101/2005) para que um devedor possa requerer a recuperação judicial, o produtor rural pode aproveitar o período anterior ao registro na Junta Comercial, pois se considera atividade empresarial regular esse período anterior ao registro (STJ. 4ª Turma. REsp 1.800.032-MT, julgado em 05/11/2019).

4.2. Quanto à responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais

Sabe-se que a sociedade tem patrimônio distinto do patrimônio dos sócios, razão pela qual o **pagamento das dívidas sociais pelos sócios é, via de regra, subsidiário**.

É, inclusive, assegurado por lei que **seja primeiro executado e exaurido o patrimônio social para que, somente após, os sócios sejam atingidos, ainda que de responsabilidade ilimitada (art. 1.024 do CC)**.

A discussão aqui é para verificar se a responsabilidade dos sócios será subsidiária em caráter limitado ou em caráter ilimitado. Nesse aspecto, a sociedade empresária se subdivide em:

- **sociedade ilimitada:** todos os sócios respondem ilimitadamente pelas obrigações sociais. Nessa categoria só há a sociedade em nome coletivo e a sociedade em comum;
- **sociedade mista:** parte dos sócios responde de forma limitada e parte responde de forma ilimitada. São os casos da **sociedade em comandita simples** (comanditado responde ilimitadamente e os comanditários respondem limitadamente) e **sociedade em comandita por ações** (sócios-diretores respondem ilimitadamente e os demais acionistas respondem limitadamente);
- **sociedade limitada:** todos os sócios respondem limitadamente pelas obrigações sociais. Há aqui as **sociedades limitadas** e a **sociedade anônima**.



4.3. Quanto ao regime de constituição e dissolução da sociedade

Segundo esse critério, haverá:

- **sociedades contratuais:** são aquelas cujo ato constitutivo é o **contrato social**. Para a sua dissolução, não basta a vontade da maioria dos sócios majoritários, visto que os sócios minoritários têm o direito de continuar a sociedade. Ex.: sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples e sociedade limitada.
- **sociedades estatutárias:** nas sociedades institucionais ou estatutárias, o ato que a regulamenta é o estatuto social. Ex.: sociedade anônima e sociedade em comandita por ações.

4.4. Quanto à composição (ou quanto às condições de alienação da participação societária)

A classificação visa entender para quem pode ser alienada a participação societária.

- **sociedade de pessoas (*ad personae*):** quem é o sócio interessa para a sociedade. Nesse caso, haverá a *affectio societatis*, podendo os sócios vetarem o ingresso de pessoas estranhas, ainda que seja herdeiro do ex-sócio;
- **sociedade de capital (*ad pecuniae*):** são as sociedade estatutárias. Aqui, não importa quem é o sócio, pois o importante é apenas o capital. Há o **princípio da livre circulabilidade**, podendo o acionista alienar as ações para quem quiser.

Nas sociedades de pessoas, via de regra, **haverá a dissolução parcial da sociedade por conta da morte de um dos sócios**, quando o sócio sobrevivente não concordar com o ingresso do sucessor.

Atente-se para o fato de que não é o tipo societário que define se a sociedade é de pessoas ou de capital. Uma sociedade limitada pode ser de capital e uma sociedade anônima pode ser de pessoas (ex: sociedade anônima fechada forma por núcleo familiar).

Na sociedade limitada, o contrato vai definir a existência ou não do chamado direito de veto. Portanto, o contrato poderá dar à sociedade limitada uma natureza de sociedade de pessoas ou de sociedade de capital. **Caso o contrato seja omissivo, será possível a cessão da quota a terceiros estranhos à sociedade, mas poderá ser obstada por sócios que tenham mais de 1/4 do capital social.** Assim, percebe-se que, **sendo omissivo o contrato social, a sociedade limitada será uma sociedade de pessoas**. Isso porque 1/4 do capital social poderá vetar a entrada de estranho no quadro social.

Questão dirimida pela jurisprudência do STJ é a da possibilidade ou não de penhora das quotas sociais em uma sociedade de pessoas. Sustentava-se que, se fosse permitida a penhora de cotas particulares dos sócios, haveria o ingresso de estranhos no quadro societário (credor ou adquirente das cotas penhoradas). Todavia, tal quadro não se sustenta. Com efeito, conforme decidiu o STJ (ex: REsp 221.625), se houver restrição ao ingresso do credor como sócio, a solução é facultar à sociedade, na qualidade de terceira interessada, “remir a execução, remir o bem ou conceder aos demais sócios a preferência na aquisição das cotas, a tanto por tanto (CPC, arts. 1.117, 1.118 e 1.119), assegurando-se ao credor, não ocorrendo solução satisfatória, o direito de requerer a dissolução total ou parcial da sociedade”.

Atualmente, o tema encontra respaldo no art. 861 do novo CPC, que prevê o seguinte:

Art. 861. Penhoradas as quotas ou as ações de sócio em sociedade simples ou empresária, o juiz assinará prazo razoável, não superior a 3 (três) meses, para que a sociedade:

I— apresente balanço especial, na forma da lei;

II— ofereça as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual;

III— não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à liquidação das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro.



§ 1º Para evitar a liquidação das quotas ou das ações, a sociedade poderá adquiri-las sem redução do capital social e com utilização de reservas, para manutenção em tesouraria.

4.5. Quanto à quantidade de sócios

A sociedade poderá ser:

- **sociedade pluripessoal:** haverá dois ou mais sócios;
- **sociedade unipessoal:** A expressão “pessoas” também deixa claro que as sociedades pressupõem a pluralidade de sócios, isto é, para sua constituição haveria a necessidade de dois ou mais sócios. Essa é a regra, que comporta exceções.

Lembre-se: Foi por isso que se criou a EIRELI, que não é sociedade, mas novo ente jurídico personificado, porque antes ou se era empresário individual (responsabilidade ilimitada) ou se constituía sociedade com outra pessoa.

Até a edição da Lei de Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019), havia duas exceções (sociedades unipessoais): a **subsidiária integral**, sociedade anônima que tem como único acionista uma sociedade brasileira (art. 251 da Lei nº 6.404/1976) – a sociedade controladora detém 100% do capital social da sociedade controlada; e a **sociedade unipessoal de advocacia** (art. 15 da Lei nº 8.906/1994, com redação dada pela Lei nº 13.247/2016). Não se trata de uma sociedade empresária, pois as sociedades de advocacia possuem natureza *sui generis*, sendo inclusive registradas em órgão específico (seccional da OAB). Com o advento da Lei nº 13.874/2019, passou-se a admitir igualmente a **sociedade limitada unipessoal** (art. 1.052, § 1º, do CC).

E se existir uma sociedade com apenas dois sócios e um vier a falecer? O Código Civil estabelece o prazo de 180 dias para reconstituição da pluralidade de sócios (art. 1.033, IV, do CC). Se não houver a reconstituição, haverá dissolução da sociedade, ou o sócio remanescente poderá transformar-se em empresário individual ou em EIRELI (parágrafo único do art. 1.033 do CC). Com o advento da sociedade limitada unipessoal, em que pese a ausência de alteração do parágrafo único do art. 1.033 do CC, sustenta-se também ser possível requerer a transformação da limitada para sua forma unipessoal.

4.6. Quanto à nacionalidade

A sociedade poderá ser:

- **sociedade nacional:** quando constituída de acordo com a legislação brasileira, tendo a sua administração sediada no Brasil (art. 1.125 do CC). Não importam a origem do capital social nem a nacionalidade dos sócios.
- **sociedade estrangeira:** quando não constituída de acordo com a legislação brasileira ou não tiver sua administração sediada no Brasil.

Observe-se que, apesar de a nacionalidade dos sócios não importar para a caracterização da sociedade como nacional ou estrangeira, a lei pode exigir, por imperativos de interesse nacional, que todos ou alguns dos sócios de sociedades que atuem em determinados ramos sensíveis (ex: defesa e imprensa) sejam brasileiros.

5. Sociedade entre cônjuges

Segundo o art. 977 do Código Civil, “faculta-se aos cônjuges contratar sociedade entre si ou com terceiros, desde que não tenham casado no regime da comunhão universal de bens, ou no da separação obrigatória.”



A regra vale tanto para sociedades empresárias quanto para sociedades simples, conforme já decidiu o STJ: “as restrições previstas no art. 977 do CC/02 impossibilitam que os cônjuges casados sob os regimes de bens ali previstos contratem entre si tanto sociedades empresárias quanto sociedades simples” (REsp 1.058.165/RS).

O objetivo do art. 977 do CC é impedir que cônjuges casados sob os regimes da comunhão universal ou da separação obrigatória façam parte de uma mesma sociedade, nada impedindo, pois, que alguém casado sob esses regimes contrate, sozinho, sociedade com terceiro, conforme **enunciado 205 das Jornadas de Direito Civil do CJF**: “a vedação à participação dos cônjuges casados nas condições previstas no artigo refere-se unicamente a uma mesma sociedade”.

É importante registrar também que a vedação em questão só se aplica a sociedades constituídas após a vigência do atual Código Civil, em respeito ao ato jurídico perfeito (art. 5º, inciso XXXVI, da CF/88), conforme **enunciado 204 das Jornadas de Direito Civil do CJF**.

Por fim, registre-se que o art. 977 do Código Civil “abrange tanto a participação originária (na constituição da sociedade) quanto a derivada, isto é, fica vedado o ingresso de sócio casado em sociedade de que já participa o outro cônjuge” (**enunciado 205 das Jornadas de Direito Civil do CJF**).

Em provas, é comum as bancas tentarem confundir os candidatos mesclando o art. 977 (para o qual o regime de bens importa) com o art. 978, que trata da alienação dos bens afetados à atividade empresarial pelo empresarial individual casado sem necessidade de outorga conjugal (que independe do regime de bens do casamento).

6. Sócio de serviço (ou sócio de indústria)

Embora o caput do art. 981 do Código Civil mencione a possibilidade de os sócios contribuírem com bens ou serviços para a constituição da sociedade, deve-se ressaltar que certos tipos societários não admitem a contribuição em serviços, como ocorre, por exemplo, com a sociedade limitada (art. 1.055, § 2º do Código Civil) e com a sociedade anônima (art. 7º da Lei nº 6.404/1976).

Por exemplo, na sociedade limitada, o § 2º do art. 1.055 do CC deixa clara a vedação da contribuição que consista em prestação de serviços. Na sociedade anônima, também há vedação legal. Confira-se:

Código Civil, art. 1.055: “O capital social divide-se em quotas, iguais ou desiguais, cabendo uma ou diversas a cada sócio. (...) § 2º É vedada contribuição que consista em prestação de serviços.”

Lei nº 6.404/1976, art. 7º: “O capital social poderá ser formado com contribuições em dinheiro ou em qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação em dinheiro.”

7. Um ou mais negócios

Por fim, o parágrafo único do art. 981 do Código Civil prevê a possibilidade de uma sociedade ter por objeto a realização de um ou mais negócios determinados, caso em que ela pode, por exemplo, ter prazo determinado de duração (exemplo: sociedades de propósito específico – SPE; essa nomenclatura não constitui um tipo societário, apenas denota uma característica de uma sociedade com prazo de existência determinado).

8. Sociedade irregular

Se há uma sociedade regular, que observa as regras legais, a sociedade irregular é aquela que não observa as regras legais. A sociedade sem registro é chamada de **sociedade irregular**



(há contrato social, mas não foi registrado) **ou sociedade de fato** (nem sequer há contrato social).

No Código Civil, embora a literalidade do art. 986 possa fazer crer que apenas a **sociedade irregular seja regida pelas normas da sociedade em comum**, estas também regem as sociedades de fato. Ambas sofrem uma série de restrições, como, por exemplo:

- não têm legitimidade para pedir a falência do seu devedor;
- não podem pedir a sua própria recuperação judicial;
- os livros, por não terem autenticação, não têm eficácia probatória em favor da sociedade.
- os sócios respondem ilimitadamente pelas obrigações sociais e os sócios que estão à frente da sociedade, administrando e fechando negócios, responderão diretamente pelas dívidas da sociedade, sem aplicação do art. 1.024 do CC. Os demais sócios respondem de forma subsidiária, ou seja, em primeiro lugar é esgotado o patrimônio da sociedade, para depois serem atingidos os bens dos sócios.
- impossibilidade de contratar com o poder público.

Ademais, a existência dessa sociedade, em demandas entre os próprios sócios, apenas pode ser provada por escrito. Já os terceiros podem prová-la de qualquer modo. Tal regra já foi chancelada também pelo STJ:

STJ - Sociedade de fato. Litígio entre supostos sócios. Prova documental. Requisito indispensável. A prova documental é o único meio apto a demonstrar a existência da sociedade de fato entre os sócios (REsp 1.706.812-DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 03/09/2019, DJe 06/09/2019).



CAPÍTULO 10 — CONSTITUIÇÃO, TRANSFORMAÇÃO E DISSOLUÇÃO DAS SOCIEDADES CONTRATUAIS

1. Natureza do ato constitutivo da sociedade contratual

Como visto, a sociedade contratual é constituída por **contrato social**.

“Art. 1.054. O contrato mencionará, no que couber, as indicações do art. 997, e, se for o caso, a firma social.”

O contrato social é classificado como um **contrato plurilateral**, visto que há uma pluralidade de contratantes com o mesmo objetivo. Eles criam uma pessoa jurídica, que poderá cobrar os sócios que subscreveram o capital social e não o integralizaram.

2. Requisitos do contrato social

São requisitos de validade do contrato social:

- **requisitos genéricos:** são os mesmos requisitos genéricos de qualquer negócio jurídico:
 - **agente capaz:** no entanto, o menor, devidamente representado ou assistido, pode ser sócio de sociedade, desde que não seja o sócio-administrador e o capital da sociedade esteja completamente integralizado.
 - **objeto lícito, possível, determinado ou determinável;**
 - **forma prescrita ou não defesa em lei;**
- **requisitos específicos:** são requisitos específicos para os atos constitutivos de uma sociedade empresária:
 - **todos os sócios devem contribuir para a formação do capital social:** seja com bem, dinheiro, etc.
 - **todos os sócios devem participar do resultado:** não é válida uma cláusula que exclua o sócio dos lucros (cláusula leonina) ou dos prejuízos, pois esta cláusula é nula. Perceba que a lei não veda a distribuição diferenciada de lucros, mas veda que o sócio seja excluído da distribuição de lucros.

A doutrina também aponta como requisito específico a ***affectio societatis***, aqui entendida como a vontade de cooperação ativa dos sócios para atingirem um fim comum.

O art. 997, do Código Civil estabelece que “a sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público (...).”

O contrato social deve ser feito por escrito porque deverá ser registrado no órgão competente: cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, quando se tratar de sociedade simples; Junta Comercial, quando se tratar de sociedade empresária, conforme o art. 1.150 do Código Civil:

Art. 1.150. O empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao Registro Público de Empresas Mercantis a cargo das Juntas Comerciais, e a sociedade simples ao **Registro Civil das Pessoas Jurídicas, o qual deverá obedecer às normas fixadas para aquele registro, se a sociedade simples adotar um dos tipos de sociedade empresária.**

IMPORTANTE: em regra, o contrato social é feito por instrumento particular, mas o caput do art. 997 do Código Civil deixa claro que o contrato social também pode ser formalizado por **instrumento público**. Vale destacar, porém, que, se o contrato social for feito por instrumento público, futuras alterações contratuais não precisarão ser feitas por instrumento público também.

Por fim, **a lei exige que o contrato social tenha a assinatura e o visto de um advogado**. É uma formalidade exigida para fins de registro. **Do contrário, não se admite o registro.**



3. Cláusulas contratuais

São cláusulas que estão no contrato social.

Nesse caso, há duas espécies de cláusulas que estão no contrato social:

- **cláusulas essenciais:** sem elas não é possível fazer o registro do contrato social;
- **cláusulas não essenciais (acidentais):** sua ausência não impede o registro do contrato social.

3.1. Cláusulas essenciais

De acordo com o inciso I do art. 997 do Código Civil, o contrato social deve mencionar “nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência dos sócios, se pessoas naturais, e a firma ou a denominação, nacionalidade e sede dos sócios, se jurídicas.”

Percebe-se, logo, que as sociedades contratuais podem, em princípio, ter como sócios tanto **pessoas físicas** (pessoas naturais) quanto **pessoas jurídicas** (outra sociedade, por exemplo). Mas cuidado: certos tipos de sociedade não admitem pessoa jurídica como sócio.

A Sociedade em nome coletivo, por exemplo, somente pode ter como sócios pessoas físicas (art. 1.039 do Código Civil). Quanto à sociedade em comandita simples, somente os sócios comanditários podem ser pessoas jurídicas (art. 1.045 do Código Civil), enquanto os comanditados devem ser pessoas naturais.

Lembre-se: quando se trata de sócio pessoa física, é preciso ter cuidado. Se esse sócio for alguém que tem impedimento legal para exercício de empresa, não poderá ter poderes de administração, nem responsabilidade ilimitada. Logo, deve ser verificado o tipo de sociedade, bem como o poder de administração. Também se deve tomar cuidado caso o sócio pessoa física seja incapaz, porque nesse caso deverão ser obedecidos os pressupostos do artigo 974, § 3º do CC (“I – o sócio incapaz não pode exercer a administração da sociedade; II – o capital social deve ser totalmente integralizado; III – o sócio relativamente incapaz deve ser assistido e o absolutamente incapaz deve ser representado por seus representantes legais”).

Conforme previsão do inciso II do art. 997 do Código Civil, o contrato social também deve mencionar “denominação, objeto, sede e prazo da sociedade.” Em vez de denominação, o dispositivo legal deveria ter usado a expressão **nome empresarial**, que é genérica e engloba também a firma.

Quanto ao **objeto social**, ele será determinante para definir a natureza da sociedade (simples ou empresária, conforme art. 982, do Código Civil), bem como o respectivo órgão de registro (Cartório ou Junta Comercial). A sede definirá o Cartório ou a Junta Comercial onde será feito o registro do contrato social, já que a competência desses órgãos é local.

O prazo definirá o período de duração da sociedade, lembrando-se apenas de que, em regra, as sociedades são constituídas por prazo indeterminado.

Outro dado que o contrato social deve necessariamente mencionar, segundo o art. 997, inciso III, do Código Civil, é o “*capital da sociedade, expresso em moeda corrente, podendo compreender qualquer espécie de bens, suscetíveis de avaliação pecuniária*”.

Capital social é o **montante de contribuições** dos sócios para a sociedade, a fim de que ela possa cumprir seu objeto social.

O capital social deve ser sempre expresso em moeda corrente nacional, e pode compreender dinheiro ou quaisquer outros bens (bens móveis, imóveis ou semoventes; materiais ou imateriais), desde que sejam suscetíveis de avaliação pecuniária.

Embora não esteja expressamente previsto na lei, há cada vez mais preocupação, tanto doutrinária quanto jurisprudencial, no sentido de que o capital social seja condizente com o objeto social, para que não se tenha o fenômeno chamado de “subcapitalização” – sociedade que tem capital irrisório em relação ao seu objeto social. Há, inclusive, quem defenda que a



subcapitalização é motivo ensejador da desconsideração da personalidade jurídica, embora não haja precedente conclusivo sobre esse assunto.

Definido o capital social da sociedade, deve o contrato social mencionar ainda “a quota de cada sócio no capital social, e o modo de realizá-la” (art. 997, inciso IV do Código Civil).

Todos os sócios têm o dever de **subscrição** e de **integralização** de quotas. Em outras palavras, todos os sócios têm o dever de adquirir quotas da sociedade e de pagar por essas respectivas quotas, contribuindo para a formação do capital social, ainda que essa contribuição seja ínfima.

A contribuição do sócio, ou seja, o modo de integralizar suas quotas, pode ser feita de diversas formas: com **bens** – móveis ou imóveis, materiais ou imateriais –, dinheiro etc. Admite-se até mesmo a contribuição em **serviços**, conforme previsão expressa do art. 997, inciso V do Código Civil.

Relembrando: na sociedade limitada, porém, a contribuição em serviços é expressamente vedada (art. 1.055, § 2º, do Código Civil).

Cada sócio deve integralizar suas respectivas quotas, na forma e no prazo previstos no contrato. O sócio que não integraliza suas cotas na forma e no prazo previstos é chamado de **sócio remisso** – ou seja – é o sócio que está em mora, quanto à integralização de sua parte do capital social.

Ademais, deve também o contrato indicar: a) as pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade, e seus poderes e atribuições; b) a participação de cada sócio nos lucros e nas perdas; c) se os sócios respondem, ou não, subsidiariamente, pelas obrigações sociais.

3.2. Cláusulas não essenciais

Poderá o contrato social ter cláusulas não essenciais, como é a cláusula de como se dará a sucessão em caso de morte de um dos sócios.

4. Participação nos resultados

Em princípio, a participação dos sócios é proporcional às suas respectivas quotas, mas o contrato social pode dispor de forma diversa: “**salvo estipulação em contrário**, o sócio participa dos lucros e das perdas, na proporção das respectivas quotas, mas aquele, cuja contribuição consiste em serviços, somente participa dos lucros na proporção da média do valor das quotas” (art. 1.007 do Código Civil).

É vedada, porém, a chamada “**cláusula leonina**”, que exclui um sócio de participação nos resultados. O art. 1.008 do Código Civil determina que “é nula a estipulação contratual que exclua qualquer sócio de participar dos lucros e das perdas”.

A cláusula leonina tem esse nome em virtude da fábula do leão, que se juntava com outros animais para caçar e depois ficava com todo produto da caça e deixava os demais animais sem nada.

Em resumo, é possível haver participação desproporcional, porém, é vedada a exclusão de sócio na participação dos resultados.

5. Forma do contrato social

O contrato social deverá ser **escrito** para a sociedade regular ser registrada.



O contrato feito oralmente é decorrente de uma sociedade não registrada (sociedade de fato), e que não será considerada regular. Sinala-se que apenas por escrito podem os sócios provar a existência de sociedade entre si, mas terceiros podem prová-la por qualquer meio.

O contrato social poderá ser celebrado por **instrumento particular** ou por **instrumento público, ainda que existam bens imóveis como forma de integralização do capital social e ainda que exista menor participando do quadro social.**

As alterações do contrato social não estão vinculadas ao ato constitutivo. Isso quer dizer que, **se o contrato se deu por meio de escritura pública, nada impede que ele seja alterado por meio de instrumento particular.**

6. Alteração do contrato social

O contrato social poderá ser alterado. Para tanto, **é preciso que os sócios deliberem sobre as alterações.**

Quando a deliberação dos sócios implicar em alteração do contrato social, no caso da **sociedade em comandita simples e na sociedade em nome coletivo, será indispensável a unanimidade dos sócios para mudar uma cláusula essencial.** Sendo cláusula não essencial, basta a vontade de mais da metade do capital social.

Na **sociedade limitada**, a alteração do contrato social **exige o voto de 3/4 do capital social a favor da alteração.** Aqui, **não importa a natureza da cláusula**, se é essencial ou não essencial.

Os minoritários, caso não concordem, deverão se submeter aos interesses da maioria, ou então exercer seu direito de retirada, devendo ser reembolsados pelo valor patrimonial de suas quotas.

7. Transformação do registro

Uma coisa é transformação do registro, outra é transformação do tipo societário.

Transformação do registro **é pegar o empresário individual e registrá-lo como sociedade empresária**, em razão do ingresso de uma pessoa na atividade.

Por exemplo, quando há uma sociedade empresária de dois sócios, mas um deles sai, permanecerá apenas 1 sócio. Nesse caso, poderá o indivíduo se registrar como empresário individual.

Há aqui uma espécie de extinção de um tipo societário, transformando o registro.

Só as sociedades limitadas, em comandita simples e a sociedade em nome coletivo é que vão admitir a constituição ou dissolução por meio da transformação do registro.

8. Dissolução de sociedade contratual

Trata-se de dissolução em sentido amplo, ou seja, do processo que encerra a personalidade jurídica de uma sociedade empresária.

8.1. Espécies de dissolução

Existem algumas espécies de dissolução, conforme a **abrangência** e o **modo** como é feita. Quanto à abrangência, a dissolução poderá ser:

- **dissolução total:**
- **dissolução parcial:** no CC, a dissolução parcial será denominada de resolução da sociedade em relação a um sócio, com a continuidade da atividade empresarial.

Além do critério acima, também poderá a dissolução se dar por meio de:

- **dissolução judicial:** em um procedimento judicial;



- **dissolução extrajudicial:** sem a intervenção do Poder Judiciário.

8.1.1. Causas de dissolução total

A dissolução total encerra a personalidade jurídica da sociedade empresária.

Essa dissolução total poderá decorrer de diversos fatores:

- **vontade dos sócios:** os sócios não querem mais continuar a sociedade;
- **decurso do prazo determinado de duração:** uma das cláusulas essenciais do contrato social é o prazo de duração da sociedade, que poderá ser indeterminado;
- **falência;**
- **exaurimento do objeto:** o objeto passa a não existir mais;
- **inexequibilidade do objeto:** não é mais viável o objeto da sociedade. Ex.: sociedade para fazer disquetes;
- **unipessoalidade por mais de 180 dias;**
- **outra causa prevista no contrato sobre algum acontecimento que gerará a extinção total da sociedade.**

Para a dissolução total da sociedade contratual por vontade dos sócios, caso se trate de uma sociedade contratada **por prazo determinado**, sendo o encerramento anterior ao prazo estipulado, **exige-se para essa dissolução total deliberação unânime**.

Sendo uma sociedade contratada por **prazo indeterminado**, bastará que **mais da metade do capital social** assim delibere.

A jurisprudência, **com base no princípio da preservação da empresa, tem reconhecido que o sócio minoritário tem direito de continuar a empresa**, ainda que haja esta previsão legal.

No caso de decurso do prazo da sociedade com prazo determinado, se a sociedade não entrar em liquidação, passará ao status de sociedade irregular, visto que a lei considerará que ela passou a ser uma sociedade com prazo indeterminado, caso não haja oposição de sócio. Todavia, nesse caso, estará em uma situação irregular, pois a alteração do contrato social deveria ter se dado antes do esgotamento do prazo, passando a prever que teria prazo indeterminado. Em outras palavras, **ela fica sujeita à aplicação analógica das sociedades em comum, a partir desse momento, pois passa a ter uma situação de sociedade irregular, até que porventura leve a registro a devida alteração contratual com a previsão de duração por prazo indeterminado ou por novo prazo**.

A unipessoalidade poderá ser causa de dissolução total da sociedade empresária, porque todas as quotas foram reunidas em uma só pessoa, e **esta pessoa não requereu a transformação do registro em empresário individual ou EIRELI (ou, atualmente, em sociedade limitada unipessoal), deixando transcorrer o prazo de 180 dias**.

Vencido esse prazo, sem o restabelecimento da pluralidade de sócio, nem transformação do registro, a sociedade deverá ser totalmente dissolvida.

8.1.2. Causas de dissolução parcial

Existem causas de dissolução parcial, que o CC chama de resolução da sociedade em relação a um sócio, com a continuidade da empresa.

Haverá a dissolução parcial por:

- **vontade do sócio;**
- **morte do sócio:** haverá liquidação e apuração da parte dele;
- **retirada do sócio;**
- **exclusão do sócio;**
- **falência do sócio;**



- **liquidação da quota a pedido do credor do sócio:** isso porque na sociedade de pessoas não cabe o ingresso do credor no quadro social por meio de penhora de quota. Neste caso, faz a liquidação da quota a pedido do credor.

Se a sociedade limitada estiver sujeita à regência supletiva da Lei de S.A., ela somente irá se dissolver parcialmente nas **hipóteses de retirada motivada**. Ex.: houve uma dissidência na alteração do contrato, ou fusão, incorporação ou da alteração do contrato, hipótese em que admitirá o direito de retirada do sócio, recebendo o direito patrimonial de sua quota. Consequentemente, haverá a redução do capital social.

8.2. Liquidação e apuração de haveres

Ocorrendo a dissolução total, haverá a liquidação e a partilha dos haveres.

Sendo uma dissolução parcial, haverá a apuração e, depois, o ex-sócio será reembolsado pelo valor da sua quota.

Liquidação é a realização do ativo e pagamento do passivo. Essa liquidação poderá ser judicial ou extrajudicial, independentemente de a dissolução ter sido judicial ou extrajudicial.

Durante a liquidação, a sociedade só estará autorizada a praticar os atos que tenham por objetivo a solução dessas pendências existentes. E mais, deverá aditar seu nome empresarial para incluir a expressão “em liquidação”. Liquidado o ativo e pago o passivo, tem-se o patrimônio líquido da sociedade, o qual será partilhado entre os sócios. Essa é a partilha. Partilhado o patrimônio líquido, encerra-se o processo de extinção da sociedade empresária, que perderá sua personalidade jurídica.

A dissolução parcial ocorrerá da mesma forma, por meio de apuração de haveres, seguida de reembolso.

Quanto ao tema, o STJ já se pronunciou no sentido de que o direito de retirada de sociedade constituída por tempo indeterminado pode ser exercido mediante a simples notificação com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, conforme o art. 1.029 do CC, dispensando a propositura de ação de dissolução parcial para tal finalidade. Após o prazo de 60 dias, o contrato societário fica resolvido, de pleno direito, em relação ao sócio retirante, devendo ser apurados haveres e pagos os valores devidos na forma do art. 1.031 do CC, considerando-se o termo final daquele prazo como a data-base para apuração dos haveres. Confira-se:

Na hipótese em que o sócio de sociedade limitada constituída por tempo indeterminado exerce o direito de retirada por meio de inequívoca e incontroversa notificação aos demais sócios, a data-base para apuração de haveres é o termo final do prazo de 60 dias, estabelecido pelo art. 1.029 do CC/02 (STJ. 3ª Turma. REsp 1.602.240, julgado em 6/12/2016).



CAPÍTULO 11 — SÓCIO DA SOCIEDADE CONTRATUAL

1. Sócio remisso

O sócio, quando subscreve o capital social, compromete-se a contribuir com o capital social. Caso ele não cumpra essa obrigação, será denominado de **sócio remisso**.

Em tal caso, os demais sócios poderão **optar por**:

- **cobrar o sócio remisso judicialmente;**
- **excluir o sócio do quadro social;**
- **reduzir a quota do sócio remisso;**
- **alienar as quotas em aberto a terceiros;**
- **deliberar pelo adimplemento pela sociedade das quotas do sócio inadimplente.**

A ação para cobrança poderá ter caráter executivo, servindo como **título executivo extrajudicial o próprio contrato social**.

É possível também que a pretensão da sociedade não se restrinja apenas à apuração do quanto o sócio remisso deve à sociedade a título de capital social propriamente dito, pois pode ser que, em razão de sua inadimplência, a sociedade tenha experimentado outros prejuízos, **devendo o sócio remisso indenizar esses danos**. Todavia, para que a sociedade cobre essa indenização, será necessário ajuizar uma **ação de conhecimento**, pois não há título executivo para ser executado.

Quanto à **redução da quota do sócio remisso**, suponha-se o seguinte cenário: o sócio subscreveu que contribuiria com 50 mil reais. No entanto, contribuiu com 30 mil reais. Nesse caso, será reduzida a quota do sócio a 30 mil reais, devendo o capital social da sociedade, que era de 150 mil reais passar a ser de 130 mil reais. Portanto, **é possível reduzir o valor da quota e consequentemente reduzir o capital social**. Todavia, caso os sócios não queiram reduzir o capital social, os demais sócios poderão atribuir para si aquela quota, pagando o valor em aberto. Ou mesmo **poderão alienar aquelas quotas em aberto para terceiros**, a fim de que ingressem na sociedade, hipótese em que não haverá redução do capital social. Também é possível que **a própria sociedade opte por adimplir as quotas do sócio remisso**.

2. Direitos dos sócios

O sócio **tem direito de participação nos resultados sociais**. Conforme já visto, é vedada a cláusula leonina.

O sócio **tem direito de administração da sociedade** ou, ainda que não administre, tem **direito de participar da escolha do administrador e da estratégia geral** adotada pela sociedade. Em regra, é assegurado a todos os sócios esse direito de participação das deliberações sociais.

Também é **direito do sócio a fiscalização da administração**, a qualquer tempo.

O sócio igualmente possui o **direito de retirada, previsto no art. 1.029 do CC**. Caso se trate de sociedade por prazo indeterminado, o sócio poderá se retirar sem qualquer motivação, bastando que comunique os demais sócios com antecedência de sessenta dias.

No entanto, no caso de retirada de sociedade com prazo determinado, esta saída antecipada do sócio só é possível se houver justa causa, a ser demonstrada judicialmente. Isso significa dizer que **é preciso comprovar motivação idônea** para se retirar antes do prazo final da duração da sociedade.

De acordo com o STJ, em que pese o art. 1.029 do CC estar no capítulo referente às sociedades simples, tal previsão se aplica a todos os demais tipos societários, exceto quanto às Sociedades Anônimas, que possuem regência específica na LSA. Trata-se, para esse Tribunal, de **“direito potestativo positivado em favor de cada sócio, individualmente considerado”** (REsp 1.602.240/MG).



No caso de **sociedade limitada**, além da previsão acima referida, **é possível exercer o direito de retirada quando há alteração contratual, incorporação ou fusão, mas um dos sócios diverge** (art. 1.077 do CC). Fica assegurado ao sócio que dissentiu se retirar da sociedade, nos trinta dias subsequentes à reunião, situação em que receberá o valor patrimonial de sua quota social, **visto que se trata de justa causa**.

A participação nos lucros sociais é uma participação que decorre da condição de sócio. **Não poderá ser confundida com a expressão pró-labore**. O pró-labore é uma **remuneração ao sócio que trabalha naquela sociedade**. A participação nos lucros sociais decorre da condição de sócio.

3. Exclusão de sócio

Poderá o sócio ser excluído judicialmente da sociedade nas seguintes hipóteses, previstas no art. 1.030 do CC:

- **mora na integralização do capital social:** nesse caso, os demais sócios podem optar por excluí-lo;
- **falta grave no cumprimento de obrigações:** ocorrerá quando houver violação ou falta de cumprimento das obrigações sociais. Ex.: sócio faz concorrência com a própria sociedade. Haverá a quebra de um dever seu, motivando a exclusão.
- **Incapacidade superveniente.**
- **Falência do sócio**
- **Liquidação da quota do sócio por credor particular (art. 1.026, p.u., do CC)**

A exclusão do sócio nas sociedades limitadas necessita do preenchimento de requisitos específicos, que serão tratados em tópico próprio.

Expulso o sócio, terá ele direito a receber o valor da sua quota, considerado o montante efetivamente realizado, e levará em consideração a situação patrimonial da sociedade na data da exclusão, verificada em balanço especialmente levantado (art. 1.031). A dissolução aqui é de caráter parcial, visto que se exclui um dos sócios mas persiste a atividade empresarial.



CAPÍTULO 12 — TIPOS SOCIETÁRIOS

1. Sociedade limitada

É o tipo societário mais utilizado na praxe comercial brasileira, porque é o ideal para pequenos e médios empreendimentos, por reunir duas características muito importantes: em primeiro lugar, a contratualidade, tornando-lhe um modelo societário mais simples de se constituir e, em segundo lugar, a limitação da responsabilidade.

Em verdade, dos cinco tipos de sociedade empresária tratados, apenas dois são usados na prática hoje em dia, a sociedade limitada e a sociedade anônima, os demais são tipo societários que, na atualidade, basicamente só existem no papel.

1.1. Limitação da responsabilidade dos sócios

De acordo com o art. 1.052 do Código Civil, “na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social”.

Assim, pois, é que se dá a responsabilidade limitada dos quotistas desse tipo societário: **se o capital social estiver totalmente integralizado**, não se deve executar eventual dívida social pendente nos bens dos sócios (salvo em situações excepcionais, como no caso de desconsideração da personalidade jurídica, por exemplo); **se, porém, o capital social não estava totalmente integralizado**, pode-se executar eventual dívida social pendente nos bens dos sócios, mas apenas até o limite da integralização. E mais: como essa responsabilidade dos sócios pela integralização do capital social é solidária, qualquer sócio pode ser executado por eventual dívida social pendente, mesmo aquele que já tenha integralizado suas quotas (cabera a ele, posteriormente, agir em regresso contra os demais).

Atenção: a redação do artigo 1.052 cai muito em prova. Cuidado com a troca de palavras e atente-se para o fato de que, enquanto não estiver totalmente integralizado o capital social, **não** haverá responsabilidade **ilimitada** dos sócios! Na responsabilidade ilimitada, os sócios respondem pela integralidade das obrigações sociais. No caso do art. 1.052, continuará havendo uma limitação na obrigação dos sócios, mas não será mais o valor de sua cota, e sim o valor que falta para a integralização do capital social.

Além disso, responderão os sócios também solidariamente pela exata estimação dos bens conferidos ao capital social, mas, nesse caso, apenas pelo prazo de cinco anos da data do registro da sociedade.

1.2. Sociedade limitada unipessoal

Muita atenção também para uma grande inovação trazida pela Lei da Liberdade Econômica: a previsão da sociedade limitada unipessoal, constante do novo § 1º do art. 1052 do Código Civil, que possivelmente tornará superada a figura da EIRELI, uma vez que não há as mesmas amarras normativas para sua constituição.

Como na sociedade limitada unipessoal não há sócios, tampouco há falar em contrato social, mas sim em mero “documento de constituição do sócio único”, que deverá observar, no que couber, as normas referentes ao contrato social (art. 1.052, § 2º, do CC).

1.3. Conselho Fiscal

O CC permite que a sociedade limitada institua **conselho fiscal**. Com efeito, dispõe o art. 1.066 que, “sem prejuízo dos poderes da assembleia dos sócios, pode o contrato instituir



conselho fiscal composto de três ou mais membros e respectivos suplentes, sócios ou não, residentes no País, eleitos na assembleia anual de que trata o art. 1.078.”

Trata-se de mera **faculdade**, a qual só tem sido exercida pelas sociedades limitadas de maior porte. Em sociedades limitadas pequenas, com poucos sócios, a existência de conselho fiscal é desnecessária.

O conselho fiscal deve ser heterogêneo e o art. 1.066, § 2º, assegura “aos sócios minoritários, que representem pelo menos um quinto do capital social, o direito de eleger, separadamente, um dos membros do conselho fiscal e o respectivo suplente.” Ademais, para que o Conselho exerça suas atribuições de maneira imparcial, dispôs o Código, em seu art. 1.066, § 1º, que

não podem fazer parte do conselho fiscal, além dos inelegíveis enumerados no § 1.º do art. 1.011, os membros dos demais órgãos da sociedade ou de outra por ela controlada, os empregados de quaisquer delas ou dos respectivos administradores, o cônjuge ou parente destes até o terceiro grau.

1.4 Possibilidade de quota preferencial em sociedade limitada

Conforme já visto anteriormente, é possível a previsão, no contrato social, de participação nos resultados desproporcional. Mas como ela é estabelecida?

Tradicionalmente, uma opção importante era a criação de quotas preferenciais, com inspiração nas ações preferenciais das sociedades anônimas. São quotas que conferem alguns direitos especiais de natureza econômica ou política, geralmente com a contrapartida de não conceder direito de voto ou restringir o seu exercício em determinados casos.

Na vigência do Decreto 3.078/1919, era prática comum a criação de quotas preferenciais nos contratos sociais de sociedades limitadas, em analogia às ações preferenciais das sociedades anônimas (arts. 17, 18 e 111 da Lei nº 6.404/1976). Mas essa matéria gerou polêmica após a vigência do atual Código Civil, porque se passou a entender que as quotas preferenciais não seriam mais possíveis, em razão de o texto legal, na parte da instalação e das deliberações em reuniões/assembleias, não mais falar em “capital votante”, mas apenas em “capital social”, presumindo-se, dessa forma, que todo capital é votante, não havendo, assim, possibilidade de possuir quota sem direito de voto (CRUZ, 2014).

O DREI inicialmente acolheu essa tese e passou a não mais admitir a criação de quotas preferenciais (IN 10/2013). No início de 2017, porém, houve uma mudança de entendimento por parte do DREI, que passou a admitir a criação de quotas preferenciais quando a sociedade limitada a dota a regência supletiva pela Lei das S.A. (IN 38/2017).

Esmiuçando: as ações preferenciais na sociedade anônima conferem essas preferências, mas geralmente exigem uma contrapartida no direito de voto, seja não conferindo direito de voto ou conferindo direito de voto com alguma restrição. Então as cotas sociais preferenciais seguiam a mesma lógica.

1.5. Regência subsidiária e supletiva

A sociedade limitada tem um capítulo próprio no Código Civil, mas com aplicação subsidiária das regras da sociedade simples em relação aos casos omissos (art. 1.053). Porém, é possível que o contrato social preveja também a aplicação supletiva por regras da Lei das Sociedades Anônimas (art. 1.053, parágrafo único), questão simples, porém de grande incidência em provas.



1.6. Exclusão extrajudicial de sócio

A regra para os tipos societários em geral é a de que a exclusão de sócio seja feita pela via judicial, nos termos do artigo 1.030 do Código Civil.

Tratando-se de sociedade limitada, todavia, o artigo 1.085 do CC prevê uma hipótese excepcional de exclusão extrajudicial de sócio, ou seja, os demais sócios podem excluir um sócio sem necessidade de ingressar em juízo. Para tanto, há a necessidade de observância dos requisitos cumulativos previstos no citado dispositivo legal, que são os seguintes:

- Deliberação pela maioria dos sócios (> ½ do capital social)
- Sócio estiver pondo em risco a continuidade da empresa
- Em virtude de atos de inegável gravidade
- Previsão da exclusão por justa causa no contrato social.
- Reunião ou Assembleia especialmente convocada para tal fim, ciente o acusado em tempo hábil para comparecer e exercer direito de defesa.

Há, porém, alguns questionamentos sobre esses requisitos.

O quórum da maioria absoluta deve ser computado considerando-se todo o capital social?

De acordo com o STJ (REsp 1.459.190/SP, Informativo nº 575), deve-se excluir a cota do interessado, computando-se a maioria absoluta com base no capital social restante. Na mesma linha é o entendimento do Enunciado 216 do CJF, amparado no art. 1.074, § 2º, do CC, que consagra o princípio da moralidade e a vedação do conflito de interesses ao estipular que “nenhum sócio, por si ou na condição de mandatário, pode votar matéria que lhe diga respeito diretamente”.

O contrato deve prever quais são os atos considerados graves?

Não. Apenas precisa prever a possibilidade de exclusão por justa causa. Porém, nada obsta que o contrato diga expressamente quais são os atos considerados graves, sendo, inclusive, boa maneira de eliminar ou ao menos reduzir possibilidade de discussão futura.

Qual o prazo decadencial que o sócio possui para pleitear judicialmente a anulação da deliberação que o excluiu da sociedade?

Conforme decidiu o STJ, o prazo decadencial será de três anos, ainda que haja regência opção pela regência supletiva pela Lei das Sociedades Anônimas (que a seu turno prevê um prazo de dois anos para requerer a anulação de deliberações da sociedade).

De acordo com esse Tribunal, não há necessidade de buscar regência supletiva na LSA em virtude da existência de norma própria na parte geral do Código Civil sobre o tema (art. 48, parágrafo único).

1.7. Cessão de quotas

As sociedades limitadas, por serem sociedades contratuais, são sociedades, em regra, de pessoas (mas nem sempre), ou seja, o vínculo formado entre os sócios é *intuitu personae*, há *affectio societatis*.

Não é o que ocorre nas sociedades institucionais, nas quais o vínculo, em regra, é de capital, *intuitu pecuniae*. Ex: Sociedade anônima, na qual as características pessoais dos sócios normalmente são irrelevantes para a formação do vínculo societário.

Por tal razão, na omissão do contrato, haverá uma limitação ao ingresso de terceiro no quadro social. De acordo com o art. 1.057 do CC:

Art. 1057 Na omissão do contrato, o sócio pode ceder sua quota, total ou parcialmente, a quem seja sócio, independentemente da audiência dos outros, ou a estranho, neste caso se não houver oposição de titulares de mais de ¼ do capital social.



Nada impede que o contrato social regule o tema de modo diverso.

Em qualquer caso, a cessão terá eficácia, quanto à sociedade e a terceiros, a partir da averbação do respectivo instrumento, subscrito pelos sócios que anuíram, no caso de cessão a estranho.

Atenção: na hipótese de cessão de quotas sociais, a responsabilidade do cedente pelo prazo de até 2 anos após a averbação da respectiva modificação contratual restringe-se às obrigações sociais contraídas no período em que ele ainda ostentava a qualidade de sócio, ou seja, antes da sua retirada da sociedade. **STJ. 3ª Turma. REsp 1537521/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 05/02/2019.**

1.8. Aquisição de quotas pela própria sociedade

Essa é outra questão polêmica e que teve mudança de entendimento no início de 2017.

O Decreto 3.078/1919 (antiga lei das limitadas – *status* de lei ordinária), no seu art. 8º, autorizava expressamente a aquisição de quotas pela própria sociedade limitada, para colocação em tesouraria ou cancelamento. Assim, essas cotas não pertenciam a ninguém, mas à própria sociedade.

Havia quatro requisitos: (i) as quotas deveriam estar devidamente integralizadas; (ii) a aquisição deveria ser feita com fundos disponíveis; (iii) não poderia resultar em diminuição do capital social; e (iv) a operação deveria ser aprovada em deliberação unânime.

Assim que o Código Civil entrou em vigor, estabeleceu-se uma polêmica sobre essa questão, e o entendimento inicial do DREI foi de que não era possível mais a aquisição de quotas pela própria sociedade.

No entanto, havia grande reclamação dos operadores do direito societário em relação a tal entendimento. Tanto que foi aprovado o **Enunciado 391 das Jornadas de Direito Civil do CJF**: “a sociedade limitada pode adquirir suas próprias quotas, observadas as condições estabelecidas na Lei das Sociedades por Ações”.

No início de 2017, o DREI revisou algumas de suas instruções normativas, passando a admitir a aquisição de quotas pela própria sociedade limitada, desde que esta adote a regência supletiva da LSA, sendo aplicado, portanto, o artigo 30, § 1º, dessa Lei, que prevê a possibilidade de a sociedade adquirir suas próprias ações para “permanência em tesouraria ou cancelamento, desde que até o valor do saldo de lucros ou reservas, exceto a legal, e sem diminuição do capital social, ou por doação”.

Destaque-se, outrossim, que o art. 861 do novo CPC, já analisado quando se tratou da possibilidade da penhora de quotas sociais, expressamente passou a prever em seu § 1º a possibilidade de aquisição de quotas sociais pela sociedade, para manutenção em tesouraria, embora disciplinasse especificamente a questão da penhora.

De qualquer modo, ante a previsão desse artigo, não teria como o DREI manter seu entendimento. Ademais, um dos fundamentos para se adquirir quotas pela própria sociedade é o artigo 1.058 do CC, pois quando o sócio remisso é excluído, a sociedade pode adquirir suas quotas, colocá-las em tesouraria para depois repassá-las a terceiros etc.

1.9. Administração da Sociedade Limitada

1.9.1 Designação do administrador

A sociedade limitada pode ser administrada por ou uma ou mais pessoas designadas no contrato social ou em ato separado, de acordo com o art. 1.060 do CC. Referido artigo não deixa claro se a administração pode ser realizada por pessoa jurídica, uma vez que só utiliza o termo “pessoa”. Porém, quando cominado com o artigo 997, inciso VI, do mesmo diploma legal, chega-se à conclusão de que os administradores precisam ser pessoas naturais.



Em se tratando de designação de administradores não sócios, haverá necessidade de aprovação da unanimidade dos sócios, enquanto o capital não estiver integralizado, e de 2/3 (dois terços), no mínimo, após a integralização, se a designação não for em ato em separado.

A sociedade limitada pode, eventualmente, instituir conselho de administração, adotando supletivamente a LSA, autorização também disposta nas instruções normativas do DREI. Atente-se: isso não será encontrado no Código Civil.

Quando a sociedade tem poucos sócios, é comum que o contrato social atribua poderes de administração a todos. Mas atenção: a administração atribuída no contrato a todos os sócios não se estende de pleno direito aos sócios que ingressem posteriormente no quadro social, havendo necessidade de cláusula expressa quanto a eventual extensão.

O administrador precisa, necessariamente ser sócio, ou a sociedade pode ser administrada por pessoa que não integre o quadro societário?

Depende do tipo de sociedade. Na **sociedade limitada é possível**, mas em outras sociedades contratuais isso não é possível. Por exemplo, na sociedade em nome coletivo (artigos 1.039 a 1.044 do CC), em que todos tem responsabilidade ilimitada, e todos precisam ser pessoas físicas, a administração compete exclusivamente a quem é sócio. Ainda, a sociedade em comandita simples (artigos 1.045 a 1.051 do CC), em que existem os sócios comanditados, com responsabilidade ilimitada, e os sócios comanditários, com responsabilidade limitada, só pode ser administrada pelos sócios comanditados.

IMPORTANTE: note que o artigo 1.061 do CC foi alterado após alguns anos de vigência do Código Civil. Antes, constava do início do artigo a expressão “se o contrato permitir”. Em virtude dessa frase, os cartórios e juntas comerciais admitiam administrador não sócio apenas na hipótese de haver permissão expressa no contrato social.

1.9.2. Responsabilidade por débitos enquadráveis como dívida ativa tributária ou não tributária

Quanto aos **débitos da sociedade que sejam enquadráveis como dívida ativa**, tributário ou não tributário, **respondem pelo inadimplemento os administradores**, sócios ou não-sócios. Esses administradores poderão alegar que o inadimplemento não implicou em descumprimento de lei ou de contrato. Trata-se de difícil sustentação.

A **certidão de dívida ativa** emitida contra aquela sociedade **poderá ser executada diretamente no patrimônio particular do administrador**. Em tal caso, caberá ao administrador apresentar embargos de devedor, sustentando que o inadimplemento não foi por violação de lei ou contrato social, ou alegar ser o valor indevido.

1.9.3. Da responsabilidade da sociedade pelos atos praticados pelo administrador

Aplicam-se às sociedades limitadas as regras da sociedade simples sobre a responsabilidade pelos atos dos administradores. Assim, em regra, a sociedade limitada responde pelos atos de seus administradores, ainda que estes tenham extrapolado seus poderes e atribuições, com base no princípio da aparência. Excepcionalmente, porém, a sociedade não responderá pelos atos excessivos de seus administradores, nas hipóteses taxativas previstas nos incisos I (*limitação de poderes registrada averbada junto ao registro da sociedade*), II (*limitação de poderes que a sociedade provou ser de conhecimento do terceiro, ainda que não averbada*) e III (*prática de operação evidentemente estranha aos negócios da sociedade*) do art. 1.015, parágrafo único, do CC.

As hipótese do inciso III do parágrafo único do artigo 1.015 do CC é conhecida como **teoria ultra vires societatis (além dos limites da sociedade)** – a sociedade não responde pelos atos que evidentemente não guardam conexão com o objeto social.



Vale lembrar, no entanto, que a adoção da teoria dos atos *ultra vires* pelo Código Civil é criticada pela doutrina, havendo quem entenda que o credor de boa-fé sempre pode cobrar a sociedade, mesmo nesses casos, em homenagem à teoria da aparência. Em verdade, trata-se de entendimento majoritário (CRUZ, 2019). Nesse sentido, existe enunciado aprovado nas Jornadas de Direito Comercial do CJF, bem como decisão do STJ. Segundo o **Enunciado 11 da I Jornada de Direito Comercial do CJF**: “a regra do art. 1.015, parágrafo único, do Código Civil deve ser aplicada à luz da teoria da aparência e do primado da boa-fé objetiva, de modo a prestigiar a segurança do tráfego negocial. As sociedades se obrigam perante terceiros de boa-fé”.

De acordo com o STJ:

Direito comercial. Sociedade por quotas de responsabilidade limitada. Garantia assinada por sócio a empresas do mesmo grupo econômico. Excesso de poder. Responsabilidade da sociedade. Teoria dos atos *ultra vires*. Inaplicabilidade. Relevância da boa-fé e da aparência. Ato negocial que retornou em benefício da sociedade garantidora.

(...) 3. A partir do Código Civil de 2002, o direito brasileiro, no que concerne às sociedades limitadas, por força dos arts. 1.015, § único, e 1.053, adotou expressamente a *ultra vires* doctrine. 4. Contudo, na vigência do antigo Diploma (Decreto n.º 3.708/19, art. 10), pelos atos *ultra vires*, ou seja, os praticados para além das forças contratualmente conferidas ao sócio, ainda que extravasassem o objeto social, deveria responder a sociedade. 5. No caso em julgamento, o acórdão recorrido emprestou, corretamente, relevância à boa-fé do banco credor, bem como à aparência de quem se apresentava como sócio contratualmente habilitado à prática do negócio jurídico. 6. Não se pode invocar a restrição do contrato social quando as garantias prestadas pelo sócio, muito embora extravasando os limites de gestão previstos contratualmente, retornaram, direta ou indiretamente, em proveito dos demais sócios da sociedade fiadora, não podendo estes, em absoluta afronta à boa-fé, reivindicar a ineficácia dos atos outrora praticados pelo gerente. (...) (REsp 704.546/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4.ª Turma, j. 01.06.2010, DJe 08.06.2010).

1.10. Deliberações Sociais

Os atos de gestão serão praticados pelos administradores que possuem poderes para isso, mas certas matérias mais importantes/complexas não podem ser decididas pelo(s) administrador(es), dependendo de uma deliberação social.

No seu art. 1.071, o CC previu, em **rol exemplificativo**, que

Art. 1.071. Dependem da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato:

- I – a aprovação das contas da administração;
- II – a designação dos administradores, quando feita em ato separado;
- III – a destituição dos administradores;
- IV – o modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato;
- V – a modificação do contrato social;
- VI – a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação;
- VII – a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas;
- VIII – o pedido de concordata.

Quanto ao último inciso, lembre-se de que o Código Civil é de 2002, ano em que ainda estava em vigor a antiga lei de falências (Decreto-Lei nº 7.661/1945), que previa falência e concordata. Em 2005, foi editada a atual lei de falência e recuperação de empresas, Lei nº 11.101/2005, que acabou com a concordata, que foi substituída pela recuperação judicial e pela



recuperação extrajudicial. Portanto, ao se ler o supratranscrito artigo, deve-se substituir o termo “concordata” por “recuperação”.

Outras matérias que também dependem de deliberação social são as hipóteses de exclusão de sócio, por exemplo.

Como são tomadas as deliberações sociais?

Em reunião ou assembleia. **A diferença entre a assembleia e a reunião está no procedimento.** Aquela segue rito mais solene, com o próprio Código ditando suas regras procedimentais. Esta, por sua vez, tem rito mais simplificado, cabendo aos sócios, no contrato social, estabelecer os detalhes de seu procedimento.

Tanto a reunião quanto a assembleia, entretanto, podem ser dispensadas e substituídas por um documento escrito, desde que todos os sócios estejam de acordo, ou seja, desde que a decisão seja unânime (art. 1.072, § 3.º).

As deliberações sociais, desde que tomadas em conformidade com a lei e o contrato social, “vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes (art. 1.072, § 5º, do CC). Por outro lado, estabelece o art. 1.080 que as deliberações infringentes do contrato ou da lei tornam ilimitada a responsabilidade dos que expressamente as aprovaram.” Assim, para evitar ser responsabilizado futuramente, o sócio dissidente deve sempre requerer a consignação em ata do seu voto contrário à deliberação tomada.

Em relação a determinadas matérias, a lei estabelece algumas formalidades específicas, como para a designação e a destituição de administradores, a modificação do contrato social, ou a expulsão de sócio minoritário etc.

Para tratar dessas matérias, **os sócios deverão se reunir em reunião ou em assembleia, que deverão observar um quórum deliberativo.** A deliberação em assembleia será obrigatória se o número dos sócios for superior a dez (art. 1.072, § 1º, do CC).

Essa assembleia é convocada por meio de avisos publicados na imprensa oficial e em jornal de grande circulação durante **3 vezes (art. 1.152, §3º, do CC)**. A **antecedência mínima** entre a última publicação e a data da assembleia é de **8 dias**. Tais formalidades são dispensadas se todos os sócios comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia.

A assembleia somente poderá deliberar se tiverem atendido àquela convocação sócios que **representem 3/4 do capital social (art. 1.074)**. Caso não haja quórum, deverá ser feita uma **nova convocação**, da mesma forma anterior. No entanto, nessa segunda, a antecedência mínima entre a última publicação e a data da assembleia será de **5 dias (art. 1.152, §3º)**. Essa segunda assembleia se instala validamente **independentemente do número de sócios presentes (art. 1.074)**.

Ao término da assembleia, é feita uma ata, a qual conterá as deliberações manifestadas na assembleia.

É garantida uma **assembleia anual (art. 1.078)**, a qual servirá para **tomar as contas dos administradores, votar o balanço patrimonial e de resultados, e se for o caso, para eleger o administrador**, caso o mandato haja se esgotado.

Segundo a lei, se a sociedade tiver **no máximo 10 sócios**, o contrato social poderá prever **reunião de sócios**, no lugar de assembleia. **O contrato social poderá dispor livremente sobre como se dará a reunião dos sócios.** Ex.: a reunião se instalará primeiramente com qualquer quórum.

A assembleia ou a reunião de sócios **poderá ser substituída por um documento** que explicita a deliberação adotada, desde que este documento seja **assinado por todos os sócios**. Em outras palavras, **se houver unanimidade, não é necessária a realização da assembleia.**

Serão quóruns deliberativos previstos na lei:

- unanimidade dos sócios para designar administrador não sócio, se o capital não estiver totalmente integralizado;
- 3/4 do capital social para modificação do contrato social: os 25% que não concordarem poderão exercer o direito de retirada;



- 3/4 para aprovar incorporação, fusão ou dissolução da sociedade: os 25% que não concordarem poderão exercer o direito de retirada;
- 2/3 do capital social para designar administrador não sócio, se o capital estiver totalmente integralizado;
- 2/3 para destituir o administrador sócio, nomeado no contrato social;
- mais da 1/2 (metade) do capital social para designar administrador em ato separado do contrato social: como é ato em separado, a exigência é menor;
- mais da 1/2 (metade) do capital social para destituir um administrador não sócio, designado em ato separado do contrato social;
- mais da 1/2 (metade) do capital social para expulsar sócio minoritário.

Aqui vale uma última ressalva, quando a sociedade limitada é microempresária ou empresa de pequeno porte, **a lei dispensa a realização de qualquer assembleia ou reunião, salvo se o objetivo é a exclusão de sócio minoritário**, hipótese em que haverá a assembleia.

A lei estabelece que nas microempresas e empresas de pequeno porte, o quórum de deliberação **será sempre a maioria do capital social**.

4.6. Sociedade limitada unipessoal

A Lei de Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019) trouxe importante novidade: a possibilidade de uma sociedade limitada ser constituída por apenas um sócio (inclusão do §1º no art. 1.052 do CC).

Em tal caso, não haverá contrato social, mas mero “documento de constituição do sócio único”, ao qual serão aplicadas, no que couber, as disposições sobre o contrato social.

A tendência é que essa novidade esvazie a utilidade prática da EIRELI, uma vez que à sociedade limitada unipessoal não se aplicam as regras restritivas constantes do art. 980-A do CC.

2. Sociedades contratuais menores

2.1. Introdução

É uma expressão utilizada por Fábio Ulhoa Coelho para se referir à **sociedade em nome coletivo**, à **sociedade em comandita simples** e à **sociedade em conta de participação**.

Trata-se de sociedades pouco usuais no ordenamento jurídico brasileiro. Cabe ressaltar que a sociedade em conta de participação é despersonalizada.

2.2. Aspectos em comum da sociedade em nome coletivo e da sociedade em comandita simples

São aspectos em comum entre a sociedade em nome coletivo e sociedade em comandita simples:

- **são sociedades de pessoas:** não são sociedades de capital;
- **adotam firma como nome empresarial:** não é denominação;
- **somente sócios poderão administrar a sociedade:** na sociedade em comandita simples, somente o sócio comanditado poderá administrar a sociedade, visto que ele responde ilimitadamente. O sócio comanditado só poderá ser pessoa física, e não jurídica. A pessoa jurídica somente pode ser sócio comanditário, não podendo praticar ato de gestão (embora participe das deliberações sociais e possua direito de fiscalização) e respondendo limitadamente.



2.3. Sociedade em nome coletivo

Na sociedade em nome coletivo, **todos os sócios devem ser pessoas físicas e respondem solidária e ilimitadamente**, sem prejuízo da repartição, entre si, da responsabilidade de cada um.

Na hipótese de **falecimento de sócio**, **haverá a liquidação da quota do falecido**, salvo se o contrato dispuser de forma diversa.

Na sociedade em nome coletivo, o uso da firma é privativo, nos limites do contrato, dos que tenham os necessários poderes para usá-la.

2.4. Sociedade em comandita simples

A sociedade em comandita simples possui duas espécies de sócios:

- **sócios comanditados:** responderão ilimitadamente;
- **sócios comanditários:** responderão limitadamente.

Somente poderá ser **administrada por sócios comanditados, que somente poderão ser pessoas físicas**. Já os sócios comanditários poderão ser pessoas físicas ou jurídicas.

Na sociedade em comandita simples, não pode o nome do sócio comanditário constar na firma social, sob pena de ficar sujeito às mesmas responsabilidades de sócio comanditado.

Ocorrendo a **morte de um sócio comanditado**, haverá a **dissolução parcial da sociedade**, devendo ser liquidado o valor das quotas sociais. Por outro lado, havendo o **falecimento de um sócio comanditário**, a sociedade, em princípio, **continua com sucessores do falecido**. Adota-se aqui uma característica de sociedade de capital, diferente da sociedade de pessoas.

2.5. Sociedade em conta de participação

Essa sociedade está definida no art. 991 do Código Civil, que assim dispõe: “na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes.”

Trata-se, em verdade, não de uma sociedade propriamente dita, mas de um contrato especial de investimento que o **sócio ostensivo** (geralmente um empresário individual ou sociedade empresária) faz com os **sócios participantes**, também chamados de sócios ocultos (podem ser empresários ou não), a fim de desenvolver determinado negócio específico.

Cuidado: quem exerce a atividade é o sócio ostensivo, não o fazendo como representante ou administrador da sociedade, mas em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade. É por isso que se diz que a sociedade em conta de participação é mais um contrato de investimento do que uma sociedade, pois provavelmente o sócio ostensivo é uma sociedade empresária, que angariou alguns investidores para fazer determinado negócio, acertando a divisão dos lucros e prejuízos ao final. Os terceiros que contratam com o sócio ostensivo sequer sabem da existência da sociedade em conta de participação ou os sócios investidores, porque negociam diretamente com o sócio ostensivo.

É o sócio ostensivo (uma sociedade limitada, por exemplo) que vai colocar em prática o negócio em questão, praticando todos os atos necessários para tanto (contratar com terceiros, por exemplo). Perceba-se que os terceiros não contratarão com a sociedade em conta de participação, mas com o próprio sócio ostensivo, e é por isso que a responsabilidade decorrente desse negócio é apenas do sócio ostensivo, e não da sociedade, muito menos dos participantes (estes, aliás, sequer devem aparecer nas relações do ostensivo com terceiros). A propósito, diz o art. 991, parágrafo único, do Código Civil: *obriga-se perante terceiro tão-somente o sócio ostensivo; e, exclusivamente perante este, o sócio participante, nos termos do contrato social.*



De acordo com o art. 992 do Código Civil, “a constituição da sociedade em conta de participação independe de qualquer formalidade e pode provar-se por todos os meios de direito”. Esse dispositivo apenas deixa claro que a conta de participação é uma sociedade extremamente informal, que sequer precisa ter um contrato escrito, e sua existência pode ser provada por qualquer meio.

O art. 993 do Código Civil prevê que “o contrato social produz efeito somente entre os sócios, e a eventual inscrição de seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade.” Caso exista contrato escrito – o qual, vale lembrar, não é obrigatório – ele não precisa ser registrado em nenhum local para que produza efeitos entre as partes. Não somente, ainda que exista contrato e ainda que ele seja eventualmente registrado em algum local (Cartório de Títulos e Documentos, por exemplo), isso não confere personalidade jurídica à sociedade em conta de participação. Ela será sempre, pois, uma **sociedade não personificada**. Por exigência da Receita Federal, deverá possuir CNPJ, mas ainda assim não adquirirá personalidade jurídica (CNPJ para fins meramente fiscais).

Justamente porque a sociedade em conta de participação não tem personalidade jurídica, **não há razão para ter nome** empresarial (art. 1.162 do CC).

No caso de **falência do sócio ostensivo, haverá obrigatoriamente a liquidação da sociedade**. Por outro lado, falecendo o sócio participante (oculto), os direitos do contrato de sociedade em conta de participação firmado poderão integrar a massa, visto que fazem parte do patrimônio do sócio. Porém, **falindo o sócio participante, o contrato social fica sujeito às normas que regulam os efeitos da falência nos contratos bilaterais do falido**.

A sociedade em conta de participação **para fins de direito tributário possui CNPJ**, sendo equiparada aos demais tipos societários. A consequência é a **possibilidade de distribuição dos dividendos da sociedade sem que incida imposto de renda**.

3. Sociedade em comum

São duas as sociedades não personificadas previstas no Código Civil, a sociedade em comum (arts. 986 a 990) e a sociedade em conta de participação (arts. 991 a 996), esta última já estudada em tópico acima.

A expressão “sociedade não personificada” é contraditória. Sendo a sociedade uma espécie de pessoa jurídica de direito privado (art. 44, inciso I, do Código Civil), é equivocado falar em uma sociedade que não possui personalidade jurídica. Teria sido melhor o legislador usar a expressão “ente não personificado”, por exemplo.

Registre-se também que essas sociedades não personificadas, embora estejam disciplinadas na parte do Código Civil referente às sociedades empresárias, podem eventualmente desenvolver atividades civis (não empresariais), caso em que serão qualificadas como sociedades simples (art. 982, do Código Civil). A propósito, confira-se o **enunciado 208 das Jornadas de Direito Civil do CJF**:

as normas do Código Civil para as sociedades em comum e em conta de participação são aplicáveis independentemente de a atividade dos sócios, ou do sócio ostensivo, ser ou não própria de empresário sujeito a registro (distinção feita pelo art. 982 do Código Civil entre sociedade simples e empresária).

Quanto à sociedade em comum, o art. 986 do Código Civil tem a seguinte redação: “enquanto não inscritos os atos constitutivos, rege-se a sociedade, exceto por ações em organização, pelo disposto neste Capítulo, observadas, subsidiariamente e no que com ele forem compatíveis, as normas da sociedade simples.”

Sociedade em comum, portanto, é aquela que **ainda não inscreveu seus atos constitutivos no órgão competente**, que pode ser a Junta Comercial (caso o objeto social seja o exercício de uma atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou



de serviços) ou o Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas (caso o objeto social seja o exercício de uma atividade econômica não empresarial, como o exercício de profissão intelectual, de natureza literária, artística ou científica).

Como é o registro que confere personalidade jurídica às sociedades (art. 985 do Código Civil), a **sociedade em comum não possui personalidade jurídica**, obviamente. Trata-se, na verdade, de uma sociedade em processo de constituição: como uma sociedade não é constituída de imediato, existe um lapso temporal entre o momento em que os sócios se decidem pela constituição e o momento em que ela é efetivamente constituída (registro no órgão competente).

Art. 985. A sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição, no registro próprio e na forma da lei, dos seus atos constitutivos (**arts. 45 e 1.150**).

IMPORTANTE: apenas as sociedades contratuais em constituição podem ser qualificadas como sociedades em comum, já que o art. 986 do Código Civil faz expressa ressalva às “**sociedades por ações em organização**”, as quais possuem tratamento específico na Lei nº 6.404/1976.

É importante distinguir a sociedade em comum da sociedade de fato e da sociedade irregular. **Sociedade de fato** é a sociedade que não possui sequer contrato escrito e já está exercendo suas atividades, sem nenhum indício de que seus sócios estejam tomando as providências necessárias à sua regularização. **Sociedade irregular**, por sua vez, é a sociedade com contrato escrito e registrado, que já iniciou suas atividades normais, mas que apresenta irregularidade superveniente ao registro (por exemplo: não averbou alterações do contrato social).

Nada impede, todavia, que eventualmente se apliquem as normas da sociedade em comum (arts. 986 a 990 do Código Civil) tanto às sociedades irregulares quanto às sociedades de fato, por analogia. Nesse sentido, confira-se o enunciado 383 das Jornadas de Direito Civil do CJF: “a falta de registro do contrato social (irregularidade originária – art. 998) ou de alteração contratual versando sobre matéria referida no art. 997 (irregularidade superveniente – art. 999, parágrafo único) conduzem à aplicação das regras da sociedade em comum (art. 986)”.

3.1. Prova da existência da sociedade em comum

Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo.

A sociedade em comum não é uma sociedade devidamente registrada, então não tem personalidade jurídica, não tem atos constitutivos registrados para que um terceiro possa consultar. Por isso, permite-se ao terceiro provar a existência dessa sociedade de qualquer modo. Porém, em se tratando dos próprios sócios que integram a sociedade, a prova da existência da sociedade deverá ser feita por escrito.

3.2. Patrimônio da sociedade em comum

De acordo com o art. 988 do CC, “os bens e dívidas sociais constituem patrimônio especial, do qual os sócios são titulares em comum”.

Sobre o tema, dispõe o Enunciado 210 das Jornadas de Direito Civil do CJF o seguinte: “o patrimônio especial a que se refere o art. 988 é aquele afetado ao exercício da atividade, garantidor de terceiro, e de titularidade dos sócios em comum, em face da ausência de personalidade jurídica”.

Assim, diz o Código Civil, que se os bens estão vinculados de certa forma à atividade, consideram-se como patrimônio especial da sociedade em comum, sendo esses bens que



deverão garantir eventuais credores. Cria-se, portanto, uma especialização patrimonial, sem prejuízo da responsabilização ilimitada dos sócios.

3.3. Responsabilidade dos sócios da sociedade em comum

Uma vez que o “patrimônio social” da sociedade em comum é formado pelos bens dos sócios que estão afetados ao objeto social, é contra esses bens que os credores sociais devem se voltar em caso de eventual execução, aplicando-se aos sócios o benefício de ordem previsto no art. 1.024 do Código Civil, isto é, os credores devem primeiro executar esses “bens sociais” antes de executar bens pessoais dos sócios. O único sócio que não poderá gozar do benefício de ordem é aquele contratou pela sociedade, conforme previsão expressa do art. 990 do Código Civil: *todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído do benefício de ordem, previsto no art. 1.024, aquele que contratou pela sociedade.*

Recomenda-se a leitura atenta dos artigos 987 e 990 do Código Civil, pois são os que mais caem em prova.

4. Sociedades de grande porte

Uma sociedade (independentemente do tipo societário) ou um conjunto de sociedades sob controle comum serão classificados como de grande porte quando:

- seu ativo superar R\$ 240.000.000,00; ou
- receita anual superar R\$ 300.000.000,00

A consequência é que essa sociedade ou conjunto societário passará a se submeter às mesmas regras existentes para a sociedade anônima no tocante à escrituração e elaboração das suas demonstrações financeiras, conforme determina o art. 3º da Lei nº 11.638/2017.

Será obrigada a escriturar seus livros mercantis, observando o regime de competência, e não o regime de caixa. Ao término do exercício financeiro, deverá levantar o balanço patrimonial, o balanço de lucros e prejuízos acumulados e a demonstração de resultado do exercício.

Haverá uma aproximação por conta do impacto dessa sociedade à força de uma sociedade anônima.

Se o patrimônio líquido da sociedade for superior a R\$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), será a sociedade obrigada a promover a demonstração de fluxo de caixa, além das hipóteses já mencionadas acima.

5. EIRELI

Criação relativamente recente do ordenamento jurídico, que veio para corrigir um problema que se apresenta aos empreendedores brasileiros. Antes, aos que queriam empreender, havia apenas duas possibilidades: ou seria empresário individual, ou sócio de uma sociedade empresária.

O empresário individual não precisa de sócios, mas tem responsabilidade direta e ilimitada. Já o sócio de uma sociedade empresária até pode ter, a depender do tipo societário, responsabilidade limitada, mas precisa se juntar a alguém para constituir a pessoa jurídica.

Por isso, a EIRELI foi criada, reúne duas características positivas, uma do empresário individual e uma da sociedade. Para se constituir EIRELI não há necessidade de sócio, e sua responsabilidade será limitada.



5.1. Natureza Jurídica da EIRELI

Polêmica: inicialmente foi dito que seria uma subespécie de sociedade, uma sociedade limitada de um sócio só. Não foi o entendimento que prevaleceu.

O que prevaleceu é que a EIRELI é uma nova categoria de pessoa jurídica de direito privado. O principal argumento é de que além de o CC ter acrescido o artigo 980-A ao seu corpo normativo, acrescentou também o artigo 44, inciso VI: “São pessoas jurídicas de direito privado: (...) VI - as empresas individuais de responsabilidade limitada. Confirmam-se os enunciados do CJF sobre o tema:

Enunciado 469 da V Jornada de Direito Civil: A empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI) não é sociedade, mas novo ente jurídico personificado.

Enunciado 3 da I Jornada de Direito Comercial: A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI não é sociedade unipessoal, mas um novo ente, distinto da pessoa do empresário e da sociedade Empresária.

5.2. Capital “Social” da EIRELI

Como a EIRELI não é uma sociedade, critica-se o uso da palavra “social” no artigo 980-A (Enunciado 472 da V Jornada de Direito Civil: “É inadequada a utilização da expressão ‘social’ para as empresas individuais de responsabilidade limitada.”)

Há, ainda, exigência de capital mínimo para se constituir EIRELI, a qual foi muito criticada, inclusive questionada por meio da ADIn nº 4.637 (relator Min. Gilmar Mendes).

O prof. André Santa Cruz (2019) é um crítico dessa exigência, porque não existe essa imposição de capital mínimo no Brasil nem para constituição de Sociedade Anônima, a não ser em situações muito específicas, não fazendo sentido exigir para constituição de EIRELI.

Outra questão sobre o capital da EIRELI: a exigência de capital mínimo é no ato da constituição, uma vez constituído tem-se ato jurídico perfeito e eventuais alterações no valor do salário mínimo não implicarão alterações do capital social, conforme já chancelado no Enunciado 4 da I Jornada de Direito Comercial: “Uma vez subscrito e efetivamente integralizado, o capital da empresa individual de responsabilidade limitada não sofrerá nenhuma influência decorrente de ulteriores alterações no salário mínimo.”

5.3. Nome empresarial da EIRELI

“Art. 980-A, §1º. O nome empresarial deverá ser formado pela inclusão da expressão “EIRELI” após a firma ou a denominação social da empresa individual de responsabilidade limitada.”

Assim, resta claro que a EIRELI pode adotar FIRMA ou DENOMINAÇÃO (conteúdo a ser estudado em aula posterior) e deve incluir a expressão EIRELI ao final do nome.

5.4. Quem pode constituir EIRELI

O artigo 980-A só fala em pessoa. É necessário ser pessoa natural ou pode ser pessoa jurídica?

Há posicionamento que diz ser possível apenas a constituição por pessoa natural, uma vez que a criação da EIRELI foi justamente para permitir que o empresário individual se tornasse pessoa jurídica, não sendo objetivo do legislador autorizar que uma pessoa jurídica constitua uma EIRELI.



Outro posicionamento é o de que não há empecilho para que uma pessoa jurídica seja sócia de outra pessoa jurídica, sendo possível a constituição de EIRELI por uma pessoa jurídica.

Inicialmente, foi o primeiro posicionamento que prevaleceu, inclusive com enunciado do CJF nesse sentido (enunciado 468 das Jornadas de Direito Civil). Apenas pessoa natural poderia constituir EIRELI.

O DREI também entendia que o titular da EIRELI tinha que ser uma pessoa natural, mas esse entendimento mudou, e agora é possível que o titular de uma EIRELI seja uma pessoa jurídica, podendo essa pessoa jurídica ser, inclusive, uma sociedade estrangeira (item 1.2, parte inicial, e item 1.2.5.c do Manual de Registro de EIRELI).

Detalhe importante: o § 2º do art. 980-A do Código Civil veda a constituição de mais de uma EIRELI pelo mesmo titular quando esse for uma pessoa natural. Assim, quando o titular da EIRELI for uma pessoa jurídica, tal vedação não se aplicará, sendo possível que uma pessoa jurídica seja titular de mais de uma EIRELI.

5.5. Aplicação Subsidiária das regras da sociedade limitada

Cuidado: da mesma forma que se pode aplicar a desconconsideração da personalidade jurídica para responsabilizar o sócio da sociedade limitada, é possível aplicar a mesma teoria para responsabilizar o titular de uma EIRELI. Nesse sentido:

Enunciado 470 da V Jornada de Direito Civil: O patrimônio da empresa individual de responsabilidade limitada responderá pelas dívidas da pessoa jurídica, não se confundindo com o patrimônio da pessoa natural que a constitui, sem prejuízo da aplicação do instituto da desconconsideração da personalidade jurídica.

Serão a ela aplicadas as mesmas regras das sociedades limitadas, mas há algumas peculiaridades:

- **nome empresarial trará a expressão “EIRELI”** ao final da firma ou denominação. Ex.: João da Silva EIRELI ou Azul Comércio de Livros EIRELI;
- **capital social será de pelo menos 100 salários mínimos**, devendo estar **totalmente integralizado** no ato da constituição da EIRELI;
- **se o sócio for uma pessoa física, não poderá participar de uma outra EIRELI**. Poderá o sócio da EIRELI ser sócio de outra sociedade limitada, mas não poderá ser unipessoal;
- **poderá também ser constituída por transformação de registro**. Isso pode se dar pelo empresário individual que decide se transformar em EIRELI ou por meio da concentração de titularidade da sociedade que era de dois sócios para que o sócio restante promova a modificação dentro do prazo de 180 dias trazido pela lei.

6. Sociedade Anônima

Vale relembrar, que dos cinco tipos de sociedade empresária tratados, apenas dois são usados na prática hoje em dia, a sociedade limitada e a sociedade anônima, os demais são tipo societários que, na atualidade, basicamente só existem no papel.

Obs.: existem também as cooperativas, mas lembre-se que essas não são sociedades empresárias, mas sociedades simples, assim como existem as sociedades simples puras e a EIRELI, que não é sociedade.

Duas são as sociedades por ações:

- **sociedade anônima;**
- **sociedade em comandita por ações.**

As regras da sociedade anônima possuem **caráter geral**.



6.1. Origem histórica

A SA é um tipo societário bem diferente dos demais, tendo características próprias, voltadas para negócios de maior porte ou de maior complexidade, o que atrai um interesse público forte quanto a seu funcionamento.

A sociedade anônima remonta às antigas companhias marítimas. A sociedade passou a ser denominada anônima a partir do momento em que os monarcas passaram a investir nas grandes navegações. Para não assumir os riscos, eles ficavam no anonimato, de modo que essa relação societária se fechava apenas entre os sócios. Se o negócio não desse lucro, o sócio anônimo não ficaria sujeito a ter seu patrimônio reclamado pelo patrimônio das dívidas societárias, passando a ser chamada de **companhias marítimas**.

Por essa razão, a legislação brasileira denomina a sociedade anônima também de companhia.

Por sempre estar ligada a grandes empreendimentos, houve tempo em que a sociedade anônima estava totalmente **submetida ao controle estatal**, necessitando de autorização para ser constituída e sendo fiscalizada no seu funcionamento, como ocorre com a sociedade anônima de capital aberto.

No Brasil, as sociedades anônimas são regidas pela Lei nº 6.404/1976 (LSA). A LSA sofreu algumas alterações a partir da década de 90, provocadas pelas Leis nº 9.457/1997, que a preparou para o processo de privatizações; nº 10.303/2001, que procurou proteger os interesses dos acionistas minoritários e tornar o mercado de capitais mais seguro e atrativo para os investidores; nº 11.638/2007 e nº 11.941/2009, que, basicamente, trouxeram novas regras acerca da elaboração e da divulgação das demonstrações financeiras desse tipo societário; nº 12.431/2011 e nº 13.129/2015, que lhe trouxeram modificações e acréscimos pontuais.

Características mais importantes (comumente cobradas em concurso):

(i) **natureza capitalista**: a sociedade anônima é, em regra, uma sociedade de capital, ou seja, nela as características pessoais dos sócios não são determinantes para a formação do vínculo societário – *intuitu pecuniae* –, de modo que a entrada de estranhos no quadro social geralmente independe da anuência dos demais sócios, sendo a participação societária – chamada de ação – livremente negociável. Há, todavia, conforme já reconheceu o STJ, a possibilidade de serem sociedades de pessoas, a exemplo de determinadas Companhias fechadas formadas por núcleo familiar (EREsp 1.079.763/SP);

(ii) **essência empresarial**: a sociedade por ações é considerada uma sociedade empresária independentemente de seu objeto social, conforme previsão do art. 982, parágrafo único, do Código Civil;

(iii) **identificação exclusiva por denominação**: a sociedade anônima só pode usar denominação social, conforme disposto no art. 3º da LSA e no art. 1.160 do Código Civil;

(iv) **responsabilidade limitada dos acionistas**: os sócios da sociedade anônima respondem somente pela integralização de suas ações, não havendo, para eles, sequer a previsão de responsabilidade solidária quanto à integralização de todo o capital social.

6.2. Classificação

Podem ser classificadas em companhias abertas ou fechadas, nos termos do art. 4º da Lei nº 6.404/76:

Art. 4º Para os efeitos desta Lei, a companhia é aberta ou fechada conforme os valores mobiliários de sua emissão estejam ou não admitidos à negociação no mercado de valores mobiliários.



§ 1º Somente os valores mobiliários de emissão de companhia registrada na Comissão de Valores Mobiliários podem ser negociados no mercado de valores mobiliários.

§ 2º Nenhuma distribuição pública de valores mobiliários será efetivada no mercado sem prévio registro na Comissão de Valores Mobiliários.

6.3. Comissão de Valores Mobiliários

A Comissão de Valores Mobiliários foi instituída pela Lei nº 6.385/76, que, em seu art. 5º, prevê o seguinte:

Art. 5º É instituída a Comissão de Valores Mobiliários, entidade autárquica em regime especial, vinculada ao Ministério da Fazenda, com personalidade jurídica e patrimônio próprios, dotada de autoridade administrativa independente, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes, e autonomia financeira e orçamentária.

Entre suas competências, podem-se citar:

- a) a regulamentar, uma vez que cabe à CVM estabelecer o regramento geral relativo ao funcionamento do mercado de capitais (possui instruções normativas);
- b) a autorizar, uma vez que é a CVM que autoriza a constituição de companhias abertas e a emissão e negociação de seus valores mobiliários; e
- c) a fiscalizatória, uma vez que a CVM deve zelar pela lisura das operações realizadas no mercado de capitais, sendo investida, para tanto, de poderes sancionatórios. (RAMOS, 2016)

6.3.1. Mercado de valores mobiliários

a) Primário x Secundário

O mercado de capitais **primário** envolve operações de emissão e subscrição de novos valores mobiliários. Exemplo: quando a sociedade anônima está emitindo ações e estas são subscritas por novos acionistas, trata-se de operação feita no mercado de capitais primário.

Não somente, são operações feitas de forma direta entre a sociedade anônima e o investidor.

O mercado de capitais **secundário** é composto por operações de compra e venda de valores mobiliários já existentes no mercado, realizadas entre investidores.

b) Bolsa de Valores x Mercado de balcão

Bolsa de valores é uma entidade **privada**, que tem a função de manter um local apropriado, uma estrutura logística administrativa para a negociação pública de valores mobiliários, com a finalidade de que se realize de forma mais dinâmica, transparente, segura, ágil etc.

Geralmente, as Bolsas de Valores eram associações civis, sem fins lucrativos - associações de corretoras, de instituições financeiras, formavam uma bolsa de valores -, mas vem ocorrendo o fenômeno chamado de desmutualização das bolsas de valores, pois estão deixando de ser associações civis sem fins lucrativos para elas próprias se tornarem empresárias, muitas vezes se tornam S.A. de capital aberto. Exemplo: BOVESPA (Bolsa de Valores de São



Paulo) se juntou com a BMF (Bolsa de Mercados do Futuro), transformando-se em BMFBOVESPA, chamada hoje de B3 (Brasil Bolsa Balcão).

O Brasil chegou a ter mais de dez Bolsas de Valores, mas essas bolsas ou já não existem mais, ou foram incorporadas pela Bolsa de Valores de São Paulo, que é uma das Bolsas de Valores mais importantes do mundo, em termos de volume de negócios, ou existem exercendo funções como organização de eventos, divulgação de informações etc., mas não têm realmente operações diárias de relevo.

Mercado de Balcão é uma expressão usada para identificar as operações que são feitas fora da bolsa de valores.

6.4 Abertura de capital

Sociedades empresárias e empresários em geral necessitam de recursos para fazer frente a seus investimentos. Esses recursos, normalmente vêm dos próprios sócios, no caso da sociedade anônima, vêm dos próprios acionistas. Mas, muitas vezes, acaba sendo necessário encontrar outras fontes de recursos. Uma forma possível é o financiamento bancário, porém, nesse caso, arca-se com altos juros, além de precisar apresentar garantia. Nesse contexto, a abertura de capital tem grande importância para as S.A., pois é um mecanismo de autofinanciamento das sociedades anônimas, porque permitem à sociedade que capte recursos junto a investidores, excluindo-se a necessidade de um intermediador financeiro.

A **abertura de capital** (IPO* — *Initial Public Offering*) de uma companhia é

um importante instrumento de captação de recursos, uma vez que suas operações no mercado de capitais não são necessariamente de crédito, em que ela assume a posição de devedora e se compromete, não raro, a devolver os valores captados em curto espaço de tempo e a taxas de juros altas. Ao contrário, muitas dessas operações são de investimento, de modo que seus participantes não se tornarão credores da companhia, mas sócios e partes interessadas no sucesso da empresa, pois é dele que advirá o retorno do investimento feito por eles.

Outra distinção entre o mercado de capitais e o mercado de crédito é que neste há sempre a atuação de um intermediário, como uma instituição financeira, o que tende a burocratizar e encarecer a operação. Naquele, em contrapartida, há uma negociação direta entre a companhia que precisa de recursos e o investidor que os possui, já que ele adquire os títulos da empresa diretamente dela. É por isso que se diz que o mercado de capitais é um mecanismo de acesso à “poupança popular”. (RAMOS, 2016)

Por esse motivo, é um mercado extremamente sensível, que sofre pesada regulação estatal, não sendo qualquer S.A. autorizada a abrir capital, já que existem regras extremamente rígidas.

Hoje em dia, pequenas sociedades vêm tentando outras formas de se financiar, pois o mercado de capitais acaba sendo muito restrito às sociedades anônimas. O desenvolvimento da tecnologia tem permitido que pequenos empresários, EIRELIs, *startups* (que são sociedade que começam um novo empreendimento, principalmente em áreas de tecnologia), etc., possuam outras formas de financiamento direto, um deles é chamado de *crowdfunding*, que tem se desenvolvido muito por causa da internet, pois capta recursos por meio de plataformas virtuais, sendo, inclusive, já regulamentado pela CVM.

6.5. Responsabilidade limitada do acionista

O acionista responde pelo preço de emissão das ações que ele subscrever ou adquirir.

A ação tem diferentes valores, mas falamos em preço de emissão, que não é todo o valor que a ação poderá ter. Isso porque a ação poderá ter diferentes valores:



- **valor nominal:** é aquele obtido a partir da divisão do **capital social pelo número de ações**. O estatuto pode prever este valor nominal, ou poderá não prever;
- **valor patrimonial:** existe ainda o valor patrimonial das ações. Nesse caso, será feito o cálculo com base no **patrimônio líquido da sociedade dividido pelo número de ações**;
- **valor de negociação:** é o **quanto o sujeito recebe por aquela ação no mercado**. É o preço que o titular da ação consegue quando a vende;
- **valor econômico:** é aquele que os **experts dizem que vale aquela ação**. Representa valor que seria racional pagar por uma ação, a partir das perspectivas de rentabilidade que se faz da ação.

O **preço de emissão** é o preço que o indivíduo deverá pagar pela ação que subscreveu, seja este pagamento à vista, seja parcelado.

Caso a companhia tenha seu capital social constituído por meio de **ações de valor nominal**, o **preço de emissão não pode ser inferior ao valor nominal**.

Por outro lado, caso tenha valor superior ao valor nominal, a diferença será denominado de **ágio**. Este ágio, que será o valor entre o preço de emissão e o valor nominal da ação, **comporá a reserva de capital daquela sociedade anônima**.

6.6. Constituição da sociedade anônima

A constituição da sociedade anônima se dá em três níveis:

- **requisitos preliminares;**
- **modalidades de constituição;**
- **providências complementares.**

6.6.1. Requisitos preliminares

São requisitos preliminares:

- **subscrição de todo o capital por pelo menos 2 pessoas:** ou seja, é a promessa de pagamento ou contribuição para o capital social;
- **pagar em dinheiro no mínimo 10% do preço de emissão das ações subscritas.** Caso seja instituição financeira, este valor sobe para 50%;
- **depósito deverá se dar no Banco do Brasil, ou em outro estabelecimento autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários.**

6.6.2. Modalidades de Constituição

São modalidades de constituição de uma sociedade anônima:

- **por subscrição pública:** os fundadores da SA vão buscar recursos para sua constituição junto a investidores. Por isso é denominada de **constituição sucessiva**, visto que vai abarcar várias etapas. Terá **início com o registro na comissão de valores mobiliários (CVM)**, seguido de o estudo de viabilidade econômico-financeira dessa companhia, com projetos de estatuto e prospectos da companhia, os quais poderão ser adaptados. Se a CVM chegar à conclusão de que não há viabilidade econômica para a SA, não haverá como adaptar. Para requerer o registro junto à CVM, o fundador da companhia deverá contratar uma instituição financeira, a qual vai intermediar a colocação das ações no mercado, por meio de venda. Feito o registro da companhia, haverá a segunda fase da constituição sucessiva, que é a subscrição das ações representativas do capital social. Isto é, irão atrás das pessoas que se comprometem a contribuir com o capital social. Esse investimento é oferecido ao público. Por isso a subscrição é pública, devendo ser feito por meio da



instituição financeira. Quando todo o capital social estiver subscrito, os fundadores então convocarão uma assembleia de fundação da companhia para deliberar sobre a constituição. Observadas todas as formalidades legais, é proclamada a constituição da sociedade anônima.

- **por subscrição particular:** não existe a preocupação de buscar recursos para sua constituição, pois o investimento será feito pelos próprios fundadores. Por isso, é denominada de **constituição simultânea**, visto que vai se concentrar num único ato. **A constituição poderá ser dar por deliberação dos subscritores, reunidos em uma assembleia, para fundação da companhia.** Não precisa oferecer ao público, tampouco que haja intermediação de instituição financeira. Também **será possível a constituição da companhia por meio de escritura pública.**

Atente-se que, independentemente da modalidade de subscrição, existem algumas regras específicas:

- **se for feita a incorporação de bens imóveis como integralização do capital social, será dispensável a escritura pública.**
- **denominação da companhia, enquanto não estiver concluído o processo de constituição, deverá vir aditado da expressão “em organização”:** serve para informar que a companhia ainda não teve seu processo de constituição concluído.

6.6.3. Providências complementares

São providências complementares, comuns às duas formas de subscrição, pública ou particular, a **necessidade de registro e publicação dos atos constitutivos da companhia.** Com isso, após essas providências, poderá a companhia dar início às suas atividades.

6.6.4. Valores mobiliários

Valores mobiliários não são apenas ações. Existem outros valores mobiliários.

Ação é aquela que representa uma unidade do capital social.

Além da ação, poderão ser emitidos:

- **debêntures:**
- **partes beneficiárias:**
- **bônus de subscrição:**
- **nota promissória:** em razão da instrução da CVM, será um valor mobiliário que se destina à captação de recursos no curto prazo, sendo no mínimo de 30 dias e no máximo de 360 dias. Capta recursos para restituição no curto prazo. É conhecido como **comercial paper**.

a) Ações e suas classificações

Há dois mecanismos de autofinanciamento (sem necessidade de financiamento externo, como empréstimos bancários, por exemplo) das sociedades anônimas: a capitalização, que consiste na emissão de novas ações; e a securitização, que se dá por meio da emissão de outros valores mobiliários, a exemplo das debêntures, das partes beneficiárias e dos bônus de subscrição.

O principal valor emitido por uma S.A. é a ação, que é valor mobiliário representativo de fração do capital social. Então, o titular desse valor mobiliário, chamado de acionista, é sócio da sociedade.

Existem duas classificações importantes das ações na sociedade anônima. Uma leva em conta os direitos e as obrigações que essas ações conferem e, outra, leva em conta a forma de transferência dessas ações.



Quanto aos direitos e obrigações conferidos pelas ações, podem ser **ordinárias, preferenciais ou de fruição**.

Ação ordinária, como o próprio nome já diz, é a ação que confere direitos normais (direitos ordinários) aos seus titulares. Entre eles, sua grande característica, é o direito de voto: “Art. 110. A cada ação ordinária corresponde 1 (um) voto nas deliberações da assembléia-geral.”

Atente-se: O direito de voto não é um direito essencial do acionista. Nas S.A., os direitos essenciais estão previstos no artigo 109, *in verbis*:

Art. 109. Nem o estatuto social nem a assembléia-geral poderão privar o acionista dos direitos de:

- I - participar dos lucros sociais;
- II - participar do acervo da companhia, em caso de liquidação;
- III - fiscalizar, na forma prevista nesta Lei, a gestão dos negócios sociais;
- IV - preferência para a subscrição de ações, partes beneficiárias conversíveis em ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, observado o disposto nos artigos 171 e 172;
- V - retirar-se da sociedade nos casos previstos nesta Lei.

As ações ordinárias de companhia aberta não podem ser divididas em classes, por expressa vedação legal.

Ação preferencial confere uma preferência ou vantagem ao seu titular, essas preferências ou vantagens podem ser de natureza política ou econômica.

Art. 17. As preferências ou vantagens das ações preferenciais podem consistir:

- I - **em prioridade na distribuição de dividendo**, fixo ou mínimo;
- II - **em prioridade no reembolso do capital**, com prêmio ou sem ele; ou
- III - **na acumulação das preferências e vantagens de que tratam os incisos I e II**.

Exemplo de vantagem política conferida: “Art. 18. O estatuto pode assegurar a uma ou mais classes de ações preferenciais o direito de eleger, em votação em separado, um ou mais membros dos órgãos de administração.”

Há, também, a *golden share*, que é um tipo de ação preferencial, que foi previsto em uma das reformas da LSA:

Art. 17 (...) § 7º Nas companhias objeto de desestatização poderá ser criada ação preferencial de classe especial, de propriedade exclusiva do ente desestatizante, à qual o estatuto social poderá conferir os poderes que especificar, inclusive o poder de veto às deliberações da assembléia-geral nas matérias que especificar.

Normalmente essas preferências ou vantagens vêm acompanhadas de alguma contrapartida, geralmente no direito de voto. De acordo com o art. 111 da LSA:

“Art. 111. O estatuto poderá deixar de conferir às ações preferenciais algum ou alguns dos direitos reconhecidos às ações ordinárias, inclusive o de voto, ou conferi-lo com restrições, observado o disposto no artigo 109.”

Ação de fruição é ação menos conhecida, apenas confere direito de gozo, porque é emitida para substituir ação que foi amortizada, conforme art. 44 da LSA:

Art. 44 (...) § 5º. **As ações integralmente amortizadas poderão ser substituídas por ações de fruição**, com as restrições fixadas pelo estatuto ou pela assembléia-geral que deliberar a amortização; em qualquer caso, ocorrendo liquidação da companhia, as ações amortizadas só concorrerão ao acervo líquido depois de assegurado às ações não a amortizadas valor igual ao da amortização, corrigido monetariamente.



Quanto à forma de transferência, as ações podem ser **nominativas** ou **escriturais**.
Ação nominativa é aquela que só se transfere mediante termo em livro próprio.

Art. 20. (...) § 1º A transferência das ações nominativas opera-se por termo lavrado no livro de 'Transferência de Ações Nominativas', datado e assinado pelo cedente e pelo cessionário, ou seus legítimos representantes.

Ação escritural é aquela que é mantida em uma conta de depósito:

"Art. 34. O estatuto da companhia pode autorizar ou estabelecer que todas as ações da companhia, ou uma ou mais classes delas, sejam mantidas em contas de depósito, em nome de seus titulares, na instituição que designar, sem emissão de certificados".

Art. 35 (...) § 1º. A **transferência da ação escritural opera-se pelo lançamento efetuado pela instituição depositária em seus livros**, a débito da conta de ações do alienante e a crédito da conta de ações do adquirente, à vista de ordem escrita do alienante, ou de autorização ou ordem judicial, em documento hábil que ficará em poder da instituição.

Os estatutos da companhia fechada podem estabelecer limites à livre circulação das ações, apesar de se tratar de uma sociedade de capital. Todavia, tais limites não poderão impedir a sua negociação.

Exemplo de limitação será o direito de preferência dos demais acionistas, ou seja, antes de oferecer para quem for de fora da sociedade, deverá oferecer a ação para os acionistas.

Além das ações, a sociedade emite outros valores mobiliários. Esses valores, porém, ao contrário das ações, não representam o capital social. Por isso, não conferem aos seus titulares a condição de sócio da S.A.. Serão eventualmente credores ou partes interessadas da sociedade.

O único valor mobiliário que integra o capital social e, portanto, confere a condição de sócio é a ação.

Os três principais valores mobiliários, além das ações emitidas pelas S.A., são as **partes beneficiárias**, as **debêntures** e os **bônus de subscrição** (sendo os mais cobrados em prova – porque são tratados diretamente na Lei das S.A.), mas existem outros na Lei do Mercado de Capitais (Lei nº 6.385/1976).

b) Partes Beneficiárias

São títulos negociáveis sem valor nominal, estranhos ao capital social, conferindo aos titulares um direito de crédito eventual, consistente na participação nos lucros anuais (art. 46 da LSA)

Por que direito de crédito eventual?

Porque esse direito de crédito consiste na participação dos lucros anuais e pode ser que em um determinado exercício a sociedade não tenha obtido lucros.

Somente companhia fechada poderá emitir partes beneficiárias.

Dos lucros da companhia, não podem ser destinados mais de 10% às partes beneficiárias. Ademais, poderão ter cláusulas para conversão em ações.

A lei diz que as partes beneficiárias podem ser emitidas pelas S.A. não apenas para captação de recursos, mas também para remuneração da prestação de serviços, ou até mesmo para atribuição gratuita.



c) Debêntures

De acordo com o art. 52 da LSA: “Art. 52. A companhia poderá emitir **debêntures** que conferirão aos seus titulares direito de crédito contra ela, nas condições constantes da escritura de emissão e, se houver, do certificado”.

É um título representativo de um contrato de mútuo, de empréstimo. O titular da debênture tem um direito de crédito em face da companhia. A comunidade de interesse dos debenturistas poderá ser representada por um agente fiduciário (*indenture trustee*), que inclusive poderá ser uma instituição financeira. Sempre que as debêntures forem negociadas no mercado de valores mobiliários, esta nomeação de um agente fiduciário é obrigatória, e poderá ser instituição financeira.

Assim como as partes beneficiárias, as debêntures **poderão ter uma cláusula que permita a sua conversão em ações**.

Por outro lado, ao contrário das partes beneficiárias, não encerram um direito de crédito eventual, mas direito de crédito certo.

São títulos que a S.A. emite para se endividar. Promete o pagamento de um valor aos adquirentes e assim consegue obter recursos para se autofinanciar, por isso é comum encontrar nos manuais a explicação de que as debêntures representam, grosso modo, um contrato de empréstimo (mútuo) que a sociedade faz com os investidores.

A própria sociedade dirá em quanto tempo pagará o título, quais são os juros, se há garantia, e etc.

Quanto à garantia, existem quatro tipos de debêntures: Debêntures com garantia real, debêntures com garantia flutuante (lucros da sociedade), debênture quirografária (aquela que não tem garantia), e a debênture subordinada (aquela que em um eventual concurso de credores ficará abaixo até mesmo dos créditos quirografários).

A debênture é título executivo extrajudicial, portanto, não honrada no seu vencimento, conforme a própria companhia estabeleceu, poderá ser executada.

d) Bônus de Subscrição

Confere ao titular desse valor mobiliário o direito de subscrever ações, se houver aumento do capital social no futuro. Nos termos do art. 75 da LSA:

Art. 75. A companhia poderá emitir, dentro do limite de aumento de capital autorizado no estatuto* (artigo 168), títulos negociáveis denominados “Bônus de Subscrição”.

Parágrafo único. Os bônus de subscrição conferirão aos seus titulares, nas condições constantes do certificado, direito de subscrever ações do capital social, que será exercido mediante apresentação do título à companhia e pagamento do preço de emissão das ações.

*Companhia de capital autorizado é aquela que no próprio estatuto já tem autorização para aumento de capital futuro.

Compete à assembleia geral a deliberação sobre a emissão de bônus de subscrição, mas o estatuto pode atribuir tal competência ao conselho de administração. (art. 76 da LSA)

Vale frisar que os bônus de subscrição conferem “aos seus titulares, nas condições constantes do certificado, direito de subscrever ações do capital social, que será exercido mediante apresentação do título à companhia e pagamento do preço de emissão das ações” (art. 75, p.u., da LSA). Trata-se de um direito de preferência na subscrição de ações, tomando-o dos acionistas. Caso o acionista deseje manter sua preferência na subscrição das ações (prevista



no art. 109, IV, da LSA), deverá subscrever a emissão de bônus, para o que também possuem preferência (art. 77, p.u., da LSA).

6.7. Órgãos societários

Há quatro órgãos importantes da Sociedade Anônima que estão disciplinados na própria Lei nº 6.404/76:

- Assembleia-geral;
- Conselho de Administração;
- Diretoria;
- Conselho fiscal.

Dependendo do tamanho, da complexidade e da estrutura de uma S.A., poderá ter outros órgãos além desses, como superintendências, departamentos, gerências, seções, etc. Esses órgãos, porém, não estão na Lei das S.A., mas serão regidos pelo estatuto.

6.7.1. Assembleia-geral

Órgão máximo da S.A., que congrega todos os acionistas.

Questiona-se: quem não tem direito de voto, não participa da assembleia geral?

Errado, mesmo os acionistas que não possuem direito de voto podem participar da assembleia-geral e exercer o direito de voz, podendo se manifestar. Apenas não poderão votar nas matérias submetidas à análise de assembleia.

a) Competências

Art. 121. A assembléia-geral, convocada e instalada de acordo com a lei e o estatuto, tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto da companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento.

Parágrafo único. Nas companhias abertas, o acionista poderá participar e votar a distância em assembleia geral, nos termos da regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários.

A competência da assembleia-geral, como órgão máximo da S.A., é bastante ampla. Porém, na prática acaba sendo convocada apenas quando necessário tratar das matérias de sua competência privativa.

A convocação da assembleia-geral é complexa, pois gera custos, demanda um lugar adequado para sua realização, bem como avisos, publicações etc.

As matérias que não são de sua competência privativa acabam sendo decididas pelo Conselho de Administração (tratado mais adiante).

O parágrafo único desse artigo 121 foi acrescentado pelas reformas anteriormente mencionadas, tendo a intenção de aumentar o ativismo societário do investidor brasileiro, porque tradicionalmente não se tinha o costume de participar da vida da sociedade, ao contrário do que ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos.

Isto porque o mercado de capitais é algo que vem se desenvolvendo nos últimos anos no Brasil. Não somos um país que tem tradição neste mercado.

Art. 122. Compete privativamente à assembleia geral:

- I - reformar o estatuto social;
- II - eleger ou destituir, a qualquer tempo, os administradores e fiscais da companhia, ressalvado o disposto no inciso II do art. 142;
- III - tomar, anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras por eles apresentadas;



- IV - autorizar a emissão de debêntures, ressalvado o disposto nos §§ 1º, 2º e 4º do art. 59*;
- V - suspender o exercício dos direitos do acionista (art. 120);
- VI - deliberar sobre a avaliação de bens com que o acionista concorrer para a formação do capital social**;
- VII - autorizar a emissão de partes beneficiárias;
- VIII - deliberar sobre transformação, fusão, incorporação e cisão da companhia, sua dissolução e liquidação, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas; e
- IX - autorizar os administradores a confessar falência e pedir concordata.

*Em princípio, quem autoriza a emissão de debêntures é a assembleia, mas há possibilidades excepcionais de ser feito pelo conselho de administração.

**Na S.A., quando se integraliza ações com bens é necessário fazer um laudo de avaliação desses bens, e a assembleia-geral deve deliberar sobre o assunto, o que não acontece na sociedade limitada, por exemplo.

Em verdade, muitas vezes, a assembleia-geral, numa S.A., é feita apenas uma vez por ano, porque a lei estabelece esse mínimo, chamada de assembleia geral ordinária:

Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver 1 (uma) assembléia-geral para:

- I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras;
- II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
- III - eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o caso;
- IV - aprovar a correção da expressão monetária do capital social (artigo 167).

b) Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Art. 131. A assembléia-geral é ordinária quando tem por objeto as matérias previstas no artigo 132, e extraordinária nos demais casos.

Parágrafo único. A assembléia-geral ordinária e a assembleia-geral extraordinária poderão ser, cumulativamente, convocadas e realizadas no mesmo local, data e hora, instrumentadas em ata única.

c) Quórum de instalação

O **quórum de instalação** de uma assembleia geral é de **1/4 do capital votante**, numa **1ª convocação**. Todavia, sendo uma **2ª convocação**, **será instalada com qualquer número**.

Se a assembleia-geral tiver como **objetivo a reforma do estatuto social**, o quórum de instalação será de **2/3 do capital votante**, sendo hipótese de assembleia-geral **extraordinária**. A partir da 2ª convocação, será instalada a assembleia-geral independentemente do número de acionistas presentes.

d) Quórum de deliberação

As decisões da assembleia-geral serão tomadas, como regra, por **mais da metade do capital social, ou seja, das ações com direito a voto**.

Mais da metade das ações presentes na assembleia é que será o quórum de deliberação.



6.7.2. Conselho de administração

A administração da S.A. é dividida entre dois órgãos, adota-se um sistema dual. Há o **Conselho de Administração**, que é um órgão colegiado deliberativo, que tem como função principal fixar as diretrizes negociais, e a **Diretoria**, formada pelos diretores, que na prática é o órgão que exerce efetivamente a administração da sociedade, representando legalmente a S.A. Vide o art. 138 da LSA:

Art. 138. A administração da companhia competirá, conforme dispuser o estatuto, ao conselho de administração e à diretoria, ou somente à diretoria.

§ 1º O conselho de administração é órgão de deliberação colegiada, sendo a representação da companhia privativa dos diretores.

§ 2º As companhias abertas e as de capital autorizado terão, obrigatoriamente, conselho de administração.

O conselho de administração, portanto, tem **caráter deliberativo**, não sendo um órgão executivo. Por conta desse caráter deliberativo, terá **parcela da competência** da assembleia-geral.

É um **órgão obrigatório** nas:

- **sociedades anônimas abertas;**
- **sociedade de capital autorizado;**
- **sociedade de economia mista.**

Assim, nas companhias fechadas, por exemplo, não é obrigatório ter Conselho de Administração.

É possível encontrar em manuais a denominação “mini assembleia”, pois o Conselho Administrativo tem por finalidade precípua dinamizar a tomada de decisões em uma companhia.

“Art. 139. As atribuições e poderes conferidos por lei aos órgãos de administração não podem ser outorgados a outro órgão, criado por lei ou pelo estatuto”.

“Art. 145. As normas relativas a requisitos, impedimentos, investidura, remuneração, deveres e responsabilidade dos administradores aplicam-se a conselheiros e diretores”.

Quando se fala em “administradores da Sociedade Anônima”, refere-se, indistintamente, tanto aos conselheiros de administração quanto aos diretores.

“Art. 146. Poderão ser eleitas para membros dos órgãos de administração pessoas naturais, devendo os diretores ser residentes no País”.

IMPORTANTE: até alguns anos atrás, exigia-se que os membros do Conselho de Administração fossem acionistas (os Diretores poderiam ser não-sócios/ não-acionistas), mas em uma das alterações recentes, retirou-se tal exigência

O conselho de administração será composto por no **mínimo 3 pessoas**, exercendo um **mandato não superior a 3 anos**. A assembleia-geral elegerá o conselho de administração, o qual deliberará sobre atuação da companhia. Será também a assembleia-geral que poderá destituir os membros do conselho de administração, a qualquer momento.

Membro do conselho de administração de S.A. pode ter residência fora do país. Nesse caso, a posse do conselheiro **fica condicionada à constituição de representante residente no País**, com poderes para receber citação em ações contra ele propostas com base na legislação societária, mediante **procuração com prazo de validade de, no mínimo, 3 anos, após o término do prazo de gestão do conselheiro**.

6.7.3. Diretoria

É o órgão de representação legal da companhia, executando as deliberações da assembleia e do conselho de administração.



A composição da diretoria **não poderá ser inferior a 2 membros**. A duração do **mandato não poderá ser superior a 3 anos**, podendo ser reconduzido quantas vezes quiserem.

Se houver conselho de administração, **os diretores serão eleitos pelo conselho de administração**. Não havendo conselho, serão eleitos pela assembleia-geral.

Até **1/3 dos membros do conselho de administração pode integrar também a Diretoria**.

Se **não existir previsão estatutária**, e não houver deliberação sobre o Conselho de Administração, a **representação legal da companhia pode ser feita por qualquer dos diretores**.

6.7.4. Conselho fiscal

O conselho fiscal possui **existência estatutária obrigatória**, mas seu efetivo **funcionamento é facultativo, a depender do que estiver previsto no Estatuto Social**.

Será composto, **no mínimo, por 3 membros**, e, **no máximo, por 5 membros**.

Não poderão compor o conselho fiscal:

- quem fizer parte da administração: não poderá se autofiscalizar;
- empregado da companhia;
- cônjuge, familiar, parente até 3º grau dos administradores;

O conselho fiscal deverá ter imparcialidade.

Ademais, **somente podem ser eleitos pessoas naturais, com residência no País**, diplomadas em curso de nível universitário, ou que tenham exercido por prazo mínimo de 3 anos cargo de administrador de empresa ou de conselheiro fiscal.

Os **titulares de ações preferenciais sem direito a voto** podem eleger em separado 1 membro do conselho fiscal, assim como os **acionistas minoritários que possuam até 10% do capital votante**.

6.8. Deveres dos administradores

6.8.1. Dever de diligência

“Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência* que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios”.

*Atuar de acordo com os padrões de gestão da ciência da administração de empresas.

É um dispositivo muito vago, pois caberia uma grande dissertação acerca do conceito de “homem ativo e probo” para o Direito Empresarial. Existe uma pequena contradição entre se exigir que o administrador leve sucesso à companhia e ao mesmo tempo seja cuidadoso demais, pois o empreendedorismo relaciona-se diretamente com a ousadia.

O dever de diligência é uma obrigação de meio e não de resultado, podendo-se, eventualmente, administrar a sociedade em um período que terá prejuízos, e mesmo assim não ter violado o dever de diligência.

Nos Estados Unidos essa questão é muito debatida, desenvolvendo-se a doutrina **business judgement rule**, que tenta estabelecer critérios minimamente objetivos, a fim de permitir uma análise de quando há ou não violação do dever de diligência, devendo-se verificar se a atuação foi (i) independente, (ii) desinteressada, (iii) informada e (iv) no interesse da companhia.

6.8.2. Dever de lealdade

Art. 155. O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os seus negócios, sendo-lhe vedado:



I - usar, em benefício próprio ou de outrem, com ou sem prejuízo para a companhia, as oportunidades comerciais de que tenha conhecimento em razão do exercício de seu cargo;

II - omitir-se no exercício ou proteção de direitos da companhia ou, visando à obtenção de vantagens, para si ou para outrem, deixar de aproveitar oportunidades de negócio de interesse da companhia;

III - adquirir, para revender com lucro, bem ou direito que sabe necessário à companhia, ou que esta tencione adquirir.

§ 1º Cumpre, ademais, ao administrador de companhia aberta, guardar sigilo sobre qualquer informação que ainda não tenha sido divulgada para conhecimento do mercado, obtida em razão do cargo e capaz de influir de modo ponderável na cotação de valores mobiliários, sendo-lhe vedado valer-se da informação para obter, para si ou para outrem, vantagem mediante compra ou venda de valores mobiliários.

§ 2º O administrador deve zelar para que a violação do disposto no § 1º não possa ocorrer através de subordinados ou terceiros de sua confiança.

§ 3º A pessoa prejudicada em compra e venda de valores mobiliários, contratada com infração do disposto nos §§ 1º e 2º, tem direito de haver do infrator indenização por perdas e danos, a menos que ao contratar já conhecesse a informação.

§ 4º É vedada a utilização de informação relevante ainda não divulgada, por qualquer pessoa que a ela tenha tido acesso, com a finalidade de auferir vantagem, para si ou para outrem, no mercado de valores mobiliários.

O mais importante é o que está nos parágrafos, principalmente no § 4º.

Todas essas questões descritas nos parágrafos se referem ao ***insider trading***, que, no Brasil, assim como em muitos outros ordenamentos, é considerado crime. Essa prática tem sido muito combatida, tanto pelo órgão regulador (CVM) quanto pelas autoridades competentes (Polícia e Ministério Público). No caso brasileiro, a tipificação penal encontra-se no art. 27-D da Lei nº 6.385/1976:

Art. 27-D. Utilizar informação relevante ainda não divulgada ao mercado, de que tenha conhecimento e da qual deva manter sigilo, capaz de propiciar, para si ou para outrem, vantagem indevida, mediante negociação, em nome próprio ou de terceiro, com valores mobiliários:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa de até 3 (três) vezes o montante da vantagem ilícita obtida em decorrência do crime.

Em fevereiro de 2011, a CVM e o Ministério Público Federal conseguiram no Judiciário a primeira condenação penal por ***insider trading*** no Brasil, em caso referente à Oferta Pública de Aquisição (OPA) da Perdigão feita pela Sadia em 2006.

6.8.3. Dever de informação

Art. 157. O administrador de companhia aberta deve declarar, ao firmar o termo de posse, o número de ações, bônus de subscrição, opções de compra de ações e debêntures conversíveis em ações, de emissão da companhia e de sociedades controladas ou do mesmo grupo, de que seja titular.

(...)

§ 4º Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à bolsa de valores e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da assembléia-geral ou dos órgãos de administração da companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia.

Trata-se de *disclosure*.



IMPORTANTE: a questão do *disclosure* é tão importante quando se trata de sociedade aberta que a CVM baixou uma norma há alguns anos obrigando as companhias abertas a divulgarem a média salarial dos seus administradores. Uma associação que congrega administradores de companhias abertas entrou com uma ação na justiça alegando que isso violaria os direitos de intimidade e privacidade, podendo colocá-los em risco em razão da violência, já que seus ganhos estariam divulgados. A princípio, a associação conseguiu uma liminar suspendendo a eficácia dessa norma da CVM, mas o TRF2 (RJ) julgou e considerou legítima/legal a decisão da CVM.

6.9. Responsabilidade dos administradores

Art. 158. O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão; responde, porém, civilmente, pelos prejuízos que causar, quando proceder:

- I - dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo;
- II - com violação da lei ou do estatuto.

Se o administrador praticou um ato regular de gestão é óbvio que ele não é pessoalmente responsável por essas obrigações, mas sim a sociedade. Porém, se agiu dentro de suas atribuições, mas com culpa ou dolo, ou se agiu fora de suas atribuições, isto é, violando a lei ou o estatuto, a sociedade responde perante terceiros, mas pode cobrar dos administradores os prejuízos que eventualmente sofreu em virtude de tais atos. Em outras palavras, a lei das S.A. adota a **teoria da aparência**, sem margem para a **teoria *ultra vires***, admitida pelo Código Civil e estudada acima (art. 1.015, parágrafo único, Código Civil).

Quando for caso de se cobrar dos administradores prejuízos que a sociedade anônima sofreu em virtude de atos por eles praticados com culpa ou dolo, ou, com a violação da lei ou estatuto, como se procederá?

Art. 159. Compete à companhia, mediante prévia deliberação da assembléia-geral, a ação de responsabilidade civil contra o administrador, pelos prejuízos causados ao seu patrimônio.

§ 1º A deliberação poderá ser tomada em assembléia-geral ordinária e, se prevista na ordem do dia, ou for consequência direta de assunto nela incluído, em assembléia-geral extraordinária.

§ 2º O administrador ou administradores contra os quais deva ser proposta ação ficarão impedidos e deverão ser substituídos na mesma assembléia.

§ 3º Qualquer acionista poderá promover a ação, se não for proposta no prazo de 3 (três) meses da deliberação da assembléia-geral.

§ 4º Se a assembléia deliberar não promover a ação, poderá ela ser proposta por acionistas que representem 5% (cinco por cento), pelo menos, do capital social.

§ 5º Os resultados da ação promovida por acionista deferem-se à companhia, mas esta deverá indenizá-lo, até o limite daqueles resultados, de todas as despesas em que tiver incorrido, inclusive correção monetária e juros dos dispêndios realizados.

§ 6º O juiz poderá reconhecer a exclusão da responsabilidade do administrador, se convencido de que este agiu de boa-fé e visando ao interesse da companhia.

§ 7º A ação prevista neste artigo não exclui a que couber ao acionista ou terceiro diretamente prejudicado por ato de administrador.

O art. 159 da Lei nº 6.404/76 é muito explorado em concursos em geral, já tendo sido cobrado em diversas provas. Vale a pena memorizar seus parágrafos e tomar cuidado contra eventuais pegadas clássicas de prova, como mesclar a hipótese do § 3º com a do § 4º.

Caso tenha havido a deliberação favorável ao ajuizamento da ação social de responsabilização do administrador pela assembleia, mas os administradores retardarem o ajuizamento da ação **por mais de 3 meses, qualquer acionista poderá propor esta ação**, em



nome da companhia. Isto significa dizer que ele próprio atuará em nome próprio, defendendo direito alheio. É um caso de **substituição processual, na modalidade derivada**, pois só nasceu em razão do retardamento da companhia.

Caso a assembleia não decida promover a responsabilização, **os acionistas que detenham ações que representem 5% ou mais do capital social poderão propor ação judicial** em nome próprio para proteção do direito alheio (da sociedade). Haverá uma **substituição processual originária**, pois independe da inércia.

O prazo prescricional dessa ação será de 3 anos, a contar da data da assembleia geral que realizou o balanço relativo àquele exercício, em que o ilícito foi praticado pelo administrador. Esse é o termo *a quo*. Há uma exceção na lei estabelecendo que esse prazo de 3 anos **vai ser contado da prescrição da ação penal, ou da sentença definitiva transitada em julgado**, caso o ilícito do administrador **for também um ilícito penal**.

Verdadeira aula sobre o tema é o resumo de precedente veiculado no informativo 563 do STJ:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA PARA AÇÃO SOCIAL. Acionistas e companhia podem litigar em litisconsórcio facultativo ativo em ação de responsabilidade civil contra o administrador pelos prejuízos causados ao patrimônio da sociedade anônima (art. 159 da Lei 6.404/1976), quando não proposta a ação pela companhia no prazo de três meses após a deliberação da assembleia-geral (§ 3º). Da análise do art. 159 da Lei 6.404/1976, constata-se que a denominada ação social, assim compreendida como aquela voltada a reparar danos causados à própria sociedade anônima pela atuação ilícita de seus administradores, pode ser promovida: i) pela própria companhia (ação social ut universi), desde que devidamente autorizada por sua assembleia geral; e ii) por qualquer acionista, caso a demanda não seja intentada pela companhia nos três meses seguintes à deliberação assemblear, ou por acionistas que representem ao menos 5% (cinco por cento) do capital social, na hipótese em que a assembleia geral tenha deliberado por não acionar os administradores (em ambos os casos, tem-se a denominada ação social ut singuli). Na ação social ut singuli, o acionista que a promove o faz em nome próprio, na defesa dos direitos e interesses da companhia. Está-se, pois, diante de uma legitimação extraordinária. Aliás, o § 5º do artigo sob exame, de modo a explicitar tal circunstância, deixa claro que o resultado obtido com a demanda é deferido à sociedade, e não ao acionista promovente. Preceitua o dispositivo legal, ainda, que o acionista demandante será indenizado por todas as despesas que suportar com o processo, nos limites do resultado. Por consectário, caso o resultado da demanda seja negativo, o autor responde pessoalmente pelas despesas processuais. Além disso, o preceito legal ainda dispõe em seu § 7º sobre a possibilidade de qualquer acionista ou terceiro promover ação destinada a reparar prejuízo próprio (e não da sociedade anônima, ressalta-se), ocasionado por ato de administrador. É a denominada ação individual, que, ante a diversidade de objetos, não se confunde com a ação social acima discriminada. De outro lado, é de se constatar que, durante os três meses contados da deliberação da assembleia geral que autoriza a companhia a promover a ação contra o administrador, somente a própria sociedade, com exclusão de qualquer outro acionista, pode assim proceder. No curso de tal interregno, portanto, a lei confere legitimidade exclusiva à sociedade anônima para promover a ação social. Após o término do aludido termo, o regramento legal expressamente admite que qualquer acionista promova a ação social, caso a companhia não o tenha feito naquele período. Veja-se, portanto, que, em tal circunstância – após o término dos três meses contados da deliberação assemblear – possuem legitimidade ativa ad causam tanto a companhia, como qualquer acionista para promover a ação social. Está-se, pois, nesse caso, diante de legitimidade concorrente – que se dá tanto na seara ordinária, como na extraordinária –, a considerar que ambos, tanto a companhia, como qualquer acionista, estão, por lei, autorizados a discutir em juízo a presente situação jurídica



(consistente na reparação de danos sofridos pela companhia por ato de administrador). Como é de sabença, na legitimidade concorrente simples ou isolada, qualquer dos legitimados pode atuar sozinho no feito. Naturalmente, em se tratando de legitimidade extraordinária, caso o titular do direito (a companhia) promova a ação isoladamente, o posterior ajuizamento de ação pelo substituto processual (qualquer acionista) consubstanciará, inequivocamente, caso de litispendência. Veja-se, que, nessa hipótese, a ação posterior deve ser extinta em virtude da existência de ação anterior idêntica, e não porque, ao substituto processual, falta legitimidade. De se destacar, ainda, que, efetivamente, não há qualquer óbice legal para a formação de um litisconsórcio ativo facultativo integrado por sujeitos de direito que, repisa-se, simultaneamente ostentam legitimidade (concorrente) para, em juízo, defender os interesses da companhia. Pode-se antever, como inarredável consequência de tal proceder, no máximo, que os autores da ação, caso não logrem êxito em seu intento, venham a arcar, cada qual, com as despesas processuais decorrentes da sucumbência em partes iguais. De todo modo, havendo expressa previsão legal a conferir legitimidade aos acionistas para ajuizarem ação social, após três meses da deliberação da assembleia, possível, inclusive, a formação de litisconsórcio facultativo ativo entre a companhia e aqueles. REsp 1.515.710-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 12/5/2015, DJe 2/6/2015 (Informativo 563).

Cuidado também com o § 7º: existem duas ações de responsabilidade distintas, a **ação social de responsabilidade**, que visa a reparar prejuízos causados à companhia, podendo ser proposta pela própria companhia, por um acionista ou por grupo de acionistas, conforme o caso, sendo ação revertida em favor da sociedade, e a **ação individual de responsabilidade**, na qual um acionista específico, entendendo ter sofrido prejuízo em virtude de atos errados de gestão, praticados por um administrador, entra com ação de responsabilidade, pedindo reparação de danos a si próprio.

Em 2019, o STJ revisitou o tema e pronunciou-se afirmando que a comprovação da deliberação por parte da Assembléia Geral, conforme determina o art. 159, poderá ser comprovada posteriormente ao ajuizamento da ação.

STJ - A ação social reparatória (*ut universi*) ajuizada pela sociedade empresária contra ex-administradores, na forma do art. 159 da Lei n. 6.404/1976, depende de autorização da assembleia geral ordinária ou extraordinária, que poderá ser comprovada após o ajuizamento da ação (REsp 1.778.629-RS, julgado em 06/08/2019, DJe 14/08/2019).

No caso em questão, a autorização assemblear para o ajuizamento da ação social contra o ex-administrador apenas foi obtida após o ajuizamento da ação. Entendeu o STJ que, por se tratar de fato atinente à capacidade de estar em juízo (capacidade processual), é possível que o vício seja sanado, nos termos do art. 76 do CPC.

6.10. Acionista controlador

As S.A. são sociedades complexas, em que, muitas vezes, não são os proprietários que dirigem os negócios sociais, por isso, diz-se que, nessas organizações, o que existe são, em verdade, **controladores**. Esses geralmente possuem uma pequena quantidade de ações, não podendo ser considerados “donos” da S.A., ou, excepcionalmente, podem ser um grupo não de acionistas, mas de administradores que conseguem se manter no poder e dirigir a sociedade. Em razão dessa questão é que o poder de controle das S.A. é tão estudado.

Existem autores que comparam as sociedades anônimas mais complexas com o próprio Estado, mostrando como a estrutura político-administrativa da sociedade se parece com a estrutura político-administrativa do Estado.



É importante verificar quem realmente detém o controle da sociedade, até para que se possam impor certos deveres e responsabilidades.

Art. 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou jurídica, ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto, ou sob controle comum, que:

- a) é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da assembléia-geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia; e
- b) usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia.

Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender.

São requisitos cumulativos. O primeiro é objetivo, e o segundo é subjetivo.

A lei não apenas orienta ação do acionista controlador, mas também impõe responsabilidade para os controladores que abusam de seu poder, o que não deve ser confundido com ação de responsabilidade, pois nesse caso há abuso do poder de controle,

Art. 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder.

§ 1º São modalidades de exercício abusivo de poder:

- a) **orientar a companhia para fim estranho ao objeto social ou lesivo ao interesse nacional**, ou levá-la a favorecer outra sociedade, brasileira ou estrangeira, em prejuízo da participação dos acionistas minoritários nos lucros ou no acervo da companhia, ou da economia nacional;
- b) promover a liquidação de companhia próspera, ou a transformação, incorporação, fusão ou cisão da companhia, com o fim de obter, para si ou para outrem, vantagem indevida, em prejuízo dos demais acionistas, dos que trabalham na empresa ou dos investidores em valores mobiliários emitidos pela companhia;
- c) **promover alteração estatutária, emissão de valores mobiliários ou adoção de políticas ou decisões que não tenham por fim o interesse da companhia e visem a causar prejuízo a acionistas minoritários, aos que trabalham na empresa ou aos investidores em valores mobiliários emitidos pela companhia;**
- d) **eleger administrador ou fiscal que sabe inapto, moral ou tecnicamente;**
- e) **induzir, ou tentar induzir, administrador ou fiscal a praticar ato ilegal**, ou, descumprindo seus deveres definidos nesta Lei e no estatuto, promover, contra o interesse da companhia, sua ratificação pela assembléia-geral;
- f) contratar com a companhia, diretamente ou através de outrem, ou de sociedade na qual tenha interesse, em condições de favorecimento ou não equitativas;
- g) **aprovar ou fazer aprovar contas irregulares de administradores, por favorecimento pessoal, ou deixar de apurar denúncia que saiba ou devesse saber procedente, ou que justifique fundada suspeita de irregularidade.**
- h) subscrever ações, para os fins do disposto no art. 170, com a realização em bens estranhos ao objeto social da companhia.

§ 2º No caso da alínea e do § 1º, o administrador ou fiscal que praticar o ato ilegal responde solidariamente com o acionista controlador.

§ 3º O acionista controlador que exerce cargo de administrador ou fiscal tem também os deveres e responsabilidades próprios do cargo”.

IMPORTANTE: o rol previsto no art. 117, § 1º, da LSA é **meramente exemplificativo**. No mesmo julgado, entendeu o STJ que a caracterização do abuso de poder independe da intenção subjetiva do controlador, mas é imprescindível a ocorrência de dano (REsp 798.264/SP).

Esse assunto foi recentemente cobrado em prova.



6.11. Acionista minoritário

Como forma de proteger o acionista minoritário, a LSA não apenas define regras que impõem deveres e responsabilidades ao acionista controlador, conforme destacamos acima, mas também disciplina a alienação do poder de controle da companhia.

Pelo estudo da LSA, percebe-se que existe preocupação do legislador em regular a alienação de controle, pois o acionista controlador pode vender o controle da companhia, e essas operações são de interesse relevante dos minoritários.

Uma das regras mais importante da LSA sobre o tema é a prevista no **art. 254-A, que trata do chamado *tag along*, também conhecido como direito de venda conjunta:**

Art. 254-A. A alienação, direta ou indireta, do controle de companhia aberta somente poderá ser contratada sob a condição, suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente se obrigue a fazer oferta pública de aquisição das ações com direito a voto de propriedade dos demais acionistas da companhia, de modo a lhes assegurar o preço no mínimo igual a 80% (oitenta por cento) do valor pago por ação com direito a voto, integrante do bloco de controle.

Essa é uma das regras colocadas em ocasião das reformas dessa lei. Quando a primeira reforma foi feita (1997), o *tag along* foi retirado, devolvendo-se o instituto modificado em outra ocasião (tornando-se um *tag along* “meia boca”), pois é só para acionista com direito de voto, não tendo o mesmo direito o acionista preferencial, e, ainda, não assegura paridade, uma vez que há necessidade de apenas 80% de pagamento.

Na prática, muitos autores dizem que este *tag along* não é utilizado, porque hoje em dia as empresas abertas devem seguir códigos de governança corporativa muito rígidos, que elas mesmas criam como forma de se mostrar ao mercado como boa empresa para investimento. Assim, nesses códigos, não raro, asseguram-se *tag along* melhor que o previsto na lei.

Por fim, *tag along* é um direito do acionista minoritário, mas este não é obrigado a vender. Quem está comprando é que é obrigado a fazer a oferta.

6.12. Acordo de acionistas

Por vezes o controle das S.A. é adquirido por meio de uma série de acordos feitos entre os acionistas da sociedade, que também são objeto de disciplina específica na LSA:

Art. 118. Os acordos de acionistas, sobre a compra e venda de suas ações, preferência para adquiri-las, exercício do direito a voto, ou do poder de controle deverão ser observados pela companhia quando arquivados na sua sede.

§ 1º As obrigações ou ônus decorrentes desses acordos somente serão oponíveis a terceiros, depois de averbados nos livros de registro e nos certificados das ações, se emitidos.

§ 2º Esses acordos não poderão ser invocados para eximir o acionista de responsabilidade no exercício do direito de voto (artigo 115) ou do poder de controle (artigos 116 e 117).

§ 3º Nas condições previstas no acordo, os acionistas podem promover a execução específica das obrigações assumidas.

§ 4º As ações averbadas nos termos deste artigo não poderão ser negociadas em bolsa ou no mercado de balcão.

§ 5º No relatório anual, os órgãos da administração da companhia aberta informarão à assembléia-geral as disposições sobre política de reinvestimento de lucros e distribuição de dividendos, constantes de acordos de acionistas arquivados na companhia.

§ 6º O acordo de acionistas cujo prazo for fixado em função de termo ou condição resolutiva somente pode ser denunciado segundo suas estipulações.



§ 7º O mandato outorgado nos termos de acordo de acionistas para proferir, em assembléia-geral ou especial, voto contra ou a favor de determinada deliberação, poderá prever prazo superior ao constante do § 1º do art. 126 desta Lei.

§ 8º **O presidente da assembléia ou do órgão colegiado de deliberação da companhia não computará o voto proferido com infração de acordo de acionistas devidamente arquivado.**

§ 9º O não comparecimento à assembléia ou às reuniões dos órgãos de administração da companhia, bem como as abstenções de voto de qualquer parte de acordo de acionistas ou de membros do conselho de administração eleitos nos termos de acordo de acionistas, assegura à parte prejudicada o direito de votar com as ações pertencentes ao acionista ausente ou omissor e, no caso de membro do conselho de administração, pelo conselheiro eleito com os votos da parte prejudicada.

§ 10. Os acionistas vinculados a acordo de acionistas deverão indicar, no ato de arquivamento, representante para comunicar-se com a companhia, para prestar ou receber informações, quando solicitadas.

§ 11. A companhia poderá solicitar aos membros do acordo esclarecimento sobre suas cláusulas.

São divididos em (i) acordos de voto, (ii) acordos de controle, e (iii) acordos de bloqueio.

Nos **acordos de voto**, os signatários assumem a obrigação de exercer o seu direito de voto nos termos que acordaram, formando um bloco para atuação conjunta. Exemplo: acordos que estabelecem a necessidade de reunião prévia a qualquer deliberação, a fim de combinar o exercício do direito de voto em bloco (*pooling agreements*).

Nos **acordos de bloqueio**, impõem-se condições para a negociação das ações ou para o exercício do direito de preferência. Exemplo: acionistas signatários ficam impedidos de negociar suas ações por certo tempo (*lock up*).

Em determinados temas, caso esse acordo de acionistas esteja arquivado na sede da companhia, a sociedade deverá observá-los obrigatoriamente.

Serão três temas:

- exercício do poder de controle ou do direito de voto;
- compra e venda de ações;
- preferência para aquisição dessas ações.

Esse arquivamento inviabiliza a possibilidade de, na hora da votação, um dos acionistas mudar o voto.

O acordo de acionistas poderá existir em relação ao **voto-vontade**.

O **voto-verdade** é aquele em que não pode haver acordo, tal como ocorre nos casos de votar o laudo de avaliação dos bens e nos casos de tomada de contas. **O voto-verdade não pode ser objeto de acordo de acionistas.**

6.13. Controle

Em virtude de toda a complexidade que a S.A. possui é necessário distinguir os tipos de controle existentes. Conforme leciona André Santa Cruz:

O **controle totalitário** se dá normalmente nas companhias fechadas familiares e na sociedade subsidiária integral (...), ou seja, nas companhias em que todos os acionistas possuem direito de voto, sendo que todas as ações são de titularidade de uma única pessoa ou grupo de pessoas. Nesses casos, percebe-se um altíssimo grau de confiança e colaboração entre os acionistas, tal como ocorre nas sociedades contratuais *intuitu personae*. (...)

O **controle majoritário** se dá nas sociedades em que o poder de controle é exercido pelo acionista que detém a maioria das ações com direito de voto. Trata-se de



modalidade de controle muito comum no universo das companhias brasileiras: o acionista que detém o maior número de ações com direito a voto usa efetivamente esse direito para controlar a companhia, assumindo a posição de acionista controlador, nos termos do art. 116 da LSA.

(...)

O **controle minoritário**, por outro lado, dá-se quando a sociedade anônima tem capital social pulverizado [Sociedade com muitos acionistas, na qual nenhum deles tem participação muito elevada], o que permite que um acionista minoritário, ou seja, que possui poucas ações com direito de voto, assuma o poder de controle da companhia. Isso é possível sobretudo em razão do *quorum* de instalação da assembleia-geral previsto no art. 125 da LSA, que permite a instalação da assembleia, em segunda convocação, com a presença de qualquer número de acionistas com direito de voto.

Por fim, **controle gerencial** se dá quando há uma grande dispersão acionária [Sociedade com muitos acionistas, na qual nenhum deles tem qualquer participação relevante], ou seja, quando o capital social é de tal forma disperso e pulverizado que os verdadeiros controladores da sociedade anônima são os administradores, assumindo os acionistas a posição de meros investidores. Trata-se de modalidade de poder de controle presente nas grandes companhias de capital aberto, em que o universo de acionistas é vastíssimo. Nessas sociedades, a adoção de boas práticas de governança corporativa é imprescindível para permitir a segurança dos investidores.

O acionista, ou grupo de acionistas, que sejam titulares da maioria dos votos da assembleia geral, caso utilizem este direito, serão considerado **acionista controlador**.

Não basta ter a maior parte do capital votante na assembleia geral, pois será necessário exercer o direito de controlar a sociedade.

O **acionista controlador responde pelas suas decisões que causarem dano à companhia, por abuso de poder**. Ex.: elege um administrador inapto moralmente e tecnicamente, de forma que promova desvios para prejudicar a companhia.

As ações que dão esta sustentação ao poder de controle acabam tendo um valor maior do que as outras ações.

A diferença entre uma ação comum e uma ação que dá o controle da companhia é denominado de **prêmio de controle**. Para evitar uma distorção muito grande entre as ações que não conferem o prêmio de controle e as que conferem esse controle, **os acionistas minoritários devem condicionar o ingresso na sociedade à uma cláusula de saída conjunta**.

Essa cláusula deverá **constar do estatuto ou no acordo de acionistas (tag along) e, quando prevista, o controlador não poderá vender as suas ações isoladamente**. Em tal caso, somente poderá haver a venda das ações controladoras se houver o compromisso de o adquirente comprar as ações beneficiárias da cláusula de saída conjunta. **Nas companhias abertas, a cláusula de saída conjunta é inclusive prevista em lei**, em favor dos acionistas que têm direito a voto, e não em relação aos que não têm.

A alienação das ações que vão conferir o poder de controle só pode ser feita se o adquirente comprar também as demais ações com direito a voto, pagando por estas ações, pelo menos, 80% do valor que ele está pagando pelas ações do acionista controlador. A diferença entre as ações, portanto, não poderá ser inferior a 20%.

6.14. Governança corporativa

Expressão que se cunhou para designar um conjunto de práticas de gestão das S.A., especialmente sociedades de capital aberto, que visam a dar longevidade, mais transparência, proteção aos sócios minoritários etc.

Trata-se, basicamente, de um movimento que visa a estabelecer padrões de gestão para os negócios explorados em sociedade, centrados, fundamentalmente, nos



seguintes princípios: (i) transparência (não se deve apenas cumprir o dever de informação previsto em lei, mas disponibilizar às partes interessadas toda e qualquer informação do seu interesse), (ii) equidade no tratamento entre os acionistas (criação de regras mais protetivas para os minoritários e mais eficientes na prevenção do abuso por parte dos controladores), (iii) prestação de contas confiável (*accountability*; a prestação de contas deve seguir critérios de contabilidade seguros, eficientes e internacionalmente aceitos), e (iv) responsabilidade corporativa (os administradores/controladores devem zelar pela sustentabilidade das empresas que administram/controlam, visando à longevidade delas e incorporando em suas gestões preocupações de ordem social e ambiental, por exemplo). (CRUZ, 2019)

Conforme leciona André Santa Cruz (2019), a governança corporativa é importante porque nas grandes companhias, principalmente naquelas com capital social disperso entre vários acionistas, a gestão dos negócios não cabe aos seus “donos” (proprietários da maioria das ações), mas aos “gerentes” (acionistas minoritários ou pessoas estranhas ao quadro social que, por sua competência/eficiência, conseguem se eleger nas assembleias anuais), verificando-se, assim, uma separação entre propriedade e controle da sociedade, que acarreta o conflito de agência e o problema o agente principal: os administradores acabam tomando decisões pensando mais no seu benefício próprio (aumento de salários e de bônus, estabilidade no comando da empresa etc.) do que no benefício dos acionistas e demais partes interessadas (*stakeholders*).

Como forma de proteger o acionista minoritário, a LSA não apenas define regras que impõem deveres e responsabilidades ao acionista controlador, conforme destacamos acima, mas também disciplina a alienação do poder de controle da companhia.

6.15. Capital social da sociedade anônima

O capital social poderá ser integralizado **em dinheiro, em bens ou em crédito**.

Para integralizar em bens, é preciso avaliar os bens, tarefa realizada por **três peritos ou por uma empresa especializada em avaliar estes bens**.

Posteriormente, é emitido um laudo, o qual será objeto de votação pela companhia, e que após considera-se que houve a integralização do capital social.

O capital social **poderá ainda ser aumentado**. Este aumento poderá decorrer de:

- **emissão de novas ações:** neste caso, há ingresso de novos recursos.
- **valores mobiliários diversos:** por meio da conversão de debêntures ou partes beneficiárias em ações, e pelo exercício do direito de subscrição dos bônus de subscrição, situação em que aumentará o capital social.
- **capitalização de lucros ou reservas:** se há lucro, ao invés de distribuir, poderá haver a capitalização. Não haverá ingresso de novos recursos, porém há o aumento do capital social.

O estatuto da companhia poderá prever a possibilidade de aumento do capital social, dentro de certo limite. Não haverá a necessidade de alteração do capital social, visto que dentro do estatuto já há esta possibilidade de aumento do capital social.

Essa medida que prevê a necessidade de aumento do capital social, sendo denominado de capital autorizado, tem por objetivo agilizar o processo de decisão do capital social, e mesmo de emissão de novas ações para o aumento do capital. Esse limite de aumento é denominado de **capital autorizado**.

Por fim, o **capital social poderá ser reduzido quando:**

- **perceber que houve excesso do capital social;**



- **capital social se mostrar irreal:** ou seja, houve um prejuízo enorme da companhia, sendo certo que o capital social não existe mais, justificando a redução do capital social.

6.16. Acionista

O acionista tem como papel principal pagar o preço da emissão da ação.

A companhia poderá promover contra o acionista remissão a cobrança do valor, por meio de ação de execução, visto que **o título é o próprio boletim da subscrição.**

A companhia **poderá vender estas ações subscritas em bolsa.** Caso tenha um fundo de reserva, a própria companhia poderá integralizar estas ações, ao invés de vendê-las.

Não tendo reservas, e não tendo encontrado compradores para aquelas ações, a **companhia terá o prazo de 1 ano para encontrar o comprador, pois, do contrário, será preciso reduzir o capital social.**

Os **direitos essenciais** do acionista são:

- **participação dos resultados sociais:** é vedada a cláusula leonina.
- **fiscalização da gestão dos negócios sociais;**
- **direito de preferência na subscrição de ações e valores mobiliários conversíveis em ação;**
- **direito de retirada:** neste caso, receberá o valor patrimonial da ação. A lei faculta que o estatuto assegure o valor econômico da ação, e não patrimonial.

Atente-se que **o direito de voto não é direito essencial!**

A lei proíbe o voto abusivo e o voto conflitante:

- **voto abusivo:** é o voto dado pelo acionista com a intenção de causar dano à companhia, ou com objetivo de obter uma vantagem indevida.
- **voto conflitante:** o acionista não pode votar numa deliberação que o afete diretamente. O acionista não pode votar quando haverá deliberação sobre os bens que o acionista irá integralizar o capital social. Também não poderá votar nas aprovações das contas do administrador, caso ele seja o administrador.

6.17. Demonstrações financeiras

Demonstração financeira é a demonstração de como estão as finanças. Ocorre ao final do exercício social.

Quando a **companhia é fechada**, serão quatro as demonstrações financeiras:

- **balanço patrimonial:** serve para dizer qual é o ativo e o passivo, resultando no patrimônio líquido;
- **lucros ou prejuízos acumulados:** é um instrumento em que se permite definir as políticas de investimento adotadas por aquela empresa;
- **resultado de exercício:** dirá se a companhia deu lucro ou prejuízo no último exercício;
- **fluxo de caixa:** serve para verificar o que ingressou e o que saiu do caixa da sociedade.

Sendo a **companhia aberta**, haverá ainda, além dessas, a demonstração financeira de **valor adicional.**

Tais demonstrações **deverão ser publicadas** para que oportunamente sejam apreciadas na assembleia-geral.

Na escrituração mercantil da companhia deverá ser observado o regime de competência, e não o regime de caixa.



6.18. Lucros, reservas e dividendos

Diferenciam-se da seguinte forma:

- **lucros**
- **reservas:** parcela dos lucros permanecem obrigatoriamente na companhia;
- **dividendos:** é a parcela do lucro líquido distribuída aos acionistas. Há uma parcela mínima prevista no estatuto para os dividendos obrigatórios.

A assembleia-geral vai **decidir o que fará com o restante do lucro**, havendo 3 alternativas:

- **reserva de lucro;**
- **distribuição de dividendos;**
- **aumento do capital social.**

A parcela mínima dos lucros a ser necessariamente distribuída aos acionistas deverá ser trazida pelo estatuto. No caso de **omissão estatutária**, a lei diz que ao menos **metade do lucro líquido** deverá ser distribuído. Normalmente, os estatutos sociais trazem uma distribuição diferente.

A distribuição dos **dividendos** obrigatórios **excepcionalmente não será feita**, quando:

- **situação financeira da companhia não permitir;**
- assembleia geral de uma companhia **fechada**, de forma **unânime**, deliberar pela não distribuição.

6.19. Dissolução e liquidação

A dissolução da companhia poderá se dar:

- de pleno direito;
- por decisão judicial;
- por decisão da autoridade administrativa competente.

6.19.1. Dissolução de pleno direito

A dissolução de pleno direito poderá se dar:

- quando houver o término do prazo de duração;
- quando estatuto prever que quando ocorrer certa situação haverá a dissolução da companhia;
- se houver uma deliberação dos acionistas detentores de pelo menos metade das ações com direito a voto;
- em caso de unipessoalidade incidente;
- em caso de extinção da autorização para funcionamento.

6.19.2. Dissolução judicial

A dissolução judicial ocorrerá:

- nos casos de **anulação da constituição da companhia;**
- nos casos de **objeto irrealizável**, como jogo do bicho, etc;
- nos casos de **falência**.

Ainda em relação às possibilidades de dissolução, destaca-se que o STJ entendeu pela possibilidade de dissolução parcial de sociedade anônima que não gera lucros.

STJ - Possibilidade de dissolução parcial da SA que não gera lucros (ainda que não formada por grupo familiar)



É possível que sociedade anônima de capital fechado, ainda que não formada por grupos familiares, seja dissolvida parcialmente quando, a despeito de não atingir seu fim – consubstanciado no auferimento de lucros e na distribuição de dividendos aos acionistas –, restar configurada a viabilidade da continuação dos negócios da companhia. STJ. 3ª Turma. REsp 1.321.263-PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 6/12/2016 (Info 595).

6.20. Transformação, incorporação, fusão e cisão

- **transformação:** é a mudança de tipo societário. Ex.: sociedade limitada se tornou anônima. Essa transformação não cria outra personalidade jurídica, tampouco extingue a anterior. A personalidade jurídica será a mesma. O procedimento de transformação deverá obedecerá às mesmas regras para criação daquele tipo societário. Para que haja alteração do tipo societário, **é necessário que haja unanimidade dos sócios**, salvo se o próprio estatuto permitir a transformação, situação em que já teria havido essa anuência;
- **incorporação:** é uma operação em que uma sociedade absorve a outra. A sociedade absorvida deixa de existir;
- **fusão:** é a junção de duas ou mais sociedades que formarão uma terceira, inexistente até então;
- **cisão:** é a transferência de parcelas do patrimônio social para outra sociedade.

A incorporação de sociedade não se confunde com a incorporação de ações, visto que neste caso a primeira sociedade continua existindo.

No caso de incorporação de sociedade, haverá a conversão de uma sociedade anônima em subsidiária integral. Todas as ações de uma sociedade anônima passarão para a incorporadora, que se tornará a única acionista daquela sociedade.

A lei faculta aos acionistas dissidentes que se retirem da sociedade incorporada. **Já os acionistas da sociedade incorporadora não têm tal direito.**

No **caso de fusão**, será assegurado o direito de retirada dos dissidentes.

Na **cisão**, só existe direito de retirada se implicar a participação dos acionistas numa sociedade que tenha objeto diferente daquele que era da sociedade anterior, ou **numa sociedade em que os dividendos obrigatórios sejam menores** do que recebia na sociedade anterior.

Também será possível o direito de retirada se aquela sociedade passar a ser integrante de um grupo, a qual não pertencia a cindida.

A **incorporação** e a **fusão** de sociedades **podem estar condicionadas à aprovação pelo CADE, se presentes os requisitos legais**. Estarão sujeitas sempre que um dos grupos envolvidos tiver faturamento igual ou superior a 400 milhões de reais e o outro tiver faturamento de ao menos 30 milhões de reais.

6.21. Grupos de sociedade e consórcio

A associação de esforços se dá para realização de algumas atividades comuns. Essa comunhão de esforços poderá dar origem a três diferentes situações:

- **grupos de fato:** atuam em conjunto para alcançar objetivos comuns, mas não há nada formalizado;
- **grupos de direito:** são grupos formalizados;
- **consórcio:** vão se estabelecer entre sociedades coligadas ou entre sociedades controladora e controlada.

A diferença entre sociedade coligada e sociedade controladora é:



- **sociedade coligada:** uma sociedade tem influência na outra, mas não há o controle de uma sobre a outra;
- **sociedade controladora:** há um exercício do controle da sociedade, em que a controladora controla a controlada.

A sociedade subsidiária integral é uma sociedade anônima constituída por escritura pública, cujo único acionista é uma sociedade. Esta sociedade controladora poderá ser anônima, limitada, etc., mas deverá ser sociedade brasileira.

Grupos de direito, por sua vez, são um **conjunto de sociedades cujo controle é titularizado por uma sociedade**. Há uma sociedade que comanda, sendo denominado de **holding**.

Esse grupo **deverá ter um registro na Junta Comercial**. Essa **holding deverá ser obrigatoriamente brasileira**.

Atente-se que **esse grupo não tem personalidade jurídica**. Por isso, em relação às sociedades do grupo, não haverá solidariedade, tampouco subsidiariedade, devendo cada uma responder pelos seus atos, salvo direito trabalhista, consumidor, etc.

No caso de consórcios, ocorrerá quando duas sociedades combinarem seus esforços, com recursos, a fim de desenvolver um empreendimento em comum. Nesse caso, as sociedades consorciadas responderão por aquilo que contratarem. No entanto, **o consórcio também não terá personalidade jurídica própria**.

6.22. Operações Societárias

Na verdade, o assunto não é exclusivo de S.A., mas é tratado na Lei das Sociedades Anônimas.

Existem quatro operações societárias principais, que apesar de também estarem disciplinadas no Código Civil, este basicamente repete o que diz a Lei das S.A.

6.22.1. Transformação

“Art. 220. A transformação é a operação pela qual a sociedade passa, independentemente de dissolução e liquidação, de um tipo para outro”.

Mera mudança no tipo de sociedade, isto é, muda-se apenas a roupagem da sociedade, por exemplo, passa de limitada para Sociedade Anônima.

“Art. 221. A transformação exige o consentimento unânime dos sócios ou acionistas, salvo se prevista no estatuto ou no contrato social, caso em que o sócio dissidente terá o direito de retirar-se da sociedade.”

6.22.2. Incorporação

Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações. § 1º A assembleia-geral da companhia incorporadora, se aprovar o protocolo da operação, deverá autorizar o aumento de capital a ser subscrito e realizado pela incorporada mediante versão do seu patrimônio líquido, e nomear os peritos que o avaliarão.

§ 2º A sociedade que houver de ser incorporada, se aprovar o protocolo da operação, autorizará seus administradores a praticarem os atos necessários à incorporação, inclusive a subscrição do aumento de capital da incorporadora

§ 3º **Aprovados pela assembleia-geral da incorporadora o laudo de avaliação e a incorporação, extingue-se a incorporada, competindo à primeira promover o arquivamento e a publicação dos atos da incorporação.**



Na incorporação não surge uma nova sociedade. A sociedade incorporada é extinta e a sociedade incorporadora aumentará suas proporções.

6.22.3. Fusão

Art. 228. A fusão é a operação pela qual se unem duas ou mais sociedades para formar sociedade nova, que lhes sucederá em todos os direitos e obrigações.

§ 1º A assembleia-geral de cada companhia, se aprovar o protocolo de fusão, deverá nomear os peritos que avaliarão os patrimônios líquidos das demais sociedades.

§ 2º Apresentados os laudos, os administradores convocarão os sócios ou acionistas das sociedades para uma assembleia-geral, que deles tomará conhecimento e resolverá sobre a constituição definitiva da nova sociedade, vedado aos sócios ou acionistas votar o laudo de avaliação do patrimônio líquido da sociedade de que fazem parte.

§ 3º Constituída a nova companhia, incumbirá aos primeiros administradores promover o arquivamento e a publicação dos atos da fusão.

6.22.4. Cisão

Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão.

§ 1º Sem prejuízo do disposto no artigo 233, a sociedade que absorver parcela do patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações relacionados no ato da cisão; no caso de cisão com extinção, as sociedades que absorverem parcelas do patrimônio da companhia cindida sucederão a esta, na proporção dos patrimônios líquidos transferidos, nos direitos e obrigações não relacionados.

§ 2º Na cisão com versão de parcela do patrimônio em sociedade nova, a operação será deliberada pela assembleia-geral da companhia à vista de justificção que incluirá as informações de que tratam os números do artigo 224; a assembleia, se a aprovar, nomeará os peritos que avaliarão a parcela do patrimônio a ser transferida, e funcionará como assembleia de constituição da nova companhia.

§ 3º A cisão com versão de parcela de patrimônio em sociedade já existente obedecerá às disposições sobre incorporação (artigo 227).

§ 4º Efetivada a cisão com extinção da companhia cindida, caberá aos administradores das sociedades que tiverem absorvido parcelas do seu patrimônio promover o arquivamento e publicação dos atos da operação; na cisão com versão parcial do patrimônio, esse dever caberá aos administradores da companhia cindida e da que absorver parcela do seu patrimônio.

§ 5º As ações integralizadas com parcelas de patrimônio da companhia cindida serão atribuídas a seus titulares, em substituição às extintas, na proporção das que possuíam; a atribuição em proporção diferente requer aprovação de todos os titulares, inclusive das ações sem direito a voto.

Mera transferência de parcela do patrimônio para outra(s) sociedade(s).

Relembrando: algumas dessas transações, uma vez preenchidos os requisitos do artigo 88 da Lei Antitruste (Lei nº 12. 529/2011), devem ser apresentadas ao CADE previamente, para que esse diga se estão autorizadas.



6.23. Sociedade de economia mista

Sociedade de economia mista é uma sociedade anônima cujo capital social é constituído em sua maioria por capital estatal, com participação também de capital particular. Ex.: Banco do Brasil.

A sua constituição depende de autorização legal. As companhias de economia mistas são sociedades abertas e estão sujeitas ao controle e **fiscalização da CVM**, visto que negociam ações em Bolsa.

Assim como as empresas públicas, devem obediência também aos ditames do Estatuto das Estatais (Lei nº 13.303/2016).

7. Sociedade em comandita por ações

Basicamente, as regras da S.A. são válidas para a sociedade em comandita por ações.

Algumas das diferenças estão nas peculiaridades que a sociedade em comandita por ações apresenta:

- **responsabilidade dos diretores:** aqui, os diretores têm responsabilidade ilimitada pelas obrigações e somente acionista poderá fazer parte da diretoria;
- **nome empresarial:** poderá ter tanto denominação quanto firma. Sendo firma, o nome civil deverá ser de alguém que administra a companhia, pois responderá ilimitadamente;
- **identificação do tipo societário pelo nome empresarial:** deverá conter C/A, ou comandita por ações.

Em razão da responsabilidade ilimitada dos diretores, a assembleia-geral não tem poderes para mudar o objeto essencial da atividade, caso não haja a anuência dos acionistas que respondem ilimitadamente, que são os diretores. Tampouco poderá prorrogar o prazo de duração, caso seja de prazo determinado. Além disso, também não poderá reduzir ou aumentar o capital social sem a anuência daqueles que têm responsabilidade ilimitada.



CAPÍTULO 13 — PROPRIEDADE INDUSTRIAL

1. Propriedade Intelectual

O direito industrial (também chamado de direito de propriedade industrial) é espécie do direito de propriedade intelectual, que também abrange o direito autoral e outros direitos sobre bens imateriais. Quando se fala de propriedade intelectual, quer-se referir à propriedade sobre bens imateriais de forma geral, sobre ideias, criações etc.

Em suma: o direito de propriedade intelectual é gênero, do qual são espécies o direito industrial, intrinsecamente ligado ao Direito Empresarial, e o direito autoral, mais ligado ao Direito Civil.

O Direito autoral no Brasil é tratado em duas leis: a Lei nº 9.609/98, que dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País e dá outras providências, e a Lei nº 9.610/98, que altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências.

2. Diferenças entre o direito industrial e o direito autoral

Como visto, o direito de propriedade industrial e o direito autoral são espécies de um gênero em comum: a propriedade intelectual. Possuem em comum, portanto, a característica de protegerem bens imateriais, direitos intelectuais. Por outro lado, possuem diferenças significativas.

Em destaque, as distinções consideradas mais importantes:

- (i) A proteção dos direitos industriais depende da concessão de registro/patente (art. 2º da Lei nº 9.279/1996), mas a proteção dos direitos autorais independe de registro (art. 18 da Lei nº 9.610/98). **Registro** é para marca e desenho industrial e **patente** é para invenção e modelo de utilidade.
- (ii) Existe uma autarquia federal específica para concessão de direitos industriais (INPI – art. 2º da Lei nº 5.648/70), mas os direitos autorais são registrados, **facultativamente** e conforme à sua natureza, em **órgãos diversos** cuja criação não se deu especificamente para isso (Escola de Música, Escola de Belas Artes da UFRJ, Biblioteca Nacional, Instituto Nacional de Cinema e CREA – art. 17 da Lei nº 5.988/1973).
- (iii) Os prazos de proteção dos direitos autorais (art. 41 da Lei nº 9.610/1998) são distintos dos prazos de proteção dos direitos de propriedade industrial (arts. 40, 108 e 133 da Lei nº 9.279/1996)

3. Previsão Constitucional

A Constituição Federal de 1988 cuida dos direitos industriais na parte dos direitos e garantias individuais, estabelecendo em seu art. 5º, inciso XXIX, o seguinte:

a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

4. Legislação específica

A lei a que se refere a CF/88 é a Lei nº 9.279/1996 (LPI – Lei de Propriedade Industrial), que revogou a antiga Lei nº 5.772/1971 e que estabelece, em seu art. 2º, o seguinte:



Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: I- concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; II- concessão de registro de desenho industrial; III- concessão de registro de marca; IV- repressão às falsas indicações geográficas; e V- repressão à concorrência desleal.

A LPI foi editada nos anos 90, período de abertura econômica brasileira, vindo em função de acordos internacionais que o Brasil celebrou na área de propriedade intelectual, especialmente os acordos “TRIPs”, que são acordos importantes em matéria de propriedade intelectual.

Cuidado: patente é para invenção e modelo de utilidade, registro é para desenho industrial e marca. É errado dizer que uma marca é patenteada, por exemplo, pois marca não é objeto de patente, mas de registro, ou seja, a marca é registrada.

Em suma: a LPI disciplina a concessão de quatro direitos industriais distintos (patente de invenção, patente de modelo de utilidade, registro de desenho industrial e registro de marca) e a repressão de pelo menos dois tipos de conduta empresarial (falsa indicação geográfica e concorrência desleal).

IMPORTANTE: os direitos industriais mencionados são considerados como bens móveis para fins legais (art. 5º, da LPI), e é por isso que eles podem ser negociados pelos seus respectivos titulares (cessão, licença, e etc.). (Incidência em provas).

5. Objetos de proteção

Propriedade industrial é um tema que, apesar de pouca familiaridade, não guarda grande complexidade nas provas.

São quatro bens imateriais protegidos pelo direito industrial:

- patente de invenção;
- patente de modelo de utilidade;
- registro de desenho industrial ;
- registro de marca.

Para fins de memorização, observe que apenas estão sujeitos a Registro bens imateriais que possuem a letra “r” (marca e desenho industrial). Os demais (invenção e modelo de utilidade) estão sujeitos à patente.

Os direitos industriais são concedidos pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal.

6. Patentes

A patente se refere à **invenção** ou ao **modelo de utilidade**.

Invenção é um ato original do ser humano. Alguém projeta algo que se desconhecia. Alguém inventa algo, mas deve ser algo realmente novo. Portanto, a novidade é condição de patenteabilidade da invenção. É preciso que seja algo novo, não abarcado pelo estado da técnica.

Modelo de utilidade é o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. Perceba que na patente de um modelo de utilidade haverá uma novidade, porém ela será parcial, visto que se trata de uma melhora da funcionalidade do objeto. Por isso é também chamado por alguns autores de “mini-invenção” ou “pequena invenção”.

IMPORTANTE: quanto à expressão “objeto de uso prático”, constante do art. 9º, da LPI, pode-se dizer que ela é aplicável a qualquer invento. É por isso que a lei afirma que criações



teóricas, como “regras de jogo” e “concepções puramente abstratas”, não são consideradas invenção nem modelo de utilidade.

Nesse sentido, confira-se o art. 10, da LPI:

Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; II - concepções puramente abstratas; III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; V - programas de computador em si; VI - apresentação de informações; VII - regras de jogo; VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

Atente-se às pegadinhas, pois as bancas costumam cobrar a letra de lei do artigo 10, supramencionado, trocando as palavras e as expressões.

6.1. Requisitos de patenteabilidade

A **patenteabilidade** das invenções e do modelo de utilidade deverá obedecer aos seguintes **requisitos**:

6.1.1. Novidade

Novidade: não basta que seja original, é preciso que seja desconhecida pela comunidade científica, ou seja, não esteja compreendida no estado da técnica. O período de graça é uma exceção ao estado da técnica e está disposto no art. 12 da LPI. Pode ocorrer de, antes do depósito do registro de patente, ser necessário mostrar aquilo considerado um invento para alguém, por exemplo, a investidores, a fim de angariar recursos para exploração da invenção, ou à comunidade científica para receber aprovação etc. Nesse caso, se o próprio inventor apresenta o invento e depósito do pedido de patente ocorre dentro de 12 meses contados a partir do ato que tornou público o invento, isso não será considerado estado da técnica. Em tese seria estado da técnica, porque já houve publicação antes do pedido de patente, mas no caso acima narrado ou se foi publicado pelo INPI, em razão de um pedido de patente feito por uma pessoa que obteve as informações do inventor e depositou o pedido de patente sem o consentimento deste, não haverá estado da técnica. Ainda, tendo havido apresentação privada, posteriormente divulgada por terceiro sem consentimento do inventor, feito o pedido pelo inventor 12 meses após a divulgação, não haverá estado da técnica. Passados 12 meses, esse período de graça não mais existirá. Segundo Denis Borges Barbosa, a regra do art. 12 da LPI serve para proteger o inventor hipossuficiente, isto é, “o inventor individual ou a pequena empresa que, historicamente, tendem a perder o direito de pedir patente por divulgarem o invento antes do depósito”. Assim, prossegue o autor, “nenhuma contemplação poderá haver no caso de invento de titularidade de uma grande ou média empresa que descure de pretender proteção a seus inventos; *dormientibus non soccurit jus*. Para estes, há que se aplicar o período de graça com o máximo de restrição” (BARBOSA, 2003).

6.1.2. Atividade inventiva

Atividade inventiva: não poderá ser de uma decorrência óbvia do estado da técnica, que qualquer um faria. É necessário que haja um real progresso naquela atividade. Isto é, o



indivíduo deve ter atuado de forma que este resultado alcançado não decorria logicamente do estado da técnica. Conforme adverte CRUZ (2014):

Serve esse requisito, enfim, para distinguir a invenção de uma mera descoberta, de modo que o direito de propriedade protege o inventor, mas não o mero descobridor. Esse, por exemplo, descobre uma jazida de metal precioso; aquele, por sua vez, cria um mecanismo para aproveitamento deste metal. Uma coisa é descobrir a eletricidade, outra coisa é inventar a lâmpada.

6.1.3. Aplicação industrial

Aplicação industrial: é preenchido “quando a invenção ou o modelo de utilidade possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria” (art. 15, da LPI). Em outras palavras: exige-se que o invento seja útil e factível, isto é, resolva um problema técnico. A lei não confere proteção a inventos inúteis.

Quanto à aplicação industrial, Ulhoa nos traz:

Na verdade, o que pretende a lei, ao eleger a industriabilidade como condição de patenteabilidade, é afastar a concessão de patentes a invenções que ainda não podem ser fabricadas, em razão do estágio evolutivo do estado da técnica, ou que são desprovidas de qualquer utilidade para o homem. Duas, portanto, são as invenções que não atendem ao requisito da industriabilidade: as muito avançadas e as inúteis. (COELHO, 2003).

6.1.4. Licitude

Licitude: Há inventos que, apesar de preencherem os requisitos de patenteabilidade, não podem ser objeto de concessão de patentes, em razão da ocorrência de algum impedimento legal específico. Vide, por exemplo, o art. 18 da LPI:

Art. 18. Não são patenteáveis:

I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;

II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e

III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

O artigo 18 difere do artigo 10 (visto acima) porque são hipóteses que até poderiam configurar uma invenção ou modelo de utilidade, mas o legislador estabelece um impedimento legal à concessão da patente.

IMPORTANTE: quanto aos impedimentos legais à patenteabilidade, é importante destacar que a LPI não mais veda a concessão de patentes na indústria farmacêutica (remédios/medicamentos). No entanto, inventos nessa área precisam preencher um requisito a mais para serem patenteados: anuência da ANVISA (art. 229-C da LPI).



6.2. Titularidade da patente

Em princípio, o pedido de concessão da patente deve ser feito ao INPI pelo próprio autor do invento (invenção ou modelo de utilidade), mas também pode ser realizado “pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade” (art. 6º, § 2º, LPI).

Se o invento foi realizado em conjunto, “a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos” (art. 6º, § 3º, da LPI).

Em caso de inventos ou modelos de utilidade concomitantes, porém independentes, terá direito à patente aquele que depositou o pedido de patente em primeiro lugar (art. 7º da LPI). O Brasil adota, portanto, o sistema *first-to-file*, “o primeiro a depositar”. Apenas os EUA adotavam o sistema *first-to-invent* até 2012/2013, depois adotaram o sistema *first-to-file*. Atente-se: o artigo 7º pode ser cobrado em prova em forma de pegadinha, pois é um dispositivo contraintuitivo.

Quando o invento é desenvolvido por funcionários do empresário (empregados ou prestadores de serviços, por exemplo), é preciso atentar para as peculiaridades do caso, a fim de determinar a correta titularidade da patente.

Há três possibilidades distintas:

- Uma situação que determinará a propriedade exclusiva da empresa sobre a patente.
- Uma situação que determinará a propriedade exclusiva do empregado sobre a patente.
- Uma situação que determinará a propriedade dividida entre empresa e empregado sobre a patente.

O art. 88, da LPI prevê o seguinte:

a invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado.

Exemplo: o engenheiro químico de uma indústria, que trabalha na área de desenvolvimento de novos produtos, tem como natureza dos serviços prestados justamente a criação de novos produtos, assim, a titularidade da patente é da empresa e não do engenheiro.

Nesse caso, “salvo expressa disposição contratual em contrário, a retribuição pelo trabalho a que se refere este artigo limita-se ao salário ajustado” (§ 1º do art. 88). Ademais, “salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato a invenção ou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado até 1 (um) ano após a extinção do vínculo empregatício” (§ 2º do art. 88). Essa regra visa proteger a empresa de eventual ação de má-fé do funcionário em caso de pedido de demissão. Presume-se, nesse caso, que a invenção foi criada sob a égide do contrato de trabalho.

Ainda que o funcionário deposite o pedido após um ano da extinção do vínculo empregatício, a empresa pode demonstrar que a invenção foi feita quando a pessoa ainda era empregada da empresa e, portanto, poderá alegar que sob a vigência do contrato de trabalho a titularidade da patente a ela pertença. Porém, nesse caso, não haveria presunção em favor da empresa (a resolução da questão seria por meio de um processo administrativo junto ao INPI).

Se, porém, um empregado desenvolveu um invento totalmente desvinculado do seu trabalho, devem-se distinguir duas situações distintas:

Se ele não usou recursos, meios dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, a titularidade da patente será exclusivamente dele (art. 90, da LPI);



Se ele usou recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, a titularidade da patente será comum, em partes iguais, salvo cláusula contratual em sentido contrário (art. 91, da LPI).

6.3. Prazo de proteção das patentes de invenção e de modelo de utilidade

Após um processo administrativo, o INPI expede a patente. Essa patente confere ao titular o direito de **exploração exclusiva**, mas **não será *ad eternum***. A patente poderá durar pelo prazo de:

- **invenção: 20 anos**, contados do respectivo depósito;
- **modelo de utilidade: 15 anos**, contados do respectivo depósito.

O depósito é o momento em que o pedido é protocolado no INPI. Essa é a data do dia *a quo*.

Caso o processo tenha sido demorado no INPI, a lei assegura que o **prazo de duração do direito industrial**:

- **não poderá ser inferior a 10 anos para a invenção, contados da expedição da patente;**
- **não poderá ser inferior a 7 anos para os modelos de utilidade, contados da expedição da patente.**

O termo *a quo* é a data do pedido de registro (depósito), mas o sujeito tem direito a exploração exclusiva a partir do momento em que é concedida a patente. No entanto, entre a concessão da patente e o fim do período de exploração exclusiva, haverá um prazo mínimo que deverá ser observado: pelo menos 7 anos para modelo de utilidade e no mínimo 10 anos para invenção. Assim, se um pedido de patente de invenção for depositado em 2020 e concedido em 2027, o prazo de proteção irá até 2040 (20 anos do depósito, já que a contagem dos 10 anos da data da expedição da patente terminaria em 2037). Porém, se o mesmo pedido for concedido apenas em 2035, o prazo de proteção irá até 2045 (não poderá ser inferior a 10 anos da data da expedição da patente).

Há situações em que o titular do direito à patente está obrigado a licenciar esta patente a terceiros, tratando-se de **licença compulsória**. Os **licenciados remunerarão o dono da patente**, mas não há outro caminho ao titular que não seja o licenciamento da patente.

Casos em que se **exige a licença compulsória**:

- **se os direitos concedidos pelo INPI são exercidos de forma abusiva:** há um princípio geral do direito que estabelece que ninguém poderá se valer da própria torpeza. O exercício do direito deverá ser regular, pois do contrário haverá uma afronta ao ordenamento.
- **se há abuso do poder econômico:** aplica-se o mesmo motivo acima.
- **se o titular da patente, tendo já transcorridos 3 anos da sua expedição, não a exerce, ou comercializa o bem de forma insatisfatória:** Se o sujeito não produz, não explora por completo ou não comercializa de forma satisfatória, será caso de licença compulsória, após esses 3 anos.

Caso concedida a licença compulsória, o licenciado tem o prazo de **2 anos** para sua exploração de forma satisfatória. Nesse caso, **persistindo a situação de irregularidade, opera-se a caducidade da patente, caindo em domínio público.**

Veja, há duas situações que justificam que o bem, outrora patenteado, caia em domínio público:

- **esgotamento do prazo da patente;**
- **caducidade da patente.**

Além dessas hipóteses, existem outras situações que ensejam a **extinção da patente**:

- **renúncia aos direitos industriais;**
- **falta de pagamento da taxa do INPI;**



- falta de representante no Brasil.

6.4. Licença da patente

6.4.1. Licença voluntária

De acordo com o art. 61 da LPI, “o titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração”.

Lembre-se: os direitos industriais são considerados bens móveis, então podem ser negociados. Pode-se licenciar a exploração de uma patente, prática, inclusive, muito comum, chamada de *royalty*.

O art. 62 da LPI, por sua vez, determina que “o contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que se produzam efeitos em relação a terceiros”. Nesse caso, o licenciado poderá explorar economicamente o objeto patenteado, e o titular receberá, em troca, a retribuição acordada voluntariamente.

6.4.2. Licença compulsória

Segundo o art. 68 da LPI, “o titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial.”

Em caso de abuso do poder econômico, a decisão administrativa será do CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica, porque tal prática é considerada infração contra a ordem econômica punida por essa autarquia.

A licença compulsória é uma forma de punir o titular da patente em virtude de alguma ilicitude por ele cometida.

Por sua vez, o § 1º do art. 68 afirma que

Art. 68 (...)§ 1º Ensejam, igualmente, licença compulsória: I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou II - a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado.

Nesse caso, não há necessariamente prática ilícita por parte do titular da patente, mas mera ausência de exploração da patente por este ou exploração que não atenda aos interesses do mercado.

Ainda, nesses casos, a licença será determinada por decisão administrativa do INPI, após requerimento de um interessado e regular processo administrativo (art. 73, da LPI).

Tal hipótese é denominada pela doutrina equivocadamente como “quebra de patente”, pois tal expressão sugere que o titular perdeu a patente, enquanto, em verdade, a pessoa continuará sendo titular da patente, bem como permanecerá recebendo os *royalties* pelo seu uso licenciado. A compulsoriedade apenas significa que não foi fruto de um acordo/contrato. Os *royalties*, nesse caso, não serão acordados, mas sim determinados pelo próprio INPI.

O art. 71 da LPI, por sua vez, tem a seguinte redação:

Art. 71 Nos casos de **emergência nacional ou interesse público**, declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória, temporária e não exclusiva, para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular.



Nesse caso, a licença será determinada por Decreto do presidente da República, que poderá agir de ofício (cite-se, por exemplo, o Decreto 6.108/2007, que concedeu licenciamento compulsório, por interesse público, de patentes referentes ao medicamento *Efavirenz*, usado no combate à AIDS).

Há, por fim, as licenças compulsórias previstas no art. 70 da LPI:

Art. 70. A licença compulsória será ainda concedida quando, cumulativamente, se verificarem as seguintes hipóteses:

I - ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em relação a outra;

II - o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em relação à patente anterior; e

III - o titular não realizar acordo com o titular da patente dependente para exploração da patente anterior.

§ 1º Para os fins deste artigo considera-se patente dependente aquela cuja exploração depende obrigatoriamente da utilização do objeto de patente anterior.

§ 2º Para efeito deste artigo, uma patente de processo poderá ser considerada dependente de patente do produto respectivo, bem como uma patente de produto poderá ser dependente de patente de processo.

§ 3º O titular da patente licenciada na forma deste artigo terá direito a licença compulsória cruzada da patente dependente.

7. Registros

O registro industrial se aplica às **marcas** e aos **desenhos industriais**. Ambos serão registrados no INPI, que é uma autarquia federal.

7.1. Desenho industrial (design)

O **desenho industrial** diz respeito à forma dos objetos. Servirá tanto para conferir ao objeto um ornamento ou uma aparência harmoniosa como para distingui-lo de outros do mesmo gênero.

Diferencia-se do modelo de utilidade porque, ao contrário deste, não guarda relação com a funcionalidade do objeto, possuindo viés mais estético. Para ajudar a gravar, a doutrina salienta que “O desenho industrial é ‘fútil’, o modelo de utilidade é útil”.

7.1.1. Requisitos do desenho industrial

O **registro** do desenho industrial tem que observar alguns **requisitos**: **novidade**, **originalidade**, **aplicação industrial** e **licitude**.

a) Novidade

O requisito da **novidade** (o mais importante), assim como ocorre com as invenções e os modelos de utilidade, resta atendido quando o desenho industrial objeto do pleito registral não estiver compreendido no estado da técnica (art. 96 da LPI), sendo esse, repita-se, “constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio, ressalvado o disposto no § 3º deste artigo e no art. 99” (§1º).



b) Originalidade

Esse requisito estará presente quando do desenho industrial resultar “uma configuração visual **distintiva**, em relação a outros objetos anteriores” (art. 97, LPI). O resultado original “poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos” (parágrafo único). Caso não se consiga dar ao produto uma configuração distintiva, capaz de distingui-lo dos demais, não se estará diante de um desenho industrial registrável, uma vez que sua função é exatamente a de distinguir aquele produto dos demais.

c) Aplicação industrial

A lei não definiu expressamente quando o desenho industrial preenche o requisito da aplicação industrial, mas se preocupou em afirmar que “não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico” (art.98, LPI), deixando de fora do âmbito de proteção legal dos desenhos industriais as obras de arte. O importante é que seja suscetível de industrialização.

d) Licitude

Tal como em relação às patentes, a lei também enumera desenhos industriais não registráveis, em razão de impedimentos legais. Confira-se:

Art. 100. Não é registrável como desenho industrial: I - o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimentos dignos de respeito e veneração; II - a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.

O inciso II corrobora ainda mais a distinção entre modelo de utilidade e desenho industrial, ao prever que, se a forma alcançada for decorrente de considerações técnicas ou funcionais, ao invés de estéticas, não será passível de registro como desenho industrial.

7.1.2. Prazo de proteção do Desenho Industrial

O prazo do registro do desenho industrial é de **10 anos**, contados da data do depósito. Esse prazo de 10 anos é prorrogável por 3 períodos sucessivos de 5 anos cada. Ou seja, **o tempo do prazo do registro do desenho industrial poderá alcançar até 25 anos** (10 anos + 3 períodos sucessivos de 5 anos). Há uma taxa quinquenal devida ao INPI, para assegurar a vigência do desenho industrial. Assim, ao contrário do que ocorre com o prazo de vigência das patentes, o prazo de vigência do registro de desenho industrial pode ser prorrogado. Esse pedido de prorrogação deve ser feito no último ano da vigência do registro (art. 108, § 1º), com comprovação do recolhimento da taxa ao INPI. Caso não feito até o término da vigência, o pedido de prorrogação poderá ser realizado nos 180 dias subsequentes, mas, em tal caso, será devida também uma retribuição adicional (art. 108, § 2º, da LPI).

O art. 94, parágrafo único, da LPI dispõe que se aplicam “ao registro de desenho industrial, no que couber, as disposições dos arts. 6º e 7º”, já vistos quando do estudo das patentes.

Aplicam-se, também, aos pedidos de registro de desenho industrial as regras previstas na LPI sobre a titularidade de patentes de inventos realizados por funcionários do empresário (art. 121, LPI).



7.2. Marca

A **marca** é um signo distintivo de um produto ou serviço. Trata-se de um elemento que **identifica o produto ou serviço**. O Brasil, ao contrário de outros países, não previu a possibilidade de registro de marca sonora, olfativa ou gustativa, pois a lei exige que o sinal distintivo seja visualmente perceptível.

7.2.1. Distintividade da marca

A marca, assim como o desenho industrial, possui a finalidade de identificar determinado produto ou serviço do empresário, de modo a distingui-lo dos demais. A marca deve ser, portanto, individualizadora do produto ou serviço que identifica. É por isso que a lei não admite (art. 124, da LPI) o registro como marca de *letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva* (inciso II), *sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo* (inciso VI), *cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo* (inciso VIII) etc. (o art. 124, da LPI traz um rol extenso de sinais não registráveis como marca).

IMPORTANTE: o STJ entende que as marcas evocativas – aquelas nas quais, pela própria evolução do mercado, os termos empregados se tornaram genéricos (mas não eram ao tempo do registro, por isso foram registradas) – podem ter sua exclusividade mitigada, pois “ainda que já tenha sido registrada no INPI, a marca que constitui vocábulo de uso comum no segmento mercadológico em que se insere – associado ao produto ou serviço que se pretende assinalar – pode ser utilizada por terceiros de boa-fé” (REsp 1.315.621-SP; no mesmo sentido; AgRg no AREsp 100.976/SP, REsp 1315621/SP e AgInt no REsp 1338834/SP).

Ainda, o STJ entende que a imitação ideológica de marcas é vedada: “a imitação ideológica ocorre quando uma marca reproduz a mesma ideia transmitida por outra, anteriormente registrada e inserida no mesmo segmento mercadológico, levando o público consumidor à confusão ou à associação indevida” (caso BigFral x MegaFral: REsp 1.721.697 -RJ).

Obs.: a expressão “Fral” é genérica, descritiva, então, não poderia ser registrada como marca, mas a expressão “BigFral” sim. No caso, “Big” é diferente de “Mega”, mas a ideia é a mesma “fralda grande”, proibiu-se, portanto, o uso da marca “MegaFral”.

7.2.2. Espécies de marca

O art. 123 da LPI descreve três espécies de marca:

- (i) marca de produto ou serviço, que é aquela “usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa”;
- (ii) marca de certificação, que é “aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada” – marca registrada por uma empresa certificadora e todos os empresários que atenderem as especificações ou normas técnicas poderão utilizar a marca – Ex: Certificados ISO; e
- (iii) marca coletiva, que é “aquela usada para identificar produtos ou serviços provenientes de membros de uma determinada entidade”. Apenas atesta que o empresário é da entidade X.

Geralmente, tanto as marcas certificadoras quanto as marcas coletivas são boas para os empresários, porque asseguram para o público consumidor certa qualidade do produto ou serviço.

A marca de produto ou serviço “representa a noção geral de marca que todos nós possuímos, ou seja, que são usadas pelos empresários para identificar os produtos ou serviços



que comercializam ou produzem” (CRUZ, 2014). Quem registra essa marca é o próprio empresário que vai usá-la, valendo destacar que ele precisa declarar que exerce a atividade à qual se relaciona a marca “efetiva e licitamente, de modo direto ou por meio de empresas que controlem direta ou indiretamente” (art. 128, §1º, LPI).

A marca de certificação, por sua vez, “é aquela que atesta a qualidade de determinado produto ou serviço conforme normas técnicas estabelecidas por institutos especializados, os quais podem ser de natureza governamental ou apenas credenciados pelos órgãos oficiais competentes” (CRUZ, 2014). Quem registra essa marca é a própria certificadora, “pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado” (art. 128, §2º), e os empresários que atenderem seus requisitos poderão utilizá-la.

Por fim, a marca coletiva “é aquela que atesta a proveniência de determinado produto ou serviço. Ela indica ao consumidor, por exemplo, que os empresários que a utilizam são membros de determinada associação, e que seus produtos ou serviços estão em conformidade com as regulamentações técnicas dessa entidade” (CRUZ, 2014). Quem registra essa marca é a própria entidade, “pessoa jurídica representativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros” (art. 128, § 3º da LPI), e estes poderão usar a marca nos termos do regulamento (exemplo: AMORANGO, que atesta que o produtor é membro da Associação dos Agricultores Familiares Produtores de Morango de Nova Friburgo).

Há outra classificação das marcas, quanto a sua forma de apresentação:

As marcas nominativas são criadas a partir de palavras e/ou números ou combinação de palavras e números, sem nenhum elemento figurativo, podendo ser expressões já existentes ou criações originais. As marcas figurativas (...) são aquelas constituídas por desenhos, símbolos ou figuras que apresentam configuração gráfica decorativa, incomum, não usual [exemplo: a estrela da Mercedes]. As marcas mistas (...) são as que se constituem por meio da combinação das duas espécies de marcas acima mencionadas [exemplo: Coca-Cola]. Por fim, as marcas tridimensionais (...) são aquelas constituídas pela forma plástica do produto, ou seja, sua configuração física, com capacidade distintiva e dissociada de efeitos técnicos (por exemplo, um vidro de perfume. Como a distinção entre a marca tridimensional e o desenho industrial nem sempre é fácil, muitas vezes o que determina o tipo de registro feito (desenho ou marca) é a escolha do empresário. (CRUZ, 2014)

7.2.3. Âmbito de proteção da marca

O princípio regente do âmbito de proteção das marcas é o princípio da especialidade ou da especificidade, segundo o qual, via de regra, a marca só é protegida na respectiva classe de produtos ou serviços em que foi registrada. Por tal razão, por exemplo, uma loja de sapatos poderia se valer da marca CP Iuris, em que pese já estar devidamente registrada junto ao INPI.

Esmiuçando: o INPI tem uma tabela com vários códigos, cada código representa uma classe de produto ou serviço, cabe à pessoa que está registrando a marca indicar em qual classe(s) está registrando a marca. Uma vez registrada, a proteção da marca ficará restrita àquela classe de produtos ou serviços, portanto, em princípio, nada impede que uma marca igual ou muito parecida seja registrada por outro empresário, em uma classe diferente de produtos ou serviços.

Exemplo: Odebrecht construtora x Odebrecht café.

Quanto à abrangência territorial, a proteção do registro da marca conferido pelo INPI vale em todo o território nacional, ao contrário da proteção conferida ao nome empresarial, que apenas vale no(s) território(s) da(s) Junta(s) Comercial(is) em que houve sua inscrição.



a) Marca de alto renome

A exceção a esse princípio se dá em relação às marcas consideradas de alto renome pelo INPI, que terão proteção especial, em todos os ramos de atividade (art. 125, da LPI).

IMPORTANTE: quem decide se uma marca é de alto renome ou não é o INPI. Até 2013 a autarquia entendia que essa análise só podia ser feita incidentalmente, como matéria de defesa, quando da apresentação de oposição a pedido de registro de marca de terceiro ou no processo administrativo de nulidade de registro de marca de terceiro.

No entanto, o STJ decidiu que, no caso da marca Absolut, embora caiba realmente ao INPI decidir se uma marca é de alto renome ou não, a autarquia deve, caso o titular da marca requeira, fazer isso não apenas de forma incidental, como matéria de defesa, mas também de forma autônoma e abstrata, sempre que houver requerimento de um interessado. “Cuida-se de um direito do titular, inerente ao direito constitucional de proteção integral da marca” (REsp 1162281/RJ):

Agravo Regimental em Recurso Especial. Direito Empresarial. Marca. Marca de alto renome. Atribuição do INPI. Na linha dos precedentes desta Corte, cabe ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI e não ao Poder Judiciário examinar se determinada marca atende aos requisitos para se qualificar como “marca de alto renome” e assim, na forma do artigo 125 da LPI, excepcionar o princípio da especialidade para desfrutar de proteção em todas as classes. Nessa seara, o Poder Judiciário somente pode ser chamado a intervir como instância de controle da atividade administrativa do INPI. (...) (AgRg no REsp 1165653/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3.ª Turma, j.17.09.2013, DJe 02.10.2013)

COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. MARCA. ALTO RENOME. DECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. LIMITES. (...) O titular de uma marca detém legítimo interesse em obter, por via direta, uma declaração geral e abstrata de que sua marca é de alto renome. Cuida-se de um direito do titular, inerente ao direito constitucional de proteção integral da marca. A lacuna existente na Resolução nº 121/05 - que prevê a declaração do alto renome apenas pela via incidental - configura omissão do INPI na regulamentação do art. 125 da LPI, situação que justifica a intervenção do Poder Judiciário. (...) (REsp 1162281/RJ, Rel.

Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 25/02/2013)

b) Marca notoriamente conhecida

Não se deve confundir a marca de alto renome com a marca notoriamente conhecida, disciplinada no art. 126 da LPI: “a marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil”. A diferença pode ser sintetizada da seguinte forma: a marca de alto renome precisa ser registrada e gozará de proteção em todos os ramos de atividade, já a marca notoriamente conhecida não precisa ser levado a registro, mas terá proteção assegurada no mesmo ramo de atividade (observa princípio da especialidade ou da especificidade da marca). Complementando, a lei diz que o INPI “poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida” (§ 2º).

Cabe ressaltar recente entendimento do STJ no sentido de que o registro de uma expressão como marca de alto renome não impede que essa mesma expressão seja utilizada como nome de um edifício ou empreendimento imobiliário, uma vez que estes não representam atividades empresariais, mas sim atos da vida civil (REsp 1.804.960-SP, 24/09/2019, DJe 02/10/2019).

7.2.4. Prazo de proteção do registro de marca

O prazo de vigência do registro de marca é de 10 (dez) anos, contado da data de concessão, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, nos termos do art. 133 da LPI.

Assim, ao contrário do que ocorre com o prazo de vigência das patentes, o prazo de vigência do registro de marca pode ser prorrogado. Ademais, ao contrário do que ocorre com a prorrogação do prazo de vigência do registro do desenho industrial, a prorrogação do prazo de vigência do registro de marca não tem limite.

A taxa, que é devida ao INPI, é paga na **concessão** e a **cada prorrogação**.

Feito o registro da marca, se ela **não for explorada**, ou **não tiver início nos 5 anos**, haverá a caducidade do registro.

Se uma marca é registrada no INPI e a empresa começa a fabricá-lo no Brasil, mas esse produto só é vendido para o mercado externo, nunca sendo comercializado internamente. Neste caso, conforme entendeu o STJ,

“se o titular da marca registrada no Brasil industrializa, fabrica, elabora o produto em território nacional, claramente inicia e faz uso da marca no Brasil, merecendo toda proteção legal, pois aqui empreende, gerando produção, empregos e riqueza, sendo indiferente que a mercadoria aqui produzida seja destinada ao mercado interno ou exclusivamente ao externo. Produzir no país o produto com a marca aqui registrada atende suficientemente ao requisito legal de ‘uso da marca iniciado no Brasil’”. (REsp 1236218/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 11/06/2015)

Por outro lado, no mesmo precedente acima indicado, decidiu o STJ que **é possível que se reconheça a caducidade do registro da marca quando, em um período de 5 anos, o valor e o volume de vendas do produto relacionado à marca forem inexpressivos** (na situação em análise, 70 pacotes de cigarros que geraram receita de R\$ 614,75) **em comparação com operações bilionárias realizadas pelo titular no mesmo período** (produção de mais de 400 207 bilhões de cigarros).

7.2.5. Requisitos para o registro da marca

Para que uma marca seja registrada exigem-se alguns requisitos:

- **novidade relativa:** significa que a marca é protegida, mas em princípio é protegida apenas no segmento de atividade econômica explorada pelo titular. Naquele segmento é protegida. Existem marcas que terão proteção em todos os ramos, como a marca notória e a marca de alto renome. Todavia, via de regra, é apenas no segmento;
- **não colidência com marca notória:** marca notória é aquela não registrada no INPI, mas é tutelada pelo direito industrial, por meio da Convenção de Paris (União de Paris). Nesse caso, a marca, ainda que não registrada no INPI, merecerá a proteção;
- **não incida em impedimentos:** não é possível registrar como marca uma arma de fabricação do exército e nem mesmo registrar nome civil, salvo com autorização do seu titular.

Para distinguir a marca de alto renome da marca notória, esta última **não tem registro no INPI**. A marca de alto renome tem.

Segundo o STJ, **é possível ao titular do registro de marca, após conceder licença de uso, impedir a utilização da marca pelo licenciado quando não houver observância à nova**



padronização dos produtos e dos serviços, ainda que o uso da marca tenha sido autorizado sem condições ou efeitos limitadores.

Isso porque o licenciamento de uso autoriza o titular do registro da marca a exercer controle sobre as especificações, natureza e qualidade dos produtos ou serviços prestados pelo licenciado. Assim, com a licença de uso, o licenciado compromete-se, *ex lege*, a preservar a integridade e a reputação da marca, obrigando-se a zelar por ela.

Ao licenciante assiste o direito de exercer controle efetivo sobre a atenção do licenciado em relação ao zelo da marca que usa. Dessa forma, **a não observância dos padrões dos produtos e serviços pelo licenciado para o uso da marca demonstra seu uso indevido e autoriza a tutela inibitória para impedir a utilização.**

O registro da marca, embora garanta proteção nacional à exploração exclusiva por parte do titular, encontra limite no princípio da especialidade, que restringe a exclusividade de utilização do signo a um mesmo nicho de produtos e serviços. Assim, **uma mesma marca pode ser utilizada por titulares distintos se não houver qualquer possibilidade de se confundir o consumidor.** Para se verificar a possibilidade de confusão na utilização da mesma marca por diferentes fornecedores de produtos e serviços, deve ser observada, inicialmente, a Classificação Internacional de Produtos e de Serviços, utilizada pelo INPI como parâmetro para concessão ou não do registro de uma marca. É verdade que a tabela de classes não deve ser utilizada de forma absoluta para fins de aplicação do princípio da especialidade, servindo apenas como parâmetro inicial na análise de possibilidade de confusão. Porém, na hipótese, embora os serviços oferecidos sejam distintos, eles são complementares, pois têm finalidades idênticas, além de ocuparem os mesmos canais de comercialização.

7.2.6. Marca evocativa (marca fraca ou marca sugestiva)

Marcas evocativas são aquelas que **constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraindo a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, pois passa a ter um âmbito de proteção limitado.**

Essa proteção é reduzida, pois o monopólio de um nome ou sinal genérico em benefício de um comerciante implicaria exclusividade inadmissível a favorecer a detenção e o exercício do comércio de forma única, com prejuízo à concorrência empresarial. Com efeito, eventual exclusividade impediria os demais industriais do ramo de divulgarem a fabricação de produtos semelhantes por meio de expressões de conhecimento comum, obrigando-os a buscar nomes alternativos estranhos ao domínio público. Ex: STJ manteve o registro da marca “America Air”, apesar de pleito da companhia aérea “American Airlines”. Entendeu o STJ que a marca impugnante valia-se de expressões de uso comum, de pouca originalidade, inviabilizando sua utilização exclusiva.

A própria Lei nº 9.279/1996 dispõe não ser registrável como marca sinal de caráter genérico, necessário, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço. Outro exemplo: não poderia haver uma marca “Maçã” que vendesse maçãs, pois guarda relação com o próprio produto. Mas nada impede que se use a marca “Maçã” para vender smartphones.

Vale destacar que **a linha que divide as marcas genéricas, que são aquelas não sujeitas a registro, das marcas evocativas é extremamente tênue**, por vezes imperceptível, fruto da própria evolução ou desenvolvimento do produto ou serviço no mercado.



7.2.7. Domínio eletrônico e marca

Como já visto, o domínio identifica o estabelecimento virtual, que será acessado pela internet a fim de comprar produtos e bens da sociedade empresária. Quem faz o registro é a “Nick.br”, associação de direito privado.

Em virtude da inexistência de regramentos detalhados quanto ao registro de domínios, muitas pessoas passaram a pegar marcas alheias e fazer registros de domínio, para depois lucrar com a venda do domínio ao legítimo titular da marca. Diante disso, o STJ decidiu que, **no conflito entre a anterioridade na solicitação de nome de domínio e o registro do INPI, prevalece a anterioridade no registro da marca, e não o registro do domínio. Em tese, quem registra primeiro a marca terá direito ao registro do domínio.** Isso evita que indivíduos registrem marcas que já existem para depois negociar a venda desses domínios.

A ordem de registro de domínio só irá prevalecer quando os dois interessados possuírem o registro da marca com aquele nome. Ex.: Lavanderia El Chaday é uma coisa e outra coisa são as Bolachas El Chaday. O dono da lavanderia registrou o domínio, pagando a taxa, tornando-se o dono do elchaday.com.br. Nesse caso, como os dois possuem o registro da marca, prevalecerá o que registrou o domínio primeiro.

8. União de Paris

O Brasil é um país unionista. Isso quer dizer que o Brasil é signatário da Convenção de Paris, que estabelece que **é vedada a criação de distinções entre nacionais e estrangeiros em matéria de direito industrial**, ou seja, o Brasil reconhece o **princípio da prioridade**.

Esse princípio da prioridade estabelece ser **possível que qualquer cidadão de um país que seja signatário dessa União de Paris venha a reivindicar prioridade de registro de uma patente ou de registro industrial no Brasil**, com base em uma concessão que obteve anteriormente no seu país de origem.

O reivindicante terá o prazo de:

- **6 meses:** para o desenho industrial, marca ou para propaganda;
- **12 meses:** para invenção ou modelo de utilidade.

Esse prazo é **decadencial**, devendo ser contado a partir do seu primeiro pedido.

8.1. Indicações geográficas

A LPI, além de disciplinar a concessão dos direitos industriais, também disciplina a repressão à concorrência desleal e às falsas indicações geográficas. De acordo com o art. 176 da LPI, “constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem”.

8.1.2. Indicação de procedência

A **indicação de procedência** está disciplinada no art. 177 da LPI, que assim dispõe: “considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro **de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço.**”

8.1.3. Denominação de origem

A **denominação de origem**, por sua vez, está disciplinada no art. 178 da LPI, que assim prescreve: “considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características



se devam **exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico**, incluídos fatores naturais e humanos.”

Quando uma indicação geográfica é reconhecida pelo INPI, só podem usá-la aqueles produtores ou prestadores de serviços que (i) sejam estabelecidos no local e (ii) atendam requisitos de qualidade para tanto.

É o que determina o art. 182 da LPI: “o uso da indicação geográfica é restrito aos produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local, exigindo-se, ainda, em relação às denominações de origem, o atendimento de requisitos de qualidade.”

Como a indicação geográfica se refere a uma localidade (país, estado, cidade, etc.), o pedido de reconhecimento ao INPI geralmente é feito por uma entidade que congrega os interesses dos produtores ou prestadores de serviço ali estabelecidos (sindicato, associação, cooperativa, etc.). Por exemplo, no caso do Vale dos Vinhedos, o registro foi obtido pela *Aprovale*, a associação de produtores de vinho da região.

CAPÍTULO 14 — DIREITO CAMBIÁRIO

1. Desenvolvimento histórico (fases do Direito Cambiário)

Ao estudar essa matéria, é importante ter em mente o motivo do surgimento dos títulos de crédito e sua função no mercado. Os títulos de crédito não devem ser analisados isoladamente, mas dentro de um contexto de evolução dos meios de troca, de negociação e pagamento.

Indo até a fase mais primitiva do mercado, tem-se que as transações comerciais se realizavam por meio de escambo (troca direta de uma mercadoria por outra). Com o passar do tempo, certas mercadorias, por serem mais demandadas que outras, acabam sendo utilizadas como meio de troca indireta, porque essas mercadorias poderiam ser facilmente trocadas por outras coisas efetivamente necessárias. Assim surge o dinheiro/a moeda. Os primeiros “dinheiros” de que se tem notícia apareceram como mercadorias que eram mais procuradas que outras, como o sal, por exemplo.

Depois de certo momento, o mercado ganha uma complexidade maior, e mesmo o dinheiro, agora em uma fase controlada pelo Estado, não consegue dar vazão às dinâmicas existentes no mercado e novos instrumentos vão surgindo e se desenvolvendo para facilitar essas trocas: são os títulos de crédito.

Os títulos de crédito continuam em evolução, pois é sabido que foram e ainda são muito importantes para a economia. Porém, vive-se hoje um novo momento, que é a fase do comércio eletrônico, das transações virtuais, das criptomoedas etc.

Os títulos de crédito são, em síntese, instrumentos de circulação de riqueza, e a sua principal função é justamente permitir que essa circulação de riqueza se dê de forma **rápida e segura**, o que, por sua vez, só se tornou possível porque durante anos se desenvolveu todo um conjunto de **regras e princípios** aplicáveis a eles: o regime jurídico cambial (Direito Cambiário).

Quanto a seu desenvolvimento histórico, podem ser apontados os seguintes períodos ou fases:

1.1. Período Italiano

Perdurou até 1650. Nessa fase, prevalecia a necessidade de proteger as moedas em trajeto (câmbio trajetício). André Santa Cruz leciona o seguinte sobre esse período:

Cidades marítimas italianas como foco do comércio. Outra característica importante desse período é o desenvolvimento das operações de câmbio, em razão da diversidade de moedas entre as várias cidades medievais. Surge o câmbio trajetício, pelo qual o transporte da moeda em um determinado trajeto ficava por conta e risco de um banqueiro. Esse câmbio trajetício se instrumentalizava por meio de dois documentos: a cautio, apontada como origem da nota promissória, por envolver uma promessa de pagamento (o banqueiro reconhecia a dívida e prometia pagá-la no prazo, lugar e moeda convencionados), e a littera cambii, apontada como origem da letra de câmbio, por se referir a uma ordem de pagamento (o banqueiro ordenava ao seu correspondente que pagasse a quantia nela fixada). (CRUZ, 2014)

1.2. Período francês

Entre 1650 e 1848. O grande marco desse período foi o advento da cláusula à ordem, na França, que passou a permitir a transferência dos títulos de crédito por meio do endosso, independentemente de autorização do sacador.



1.3. Período alemão

Nesse período (de 1848 a 1930), houve a ordenação geral do direito cambiário (normas especiais sobre letras de câmbio), com consequente consolidação da letra de câmbio e dos títulos de crédito como instrumentos de crédito viabilizadores da circulação de direitos.

1.4. Período Uniforme

De 1930 em diante. Caracteriza-se pela edição de diversos tratados internacionais uniformizando as normas incidentes sobre os principais títulos de crédito então existentes, a exemplo da Lei Uniforme sobre Letras de Câmbio e Notas Promissórias e da Lei Uniforme do Cheque.

Questiona-se, na doutrina, se estamos vivenciando um novo período, em virtude do desuso dos títulos de crédito clássicos e a preponderância de transações eletrônicas. André Santa Cruz (2014) cogita estarmos passando pela era do comércio eletrônico.

2. Conceito de título de crédito

Seguindo os ensinamentos do jurista italiano *Cesare Vivante*, costuma-se conceituar título de crédito como o “**documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele mencionado**”. Tal conceito nos remete aos três mais importantes princípios do regime jurídico cambial: **cartularidade, literalidade e autonomia**.

Título de crédito é um documento que representa uma obrigação pecuniária. Não podem ser confundidos com a própria obrigação, pois apenas a representam.

3. Princípios gerais do Direito Cambiário

São princípios gerais do Direito Cambiário:

- **cartularidade:** para o credor de um título de crédito exercer os direitos representados pelo título, deverá o indivíduo estar na posse desse documento. Por exemplo, não se pode promover execução com a cópia do cheque, devendo ser colocado o título original. Esse princípio vem sendo mitigado, visto que, por exemplo, a Lei das Duplicatas estabelece que esse crédito pode ser executado sem que o título esteja com o credor. Outra exceção que mitiga esse princípio é a criação dos títulos de crédito eletrônicos. Ademais, em decorrência desse princípio, a posse do título pelo devedor implica presunção de pagamento e apenas é possível protestar um título, em regra, apresentando-o.
- **literalidade:** o título de crédito vale pelo que nele está escrito. Nem mais, nem menos.

Em outros termos, nas relações cambiais somente os atos que são devidamente lançados no próprio título produzem efeitos jurídicos perante o seu legítimo portador. A literalidade, em síntese, é o princípio que assegura às partes da relação cambial a exata correspondência entre o teor do título e o direito que ele representa. Por um lado, o credor pode exigir tudo o que está expresso na cártula, não devendo se contentar com menos. Por outro, o devedor também tem o direito de só pagar o que está expresso no título, não admitindo que lhe seja exigido nada mais. (CRUZ, 2014)

- **autonomia:** o título de crédito configura



documento constitutivo de direito novo, autônomo, originário e desvinculado da relação que lhe deu origem. Assim, as relações jurídicas representadas num título de crédito são autônomas e independentes entre si, razão pela qual o vício que atinge uma delas não contamina a(s) outra(s). Melhor dizendo: o legítimo portador do título pode exercer seu direito de crédito sem depender das demais relações que o antecederam, estando imune aos vícios ou defeitos que eventualmente as acometeram. Assim, como bem ensinou o próprio Cesare Vivante, o direito representado num título de crédito é autônomo porque a sua posse legítima caracteriza a existência de um direito próprio, não limitado nem destrutível por relações anteriores. (CRUZ, 2014)

Então, se houve a venda de algo para alguém e o pagamento foi em emissão de título de crédito, por exemplo, uma nota promissória, e, em seguida, houve a transmissão dessa nota promissória a outra pessoa, que, por sua vez, efetuou nova transferência a terceiro, quando chegar ao vencimento, o portador legítimo dessa nota promissória (credor) poderá procurar o emitente (subscritor/devedor) para pagamento e este não poderá alegar que houve imprestabilidade da venda que originou a emissão do título como defesa para não efetuar o pagamento, justamente porque o título de crédito é autônomo. Em outras palavras, eventuais vícios ocorridos nas relações que deram origem ao título e suas transmissões não atingem o título em si, porque o título representa uma obrigação autônoma, um direito autônomo.

Daí decorre a inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé. Isso significa que eventuais exceções/defesas que o devedor do título tiver contra o credor originário não são oponíveis ao terceiro que recebeu o título por endosso e que tem expectativa legítima de recebimento do valor. No exemplo dado, o terceiro de boa-fé é o portador do título.

Esse é o princípio mais importante do regime cambial, pois sem a autonomia do título de crédito haveria perda da segurança da transação e dificilmente as pessoas aceitariam negociar com títulos de crédito.

4. Classificação dos títulos de crédito

Existem quatro critérios para classificação dos títulos de crédito:

- quanto ao modelo;
- quanto à estrutura;
- quanto às hipóteses de emissão;
- quanto à circulação.

4.1. Quanto ao modelo

Os títulos de crédito podem ser:

- **títulos de crédito de modelo livre:** a forma não precisa respeitar modelos previamente estabelecidos. Devem ser observados requisitos, mas não devem seguir um modelo predeterminado. Ex.: letra de câmbio e nota promissória;
- **títulos de crédito de modelo vinculado:** é aquele que necessita preencher, além dos requisitos formais, requisitos de padronização específicos para produzirem os efeitos legais. Ex.: cheque e duplicata.

4.2. Quanto à estrutura

Os títulos de crédito podem ser:



- **títulos de ordem de pagamento:** a exemplo do cheque e da letra de câmbio. O saque, que é o ato de criação do título, dá origem a três situações jurídicas:
 - quem dá a ordem, que é o sacador;
 - quem recebe a ordem, que é o beneficiário/tomador;
 - quem terá de pagar, que é o sacado.

O sacador manda o sacado pagar ao tomador, por isso que é uma ordem de pagamento. O sacador não diz que vai pagar, o sacador manda alguém pagar.

No caso do cheque, o sacado é um banco, que não participa diretamente da relação cambial. A duplicata também é uma ordem de pagamento, mas geralmente o sacador manda o sacado pagar a ele mesmo.

Na ordem de pagamento, normalmente, existe um ato cambiário específico que é o **aceite**, pois, como o sacador manda o sacado pagar ao tomador, o sacado, em regra, precisa praticar um ato para assumir aquela obrigação cambial, esse ato é o aceite. Obs.: o cheque não comporta aceite em virtude de suas peculiaridades (e a própria lei é expressa nesse sentido).

Na letra de câmbio, o aceite é facultativo, o sacado não é obrigado a aceitar a letra, ele pode recusar o aceite. Nesse caso, opera-se o vencimento antecipado da letra de câmbio e o tomador pode cobrar o título diretamente do sacador.

Na duplicata, o aceite é obrigatório, embora não seja irrecusável. A recusa deverá ser fundamentada em uma das hipóteses legais. Além disso, em certas situações, quando não há recusa fundamentada, a duplicata poderá ser cobrada mesmo sem aceite, pois há uma espécie de aceite presumido (que será analisado oportunamente quando do estudo da duplicata).

- **títulos de promessa de pagamento:** a exemplo da nota promissória. O sacador não manda alguém pagar, ele diz que vai pagar. Não existe a terceira figura do sacado. O saque dá origem a duas situações jurídicas:
 - quem promete pagar;
 - quem recebe, que é o beneficiário.

4.3. Quanto às hipóteses de emissão

Os títulos de crédito podem ser:

- **títulos causais:** a lei estabelece a necessidade de ocorrer determinada situação para que aquele título de crédito seja emitido. Ex.: duplicata mercantil pressupõe uma venda mercantil para que seja emitida. Emissão de duplicata falsa é crime;
- **títulos abstratos ou não causais:** não se exige uma causa específica predeterminada em lei para sua emissão. Ex: o cheque.

4.4. Quanto à circulação

Os títulos de crédito podem ser:

- **título de crédito ao portador:** é aquele em que o credor não é identificado, bastando que detenha (porte) o título. Haverá a transmissão do crédito pela simples tradição. Quem estiver com o título em mãos poderá cobrá-lo, ainda que seu nome não figure em local algum do título.
- **títulos nominativos:** CC, Art. 921: “É título nominativo o emitido em favor de pessoa cujo nome conste no registro do emitente”. Transfere-se o título nominativo mediante termo, em registro do emitente, assinado pelo proprietário e pelo adquirente (art. 922 do CC).
- **título de crédito nominal:** é aquele em que há a identificação expressa de seu titular e exige um ato formal para a transferência da titularidade do crédito. Esses títulos poderão se subclassificados em:



- **à ordem:** circulam mediante endosso, acompanhado da tradição da cártula. Lembrando que o endosso (translativo) é o ato que transfere a titularidade do crédito;
- **não à ordem:** circulam mediante cessão civil de crédito, em relação à qual não se aplicam o princípio cambial da autonomia e a consequente inoponibilidade de exceções pessoais contra terceiros de boa fé.

Cuidado! Pega clássico de prova é dizer que os títulos de crédito não à ordem não admitem circulação. Errado! Podem circular, mas não dentro do regime cambial (por endosso), apenas no âmbito civil, por cessão de crédito.

Exemplo: Existe uma nota promissória nominal à André, que entrega a nota promissória à João. João tem o título, mas o crédito está em nome de André. Não basta a mera entrega do documento à João, é preciso que André pratique um ato que transfira o crédito mencionado no documento. Se for um **título nominal à ordem**, esse ato será o **endosso**, André endossará o título para João, esse endosso transferirá o crédito para João. Se for um **título nominal não à ordem** o ato será uma **cessão civil**.

Os títulos de crédito são títulos nominais à ordem por natureza.

Embora o Código Civil considere não escrita a cláusula proibitiva do endosso, leis especiais a admitem. Em tais casos, será possível a transformação de um título de crédito nominal à ordem em um título de crédito nominal não à ordem. Exemplo: o cheque. Uma vez riscada a expressão “ou à sua ordem” ou, o que é preferível, após riscar a palavra “ou” e acrescentar em seu lugar a palavra “não”, haverá a transformação, passando-se a admitir a transferência do título apenas por cessão de crédito.

Enquanto o **endosso é ato unilateral** que deve ser feito no próprio título, em obediência ao princípio da literalidade, a cessão civil de crédito é negócio bilateral formalizado, via de regra, por meio de contrato, ou seja, instrumento à parte.

Ademais, na prática, o endosso acarreta a **responsabilização do endossante** (embora a regra geral constante do Código Civil, aplicável aos títulos inominados e aos em que há lacuna na legislação de regência, seja no sentido contrário: “Art. 914. Ressalvada cláusula expressa em contrário, constante do endosso, não responde o endossante pelo cumprimento da prestação constante do título”), o qual passa a ser codevedor da dívida representada no título. Na cessão civil de crédito, por sua vez, a regra é a de que o cedente não assume responsabilidade pelo adimplemento da obrigação que cedeu, respondendo tão somente pela existência do crédito cedido.

Em outras palavras, na cessão de crédito, o cedente não se torna codevedor da obrigação que cedeu, apenas responde pela existência do crédito.

Por fim, outra diferença relevante entre endosso e a cessão civil de crédito está relacionada à **inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé** (art. 17 da LUG e arts. 915 e 916 do Código Civil).

Em decorrência do princípio da autonomia, o endosso transfere o crédito sem nenhum vício relativo aos negócios subjacentes à emissão do título. Assim, o devedor não poderá opor ao endossatário – se este recebeu o título de boa-fé, o que em princípio se presume – exceções que não digam respeito a este, ou seja, exceções relacionadas a relações antecedentes. Na cessão civil de crédito, no entanto, isso não ocorre: o devedor pode opor contra o cessionário qualquer exceção pessoal que tinha contra o cedente (nesse sentido é a regra do art. 294 do Código Civil).

5. Endosso

Há de se tomar cuidado com o assunto, porque existe uma lei, fruto de um tratado internacional, chamada de Lei Uniforme de Genebra (LUG), que há muitas décadas serve de referência informal como uma espécie de “Lei Geral sobre títulos de crédito no Brasil” e, apesar



de regular especificamente as notas promissórias e as letras de câmbio, traz regras sobre aval, endosso, pagamento, protesto, vencimento, etc., consideradas pela doutrina como padrão para fins de ensino e que nortearam boa parte dos títulos de crédito mais importantes.

O problema é que o Código Civil de 2002, ao tratar sobre títulos de crédito (artigos 887 a 926), trouxe regras que vão de encontro às regras da LUG, com importantes divergências, como veremos abaixo.

O entendimento que prevaleceu foi o seguinte: as disposições do Código Civil, em princípio, não se aplicam aos títulos de crédito nominados/típicos que possuem legislação especial. É o caso da duplicata, da letra de câmbio, da nota promissória e do cheque, para citar apenas os principais.

O Código Civil funciona, pois, na parte relativa aos títulos de crédito, como um regramento geral para os chamados **títulos atípicos/inominados**, isto é, que não possuem lei específica. Quanto aos títulos típicos/nominados, o Código Civil somente se aplica quando há lacuna ou omissão na legislação específica. Confira-se:

Enunciado 464 das Jornadas de Direito Civil: “As disposições relativas aos títulos de crédito do Código Civil aplicam-se àqueles regulados por leis especiais no caso de omissão ou lacuna”.

Enunciado 39 da I Jornada de Direito Comercial: “Não se aplica a vedação do art. 897, parágrafo único, do Código Civil, aos títulos de crédito regulados por lei especial, nos termos do seu art. 903, sendo, portanto, admitido o aval parcial nos títulos de crédito regulados em lei especial”.

Tanto a letra de câmbio quanto a nota promissória são reguladas pela Lei Uniforme de Genebra – LUG. Nos próximos tópicos, trataremos sobre os principais atos cambiais fazendo referência tanto à LUG quanto ao Código Civil, o que servirá de estudo geral sobre esses atos e também de estudo específico sobre o funcionamento das letras de câmbio e de notas promissórias. Além disso, alguns pontos de distinção entre tais títulos e o cheque serão tratados no tópico específico sobre cheques. Por essa razão, a letra de câmbio e a nota promissória não contarão com tópico próprio extenso, pois serão analisados juntamente com a exposição geral dos demais temas.

5.1. Endosso

O endosso é o ato cambiário que opera **transferência do crédito que está representado por um título à ordem. Caso seja um título não à ordem, poderá haver apenas cessão de crédito.**

Apesar de os títulos de crédito típicos/nominados serem essencialmente títulos nominais à ordem, portanto transmissíveis via endosso, é possível a inserção da cláusula não à ordem na maioria deles, caso em que o título poderá circular somente pela via da cessão civil (art. 11 da LUG e art. 17, § 1º, da Lei do Cheque).

IMPORTANTE: O art. 890 do CC determina que sejam consideradas não escritas no título, entre outras cláusulas, a cláusula proibitiva de endosso! Essa é uma das diferenças importantes entre a norma geral do CC e o previsto no art. 11 da LUG e no art. 17, § 1º, da Lei do Cheque, que expressamente admitem a cláusula não à ordem (obs: duplicata não admite cláusula não à ordem)

Nos títulos de crédito típicos/nominados, o endosso produz **dois efeitos**: (i) transferência da titularidade do crédito (ex: art. 14 da LUG) e (ii) em regra, responsabilização do endossante, o qual se torna codevedor (devedor indireto) do título (ex: art. 15 da LUG; art. 21 da Lei do Cheque e art. 15, § 1º, da Lei das Duplicatas), admitindo alguns títulos a possibilidade de se registrar expressamente a ausência de responsabilidade do endossante.



IMPORTANTE: o art. 914 do Código Civil prevê o contrário do que prevê o art. 15 da LUG “ressalvada cláusula expressa em contrário, constante do endosso, não responde o endossante pelo cumprimento da prestação constante do título”, mas essa regra do Código Civil, assim como a do aval parcial (art. 897, parágrafo único), aplica-se aos títulos atípicos/inominados.

O **endosso deve ser feito no verso do título**, mediante simples assinatura do endossante. Se o endosso for feito no anverso da cártula, deverá conter, além da assinatura do endossante, menção expressa de que se trata de endosso, para fins de diferenciá-lo de um aval (art. 13 da LUG e art. 910, § 1º do Código Civil).

É **vedado o endosso parcial** ou limitado a certo valor da dívida representada no título, o qual é considerado nulo. Veda-se também o endosso subordinado a alguma condição, a qual será considerada não escrita (art. 12 da LUG, art. 18 da Lei do Cheque e art. 912 do Código Civil).

Ademais, não há limite quanto ao número de endossos, inclusive quanto ao cheque, uma vez que foi revogada a legislação tributária aplicável à CPMF, que admitia apenas um único endosso nesse título de crédito.

5.1.1. Endosso em branco/geral

O endosso poderá ser feito em branco ou em preto (art. 13 da LUG, art. 19, § 1º, da Lei do Cheque e art. 913 do Código Civil). O **endosso em branco/geral** é aquele que não identifica o seu beneficiário (endossatário). Em tal caso, o endossante assina sem identificar a quem está endossando, permitindo que o título circule ao portador, pela mera tradição da cártula, de modo que o portador final do título poderá cobrar o crédito independentemente do fato de seu nome não constar da cadeia cambial.

Ex: alguém emite um título nominal a André, que, por sua vez, endossa a nota promissória a terceiro. Esse endosso, se for em branco, não diz para quem está sendo endossado. André apenas escreve “por endosso e assina”. O título foi transformado em um título ao portador, qualquer pessoa que estiver na posse desse título será a portadora do crédito. Assim, a pessoa que o recebeu, se quiser repassar o título, não precisará fazer novo endosso.

Conforme preceitua o art. 913 do CC: “O endossatário de endosso em branco pode mudá-lo para endosso em preto, completando-o com o seu nome ou de terceiro; pode endossar novamente o título, em branco ou em preto; ou pode transferi-lo sem novo endosso”.

5.1.2. Endosso em preto/especial

O **endosso em preto/especial**, por sua vez, é aquele que identifica expressamente o endossatário. Em tal caso, somente poderá circular novamente por meio de novo endosso, que, a seu turno, poderá ser em branco ou novamente em preto. O título continuará sendo nominal até que sobrevenha algum endosso em branco.

5.1.3. Endosso translativo/próprio

O endosso que foi trabalhado até aqui, “endosso normal”, é chamado de **endosso translativo ou próprio, que transmite a titularidade do crédito**.

5.1.4. Endosso impróprio

O **endosso impróprio** traduz a prática de certo ato no título que não produz os efeitos normais de um endosso, de transmissão da titularidade do crédito pura e simples. Será feito com outros objetivos. Esse ato apenas legitima a posse de alguém sobre um título. Existem três espécies: o endosso-mandato, o endosso-caução/penhor/pignoratício e o endosso-fiduciário.



a) Endosso-mandato/procuração

O **endosso-mandato/endosso-procuração**, está previsto, por exemplo, no art. 18 da LUG, no art. 26 da Lei do Cheque e no art. 917 do Código Civil. Aqui, o endossante confere poderes ao endossatário para agir como seu legítimo representante, podendo cobrar o crédito, protestá-lo, executá-lo etc. Para tanto, deve qualificar o endosso, no título, como “para cobrança”, “por mandato” ou “por procuração”, para diferenciá-lo do endosso translativo (sem qualificação especial).

Ex: empresário que recebe muitos pagamentos por meio de título de crédito, contrata uma instituição financeira para que verifique a adimplência, efetuando cobranças, protestando etc. Não há transferência do título à instituição financeira, mas transformação da instituição financeira em mandatária/representante para que ela possa exercer os direitos de crédito em nome do empresário.

IMPORTANTE: o STJ entende que os bancos, como mandatários decorrentes de endosso-mandato, só respondem por eventuais danos causados ao devedor do título se for comprovada a sua atuação culposa, extrapolando os poderes de mandatário (Súmula 476 do STJ: “O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário”).

Esmiuçando: nos casos em que um título é transferido a uma instituição financeira por meio de endosso-mandato, quando não há pagamento do título, o banco o encaminha para protesto. Às vezes o protesto é considerado indevido, então, a parte protestada ingressava com ação judicial tanto contra o credor quanto contra o banco, porque foi o banco que apresentou o título a protesto. Os bancos diziam não ter legitimidade para estar no polo passivo da ação, por serem meros mandatários/representantes. Nesse contexto é que adveio o entendimento do STJ.

Por outro lado, a Súmula 475 do STJ estabelece que “responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas”.

b) Endosso-caução/penhor/pignoratício

O **endosso-caução/penhor/pignoratício** está previsto, por exemplo, no art. 19 da LUG e no art. 918 do Código Civil, e tem por objetivo transferir o título como forma de garantia de uma dívida contraída perante o endossatário. Para tanto, deve qualificar o endosso, no título, como “em garantia”, “por penhor”, para diferenciá-lo do endosso translativo (sem qualificação especial).

Conforme esclarece André Santa Cruz,

Havendo o endosso-caução, o endossatário não assume a titularidade do crédito, ficando o título em sua posse apenas como forma de garantia da dívida que o endossante contraiu perante ele. Caso o endossante pague a dívida contraída, resgata o título; caso, todavia, a dívida não seja honrada, o endossatário poderá executar a garantia e passar, então, a possuir a titularidade plena do crédito. (CRUZ, 2014)

c) Endosso-fiduciário

A Lei nº 4.728/65, em seu art. 66-B, § 3º, admite a alienação fiduciária em garantia de títulos de crédito. Referida “alienação fiduciária” se efetiva mediante a aposição do endosso-fiduciário no título, acrescentando-se a expressão “por fidúcia” ou “em alienação fiduciária”.



Opera-se de modo semelhante a outras alienações-fiduciárias em garantia. Ao término da quitação da dívida garantida, a titularidade retorna ao endossatário-fiduciante.

d) Endosso póstumo/tardio

O art. 920 do Código Civil e o art. 20 da LUG, por exemplo, admitem que o endosso seja dado após o vencimento do título, hipótese em que decorrerão normalmente seus efeitos de transferência do crédito e de responsabilização do endossante. Contudo, o art. 20 da LUG prevê ainda que “(...) o endosso posterior ao protesto por falta de pagamento, ou feito depois de expirado o prazo fixado para se fazer o protesto, produz apenas os efeitos de uma cessão ordinária de créditos.” O art. 27 da Lei do Cheque traz previsão semelhante para os endossos realizados após o protesto ou após a expiração do prazo de apresentação do cheque.

Tal endosso realizado após o protesto ou após o prazo para a realização do protesto é denominado pela doutrina de **endosso póstumo ou tardio**. Em tal caso, não produz os efeitos normais de um endosso, valendo tão somente como uma mera cessão civil de crédito.

Por fim, o art. 20 da LUG estabelece a presunção de que o endosso sem data foi feito antes do prazo para a realização do protesto. No mesmo sentido é a parte final do art. 27 da Lei do Cheque.

A diferença entre a cessão civil de crédito e o endosso são basicamente duas:

- o cedente, que é quem cedeu o crédito, responde **apenas pela existência do crédito**, mas não pela solvência do devedor. Via de regra (ao menos nos títulos típicos), **o endossante responde pela existência do crédito e pela solvência do devedor**;
- o devedor, quando há uma cessão civil, sendo **executado pelo cessionário, poderá arguir matérias relacionadas a sua relação jurídica com o cedente**. Em outras palavras, poderá o devedor alegar, contra o cessionário, matérias de natureza pessoal que possuir contra o cedente (art. 294 do CC). No caso do endosso, vigora a inoponibilidade das exceções pessoais em face de terceiro de boa-fé, em decorrência do princípio da autonomia e do subprincípio da abstração.

Há alguns **endossos que produzem efeitos de cessão civil de crédito**, não respondendo, por exemplo, pela solvência do devedor, **sendo possível eventualmente levantar exceções pessoais**:

- **quando o endosso é praticado após o protesto por falta de pagamento**. Isto é, já houve o protesto por falta de pagamento, mas foi feito o endosso, garante-se apenas a existência do crédito, mas não a solvência;
- **o endosso de títulos com cláusula não à ordem**. Lembrando que para ser cláusula não à ordem deverá ter cláusula expressa e haver disciplina sobre o tema na legislação especial, pois o CC (norma geral) determina que seja considerada não escrita a cláusula não à ordem. Caso tenha essa cláusula não à ordem, eventual endosso produzirá efeitos de cessão civil de crédito.

6. Aval

É o ato cambiário pelo qual um terceiro (o avalista) garante o pagamento da obrigação constante do título. Está regulado pelos arts. 30 da LUG e 897 do Código Civil, além de em disposições específicas nas leis de regência dos demais títulos típicos. O avalista equipara-se a seu avalizado no que diz respeito à posição deste na cadeia cambial.

Ao contrário do endosso, o aval é dado no **anverso do título**, mediante **simples assinatura** do avalista. Caso feito no verso da cártula, além da assinatura, será necessária expressa menção de que se trata de aval (art. 31 da LUG e art. 898, § 1º do Código Civil).

6.1. Aval em branco e em preto

Assim como no endosso, admite-se o aval **em branco** (sem especificação do avalizado) e o **em preto** (com indicação do avalizado). Quando o aval é em branco, no caso da letra de câmbio, presume-se em favor do sacador (art. 31, parte final, da LUG); nos demais títulos, em favor do emitente ou subscritor (art. 77, parte final, da LUG e art. 899 do Código Civil).

6.2. Avais simultâneos x avais sucessivos

No **aval simultâneo**, ou coaval, duas pessoas avalizam o mesmo indivíduo, passando ambos a se equiparar a uma mesma pessoa da cadeia cambial. Assim, são responsáveis solidariamente pela obrigação garantida. Eventual credor poderá optar por direcionar a execução contra ambos ou contra apenas um deles, caso em que este apenas poderá cobrar regressivamente do outro avalista a parte deste (em caso de omissão, presume-se 50%). Obs: qualquer dos dois poderá ajuizar ação regressiva integral contra o avalizado ou devedor final do título, ou mesmo contra os demais integrantes da cadeia cambial por endosso (nos casos em que os endossantes forem coobrigados e o devedor final não pagar a dívida).

Já o **aval sucessivo/aval de aval** caracteriza-se pelo fato de um avalista avalizar outro avalista. Em tal caso, o último avalista não poderá ser acionado regressivamente pelo primeiro avalista (seu avalizado), mas poderá exigir deste em regresso o valor integral que houver pagado.

Como um aval em branco presume-se dado em favor do devedor principal ou do emitente do título, conforme o caso, se houver dois ou mais avais em branco, serão considerados dados em prol de uma mesma pessoa (devedor principal ou emitente), ou seja, serão considerados simultâneos. Por essa razão, preceitua a Súmula 189 do STF (cobrada em provas) que “Avais em branco e superpostos consideram-se simultâneos e não sucessivos”. Logo, aval sucessivo deve ser sempre em preto (também cobrado em provas).

Fábio Ulhoa, por sua vez, afirma que o **avalista se insere na posição imediatamente posterior ao avalizado**, uma vez que terá direito de regresso contra este.

6.3. Aval x fiança

O instituto da fiança é semelhante ao aval, pois ambos são garantias pessoais, mas há diferenças relevantes entre eles, que também são cobradas em prova.

O aval constitui uma **obrigação autônoma** em relação à dívida assumida pelo avalizado. Logo, se a obrigação do avalizado estiver contaminada por algum vício (salvo vício de forma), este não se transmite para a obrigação do avalista (art. 32 da LUG e art. 899, § 2º do Código Civil). Como a fiança é uma obrigação acessória, isso não ocorre, pois seguirá a sorte da obrigação principal a que está relacionada.

Já caiu em prova: “O cheque foi emitido e avalizado por alguém. Após, descobriu-se que a assinatura do emitente do cheque era falsa. Ainda assim, o aval permanece válido” — correto. A obrigação do avalista é autônoma.

Ademais, o aval não admite o **benefício de ordem**, razão pela qual o avalista pode ser acionado juntamente com o avalizado, tendo, pois, **responsabilidade solidária** (art. 32 da LUG e art. 899 do Código Civil).

Já na fiança, o benefício de ordem assegura ao fiador que apenas seja acionado após tentativa de execução contra o afiançado. A responsabilidade do fiador é, portanto, subsidiária (art. 827 do Código Civil).



6.4. Necessidade de outorga conjugal

O art. 1.647, III, do Código Civil tratou de forma equivalente o aval e a fiança, no que diz respeito à **necessidade de outorga conjugal** para que tais garantias sejam prestadas por **pessoa casada**, ressalvando apenas a hipótese de os cônjuges serem casados no regime de bens da **separação absoluta**, hipótese em que a outorga conjugal seria dispensada.

Sobre o tema, o STJ decidiu que se refere apenas ao regime da separação **convencional** de bens, mas não ao da separação obrigatória de bens (em que a lei impõe esse regime aos cônjuges). Desse modo, se os cônjuges forem casados no regime de separação convencional, um deles pode prestar aval sem outorga do outro. Se forem casados no regime da separação obrigatória, será necessária a autorização. Confira-se o que restou noticiado no Informativo 420 do STJ:

Segundo a exegese do art. 1.647, III, do CC/2002, é necessária a vênua conjugal para a prestação de aval por pessoa casada sob o regime da separação obrigatória de bens. Essa exigência de outorga conjugal para os negócios jurídicos de (presumidamente) maior expressão econômica, tal como a prestação de aval ou a alienação de imóveis, decorre da necessidade de garantir a ambos os cônjuges um meio de controlar a gestão patrimonial; pois, na eventual dissolução do vínculo matrimonial, os consortes podem ter interesse na partilha dos bens adquiridos onerosamente na constância do casamento. Anote-se que, na separação convencional de bens, há implícita outorga prévia entre os cônjuges para livremente dispor de seus bens, o que não se verifica na separação obrigatória, regime patrimonial decorrente de expressa imposição do legislador. Assim, ao excepcionar a necessidade de autorização conjugal para o aval, o art. 1.647 do CC/2002, mediante a expressão "separação absoluta", refere-se exclusivamente ao regime de separação convencional de bens e não ao da separação legal. A Súm. n. 377-STF afirma haver interesse dos consortes pelos bens adquiridos onerosamente ao longo do casamento sob o regime de separação legal, suficiente razão a garantir-lhes o mecanismo de controle de outorga uxória ou marital para os negócios jurídicos previstos no art. 1.647 do CC/2002. Com esse entendimento, a Turma, ao prosseguir o julgamento, deu provimento ao especial para declarar a nulidade do aval prestado pelo marido sem autorização da esposa, ora recorrente. (REsp 1.163.074-PB)

Por fim, registre-se que o STJ também já decidiu que **a regra do art. 1.647, III do Código Civil apenas se aplica aos títulos de crédito atípicos/inominados**, de modo que em títulos de crédito típicos/nominados – letra de câmbio, nota promissória, cheque, duplicata etc. – é possível que pessoa casada preste aval sem necessidade de outorga conjugal (REsp 1633399/SP), devendo-se proteger apenas a meação do cônjuge em relação a eventuais bens comuns, caso sejam casados em regime que os comporte.

7. Exigibilidade do crédito cambiário

Os devedores do título de crédito poderão ser classificados como **devedor principal e coobrigados**.

Para se tornar exigível o crédito cambiário em face do devedor principal, **basta que o título vença e o credor cobre do devedor principal**.

Porém, **com relação aos coobrigados, também é necessária a negativa de pagamento pelo devedor principal**. Isto é, se o devedor principal não paga, aí poderá cobrar dos coobrigados. Para comprovar que o devedor principal não quis pagar, **basta que se faça o protesto do título**. Essa é a importância de o protesto do título ser uma **condição de exigibilidade** do crédito em face do coobrigado.



Da mesma forma, **o protesto também será condição de exigibilidade no caso da recusa do aceite**. Isso porque, nesse caso, protesta-se o título por falta de aceite, sendo a forma pela qual se comprova que o devedor, ou que o sacado, não quis aceitar o título, devendo se voltar contra o sacador.

Os coobrigados não estão vinculados ao pagamento do título se ele não foi protestado, ou, caso tenha sido protestado, **tenha sido feito fora do prazo legal**.

Pagando o coobrigado o valor do título, terá ele direito de regresso contra o devedor principal e contra os coobrigados anteriores a ele nos títulos que assim possibilitarem (maioria dos títulos típicos), lembrando que a regra constante do art. 914 do Código Civil para os títulos de crédito nominados é a de que “ressalvada cláusula expressa em contrário, constante do endosso, não responde o endossante pelo cumprimento da prestação constante do título”.

Para se identificarem os coobrigados, **basta que se compreenda que o sacador é anterior aos endossantes. O sacador é o primeiro que responde se o devedor principal não pagar**. Os endossantes são dispostos em cadeias, as quais observarão o critério cronológico.

8. Protesto

Outro instituto cambiário importante é o protesto, “que pode ser definido como o ato formal pelo qual se atesta um fato relevante para a relação cambial. Esse fato relevante pode ser (i) a falta de aceite do título, (ii) a falta de devolução do título ou (iii) a falta de pagamento do título” (CRUZ, 2014).

Segundo o **art. 1º da Lei nº 9.492/1997**, “protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida”.

No que toca estritamente à relação cambiária, o protesto, em regra, ao contrário do que muitos pensam, só é indispensável se o credor deseja executar os codevedores (ou devedores indiretos), como é o caso, por exemplo, do endossante. Daí porque ser comum a afirmativa genérica de que o protesto garante o direito de regresso em face dos devedores indiretos do título. Em contrapartida, se a execução é dirigida contra o devedor principal (ou devedor direto) do título, o protesto é desnecessário. De acordo com o art. 202, III do Código Civil, o protesto cambial interrompe a prescrição, desde que feito no prazo e na forma da lei. Essa regra do atual Código Civil acabou por superar entendimento cristalizado na Súmula 153/STF, de seguinte teor: “*o simples protesto cambiário não interrompe a prescrição*”. Portanto, antes do Código Civil de 2002, o protesto cambial não interrompia a prescrição, por força do disposto na Súmula 153/STF. Após a entrada em vigor do Código Civil, porém, o protesto cambial interrompe a prescrição, por força de regra legal expressa (art. 202, III). (CRUZ, 2014)

No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ (REsp 694.766/RS).

IMPORTANTE: em caso de protesto legitimamente realizado e pagamento posterior do título pelo devedor, cabe a este, não ao credor, proceder à respectiva baixa em cartório. Esse é também o entendimento do STJ, consolidado no REsp 1.339.436/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos:

para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil, no regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto.

Não confundir essa hipótese com a da exclusão da inscrição do devedor nos cadastros de inadimplentes, que compete ao credor, no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito, nos termos da S. 548 do STJ.



9. Letra de Câmbio

Sua regência se dá com base na Lei Uniforme de Genebra (LUG) ou Lei Uniforme sobre Letras de Câmbio e Notas Promissórias. Além das normas da LUG já citadas nos tópicos anteriores, merecem destaque também os temas a seguir analisados.

9.1. Saque

A constituição do crédito cambiário se dá por meio do saque, **que é o ato de criação do título.**

A letra de câmbio é uma ordem de pagamento. Isso significa que do saque surgem três situações **jurídicas distintas:**

- quem dá a ordem, que é o sacador;
- a quem a ordem é dirigida, que é o sacado;
- quem é o beneficiário da ordem, que é o tomador.

O saque produz ainda o efeito de vincular o sacador ao pagamento da letra de câmbio, em caso de ausência de aceite ou inadimplemento pelo sacado.

Ao criar a letra de câmbio, **por meio do saque, o sacador se torna codevedor do título.**

A lei faculta que uma mesma pessoa ocupe mais de uma posição. Por exemplo, o **sacador poderá ser o tomador.** Ou seja, ele poderá ser eventualmente o responsável pelo pagamento e ser o beneficiário da letra de câmbio.

São **requisitos da letra de câmbio (arts. 1º e 2º da LUG):**

- deve ter a expressão **“letra de câmbio”** constante no próprio título;
- deve conter uma **ordem pura e simples de pagamento de quantia específica**, não podendo haver menções condicionais (deve ser uma ordem incondicional);
- deve conter o **nome do sacado**: quem vai pagar o crédito;
- deve conter o **lugar do pagamento**: não havendo, deve haver menção ao lugar ao lado do nome do sacado, visto que será considerado que nesse lugar ocorrerá o pagamento;
- deve conter o **nome do tomador/beneficiário**: não se admite letra de câmbio ao portador;
- deve conter o **local do saque ou a menção de um local junto ao nome do sacador**
- deve conter a **data do saque**;
- deve conter **assinatura do sacador**.

A época do vencimento deve constar da letra, para fins de definição data do pagamento.

Caso **não conste** a data do vencimento, a lei considera que a **letra de câmbio é à vista.**

IMPORTANTE: Pega clássico de prova: Esses requisitos não são exigidos na época da emissão do título, devendo estar presentes na época do pagamento, pois **admite-se a emissão de títulos de crédito em branco ou incompletos** (S. 387 do STF e art. 891 do CC).

9.2. Aceite

Feito o saque, o beneficiário buscará o **sacado** para verificar se ele aceitará o título.

O sacado de uma letra de câmbio, antes de aceitar, não tem qualquer obrigação cambial pelo fato de o sacador ter endereçado a ele a ordem.

O sacado só fica vinculado àquele título se ele concordar. O ato cambial pelo qual concorda com a letra de câmbio é denominado aceite.

Com o **aceite, o sacado passa a ser o devedor principal daquele título.**

O aceite decorre da simples assinatura do sacado, lançado no anverso do título. Caso seja **assinado no verso do título**, deverá mencionar a expressão **“aceito”** ou **“estou aceitando”**.



Em caso de **recusa do aceite**, a qual é lícita na letra de câmbio (neste título, o aceite é facultativo, embora irretratável), haverá consequências previstas em lei, sendo a principal delas o **vencimento antecipado da dívida**. No caso da recusa do aceite, o tomador/beneficiário poderá cobrar imediatamente do sacador o valor do título.

No caso de **recusa parcial**, o **aceite poderá ser parcial**, que admite duas espécies: limitativo ou modificativo.

No **aceite limitativo**, o sacado não concorda com o valor contido na letra. Ex.: o indivíduo aceita pagar R\$ 50,00 em vez de R\$ 100,00. Em tal caso, haverá vencimento antecipado parcial do título, em relação à parcela não aceita.

No **aceite modificativo**, a recusa diz respeito a alguma condição de pagamento do título, mas não ao valor. Ex.: sujeito apresenta o título para o sacado pagar em 30 dias. Ele diz que não tem condições de pagar em 30 dias, mas que concorda em pagar em 60 dias., hipótese em que também **haverá o vencimento antecipado do título**.

Para evitar que a recusa do aceite tenha o vencimento antecipado, **o sacador poderá lançar no título a chamada cláusula não aceitável**. Com esta cláusula, o credor só poderá apresentar o título ao sacado no dia do vencimento do título. Por conta disso, caso o sacado recuse, não haverá maiores consequências contra o sacador.

Apresentado o título ao sacado, poderá ele se valer do **prazo de respiro**. Isto é, terá o direito de pedir para que o título seja reapresentado **no dia seguinte**.

9.3 Vencimento e Pagamento

Em resumo, a letra de câmbio pode ser:

- **à vista**: título à vista é aquele que pode ser exigível de imediato;
- **com data certa**: título com data certa é aquele em que a data é definida, marcada.
- **a certo termo de vista**: neste caso, o título vence a um número “X” de dias da vista, ou seja, do aceite (ex.: a 90 dias da data em que foi dado o aceite). Para André Santa Cruz Ramos, a **cláusula não-aceitável** (que afasta o vencimento antecipado quando não há aceite pelo sacado) não é admitida nas letras de câmbio a certo termo de vista, já que o prazo do vencimento se inicia a partir do aceite;
- **a certo termo de data**: neste caso, o título vence a um número “X” de dias da data, ou seja, da emissão (ex.: a 90 dias da emissão).

A identificação do momento do vencimento do título é importante, entre outros fatores, para a contagem dos juros moratórios, cujo termo inicial se dá a partir do vencimento do título.

A inobservância desses prazos tem consequências: **o credor perde o direito de cobrança contra os coobrigados do título**.

A letra de câmbio não aceita poderá ser protestada, mas não será por falta de pagamento, **e sim por falta de aceite**. Nesse caso, **o protestado será o sacador**, pois o sacado não se vinculou àquele título.

Não se pode confundir o prazo de vencimento com o prazo de apresentação para fins de aceite. Na letra à vista, não há necessidade de o tomador levar o título para aceite primeiramente, cabendo-lhe a faculdade de apresentar a letra de câmbio diretamente para pagamento, dentro do prazo de um ano a partir de sua emissão.

Já na letra a certo termo da vista, o tomador precisa apresentá-la ao sacado para aceite no prazo estabelecido no título ou, em caso de ausência de especificação de prazo, dentro de um ano, contado da emissão da letra de câmbio (art. 23 da LUG).

Uma vez paga a letra de câmbio, em razão do princípio da literalidade, **a quitação deve se dar no próprio título**. Já em virtude do princípio da cartularidade, o devedor que paga a letra de câmbio tem o direito de que lhe seja entregue o título. Quem paga tem que exigir o título de crédito.



Tem-se admitido o **pagamento parcial**, sendo necessário observar o seguinte: Primeiramente, **somente o aceitante poderá optar pelo pagamento parcial**, e neste caso o credor é obrigado a aceitar. Segundo, se o pagamento é parcial, o título permanece com o credor, mas deverá lançar no título a quitação parcial. Os coobrigados e avalistas do aceitante podem ser cobrados pelo saldo não pago.

9.4. Ação cambial

Se o título não for pago no vencimento, o credor poderá executar diretamente o título, visto que todos os títulos de crédito são títulos executivos extrajudiciais (arts. 784, I e XII, do CPC/2015).

Os prazos prescricionais para o ajuizamento da execução da **letra de câmbio** variam a depender de quem ajuíza e de quem está no polo passivo:

- **deverá ser proposta no prazo de 3 anos**, contados do vencimento do título, contra o devedor principal ou contra seu avalista;
- **deverá ser proposta no prazo de 1 ano**, contados do protesto, caso seja execução contra os coobrigados ou contra os avalistas;
- **deverá ser proposta no prazo de 6 meses**, a contar do pagamento, para exercício de direito de regresso.

10. Nota promissória

Em relação à nota promissória, aplicam-se as mesmas regras da letra de câmbio, com algumas diferenças.

A nota promissória é uma promessa de pagamento. Com o saque da nota promissória, surgem duas situações jurídicas: a do que promete pagar (subscritor ou sacador, emitente) e o beneficiário da promessa de pagamento (tomador).

Os **requisitos** da nota promissória são (art. 75 da LUG):

- **do título deverá constar nota promissória;**
- **promessa deverá ser incondicional (não sujeita a condições);**
- **nome do beneficiário da promessa.** Não é possível emitir uma nota promissória ao portador (ao menos em tese);
- **data do saque;**
- **local do saque ou menção a um lugar ao lado do nome do subscritor;**
- **assinatura do subscritor.**

Se a nota promissória não menciona sua data de vencimento, **considera-se que seja à vista.**

Caso não seja observado o prazo prescricional para a cobrança da nota promissória, é possível o ajuizamento de ação de locupletamento ilícito contra o devedor principal, no prazo de 3 anos (art. 206, § 3º, IV, do CC), conforme já decidiu o STJ. Além dessa possibilidade, cabe também o ajuizamento de ação monitória contra o emitente de nota promissória sem força executiva, no prazo de 5 anos contados do dia seguinte ao de vencimento do título, nos termos da Súmula 504 do STJ.

11. Cheque

11.1. Considerações gerais

É um título de crédito regido pela **Lei nº 7.357/87**. Suas características principais são as seguintes:



Título abstrato/não causal: Pode ser emitido em qualquer situação. Não há causa pré-determinada na lei para sua emissão.

Ordem de pagamento: mas não comporta aceite. Sempre emitido contra um Banco. Assim, terá o emitente do cheque (sacador), o banco, que será o sacado (contra quem a ordem é emitida) e o tomador, que poderá ou não ser especificado (mas cuidado: somente poderá ser ao portador se seu valor não for superior a R\$ 100,00). O banco obedecerá à ordem de pagamento em função da existência de fundos disponíveis do emitente do cheque na conta que possui junto ao banco.

Vencimento à vista, considerando-se não escrita qualquer menção em contrário: É o título que vence no momento da apresentação. Em regra, não se admite cheque pré-datado, pois se considera não escrita qualquer menção contrária ao fato de se tratar de ordem de pagamento à vista (art. 32 da Lei do Cheque). Por isso, ainda que o cheque seja “pré-datado”, o banco é obrigado a realizar o pagamento ao apresentante do cheque. Todavia, o apresentante que levar o cheque antes da data nele consignada responderá por danos morais, em virtude da quebra da boa-fé em sua relação com o emitente (S. 370 do STJ).

11.2. Modalidades de cheque

A lei do cheque prevê as seguintes modalidades:

- **Cheque visado:** o banco lança a declaração de suficiência de fundos. Decorre a obrigação do sacado (banco) de reservar na conta do emitente uma quantia equivalente ao valor do cheque durante o prazo de sua apresentação (30 dias se for da mesma praça e de 60 dias se for de praças distintas);
- **Cheque administrativo:** Este cheque administrativo é emitido pelo próprio banco em face do seu estabelecimento, só podendo ser emitido de forma nominal;
- **Cheque cruzado:** tem por finalidade possibilitar a identificação da pessoa em favor de quem será liquidado. Haverá dois traços paralelos na diagonal no anverso do cheque. Dentro desses traços será possível designar um banco, sendo denominado de **cruzamento em preto**. Caso não o faça, haverá um **cruzamento em branco**. O cheque com cruzamento em branco só poderá ser pago a um banco ou a um cliente do sacado, mediante crédito em conta, ou seja, o apresentante não sai com dinheiro do local. Neste caso, haverá identificação do beneficiário. O cheque com cruzamento em preto só pode ser pago ao banco cujo nome consta do cruzamento. Com o crédito em conta também será possível saber quem foi pago;
- **Cheque ser creditado em conta:** terá o mesmo objetivo do cheque cruzado, pois identifica o credor. Não poderá ser pago em dinheiro, devendo ser depositado na conta corrente do favorecido. Acrescenta-se no anverso a expressão “para ser creditado em conta” (como prevê a lei) ou coloca-se entre os traços do cruzamento o número da conta do beneficiário.

11.3. Requisitos legais

Como se sabe, o cheque é um título de modelo vinculado, o qual deverá cumprir os seguintes requisitos legais:

Art. 1º O cheque contém:

- I - a denominação “cheque” inscrita no contexto do título e expressa na língua em que este é redigido;
- II - a ordem incondicional de pagar quantia determinada;
- III - o nome do banco ou da instituição financeira que deve pagar (sacado);
- IV - a indicação do lugar de pagamento;



V - a indicação da data e do lugar de emissão;

VI - a assinatura do emitente (sacador), ou de seu mandatário com poderes especiais.

Parágrafo único - A assinatura do emitente ou a de seu mandatário com poderes especiais pode ser constituída, na forma de legislação específica, por chancela mecânica ou processo equivalente.

Destacando o princípio da formalidade dos títulos de crédito, o art. 2º da Lei do Cheque prevê o seguinte:

Art. 2º O título, a que falte qualquer dos requisitos enumerados no artigo precedente não vale como cheque, salvo nos casos determinados a seguir:

I - na falta de indicação especial, é considerado lugar de pagamento o lugar designado junto ao nome do sacado; se designados vários lugares, o cheque é pagável no primeiro deles; não existindo qualquer indicação, o cheque é pagável no lugar de sua emissão;

II - não indicado o lugar de emissão, considera-se emitido o cheque no lugar indicado junto ao nome do emitente.

O cheque é um modelo **padronizado** fornecido pelo banco. Não é possível que alguém faça um cheque em casa, ainda que tenha todos os requisitos.

O cheque, caso seja de valor não superior a R\$ 100,00, poderá ser dado ao portador. Sendo acima de R\$ 100,00, é necessário que o cheque seja nominal, endereçado a alguém (art. 69 da Lei nº 9069/95), contendo a cláusula à ordem ou não à ordem.

11.4. Endosso no cheque

O cheque observa as **mesmas regras da letra de câmbio** quanto à sua circulação, com algumas diferenças:

- **não admite o chamado endosso-caução;**
- **o endosso feito pelo sacado é nulo como endosso, valendo apenas como quitação:** isso porque a lei veda que a instituição financeira proceda ao endosso;
- **o endosso feito após o prazo de apresentação (endosso-tardio) não tem efeitos de endosso, mas tem efeitos de cessão civil de crédito.**

11.5. Aval no cheque

É possível avalizar o cheque de duas formas:

- **aval em preto:** irá dizer quem é o avalizado;
- **aval em branco:** não contendo quem será o avalizado, considera-se que será avalizado o emitente. O devedor principal do cheque é o emitente.

O avalista se obriga da mesma maneira que o avalizado. Neste caso, **subsiste sua obrigação, ainda que nula a por ele garantida, salvo se a nulidade resultar de vício de forma.**

11.6. Prazos para pagamento/cobrança do cheque

O cheque é pago **com a sua apresentação**, já que se trata de uma ordem de pagamento à vista.

O prazo para a apresentação do cheque varia:

- **30 dias, se for da mesma praça,** contados da data de emissão;
- **60 dias, se for de praças distintas,** contados da data de emissão.



Ex.: se a minha praça é Brasília, mas foi emitido em Goiânia. O sujeito terá 60 dias para apresentar.

São **consequências para o credor que não observar o prazo**:

- **perda do direito de cobrar dos coobrigados;**
- **perda do direito de executar o cheque contra o emitente, se dentro daquele prazo havia fundos e não há mais fundos por uma circunstância não imputável ao devedor:** ex.: banco faliu. Se o sacador emitiu o cheque e o credor teria 30 dias para apresentar o cheque, mas não o fez, caso o banco venha a falir, como o devedor tinha o dinheiro na conta antes, não poderá ser executado, visto que só o credor é o culpado pelo não recebimento e não o devedor.

O cheque apresentado fora do prazo de apresentação poderá ser pago pelo banco, desde que não esteja prescrito. Ex.: apresentação do cheque no 62º dia. O pagamento do cheque pelo próprio banco é uma obrigação enquanto não estiver prescrito e houve recursos na conta. **Também poderá ser executado contra o emitente ou seus avalistas (S. 600/STF), observado o prazo prescricional.**

A partir do término do prazo de apresentação começa a correr o prazo prescricional de 6 meses para sua execução. **O direito de regresso de um coobrigado contra outro também prescreve no prazo de 6 meses, contados do momento em que um coobrigado pagou o título,** nascendo o direito de regresso contra o outro coobrigado.

Ainda que prescrita a ação executiva (ultrapassados os seis meses), a própria lei do cheque prevê o prazo de dois anos para o ajuizamento de ação de locupletamento ilícito (art. 61).

Além disso, é cabível também ação monitória, nos termos da **Súmula 299/STJ**: “é admissível ação monitória fundada em cheque prescrito”. Quanto ao prazo desta ação, a **Súmula 503/STJ** estabelece o seguinte: “o prazo para ajuizamento da ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula”. Já na Súmula 531/STJ, consta que “em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”.

Destaque-se, por fim, que passará a ser possível a oposição de exceção pessoal ao portador de cheque após sua prescrição, conforme decidiu o STJ em precedente noticiado no Informativo 658:

Prescrito o cheque, não há mais que se falar em manutenção das suas características cambiárias, tais quais a autonomia, a independência e a abstração. Inclusive, em razão da prescrição do título de crédito, a pretensão fundar-se-á no próprio negócio subjacente, inviabilizando a propositura de ação de execução. Assim, perdendo o cheque prescrito os seus atributos cambiários, dessume-se que a ação monitória neste documento admitirá a discussão do próprio fato gerador da obrigação, sendo possível a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou mesmo ao próprio emitente do título. Ressalte-se que tal entendimento vai ao encontro da jurisprudência firmada nesta Corte Superior no sentido de que, embora não seja exigida a prova da origem da dívida para a admissibilidade da ação monitória fundada em cheque prescrito (Súmula 531/STJ), nada impede que o emitente do título discuta, em embargos monitórios, a *causa debendi*. Isso significa que, embora não seja necessário debater a origem da dívida, em ação monitória fundada em cheque prescrito, o réu pode formular defesa baseada em eventuais vícios ou na inexistência do negócio jurídico subjacente, mediante a apresentação de fatos impositivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. (Informativo 658/STJ)

11.7. Sustação do cheque

O cheque poderá ser sustado, ou seja, **não ser pago**, trazendo a lei duas modalidades:



@cpiuris



www.cpiuris.com.br



contato@cpiuris.com.br



- **revogação:** é uma contraordem de pagamento, um ato exclusivo do emitente, o qual deverá expor as razões da contraordem (revogação). Essa contraordem apenas produzirá efeitos **após o esgotamento do prazo de apresentação do cheque**;
- **oposição:** poderá o emitente ou o portador do cheque emitir a sustação **quando houver um extravio, roubo, furto dos cheques**, etc. Por isso, tanto o emitente quanto o portador poderão promover a oposição.

Em ambas as hipóteses, **o sacado (banco) não pode questionar a ordem**, pois somente quem poderá dizer se o motivo é legítimo ou não é o Poder Judiciário.

11.8. Papel de curso não forçado

O cheque **não é um papel de curso forçado**. Isso significa que ninguém está obrigado a receber um cheque contra a sua vontade. Ex.: restaurante com placas “não aceitamos cheque”. O que não pode ocorrer é se negar a aceitar moedas nacionais.

11.9. Cheque sem fundos

O pagamento por meio de cheque tem **efeito *pro-solvendo*, e não somente *pro-soluto***. Ou seja, o fato de o cheque ter sido emitido e entregue ao credor não significa dizer que a obrigação está quitada. A obrigação estará quitada apenas a partir do momento em que se compensar o cheque.

Suponhamos a emissão de cheque para fins de pagamento de aluguel. A importância de se entender essa obrigação como *pro-solvendo* é a de que, se o cheque não for compensado por estar sem fundos, é possível que o credor se utilize da ação de despejo contra o emitente. Se considerássemos o cheque *pro-soluto*, caso ele não fosse pago, o aluguel seria considerado pago, podendo o credor apenas promover uma ação de execução contra o devedor.

Obviamente as partes podem pactuar de modo diverso, estabelecendo que o cheque terá efeitos *pro-soluto*. Nesse caso, se eventualmente não for pago, restará apenas ao Direito Cambial a regência da execução, mas essa não é a regra.

O cheque sem fundos deverá ser protestado dentro do prazo de apresentação. Isso porque, somente assim, conservar-se-á o direito contra os coobrigados do título.

Em outras palavras, para se poder processar eventuais coobrigados, é necessário o protesto, salvo quando o cheque possuir a cláusula sem despesas. **Se o cheque possui cláusula sem despesas, para se executar o coobrigado não haverá necessidade de se protestar o título.**

O protesto do cheque poderá ser substituído por uma declaração do banco, informando que seriam indisponíveis os recursos do emitente para pagar aquele cheque (art. 47, II, da Lei do Cheque).

A emissão de cheque sem fundos poderá caracterizar crime de fraude por meio do uso de cheque, enquadrando-se como **estelionato**. Em tal caso, se o emitente pagar o cheque até o oferecimento da denúncia, não haverá mais justa causa para a ação penal. Todavia, caso haja o pagamento do cheque após o oferecimento da denúncia, não obstará o prosseguimento da ação penal, conforme súmula do STF.

11.9. Juros e correção monetária

Em julgamento de REsp repetitivo, decidiu o STJ que a correção monetária do valor estampado no cheque tem por termo inicial a data de sua emissão, enquanto os juros de mora incidem apenas a contar da data da primeira apresentação do cheque à instituição financeira sacada ou câmara de compensação (vide REsp 1.556.834, Informativo 587).



12. Duplicata

12.1. Conceito

Duplicata é um título de crédito regido pela Lei 5.474/68 (Lei das Duplicatas).

A emissão de duplicata **é sempre facultativa**, não sendo obrigatória sua emissão. Além disso, a compra e venda mercantil ou prestação de serviços poderá ser representada por outro título de crédito, como uma nota promissória ou um cheque. A diferença é que tanto a nota promissória quanto o cheque são emitidos pelo comprador, enquanto a duplicata é emitida pelo próprio vendedor.

A **duplicata** é um **título causal**, visto que apenas pode ser emitida diante de uma compra e venda mercantil (art. 1º da Lei das Duplicatas) ou prestação de serviços (art. 20 da Lei das Duplicatas).

Atenção: a duplicata, apesar de causal no momento da emissão, com o aceite e a circulação adquire abstração e autonomia, desvinculando-se do negócio jurídico subjacente, impedindo a oposição de exceções pessoais a terceiros endossatários de boa-fé, como a ausência ou a interrupção da prestação de serviços ou a entrega das mercadorias. **(STJ. 2ª Seção. EREsp 1.439.749-RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 28/11/2018 - Info 640).**

12.2. Requisitos da duplicata

São requisitos da duplicata:

Art. 2º No ato da emissão da fatura, dela poderá ser extraída uma duplicata para circulação como efeito comercial, não sendo admitida qualquer outra espécie de título de crédito para documentar o saque do vendedor pela importância faturada ao comprador.

§ 1º A duplicata conterá:

I - a denominação "duplicata", a data de sua emissão e o número de ordem;

II - o número da fatura;

III - a data certa do vencimento ou a declaração de ser a duplicata à vista;

IV - o nome e domicílio do vendedor e do comprador;

V - a importância a pagar, em algarismos e por extenso;

VI - a praça de pagamento;

VII - a cláusula à ordem;

VIII - a declaração do reconhecimento de sua exatidão e da obrigação de pagá-la, a ser assinada pelo comprador, como aceite, cambial;

IX - a assinatura do emitente.

§ 2º Uma só duplicata não pode corresponder a mais de uma fatura.

§ 3º Nos casos de venda para pagamento em parcelas, poderá ser emitida duplicata única, em que se discriminarão todas as prestações e seus vencimentos, ou série de duplicatas, uma para cada prestação distinguindo-se a numeração a que se refere o item I do § 1º deste artigo, pelo acréscimo de letra do alfabeto, em sequência.

A declaração do reconhecimento de sua exatidão e da obrigação de pagá-la deverá constar nela, pois quando chegar ao comprador, ele simplesmente dará o seu "aceite", reconhecendo a sua obrigação.

Ante o rigor da formalidade aplicável aos títulos de crédito (parte final do art. 887 do CC), se houver a aposição de número incorreto da fatura na duplicata, esta não valerá como título de crédito, perdendo sua força executiva extrajudicial (Informativo 660 do STJ).

A duplicata deverá conter a assinatura do seu emitente. Todavia, poderá ser substituída a assinatura pela rubrica mecânica.



Lembre-se de que a duplicata é um título de modelo vinculado, pois deverá ser lançada e impressa pelo sistema próprio do vendedor, estando sujeita a uma escrituração.

Quem emite duplicata deverá obrigatoriamente escriturar o livro de registro das duplicatas. Em razão disso, cada duplicata terá um número de ordem.

A lei não admite a emissão de duplicata que represente mais de uma fatura. Sendo o pagamento parcelado, é possível que o vendedor saque uma única duplicata, “em que se discriminarão tôdas as prestações e seus vencimentos, ou série de duplicatas, uma para cada prestação distinguindo-se a numeração a que se refere o item I do § 1º dêste artigo (número de ordem), pelo acréscimo de letra do alfabeto, em sequência” (art. 2º, § 3º, da Lei das Duplicatas). Ex.: duplicata tem o número de ordem 124, será possível emitir as duplicatas 124-A, 124-B e 124-C, pois o pagamento foi parcelado, representando cada letra uma das parcelas.

Detalhe para o “pega” que vem caindo em provas: cada duplicata deve corresponder a uma fatura, mas esta poderá abranger mais de uma nota fiscal parcial (art. 2º da Lei das Duplicatas e Informativo 581 do STJ).

Destaque-se, ainda, que o art. 172 do CP prevê como crime a emissão de duplicata simulada.

12.3. Aceite na duplicata

Emitida a duplicata pelo vendedor, é necessário que o comprador dê o seu aceite.

Este **aceite é obrigatório**, salvo se houver uma justificativa para não ocorrer.

Recebendo a duplicata, o comprador poderá:

- assinar o título e devolver ao vendedor, estando feito o aceite;
- devolver o título sem assinatura, constando as razões que motivam a recusar o aceite;
- não devolver o título, e comunicar ao vendedor o seu aceite;
- não devolver o título, e simplesmente não comunicar o devedor.

A duplicata, como dito, é título de aceite obrigatório. Isso significa que **a vinculação do comprador independe de sua vontade**.

Por isso, a **sua recusa**, a qual o desobrigaria, **só é possível se estivermos diante de uma das hipóteses legais que excepcionam esta obrigatoriedade**:

- comprador poderá recusar aceite se a mercadoria não foi recebida ou se houve avaria;
- se houver vício na quantidade ou na qualidade de mercadorias;
- quando houver divergência nos prazos e nos preços ajustados.

O aceite da duplicata mercantil pode ser classificado em três categorias:

- **aceite ordinário**: devedor assina a duplicata, aceitando-a;
- **aceite por comunicação**: o devedor retém a duplicata, mas comunica ao devedor, por escrito, que foi aceite;
- **aceite por presunção**: ocorre quando o comprador recebe as mercadorias normalmente, assina o comprovante de entrega sem ressalvas, mas se omite em aceitar a duplicata ou em devolvê-la.

12.4. Protesto da duplicata

A duplicata poderá ser protestada por:

- **falta de aceite**;
- **falta de devolução**;
- **falta de pagamento**.



Qualquer que seja a causa do protesto, se o comprador não restituiu o título ao vendedor (credor), como seria feito o protesto?

Em tese, para se fazer um protesto, é necessária a cártula do título.

No caso de **protesto por falta de devolução, o protesto será feito por indicações**. Ou seja, o credor fornecerá as indicações sobre a duplicata ao cartório de protestos. Há aqui uma **exceção ao princípio da cartularidade**. A mesma situação ocorre com o protesto das duplicatas virtuais, que também é feito por indicação.

O protesto deverá ser feito na praça de pagamento, porquanto se trata de obrigação quesível, devendo o credor ir até o cartório de protesto da cidade do devedor. O prazo para protesto é 30 dias a contar do vencimento da duplicata. Caso perca tal prazo, o credor perderá o direito de regresso contra os endossantes e respectivos avalistas (art. 13, § 4º, da Lei das Duplicatas).

Segundo a Súmula 361 do STJ, a notificação do protesto para fins especiais falimentares, para embasar requerimento de falência da empresa devedora, exige a identificação da pessoa que a recebeu.

Sendo o aceite ordinário, ou seja, com a simples assinatura lançada na duplicata, para fins de ajuizamento da ação de execução, basta a juntada do título original da duplicata ao processo para se executar o devedor principal. Todavia, o protesto é necessário caso o credor queira executar um coobrigado.

Portanto, o protesto será obrigatório em relação à execução dos coobrigados. Todavia, será protesto facultativo em relação ao devedor principal.

Sendo o aceite por comunicação, a própria carta, com a referência pelo comprador de que aceita a duplicata, serve como título executivo.

Em relação ao aceite por presunção, para constituir o título executivo, é necessário cumprir os seguintes requisitos:

- **comprovação do protesto cambial;**
- **comprovante de entrega da mercadoria ou da prestação de serviços:** não há a cártula, mas há prova de que o sujeito recebeu a mercadoria ou serviço;
- **não existir recusa justificada do aceite.**

Somados esses três fatores, há a possibilidade de execução da duplicata aceita por presunção.

Ressalte-se, ainda, que, diante de uma duplicata sem aceite devidamente protestada, o comprovante de entrega da mercadoria ou da prestação de serviço não é exigível quando eventual endossatário promover execução contra o próprio emitente da duplicata, outros endossantes ou avalistas, de acordo com o STJ (REsp 250.568). Apenas se exige o comprovante de entrega para fins de execução contra o sacado.

Por fim, de acordo com o STJ, também se admite ação monitória para fins de cobrança de duplicata sem aceite (REsp 204.894).

12.5. Duplicata virtual (duplicata eletrônica ou sob forma escritural)

Segundo o STJ, as duplicatas virtuais encontram previsão legal no art. 8º, parágrafo único, da Lei nº 9.492/97 e no art. 889, § 3º, do CC, além de estarem atualmente disciplinadas na Lei nº 13.775/2018. Como prescinde (não necessita) de um suporte físico (documento), constando apenas de registros eletrônicos, é uma **exceção ao princípio da cartularidade**.

O procedimento para emissão e cobrança da duplicata virtual é o seguinte:

- o contrato de compra e venda ou de prestação de serviços é celebrado;
- em vez de emitir uma fatura e uma duplicata em papel, **o vendedor ou fornecedor dos serviços transmite em meio magnético (pela internet) os dados referentes a esse negócio jurídico a uma instituição financeira**, contendo as partes, a relação das mercadorias vendidas, o preço, etc.



- a instituição financeira, **eletronicamente, encaminha um boleto bancário** para que o devedor (comprador) pague a obrigação originada no contrato. **Esse boleto bancário não é título de crédito**, porém, contém as características da duplicata virtual.
- no dia do vencimento, **caso não seja pago o valor, o credor ou o banco encaminharão as indicações do negócio jurídico ao Tabelionato**, também em meio magnético, **o qual irá protestar o título por indicações**.
- feito o protesto, **se o devedor continuar inadimplente, o credor ou o banco ajuizarão uma execução contra ele**.

Nesse caso, o **título executivo extrajudicial** será formado por:

- **boleto** de cobrança bancária;
- instrumento de **protesto por indicação** e;
- **comprovante de entrega da mercadoria** ou da **prestação dos serviços**.

A maioria da doutrina e o STJ entendem que a duplicata virtual já era válida mesmo antes do advento da Lei nº 13.775/2018, que as regulamentou formalmente.

Segundo decidiu o STJ, as duplicatas virtuais emitidas e recebidas por meio magnético ou de gravação eletrônica podem ser protestadas por mera indicação, de modo que a exibição do título não é imprescindível para o ajuizamento da execução, conforme previsto no art. 8º, parágrafo único, da Lei nº 9.492/1997.

12.6. Prazos para cobrança da duplicata

A ação de execução da duplicata prescreve em 3 anos, contados da data de vencimento do título contra o devedor principal ou seu avalista.

Esta execução prescreve em 1 ano da data do protesto, se a execução se dirige contra os coobrigados, que são os endossantes e os avalistas dos endossantes.

Também prescreve em 1 ano o exercício do direito de regresso, que é contado da data do pagamento do título.

12.7. Duplicatas de prestação de serviços

A duplicata não se restringe à duplicata mercantil, existindo ainda as denominadas duplicatas de prestação de serviços (art. 20 e seguintes da Lei das Duplicatas).

Essas duplicatas poderão ser emitidas por pessoa natural ou por pessoa jurídica.

Elas têm o regime jurídico idêntico ao da duplicata mercantil, com duas especificidades:

- **a causa que a autoriza é a prestação de serviços;**
- **o protesto por indicação depende de um documento que comprove um vínculo contratual e a efetiva prestação de serviço.**

12.8. Duplicata por conta de serviços

Outro título de crédito por prestação de serviços é a **duplicata por conta de serviços**. Esta duplicata pode ser emitida pelo **profissional liberal** ou pelo **prestador de serviços eventual**.

Perceba que não se está tratando de empresário aqui.

Como se trata de prestador de serviço eventual, ficará **dispensado de qualquer escrituração**, devendo registrar a duplicata no cartório de títulos e documentos.

Esse título de crédito é um **título impróprio** pois a conta de serviços não é suscetível de circulação cambial.



13. Títulos de créditos impróprios

Alguns instrumentos jurídicos se sujeitam apenas parcialmente ao regime jurídico cambial, sendo denominados de **títulos de crédito impróprios**.

Dentro dos títulos de crédito impróprios, há quatro categorias:

- **título de legitimação;**
- **título representativo;**
- **título de financiamento;**
- **título de investimentos.**

13.1. Título de legitimação

O portador desse título tem direito a uma prestação de serviço, ou acesso a um prêmio, como o título de um metrô, que é um título de legitimação, pois com base nele se legitima o uso do metrô. O mesmo ocorre com relação ao bilhete da loteria.

13.2. Título representativo

Título representativo é um instrumento que representa a titularidade de mercadorias que estão custodiadas.

Mercadoria custodiada é aquela que está sob a custódia de uma pessoa, mas que pertence a outra pessoa. Entre os títulos representativos existem o **conhecimento de depósito**, o **warrant** e o **conhecimento de frete**. Esses títulos possibilitam a negociação da mercadoria pelo proprietário. Em outras palavras, a mercadoria continuará custodiada, mas o título representará a mercadoria. Por isso o nome de título representativo.

O conhecimento de depósito e o conhecimento de frete são **títulos dos armazéns gerais**, os quais representam as mercadorias neles custodiadas.

A mercadoria depositada em armazém geral somente poderá ser entregue a quem apresentar o **conhecimento de depósito** e o **warrant**.

- **conhecimento de depósito:** atesta que a mercadoria existe e foi depositada em uma empresa de armazém geral;
- **warrant:** serve para a finalidade de constituir penhor sobre tal mercadoria.

Dito de outra forma, quem detém o conhecimento de depósito é considerado o proprietário das mercadorias, ao passo que o detentor do **warrant** é considerado credor de um determinado valor, sendo que as mercadorias representam a garantia.

Ambos os títulos **poderão circular separadamente. Quem recebe o conhecimento de depósito tem a propriedade da mercadoria, ou seja, o endossatário será o proprietário da mercadoria**. No entanto, quem recebe o endosso do **warrant**, recebe um direito real de garantia. Então, o endossatário do **warrant** é um **credor com garantia real**.

Por isso, a liberação da mercadoria exige, em regra, daquele que requer a liberação, o porte os dois títulos: tanto o conhecimento de depósito quanto o **warrant**.

A **exceção** é de que é possível a liberação da mercadoria em prol do titular apenas do do conhecimento do depósito (sem ter o **warrant**), se este depositar o valor correspondente ao garantido pelo **warrant**.

Outra **exceção** é a possibilidade de retirada da mercadoria se estivermos diante de um caso de execução da garantia, após o protesto do **warrant**.

Lembre-se de que o conhecimento de depósito e o **warrant** também **poderão ser agropecuários** (conhecimento de depósito agropecuário e o **warrant** agropecuário), em que as características serão idênticas, servindo como lastro de operações no mercado agropecuário. No caso do conhecimento de depósito agropecuários e do **warrant agropecuários**, a lei permite



que os títulos circulem no mercado financeiro e de capitais, tendo uma circulação maior do que os *warrants* gerais.

O **conhecimento de frete** é um título representativo de uma mercadoria que está sendo transportada. Quem tem o conhecimento de frete tem a propriedade da mercadoria. O conhecimento de frete prova que a empresa transportadora recebeu a mercadoria. Em tal caso, passa a ser possível ao proprietário da mercadoria despachada que negocie a mercadoria mediante o endosso do título. O endossatário passará a ser o proprietário da mercadoria. A lei veda a negociação do conhecimento de frete se ele possuir uma cláusula não à ordem, se se tratar de mercadoria perigosa ou se forem cargas destinadas a armazéns gerais.

13.3. Títulos de financiamento

São instrumentos que representam créditos decorrentes de um financiamento aberto por instituições financeiras.

Haverá aqui:

- cédulas e notas de crédito rural;
- cédulas e notas de crédito industrial;
- cédulas e notas de crédito comercial;
- cédulas e notas de crédito à exportação.

Basicamente, a diferença entre cédula de crédito para nota de crédito é a seguinte:

- **cédulas de crédito:** possuem garantia real (ex: hipoteca ou penhor);
- **notas de crédito:** não possuem garantia real, mas gozam de privilégio especial.

13.4. Títulos de investimentos

Títulos de investimento são **instrumentos que se destinam à captação de recursos pelo emitente**.

Nesses títulos estão as letras de crédito imobiliário (LCI). Também podemos citar as letras de arrendamento mercantil, que são emitidas por sociedades de arrendamento mercantil, etc.



CAPÍTULO 15 — DIREITO FALIMENTAR E RECUPERACIONAL

1. Principais inovações da Lei nº 11.101/2005:

(i) substituição da concordata pela recuperação (quando o comerciante estava em crise, ele podia pedir concordata; a lei atual não prevê mais a figura da concordata, mas a recuperação, que pode ser judicial ou extrajudicial);

(ii) aumento do prazo de contestação no processo de falência (o prazo era de 24 horas, passou para 10 dias);

(iii) exigência de que a impontualidade injustificada que embasa o pedido de falência seja relativa a dívida superior a 40 salários mínimos (na lei anterior, o pedido de falência por impontualidade injustificada poderia ser por qualquer valor, embora os juízes já estivessem fazendo um controle disso);

(iv) redução da participação do Ministério Público (será estudada a interpretação dos Tribunais quanto ao tema);

(v) alteração de regras relativas ao síndico (agora é chamado de administrador judicial): houve mudanças importantes, inclusive nas regras para definir quem pode ser administrador judicial;

(vi) mudança na ordem de classificação dos créditos (os créditos tributários estão em terceiro lugar, em segundo lugar estão os créditos com garantia real. Houve limitação da preferência quanto aos créditos trabalhistas para até 150 salários mínimos, por trabalhador);

(vii) alteração nas regras relativas à ação revocatória (ação que os credores e o MP podem propor para tentar trazer mais bens para a massa falida);

(viii) fim da medida cautelar de verificação de contas (medida que existia para tentar demonstrar a insolvência do devedor e assim pedir sua falência); e

(ix) fim do inquérito judicial para apuração de crime falimentar (na lei anterior, os crimes falimentares eram apurados no próprio juízo falimentar).

IMPORTANTE: a LFRE foi objeto de duas ações diretas de inconstitucionalidade: da **ADI 3424** e da **ADI 3934**, que atacaram vários dispositivos da lei, principalmente relacionados ao crédito trabalhista. A ADI 3934, relatada pelo Ministro Ricardo Lewandowski, já foi julgada improcedente pelo STF, que reconheceu a constitucionalidade do art. 60, parágrafo único; do art. 83, incisos I e IV; e do art. 141, inciso II, da LFRE (artigos que permitem a venda de empresa falida, ou venda de unidades produtivas isoladas ou filiais em recuperação judicial sem ônus nenhum para o arrematante, permitiram a limitação da preferência dos créditos trabalhistas, que agora só fica em primeiro lugar até 150 salários mínimos por trabalhador, etc.).

2. Incidência subjetiva da Lei nº 11.101/2005

O Art. 1º da LFRE prevê que “esta lei disciplina a recuperação judicial, a recuperação extrajudicial e a falência do **empresário** e da **sociedade empresária**, doravante referidos simplesmente como devedor”.

Quando o dispositivo cita “empresário”, refere-se ao **empresário individual**.

A lei se aplica à EIRELI?

Sim. A lei só fala de empresário e sociedade empresária porque é de 2005, ano em que ainda não existia a EIRELI, que é do ano de 2011 (Lei nº 12.441/11).

As regras da LFRE não se aplicam a **devedores civis** (não empresários), os quais se submetem, quando caracterizada a sua insolvência, às regras da execução contra devedores insolventes previstas no Código de Processo Civil de 1973 (arts. 748 a 786-A do CPC/73 não foram revogado pelo CPC/2015, permanecendo em vigor até que venha a ser editada uma lei específica sobre o tema, nos termos do art. 1.052 do CPC/2015).



As **cooperativas**, por serem **sociedades simples**, independentemente do seu objeto social (art. 982, parágrafo único, do Código Civil), **não** podem requerer recuperação nem ter sua falência requerida.

STJ: “as sociedades cooperativas **não** se sujeitam à falência, dada a sua natureza civil e atividade não empresária, devendo prevalecer a forma de liquidação extrajudicial prevista na Lei 5.764/71” (AgRg no REsp 999.134/PR; no mesmo sentido: AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 1.129.512/SP).

Cuidado: apenas empresários e sociedades empresárias podem ter contra si pleiteada a falência ou requerer recuperação judicial, mas os credores não empresários (ex: sociedades simples), podem pleitear a falência daqueles.

Quanto às empresas públicas e sociedades de economia mista que explorem atividade econômica, é certo que a Constituição Federal afirma que a lei que disciplinar o estatuto jurídico delas, que demorou décadas para ser editada (apenas em 2016), deve sujeitá-las às mesmas regras das empresas privadas (art. 173, § 1º, II, da CF/88).

Porém, a Lei nº 13.303/2016 nada disciplina sobre aspectos falimentares, prevalecendo o art. 2º, I, da LFRE, segundo o qual “esta lei **não** se aplica: I- a empresa pública e sociedade de economia mista”, sem sequer fazer distinção entre estatais exploradoras de atividade econômica ou prestadoras de serviços públicos.

Existem diversas interpretações quanto ao tema:

a) Interpretação literal: a Lei das Estatais silenciou e a LFRE é muito clara ao dizer que não se aplica a empresa pública e sociedade de economia mista.

b) Interpretação à luz da Constituição: a regra é clara no art. 173 da Constituição e o artigo 2º, inciso I, da LFRE é inconstitucional.

c) Interpretação conforme: o artigo 2º, inciso I, da LFRE diz que não se aplica a empresa pública e sociedade de economia mista, mas se ela for exploradora de atividade econômica se aplica, em razão do que diz a Constituição.

Para provas de concurso, recomenda-se a aplicação literal da Lei: “a Lei não se aplica a empresa pública e sociedade de economia mista”, pois é assim que os gabaritos estão entendendo.

Também estão excluídas da abrangência da LFRE as entidades citadas no inciso II do art. 2º, a saber:

Art. 2º (...) II - a instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores.

São agentes econômicos que atuam em mercados regulados, que possuem leis específicas disciplinando a **liquidação extrajudicial** em caso de insolvência (ex.: Lei nº 6.024/1974, aplicável às instituições financeiras, e o Decreto-lei 73/1966, aplicável às seguradoras).

Se cair em provas de concurso a redação literal do art. 2º, dizendo que a lei de falências não se aplica às entidades citadas no inciso II, deve-se marcar como correta a alternativa (ao menos é o que tem prevalecido por ora nos concursos).

Mas se atente para o fato de que o art. 197 da LFRE prevê a possibilidade de aplicação subsidiária de seus termos enquanto não houver legislação falimentar específica para seguros privados, instituições financeiras e entidades de crédito. A própria Lei 6.024/74 também prevê possibilidade de aplicação subsidiária da legislação falimentar (art. 34). Considerando que, em 2018 e 2019, apareceram mais de um julgado sobre essa aplicação subsidiária nos informativos do STJ, é possível que os examinadores passem a questionar especificamente sobre essa possibilidade nas provas.



3. Foro competente

O art. 3º da LFRE afirma que: “é competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do **principal estabelecimento** do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil”.

Cuidado: para o Direito Falimentar, o principal estabelecimento não é necessariamente a sede da empresa! O que se leva em consideração é o aspecto econômico, que o estabelecimento seja o centro vital da atividade empresarial e não o aspecto estatutário/contratual. Nesse sentido: **Enunciado 466 das Jornadas de Direito Civil do CJF**: “para fins do direito falimentar, o local do principal estabelecimento é aquele de onde partem as decisões empresariais, e não necessariamente a sede indicada no registro público”.

Já de acordo com o STJ, vale o seguinte:

(...) nos termos do art. 3º da Lei n. 11.101/2005, o foro competente para o processamento da recuperação judicial e a decretação de falência é aquele onde se situe o principal estabelecimento da sociedade, assim considerado o local onde haja o **maior volume de negócios**, ou seja, o local mais importante da atividade empresária sob o ponto de vista econômico. **Precedentes** (AgInt no CC 147.714/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 07/03/2017).

Segundo a **Súmula 480 do STJ**, o juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa.

Por outro lado, o STJ decidiu que o juízo onde tramita o processo de recuperação judicial é o competente para decidir sobre o destino dos bens e valores objeto de execuções singulares movidas contra a recuperanda, ainda que se trate de crédito decorrente de relação de consumo (RESP 1.630.702-RJ).

4. Participação do MP

De acordo com o art. 4º da LFRE, vetado, “o representante do Ministério Público intervirá nos processos de recuperação judicial e de falência. Parágrafo único. Além das disposições previstas nesta Lei, o representante do Ministério Público intervirá em toda ação proposta pela massa falida ou contra esta”. (vetado).

O artigo 4º foi vetado sob a alegação de que da forma como estava redigido, poder-se-ia entender que a ausência de manifestação do MP, em alguns casos, acarretaria nulidade, prejudicando o andamento dos processos. Além disso, pela forma vaga, poder-se-ia entender que a todo momento teria de ser ouvido o MP, atrasando o processo pelas sucessivas aberturas de vista. Ainda, se não ouvido em algum momento, poderia o MP alegar nulidade, atrasando a marcha processual.

Apesar de vetado o dispositivo, o MP ainda participa, mas o entendimento dominante é de que só participa obrigatoriamente dos processos de falência ou de recuperação nos momentos processuais em que houver expressa disposição legal nesse sentido. Fora das hipóteses expressas da lei, não será imprescindível a oitiva ministerial, podendo ainda assim o juiz optar por lhe conceder vista sobre determinada questão.

Sobre o tema, vide a jurisprudência do STJ:

STJ: na vigência do DL 7.661/45 era possível a intervenção do Ministério Público durante todo o procedimento de quebra, inclusive em sua fase pré-falimentar, alcançando também as ações conexas. (...) com o advento da Lei 11.101/05, houve sensível alteração desse panorama, sobretudo ante a constatação de que o número excessivo de intervenções do Ministério Público vinha asoberbando o órgão e embaraçando o trâmite das ações falimentares. Diante disso, vetou-se o art. 4º da



Lei 11.101/05, que mantinha a essência do art. 210 do DL 7.661/45, ficando a atuação do Ministério Público, atualmente, restrita às **hipóteses expressamente previstas em lei** (REsp 1.230.431/SP).

São hipóteses de participação do MP expressamente previstas na lei:

- Pode impugnar relação de credores (prazo: 10 dias)
- Pode pedir, até encerramento da falência ou da rec. jud. exclusão, reclassificação ou retificação de qualquer crédito nos casos de falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou documentos ignorados à época.
- Pode requerer substituição do administrador judicial ou de membros do Comitê nomeados em desobediência aos preceitos legais.
- Decisão que defere processamento da recuperação judicial deve ordenar intimação do MP.
- Pode agravar da decisão que conceder recuperação judicial.
- Deve ser intimado em qualquer modalidade de alienação ordinária do ativo, sob pena de nulidade, podendo apresentar impugnação no prazo de 48 horas da arrematação.
- Pode ajuizar ação revocatória (prazo de três anos contado da decretação da falência) contra atos praticados com a intenção de prejudicar credores.

5. Aplicação subsidiária do CPC

Art. 189 da LFRE: “aplica-se a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, no que couber, aos procedimentos previstos nesta Lei”. E quanto à contagem dos prazos? Aplica-se o disposto no art. 219 do CPC (“Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais.”)?

A polêmica advinda desse dispositivo é que na LFRE nem todos os prazos são de natureza propriamente processual e outros são deveras longos.

Para o STJ, é preciso analisar a natureza de cada prazo, além da finalidade do processo falimentar e recuperação. Quanto ao *stay period* (art. 6º, § 4º, da LFRE), possui natureza material (suspende inclusive prazo prescricional) e sua contagem em dias úteis, por ser um prazo de 180 dias, iria contra a unidade lógica da recuperação e do objetivo de uma solução célere para a situação de dificuldade da empresa em dificuldades financeiras (REsp 1.698.283-GO).

6. Cabimento de agravo de instrumento nos procedimentos falimentares e recuperacionais

O art. 1.015 do novo CPC trouxe rol específico para as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, o que levou doutrina e jurisprudência a questionar se tal rol seria taxativo, exemplificativo ou algo entre os dois (taxativo mitigado). O inciso XIII desse dispositivo assegura o cabimento de agravo de instrumento em “outros casos expressamente referidos em lei”.

De fato, há alguns casos em que a própria LFRE prevê o cabimento de Agravo de Instrumento, não havendo dúvida quanto a esses, em virtude do citado dispositivo.

Mas, e nas decisões interlocutórias tomadas ao longo do “processo de recuperação”, cabe Agravo de Instrumento?

Decidiu o STJ que é sim possível e que o rol do art. 1.015 do novo CPC é um rol taxativo mitigado, admitindo extensão a casos cuja teleologia se amolde a uma das hipóteses previstas nesse artigo. No caso, admite-se o agravo de instrumento nos processos falimentares e recuperacionais a partir de uma leitura teleológica do parágrafo único do art. 1.015, que prevê o recurso de agravo de instrumento contra as decisões proferidas em processos executivos. Isso porque, no processo de recuperação e mesmo na falência, o objeto é semelhante ao de uma execução ou de um cumprimento de sentença: ir atrás dos bens do devedor para assegurar o



adimplemento do crédito. Assim, falência e recuperação entrariam na ideia ampla de processo de execução. Nesse sentido também é o Enunciado 69 das Jornadas de Direito Processual Civil do CJF: “a hipótese do art. 1.015, parágrafo único, do CPC abrange os processos concursais, de falência e recuperação”.

7. Administrador judicial

Prevê o art. 21 da LFRE o seguinte: “O administrador judicial será profissional idôneo, **preferencialmente** advogado, economista, administrador de empresas ou contador, ou pessoa jurídica especializada.”

Cuidado: têm caído muitas questões com pegadinha, trocando-se a expressão “preferencialmente” por outra.

A seu turno, dispõe o art. 24 da LFRE: “O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.”

A regra geral é que o valor da remuneração “não excederá 5% do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência” (§ 1º), mas no caso de ME/EPP a remuneração do administrador judicial ficará reduzida ao limite de 2% (§ 5º).

O § 2º desse artigo dispõe que: “será reservado 40% (quarenta por cento) do montante devido ao administrador judicial para pagamento após atendimento do previsto nos arts. 154 e 155 desta Lei”. Por outro lado, o STJ firmou o entendimento de que a referida reserva de 40% dos honorários do administrador judicial se aplica apenas às ações de falência, mas não se aplica no âmbito da recuperação judicial (REsp 1.700.700-SP, julgado em 05/02/2019, DJe 08/02/2019).

Ainda quanto ao administrador judicial (síndico), recentemente o STJ firmou o entendimento de que ele também é responsável pelos atos realizados pelo gerente na continuidade provisória das atividades, devendo prestar contas disso ao juiz:

(...) O síndico é responsável pela prestação de contas da massa falida ao juízo a partir do momento de sua nomeação, incluídos os atos realizados pelo gerente na continuidade provisória das atividades (STJ. 4ª Turma. REsp 1.487.042-PR, julgado em 05/12/2019).

8. Recuperação Judicial

8.1. Introdução e diferenças entre a recuperação e a concordata

A recuperação judicial surgiu para substituir a antiga “concordata” e tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise do devedor, a fim de permitir que a atividade empresária se mantenha e, com isso, sejam preservados os empregos dos trabalhadores e os interesses dos credores.

A recuperação judicial consiste, portanto, em um **processo judicial, no qual será construído e executado um plano com o objetivo de recuperar a empresa que está em vias de efetivamente ir à falência**. A recuperação visa recuperar quem tem chance de ser recuperado. Do contrário, deverá falir.

A concordata era um direito do devedor, os credores não tinham muita participação no processo, o juiz verificava se o devedor preenchia os requisitos e deferia a concordata, os credores não eram ouvidos. Na recuperação judicial, quem decide são os credores. O devedor



apresenta um plano de recuperação, os credores vão deliberar sobre esse plano e dizer se o aprovam ou não e o juiz fica, quase sempre, vinculado à decisão da assembleia de credores. A exceção a essa regra será estudada mais adiante (*cram down*).

Na concordata, o devedor apenas poderia pedir parcelamento da dívida, abatimento da dívida ou as duas coisas (concordata dilatatória, concordata remissória ou concordata mista). Na recuperação, o devedor tem que apresentar um plano, no qual pode propor diversas medidas em prol de seu soerguimento. A própria lei, em seu artigo 50, sugere algumas dessas medidas, sendo esse um rol exemplificativo:

- concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas;
- cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade, constituição de subsidiária integral, ou cessão de cotas ou ações, respeitados os direitos dos sócios, nos termos da legislação vigente;
- alteração do controle societário;
- substituição total ou parcial dos administradores do devedor ou modificação de seus órgãos administrativos;
- concessão aos credores de direito de eleição em separado de administradores e de poder de veto em relação às matérias que o plano especificar;
- aumento de capital social;
- trespasse ou arrendamento de estabelecimento, inclusive à sociedade constituída pelos próprios empregados;
- redução salarial, compensação de horários e redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva;
- dação em pagamento ou novação de dívidas do passivo, com ou sem constituição de garantia própria ou de terceiros;
- constituição de sociedade de credores;
- venda parcial dos bens;
- equalização de encargos financeiros relativos a débitos de qualquer natureza, tendo como termo inicial a data da distribuição do pedido de recuperação judicial, aplicando-se inclusive aos contratos de crédito rural, sem prejuízo do disposto em legislação específica;
- usufruto da empresa;
- administração compartilhada;
- constituição de sociedade de propósito específico para adjudicar, em pagamento dos créditos, os ativos do devedor.

Com base no art. 47 da LFRE, o STJ já admitiu a participação, em procedimento licitatório, de sociedade empresária em recuperação judicial, entendendo ser dispensável a apresentação de “certidão negativa de recuperação judicial” por parte da licitante (AgRg na MC 23.499/RS).

Obs.: a empresa em recuperação judicial continua suas atividades normalmente.

8.2. Requisitos para que o devedor possa pedir recuperação

De acordo com o art. 48 da LFRE, o devedor que quiser pleitear sua recuperação judicial deverá estar no exercício regular de suas atividades há mais de dois anos na data do pedido. A atividade regular a que se refere o *caput* significa estar devidamente registrado na Junta Comercial, ter todos os livros corretamente escriturados, ter registrado na Junta as alterações escriturais, etc., ou seja, estar em dia com suas obrigações registraes e escriturais. Ressalte-se que o STJ decidiu que, em se tratando de sociedades ou empresários rurais, cuja inscrição perante o Registro Público de Empresas Mercantis é facultativa, é possível o cômputo do período



de atividade rural anterior ao registro na Junta Comercial para fins de preenchimento do requisito temporal do art. 48, caput.

Além disso, deverá atender aos seguintes requisitos cumulativos, previstos nos incisos do art. 48:

- I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes;
 - II – não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial;
 - III - não ter, há menos de 5 (cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a Seção V deste Capítulo;
 - IV – não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta Lei.
- § 1º A recuperação judicial também poderá ser requerida pelo cônjuge sobrevivente, herdeiros do devedor, inventariante ou sócio remanescente.
- § 2º Tratando-se de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo por meio da Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ que tenha sido entregue tempestivamente.

Destaque-se que esses requisitos são apenas para o ingresso do pedido em si, não se confundindo com a efetiva concessão da recuperação judicial. Da mesma forma, a decisão judicial que defere o processamento do pedido de recuperação judicial tampouco se confunde com a decisão que concede a Recuperação Judicial (com a homologação do plano). São decisões distintas, tomadas em momentos distintos e que produzem efeitos igualmente diversos, que serão adiante explorados.

O requisito do inciso I (não ser falido e, se o foi, que estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes) é específico para o empresário individual.

Em 2019, o STJ entendeu que as sociedades empresárias integrantes de grupo econômico devem demonstrar individualmente o cumprimento do requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular de suas atividades, que consta no caput do referido art. 48, para postular a recuperação judicial em litisconsórcio ativo (REsp 1.665.042-RS, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

8.3. Processo de recuperação judicial

O processo de recuperação judicial se divide em 3 fases distintas:

- **fase postulatória:** começa com a petição inicial que traz o pedido de recuperação judicial, encerrando-se com o despacho do juiz que manda processar o pedido de recuperação;
- **fase de deliberação (ou de processamento):** o início se dá com o despacho que manda processar o pedido de recuperação, concluindo-se com a homologação do plano, aprovado pela assembleia geral de credores;
- **fase de execução:** aqui há a fiscalização do cumprimento do plano. Inicia-se com a concessão da recuperação judicial (e não com a que manda processar), após a homologação do plano, encerrando-se com a sentença de encerramento do processo.

8.3.1. Fase postulatória

Atendidos os requisitos do art. 48 da LFRE, vistos acima, poderá o devedor requerer sua recuperação judicial. A petição inicial deverá trazer, obrigatoriamente, os motivos da situação de dificuldade financeira, com as demonstrações contábeis, relações dos credores, relação dos



empregados, atos constitutivos (contrato social ou estatuto), certidões de protesto, além das ações judiciais em andamento, sem prejuízo dos demais documentos citados no art. 51 da LFRE.

Se a documentação estiver em termos e o postulante preencher os requisitos, o juiz mandará processar a recuperação judicial, proferindo despacho. O pedido acolhido aqui é o de **processamento**, verificando apenas a legitimidade e se foi instruída a petição inicial nos termos da lei.

No despacho de processamento, o juiz nomeará o administrador judicial e determinará **a suspensão da prescrição e das ações e execuções contra o devedor e contra o sócio solidário**.
Obs: Com o mero **pedido de recuperação judicial, já ficam suspensos os pedidos de falência**.

Quando o juiz determina o processamento da recuperação judicial, **as demais ações e execuções terão suas tramitações suspensas**.

No entanto, existem exceções. Isso é, **não serão suspensas, pois continuarão a tramitar**:

- ações que demandem quantias ilíquidas;
- reclamações trabalhistas;
- execuções fiscais;
- execuções por credores não sujeitos à recuperação judicial (ex.: proprietário fiduciário; ações de despejo e demais créditos citados nos §§ 3º e 4º do art. 49 da LFRE).

Pela sua importância para fins de prova, vale transcrever o art. 6º da LFRE:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.

§ 2º É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 8º desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença.

§ 3º O juiz competente para as ações referidas nos §§ 1º e 2º deste artigo poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na recuperação judicial ou na falência, e, uma vez reconhecido líquido o direito, será o crédito incluído na classe própria.

§ 4º Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.

§ 5º Aplica-se o disposto no § 2º deste artigo à recuperação judicial durante o período de suspensão de que trata o § 4º deste artigo, mas, após o fim da suspensão, as execuções trabalhistas poderão ser normalmente concluídas, ainda que o crédito já esteja inscrito no quadro-geral de credores.

§ 6º Independentemente da verificação periódica perante os cartórios de distribuição, as ações que venham a ser propostas contra o devedor deverão ser comunicadas ao juízo da falência ou da recuperação judicial:

I – pelo juiz competente, quando do recebimento da petição inicial;

II – pelo devedor, imediatamente após a citação.

§ 7º As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica.

§ 8º A distribuição do pedido de falência ou de recuperação judicial previne a jurisdição para qualquer outro pedido de recuperação judicial ou de falência, relativo ao mesmo devedor.

Embora execuções fiscais não se suspendam (§ 7º), o STJ tem entendimento de que não é possível ao juízo da execução fiscal determinar a prática de atos constritivos, pois tais decisões devem estar sujeitas ao crivo da Recuperação Judicial.

O art. 5º, I, da LFRE, afasta também da recuperação judicial obrigações a título gratuito. Quanto aos avais, o avalista pode realmente figurar em um título gratuitamente (ex: um familiar que se oferece para avalizar um título em prol de um parente próximo) ou onerosamente (mais comum no caso de avais prestados por sociedades empresárias). Por essa circunstância, o STJ firmou entendimento no sentido de que é imprescindível a verificação da natureza onerosa ou gratuita do aval prestado antes do pedido de recuperação judicial por sociedade empresária, para que se determine se a garantia se sujeita ou não ao processo de soerguimento. Isso porque nas relações empresariais geralmente existe alguma contraprestação direta ou indireta pelo aval com o objetivo de se obter algum tipo de ganho, situações nas quais não será possível considerar tal obrigação como a título gratuito (REsp 1.829.790-RS, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019).

A suspensão das ações e execuções de que cuida o art. 6º é temporária em relação à Recuperação Judicial podendo cessar em dois momentos, o que ocorrer primeiro:

- após aprovação do plano de recuperação judicial, que implica novação da dívida;
- com o decurso do prazo de 180 dias.

Em que pese a redação peremptória do § 4º do art. 6º da LFRE, entende o STJ que esse prazo de 180 dias, denominado de *stay period*, pode ser prorrogado, em prol do princípio da preservação da empresa, se o retardamento da ação de recuperação judicial não puder ser atribuído ao devedor.

A decisão que defere o processamento da recuperação judicial é recorrível?

No início da vigência da lei, alguns entendimentos surgiram dizendo que não seria recorrível, aplicando-se por analogia uma súmula antiga do STJ referente à concordata, que dizia ser a decisão que defere o processamento da concordata irrecurrível. Todavia, atualmente há posicionamento forte doutrinário, amparado pelo Enunciado 52 das Jornadas de Direito Comercial do CJF, no sentido de que “a decisão que defere o processamento da recuperação judicial desafia agravo de instrumento”.

8.3.2. Fase de deliberação (plano de recuperação)

O principal objetivo dessa fase é a análise do plano de recuperação.

a) Requisitos do plano de recuperação judicial

Uma vez deferido o processamento da recuperação, o mesmo despacho determinará a intimação do devedor para apresentação do plano de recuperação judicial no prazo improrrogável de 60 dias, sob pena de convalidação (conversão) do processo de recuperação em falência.

Esse plano deverá conter:

- discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a serem empregados (art. 50);
- demonstração de sua viabilidade econômica; e
- laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor, subscrito por profissional legalmente habilitado ou empresa especializada.

b) Meios de recuperação judicial

O plano de recuperação deverá indicar de forma fundamentada os meios pelos quais o devedor pretende superar as dificuldades que enfrenta. O art. 50 da LFRE descreve, em rol



meramente exemplificativo, quais são esses meios que o devedor pode propor em seu plano de recuperação judicial para solução de sua crise econômico-financeira, que podem ser simples, como a “concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas” (inciso I), ou complexos, como a “cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade” (inciso II).

Na prática, geralmente o que se pede é dilação do prazo de pagamento, tal como era na vigência da concordata.

Dentre as medidas que o devedor pode propor para solucionar sua crise, está também a venda judicial de filiais e unidades produtivas isoladas. Nesse caso, o parágrafo único do artigo 60, trouxe uma medida inovadora (“O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, observado o disposto no § 1º do art. 141 desta Lei”), que inclusive foi atacada em ADI junto ao STF, posteriormente julgada improcedente. Sobre tal artigo, vide o **Enunciado 47 das Jornadas de Direito Comercial**: “nas alienações realizadas nos termos do art. 60 da Lei 11.101/2005, não há sucessão do adquirente nas dívidas do devedor, inclusive nas de natureza tributária, trabalhista e decorrentes de acidentes de trabalho”.

Ainda sobre o plano, a lei trouxe algumas diretrizes gerais. Por exemplo:

- O plano de recuperação judicial não poderá prever prazo superior a 1 (um) ano para pagamento dos créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho vencidos até a data do pedido de recuperação judicial.
- O plano não poderá prever prazo superior a 30 (trinta) dias para o pagamento, até o limite de 5 (cinco) salários-mínimos por trabalhador, dos créditos de natureza estritamente salarial vencidos nos 3 (três) meses anteriores ao pedido de recuperação judicial.
- deverá buscar o parcelamento do crédito fiscal;
- se o plano prever a alienação de bens onerados, para que seja viável essa supressão da garantia ou sua substituição, deverá haver a concordância do credor titular da garantia;
- os créditos em moeda estrangeira, para sua conversão em moeda nacional, também dependerão da concordância de quem é o titular desse crédito.

c) Análise e deliberação sobre o plano

Após o devedor apresentar o plano de recuperação, o juiz ordenará a publicação de edital contendo aviso aos credores sobre o recebimento do plano e fixando prazo para a manifestação de eventuais objeções. O prazo para os credores apresentarem objeções é de 30 dias, nos termos do art. 55 da LFRE, contado da publicação da segunda relação de credores (tema que será visto adiante).

Se nenhum credor se opuser ao plano de recuperação judicial, ele será tacitamente aprovado. Nessa hipótese, não será necessária a convocação de assembleia-geral de credores para deliberar sobre o plano. Se houver objeção, quem decidirá a respeito será a assembleia-geral de credores.

Art. 56. Havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o juiz **convocará a assembléia-geral de credores** para deliberar sobre o plano de recuperação.

(...)

§3º O plano de recuperação judicial poderá sofrer **alterações** na assembléia-geral, desde que haja expressa concordância do devedor e em termos que não impliquem diminuição dos direitos exclusivamente dos credores ausentes.

§4º **Rejeitado** o plano de recuperação pela assembléia-geral de credores, o juiz decretará a falência do devedor.



Como visto acima, a assembleia pode aprovar o plano sem alterações ou com alterações, ou, ainda, rejeitar o plano. Em qualquer caso, o resultado é submetido ao juiz, mas a decisão judicial dependerá daquilo que ficou decidido em assembleia.

Para a aprovação do plano, a assembleia-geral de credores será dividida nas classes indicadas no art. 41 da LFRE:

- **1ª classe: credores trabalhistas;**
- **2ª classe: titulares de garantia real;**
- **3ª classe: titulares de privilégios, seja geral, seja especial, além dos quirografários e subordinados;**
- **4ª classe: microempresários individuais e empresários de pequeno porte.**

Será considerado aprovado o plano que for efetivamente aprovado no âmbito de cada uma das classes, observadas as regras constantes do art. 45 da lei.

Nas classes dos credores trabalhistas e dos microempresários individuais e empresários de pequeno porte, será votado por cabeça, ou seja, não será levado em conta o valor do crédito dos credores, mas sim o voto singularizado dos credores.

Já em relação à 2ª e à 3ª classes acima citadas, a aprovação do plano de recuperação, **além de depender da aprovação dos credores em cada classe por cabeça**, exigirá também a **aprovação da maioria dos créditos presentes**. Em outras palavras, exige-se a maioria dos credores e a maioria dos créditos. Há, como se vê, um **requisito cumulativo**.

Por exemplo, se o credor A possuir um crédito de R\$ 100 mil, o credor B possuir um crédito de R\$ 20 mil e o credor C um crédito de R\$ 30 mil e eles forem credores trabalhistas, bastará o voto de quaisquer dois deles (inclusive apenas B e C) para o plano ser aprovado nessa classe.

Todavia, se forem credores com garantia real, B e C sozinhos não conseguem aprovar o plano, pois apenas preenchem o requisito da maioria dos credores, mas não da maioria dos créditos. Por outro lado, A, sozinho, em que pese tenha créditos que correspondam ao dobro do crédito somado dos demais, tampouco logrará obter a aprovação do plano, pois nessas duas classes se exige a maioria por cabeça também. Ressalte-se que essas contagens são feitas com base nos credores e nos créditos **presentes** à Assembleia!

Obs: o STJ entendeu que é possível a criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial, desde que estabelecido um critério **objetivo**, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a anulação de direitos de eventuais credores isolados. (REsp 1.634.844-SP, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019).

Caso qualquer das classes rejeitem o plano, será considerado não aprovado e, em regra, convolar-se-á a recuperação judicial em falência, salvo se presentes os requisitos da *cram down*.

d) *Cram down*

Ainda que rejeitado o plano, há uma hipótese em que o juiz poderá, a despeito de tal fato, homologar o plano de recuperação, desde que presentes os requisitos do art. 58, §§ 1º e 2º, da LFRE, hipótese denominada de *cram down*. Confirmam-se os requisitos:

Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembleia-geral de credores na forma do art. 45 desta Lei.

§ 1º O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não obteve aprovação na forma do art. 45 desta Lei, desde que, na mesma assembleia, tenha obtido, de forma cumulativa:

I – o voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à assembleia, independentemente de classes;



II – a aprovação de 2 (duas) das classes de credores nos termos do art. 45 desta Lei ou, caso haja somente 2 (duas) classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos 1 (uma) delas;

III – na classe que o houver rejeitado, o voto favorável de mais de 1/3 (um terço) dos credores, computados na forma dos §§ 1º e 2º do art. 45 desta Lei.

§ 2º A recuperação judicial somente poderá ser concedida com base no § 1º deste artigo se o plano não implicar tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houver rejeitado.

e) Soberania da AGC e controle exercido pelo magistrado

Existe uma discussão acerca de até onde vai o controle jurisdicional da assembleia geral de credores. Em princípio, trata-se de um órgão soberano, mas doutrina e jurisprudência se debruçam sobre o tema.

O Enunciado 46 das Jornadas de Direito Comercial do CJF, por exemplo, prevê que: “não compete ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores”. No mesmo sentido caminhou a jurisprudência do **STJ**: “cumpridas as exigências legais, o juiz deve conceder a recuperação judicial do devedor cujo plano tenha sido aprovado em assembleia (art. 58, caput, da Lei 11.101/2005), não lhe sendo dado se imiscuir no aspecto da **viabilidade econômica** da empresa” (REsp 1.359.311).

Há também os seguintes enunciados do CJF:

Enunciado 44 das Jornadas de Direito Comercial do CJF: “a homologação de plano de recuperação judicial aprovado pelos credores está sujeita ao controle judicial de legalidade”.

Enunciado 45 das Jornadas de Direito Comercial do CJF: “o magistrado pode desconsiderar o voto de credores ou a manifestação de vontade do devedor, em razão de abuso de direito”.

Os enunciados 44 e 45 se completam e no mesmo sentido já decidiu o **STJ**:

“a assembleia de credores é soberana em suas decisões quanto aos planos de recuperação judicial. Contudo, as deliberações desse plano estão sujeitas aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos a controle judicial” (REsp 1314209/SP).

Assim, frise-se que, em princípio, a assembleia é soberana, não cabendo ao juiz, por exemplo, se imiscuir em aspectos de viabilidade econômica do plano para fins de indeferir homologação de um plano aprovado pela AGC. No entanto, isso não significa que ela está imune ao controle judicial. É possível um controle judicial da assembleia de credores quando se analisa aspectos de legalidade, como na hipótese de abuso de direitos no exercício de votos por parte de um credor.

É possível, em tese, que o Poder Judiciário faça o controle de legalidade do plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores?

Sim. Afigura-se absolutamente possível que o Poder Judiciário, sem imiscuir-se na análise da viabilidade econômica da empresa em crise, promova controle de legalidade do plano de recuperação judicial. Esse controle de legalidade do plano de recuperação não significa a desconsideração da soberania da assembleia geral de credores. À assembleia-geral de credores compete analisar, a um só tempo, a viabilidade econômica da empresa, assim como da consecução da proposta apresentada. Ao Poder Judiciário, por sua vez, incumbe velar pela validade das manifestações expendidas, e, naturalmente, preservar os efeitos legais das normas que se revelarem cogentes. Esse é o entendimento do STJ, firmado no Info 591.



8.3.3. Fase de execução

Aprovado o plano, passa-se à etapa de acompanhamento de seu cumprimento.

a) Aprovação do plano e retirada do nome da devedora dos cadastros de inadimplentes

Observação: O mero deferimento do processamento de recuperação judicial, por si só, não enseja a suspensão ou o cancelamento da negativação do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito e nos tabelionatos de protestos. Segundo o STJ, somente após a concessão da recuperação judicial, com a homologação do plano e a novação dos créditos (arts. 58 e 59), é que pode haver a retirada do nome da recuperanda dos cadastros de inadimplentes.

b) Novação *sui generis* e Súmula 581 do STJ

De acordo com o art. 59 da LFRE, o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos, mas está-se diante de uma novação *sui generis*.

Com efeito, a novação prevista no Código Civil extingue os acessórios e as garantias da dívida, sempre que não houver estipulação em contrário (art. 364). No entanto, na novação prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/2005 ocorre justamente o contrário, ou seja, as garantias são mantidas, sobretudo as garantias reais, as quais só serão suprimidas ou substituídas “mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia”, por ocasião da alienação do bem gravado (art. 50, § 1º).

Ademais, como implica novação das obrigações anteriores, as execuções individuais ajuizadas contra o próprio devedor devem ser extintas. Porém, como é uma novação *sui generis*, as garantias reais ou fidejussórias, de regra, são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.

Nessa linha de inteligência, o STJ entende que a homologação do plano de recuperação judicial da devedora principal não implica a extinção de execução de título extrajudicial ajuizada em face de sócio coobrigado, visto que as garantias (reais ou fidejussórias), como regra, são preservadas.

Por conta disso, o próprio STJ fixou a tese em recursos repetitivos no sentido de que a recuperação judicial do devedor principal **não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória**, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei nº 11.101/2005.

Atualmente, a questão está inclusive sumulada (Súmula 581), no sentido de que a **recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória**.

Outra característica *sui generis* da novação decorrente do plano de recuperação judicial é sua sujeição a uma cláusula resolutiva: em caso de eventual decretação da falência da devedora dentro do curso da ação de recuperação judicial, o § 2º do art. 61 determina que § 2º “os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da recuperação judicial”.



c) Dispensa de garantias

Cabe ressaltar que, na deliberação do plano de recuperação, os credores negociam com a empresa devedora e decidem a extensão de esforços e renúncias que estão dispostos a suportar, no intento de reduzir os prejuízos que se avizinham. Apesar de isso não ser exigido pela lei, os credores poderão decidir dispensar as garantias real e fidejussórias se assim entenderem pertinente. Essa deliberação atinge a todos os credores, inclusive os que não compareceram à Assembleia ou os que, ao comparecerem, abstiveram-se ou votaram contrariamente à homologação do acordo.

Consoante o entendimento do STJ,

se, no âmbito de Assembleia-Geral de Credores, a maioria deles – devidamente representados pelas respectivas classes – optar, por meio de dispositivo expressamente consignado em plano de recuperação judicial, pela supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes em nome dos credores na data da aprovação do plano, todos eles – inclusive os que não compareceram à Assembleia ou os que, ao comparecerem, abstiveram-se ou votaram contrariamente à homologação do acordo estarão indistintamente vinculados a essa determinação”. (Informativo 591).

d) Prazo de duração da recuperação judicial

Se a sociedade beneficiária não cumprir as obrigações decorrentes do plano de recuperação judicial **dentro dos 2 anos seguintes à aprovação do plano**, haverá a convalidação da recuperação em falência, com o retorno às condições originais dos créditos (art. 61 da LFRE). Após tal prazo haverá o encerramento da recuperação judicial e, caso haja inobservância de alguma obrigação prevista no plano para meses posteriores, não haverá o desfazimento da novação, consolidando-se definitivamente as obrigações constantes do plano, cabendo aos credores requererem a execução específica da obrigação do plano ou mesmo pleitearem a falência da devedora, se presente alguma das hipóteses do art. 94 da LFRE.

Atente-se: uma coisa é o plano de recuperação. Outra coisa é o processo de recuperação judicial. Esse não vai durar necessariamente o mesmo tempo do plano de recuperação judicial.

Durante toda a fase de execução, a sociedade vai agregar ao seu nome empresarial a expressão “em recuperação judicial”.

Essa fase de execução se encerra de duas formas possíveis:

- cumprimento de todas as obrigações que se vencerem até 2 anos depois da concessão da recuperação (art. 63 da LFRE);
- pedido de desistência do devedor, o qual deverá ser aprovado pela assembleia de credores.

8.4. Créditos sujeitos à recuperação judicial e *Stay period*

8.4.1. Créditos sujeitos à recuperação judicial

De acordo com o art. 49 da LFRE, “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Mas não é bem assim. Além dos créditos tributários, que não se sujeitam à recuperação judicial, os §§ 3º e 4º do mesmo artigo também preveem exceções:

Art. 49 (...) § 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de



irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

§ 4º Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se refere o inciso II do art. 86 desta Lei.

No tocante aos “credores proprietários” (§ 3º), suas ações e execuções também não se suspendem com o deferimento do processamento da recuperação judicial, porque esses créditos não se sujeitam à recuperação (art. 49, §§ 3º e 4º da LFRE). A lei veda, porém, “durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º [180 dias], a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial”.

De acordo com a jurisprudência do STJ, a competência para analisar se o bem é ou não essencial à atividade empresarial da recuperanda é do juízo da recuperação judicial.

Outro importante entendimento do STJ a respeito do tema é o de que os créditos concernentes a contrato de compra e venda com reserva de domínio não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial da compradora, independentemente de registro da avença em cartório (REsp 1.725.609-RS, julgado em 20/08/2019, DJe 22/08/2019).

Quanto ao adiantamento de câmbio, em 2019 o STJ firmou o entendimento de que “os encargos derivados de adiantamento de contratos de câmbio se submetem aos efeitos da recuperação judicial da devedora” (Informativo 661). Não se pode confundir o valor do principal do contrato de adiantamento de câmbio (que não se sujeita à recuperação), com os encargos (ex: juros de mora) que sobre ele incidem. A despeito de os arts. 49, § 4º, e 86, II, da Lei n. 11.101/2005 estabelecerem a extraconcursalidade dos créditos referentes a adiantamento de contratos de câmbio, há de se notar que tais normas não dispõem, especificamente, quanto à destinação que deve ser conferida aos encargos incidentes sobre o montante adiantado ao exportador pela instituição financeira. Inexistindo regra expressa a tratar da questão, a hermenêutica aconselha ao julgador que resolva a controvérsia de modo a garantir efetividade aos valores que o legislador privilegiou ao editar o diploma normativo, e, no caso, sujeição dos encargos aos efeitos do procedimento recuperacional “é a medida que mais se coaduna à finalidade retro mencionada, pois permite que a empresa e seus credores, ao negociar as condições de pagamento, alcancem a melhor saída para a crise enfrentada”. (REsp 1.810.447-SP, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019).

8.4.2. Stay period

O art. 52, III da LFRE determina que o juiz, ao deferir o processamento da recuperação judicial,

ordenará a **suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor**, na forma do art. 6º desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 6º desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 desta Lei.

O art. 6º da LFRE, por sua vez, tem a seguinte redação: “(...) o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário”.

Assim, a regra é a suspensão das ações e execuções individuais contra o devedor, devendo-se ressaltar, porém, as **ações que demandam quantia ilíquida** (art. 6º, § 1º), as



reclamações trabalhistas (art. 6º, § 2º), as **execuções fiscais** (art. 6º, § 7º) e as ações e execuções movidas por credores cujos créditos não se sujeitam à recuperação judicial (art. 49, §§ 3º e 4º: **alienação fiduciária, arrendamento mercantil** etc.).

Na recuperação judicial, a **suspensão de que trata o art. 6º da LFRE é temporária (stay period)**:

na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial (§ 4º).

Cabe menção a recente entendimento do STJ no sentido de que o Juízo da recuperação é competente para avaliar se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência objetivando antecipar o início do *stay period* (pausa momentânea de 180 dias corridos das ações e execuções) ou suspender os atos expropriatórios determinados em outros juízos, antes mesmo de deferido o processamento da recuperação (STJ. 2ª Seção. CC 168.000-AL, julgado em 11/12/2019).

Outra importante discussão é sobre a possibilidade ou não de prorrogar o prazo do *stay period*. Em que pese a literalidade do § 4º do art. 6º no sentido de sua impossibilidade, doutrina e jurisprudência entendem de modo contrário.

Cite-se, por exemplo, o Enunciado 42 das Jornadas de Direito Comercial: “o prazo de suspensão previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005 pode **excepcionalmente** ser prorrogado, se o retardamento do feito não puder ser imputado ao devedor”.

No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ:

(...) a extrapolação do prazo de 180 dias previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005 não causa o automático prosseguimento das ações e das execuções contra a empresa recuperanda, senão quando comprovado que sua desídia causou o retardamento da homologação do plano de recuperação (AgRg no CC 113.001/DF; no mesmo sentido: REsp 1.193.480/SP e AgRg no CC 111.614/DF).

Quanto às **execuções fiscais**, embora elas realmente não se suspendam (**art. 6º, § 7º da LFRE**), o STJ tem entendido que, em respeito ao princípio da preservação da empresa, é incompatível o cumprimento da recuperação judicial e o prosseguimento normal dessas execuções (com penhoras, bloqueios de ativos etc.), porque isso atinge o patrimônio do devedor e pode comprometer o sucesso do plano de recuperação. Assim, quaisquer atos de constrição do patrimônio do devedor devem se submeter ao crivo do juízo da recuperação judicial, mesmo que sejam referentes a eventual execução fiscal. Nesse sentido: “apesar de a execução fiscal não se suspender em face do deferimento do pedido de recuperação judicial (art. 6º, § 7º, da LF n. 11.101/05, art. 187 do CTN e art. 29 da LF n. 6.830/80), submetem-se ao crivo do juízo universal os atos de alienação voltados contra o patrimônio social das sociedades empresárias em recuperação, em homenagem ao princípio da preservação da empresa” (CC 114.987/SP; no mesmo sentido: AgInt no REsp 1605862/SC, AgInt no CC 140.021/MT, AgRg no REsp 1.519.405/PE e AgRg no AREsp 760.111/RS).

8.5. Habilitação dos créditos, divergências e impugnações

Um dos documentos que devem acompanhar a inicial da recuperação judicial é a relação de credores. Ao deferir o processamento da recuperação judicial, o juiz determina a publicação dessa relação, a fim de que os credores a analisem e eventualmente apresentem habilitações de créditos (quando não há menção, na relação de credores, a determinado crédito) ou divergências (quando seu crédito está equivocado).



O prazo para a habilitação ou apresentação de divergências é de 15 dias (art. 7º, § 1º).

Quem faz todo processo de habilitação de crédito na lei nova é o administrador judicial, o juiz participa se houver alguma impugnação.

Apresentados os pedidos de habilitação ou as divergências, o administrador judicial, com base na relação inicial fornecida pelo devedor e nos documentos apresentados pelos credores nas habilitações/divergências, fará publicar, no **prazo de 45 (quarenta e cinco) dias** novo “edital contendo a relação de credores” (art. 7º, § 2º da LRE). Observe-se que é a partir da publicação desse edital que começa a correr o prazo de 30 dias para os credores apresentarem objeções ao plano de recuperação judicial.

Pode ser que algum credor não tenha apresentado sua respectiva habilitação/divergência no prazo legal de 15 (quinze) dias do art. 7º, § 1º da LFRE, fazendo-o posteriormente. Nesse caso, a habilitação/divergência é considerada **retardatária**, nos termos do **art. 10 da LFRE**.

Se as habilitações/divergências retardatárias forem apresentadas antes da homologação do quadro-geral de credores, elas serão recebidas e processadas como impugnação (art. 10, § 5º da LFRE). Se, no entanto, já tiver sido homologado o quadro-geral, o credor retardatário terá que requerer ao juízo a sua retificação em ação própria, que obedecerá ao procedimento comum do novo CPC (art. 10, § 6º da LFRE). Sobre o tema, vide o seguinte julgado do STJ:

STJ - A ação de habilitação retardatária de crédito deve ser ajuizada até a prolação da decisão de encerramento do processo recuperacional, pois uma vez encerrada a recuperação judicial, não se pode mais autorizar a habilitação ou a retificação de créditos. A única via que ainda resta para esse credor será a ação judicial autônoma que tramitará pelo rito ordinário, nos termos do art. 10, § 6º da LFRE (STJ. 3ª Turma. REsp 1.840.166-RJ, julgado em 10/12/2019).

Enfim, contra essa relação de credores feita pelo administrador judicial, “o comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público” terão **10 (dez) dias** para apresentar **impugnação** (art. 8º da LFRE), que será autuada em apartado. Caso, todavia, não haja impugnação, a referida relação se consolidará como quadro-geral de credores (art. 14 da LFRE).

Obs.: o comitê de credores é um órgão não obrigatório, que pode existir quando for requerido pela assembleia geral ou se o juiz entender pela sua instalação.

Após autuar as impugnações em apartado, o **cartório providencia a intimação dos credores impugnados**, os quais se manifestarão no **prazo de 5 dias** dessa intimação.

Feito isso, serão intimados o devedor ou o representante legal do devedor, bem como o comitê de credores. Vencidos os prazos, quem dará o parecer será o administrador judicial **em 5 dias**.

Os autos, então, retornam ao juiz. Se for necessária a dilação probatória, ele designará a audiência de instrução e julgamento. Não sendo o caso de designar a audiência, o juiz poderá julgar a impugnação desde já.

Homologado o quadro-geral, ele ainda poderá ser alterado, tanto por eventual ação de credor retardatário, conforme já mencionado (art. 10, § 6º da LFRE), quanto por ação do administrador judicial, qualquer credor, comitê de credores ou Ministério Público, desde que, nesse caso, se demonstre que houve “falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou, ainda, documentos ignorados na época do julgamento do crédito ou da inclusão no quadro-geral de credores” (art. 19 da LFRE).

IMPORTANTE: de acordo com o STJ, uma vez que o procedimento de habilitação de crédito tem **caráter contencioso**, com instrução probatória, o título que o embasa não precisa ser um título executivo, entendimento que vale tanto para a lei anterior quanto para a lei atual (REsp 992.846/PR).



O STJ também possui entendimento no sentido de que o procedimento de impugnação de crédito é uma ação incidental de natureza declaratória, não mero incidente processual, com possibilidade inclusive de produção de provas e audiência de instrução e julgamento. Por tal razão,

No caso de haver pronunciamento a respeito do crédito e sua classificação, mérito da ação declaratória, o agravo de instrumento interposto contra essa decisão, julgado por maioria, deve se submeter à técnica de ampliação do colegiado prevista no artigo 942, § 3º, II, do Código de Processo Civil de 2015. (REsp 1.797.866-SP).

O STJ também firmou o entendimento de que são devidos honorários advocatícios nos casos em que a habilitação de crédito é impugnada, porque nesse caso a impugnação confere litigiosidade ao procedimento (REsp 1197177/RJ e AgRg no AREsp 62.801/SP).

8.6. Cessão fiduciária de créditos

Pode ser que a propriedade fiduciária seja constituída sobre créditos. Isso ocorre quando o empresário dá em garantia créditos que tem a receber (recebíveis), constituindo garantia fiduciária. Isto é feito a partir da abertura de uma conta, os recebíveis entrarão nesta conta e irão direto para o Banco credor. Então, quando há pedido de recuperação judicial, caso se entenda que esses créditos não se sujeitam à Recuperação Judicial, o devedor não poderá incluir no plano e nem terá acesso a esse dinheiro (“travas bancárias”), ficando sua recuperação comprometida.

Assim, foi lançada a tese de que esses contratos seriam ilegítimos, uma vez que não se poderia constituir propriedade fiduciária sobre créditos e, ainda, argumentando com base no princípio da preservação da empresa, pois estariam sendo criadas travas bancárias, impedindo o empresário de se recuperar, requerendo-se aos juízes que desconsiderassem tais contratos.

Todavia, o STJ já firmou jurisprudência sobre o tema:

a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, possuem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3.º, da Lei n.º 11.101/2005 (REsp 1202918/SP; no mesmo sentido: REsp 1263500/ES, AgRg no REsp 1.181.533/MT e AgRg no REsp 1.326.851/MT).

8.7. Sócio solidário

Imagine que uma sociedade está em crise, contando com empréstimos, nos quais seus sócios são avalistas. Não tendo pago, a empresa está sendo executada, assim como seu sócio avalista. A sociedade, então, pede recuperação judicial, sendo deferido o processamento pelo juiz, que também determina a suspensão das ações de execuções individuais contra a sociedade empresária.

No caso de credor executando contrato contra a empresa e contra o avalista, a execução continuou contra o sócio. O advogado do sócio entra com pedido na execução, requerendo a suspensão desta em relação ao sócio (avalista) também, em virtude do disposto na parte final do artigo 6º da LFRE.

O juiz poderá indeferir o pedido, sob a fundamentação de que a expressão “**sócio solidário**” constante da parte final do art. 6º da LFRE, de acordo com o entendimento do STJ, trata apenas do sócio que tem responsabilidade ilimitada e solidária com a sociedade, como o sócio da sociedade em nome coletivo, por exemplo. Segundo esse entendimento, a expressão não abrange sócios de responsabilidade limitada que são avalistas da sociedade em certas operações. Nesse caso, aplica-se o art. 49, § 1º, da LFRE (“os credores do devedor em



recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”), de modo que a execução se suspende contra o devedor (sociedade empresária que pediu recuperação judicial), mas não contra os sócios avalistas (AgRg no REsp 1.342.833/SP). No mesmo sentido, o **enunciado 43 das Jornadas de Direito Comercial do CJF** dispõe o seguinte: “a suspensão das ações e execuções previstas no art. 6º da Lei n. 11.101/2005 não se estende aos coobrigados do devedor”.

8.8. Órgãos da recuperação judicial

São três os órgãos da recuperação judicial:

- administrador judicial;
- assembleia-geral de credores;
- comitê de credores.

8.8.1. Assembleia-geral

A assembleia-geral é um órgão colegiado e deliberativo, que visa manifestar a vontade predominante dos credores sujeitos ao plano de recuperação judicial.

a) Convocação da assembleia

Poderá a assembleia ser **convocada pelo juiz**, mas também poderá ser **convocada pelos próprios credores**, desde que os créditos desses credores **representem ao menos 1/4 do passivo do recuperando (25%)**.

Para instaurar a assembleia, é necessário que haja credores que representem **mais da metade do passivo em cada classe**. Caso não seja alcançado tal quórum, será necessário fazer uma **2ª convocação**, devendo ser instaurada a assembleia com **qualquer número de credores**.

b) Competências da assembleia

- aprovar ou rejeitar, ou revisar, o plano de recuperação judicial;
- aprovar, se necessário, a instalação do comitê dos credores e eleger os seus membros: o comitê é órgão facultativo;
- deliberar sobre qualquer matéria de interesse dos credores.

Quando a deliberação versar sobre o **plano de recuperação** ou sobre a **composição do comitê**, a assembleia **será dividida em classe**, ao invés de a deliberação se dar no plenário da assembleia (todos os credores). São elas (art. 41 da LFRE):

- **1ª classe: credores trabalhistas;**
- **2ª classe: titulares de garantia real;**
- **3ª classe: titulares de privilégios, seja geral, seja especial, além dos quirografários e subordinados;**
- **4ª classe: microempresários individuais e empresários de pequeno porte.**

Mas cuidado: quando se tratar da **composição e constituição do comitê**, as instâncias classistas da assembleia irão se organizar de forma que **os credores com privilégios especiais passarão a compor a mesma classe dos credores com garantia real**, mas **somente na questão da eleição do comitê**.

Conforme já visto, **o plano de recuperação será deliberado e votado em cada classe**, sendo aprovado por cabeça nas classes dos credores trabalhistas e dos microempresários individuais e empresários de pequeno porte, isto é, não é levado em conta o crédito dos credores, mas o voto singularizado dos credores.



Já em relação à 2ª e à 3ª classes acima citadas, a aprovação do plano de recuperação, **além de depender da aprovação dos credores em cada classe por cabeça**, exigirá também a **aprovação considerando o percentual que cada um deles tem no passivo do sujeito com recuperação judicial**. Em outras palavras, exige-se a maioria dos credores e a maioria dos créditos. Há, como se vê, um **requisito cumulativo**.

8.8.2. Comitê de credores

O comitê é órgão facultativo, pois quem decide a sua instalação é a assembleia geral.

Cada **classe** de credores **elegerá 1 membro, com 2 suplentes**. Nessa deliberação, os credores com privilégio especial passarão a compor a classe dos credores de garantia real (2ª classe).

a) Competências do comitê

A competência do comitê é **eminentemente fiscal**, fiscalizando a atuação do **administrador judicial**, como os bens estão sendo administrados, como é feita a realização do ativo para pagar o passivo etc. Em síntese, suas atribuições serão as seguintes:

Na recuperação judicial e na falência:

- a) fiscalizar as atividades e examinar as contas do administrador judicial;
- b) zelar pelo bom andamento do processo e pelo cumprimento da lei;
- c) comunicar ao juiz, caso detecte violação dos direitos ou prejuízo aos interesses dos credores;
- d) apurar e emitir parecer sobre quaisquer reclamações dos interessados;
- e) requerer ao juiz a convocação da assembleia-geral de credores;
- f) manifestar-se nas hipóteses previstas na Lei Falimentar.

Na recuperação judicial:

- a) fiscalizar a administração das atividades do devedor, apresentando, a cada 30 (trinta) dias, relatório de sua situação;
- b) fiscalizar a execução do plano de recuperação judicial;
- c) submeter à autorização do juiz, quando ocorrer o afastamento do devedor nas hipóteses previstas na Lei Falimentar, a alienação de bens do ativo permanente, a constituição de ônus reais e outras garantias, bem como atos de endividamento necessários à continuação da atividade empresarial durante o período que antecede a aprovação do plano de recuperação judicial.

8.8.3. Administrador judicial

O administrador judicial é o auxiliar do juiz, sendo supervisionado diretamente pelo magistrado.

Será **nomeado pelo despacho do juiz que determinar que se processe a recuperação judicial**. Não é do despacho que concede a recuperação judicial.

Poderá ser administrador judicial a pessoa idônea, preferencialmente advogado, economista, administrador de empresas ou contador, ou pessoa jurídica especializada.

a) Funções do administrador

O administrador tem como função administrar a sociedade nos casos em que houver o afastamento dos diretores da sociedade e enquanto não for eleito gestor judicial pela assembleia, o qual fará as mesmas atividades que os administradores faziam.



Não tendo o juiz afastado os diretores e administradores da sociedade, o administrador judicial terá a função de fiscal, analisará os créditos e presidirá a assembleia geral de credores, mas irá precipuamente fiscalizar a atuação daqueles que estão gerindo a sociedade.

8.9. Certidões Negativas de Débitos Tributários

Art. 57 da LFRE. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembleia-geral de credores ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de credores, o devedor apresentará **certidões negativas de débitos tributários** nos termos dos arts. 151, 205, 206 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional.

Dispositivo polêmico, pois ou o plano foi aprovado tacitamente, porque não houve objeções, ou o plano foi apresentado em assembleia. Há quem critique muito esse dispositivo, sob a alegação de que há uma sanção política, questionando-se a constitucionalidade desse dispositivo.

Para compensar, tem-se o dispositivo 68:

Art. 68 da LFRE. As Fazendas Públicas e o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS poderão deferir, nos termos da **legislação específica**, parcelamento de seus créditos, em sede de recuperação judicial, de acordo com os parâmetros estabelecidos na Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.

Primeiro, diz-se que há necessidade de apresentar CND antes da concessão de recuperação, depois se diz que a Fazenda Pública pode oferecer parcelamento nos termos de legislação específica para os devedores em recuperação.

Assim, se a empresa parcelar terá certidão positiva com efeitos negativos, porque o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário.

Sobre o tema, firmou-se inicialmente o seguinte entendimento:

Enunciado 55 das Jornadas de Direito Comercial: “o parcelamento do crédito tributário na recuperação judicial é um direito do contribuinte, e não uma faculdade da Fazenda Pública, e, **enquanto não for editada lei específica, não é cabível a aplicação do disposto no art. 57** da Lei n. 11.101/2005 e no art.191-A do CTN”.

STJ: o parcelamento tributário é direito da empresa em recuperação judicial que conduz a situação de regularidade fiscal, de modo que eventual descumprimento do que dispõe o art. 57 da LRF só pode ser atribuído, ao menos imediatamente e por ora, à ausência de legislação específica que discipline o parcelamento em sede de recuperação judicial, **não constituindo ônus do contribuinte, enquanto se fizer inerte o legislador, a apresentação de certidões de regularidade fiscal** para que lhe seja concedida a recuperação (REsp 1187404/MT).

Atualmente, porém, já foi editada a lei específica prevendo parcelamento para devedores em recuperação judicial (**Lei nº 13.043/2014, cujo art. 43 acresceu o art. 10-A na Lei nº 10.522/2002**). Agora, o empresário, a sociedade empresária e a EIRELI, a partir do momento em que pleiteiam a recuperação judicial, podem ter seus débitos com a Fazenda Nacional divididos em 84 parcelas mensais e consecutivas.

Ainda há doutrinadores que continuam defendendo a inexigência de CND, não apenas com base nos argumentos anteriormente mencionados, mas também porque o parcelamento da Lei 13.043/2014 é para tributo federal. Além disso, esse parcelamento, segundo quem atua na área, é ruim, pois os devedores não conseguem cumprir os requisitos para parcelar, continuando a pendência.

Para fins de concurso, interpretando a decisão da corte especial do STJ sobre o tema, enquanto não havia parcelamento tributário previsto em lei específica, não se exigia CND. Uma



vez que passou a ser regulamentado o parcelamento, pode-se exigir a CND, levando-se em conta as circunstâncias mencionadas.

8.10. Recuperação judicial especial para ME/EPP

A lei estabeleceu um procedimento específico para o plano especial de recuperação judicial para ME/EPP. Originalmente esse plano era bem diferente do plano normal de recuperação judicial, porque só abrangia créditos quirografários, limitava-se ao parcelamento das dívidas em x tempo, carência de y, juros de 12% ao ano. Atualmente, porém, encontra-se regulado nos seguintes dispositivos da LFRE:

Art. 70. As pessoas de que trata o art. 1º desta Lei e que se incluam nos conceitos de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da legislação vigente, sujeitam-se às normas deste Capítulo.

§ 1º As microempresas e as empresas de pequeno porte, conforme definidas em lei, poderão apresentar **plano especial de recuperação judicial**, desde que afirmem sua intenção de fazê-lo na petição inicial de que trata o art. 51 desta Lei.

§ 2º Os credores não atingidos pelo plano especial não terão seus créditos habilitados na recuperação judicial.

Art. 71. O plano especial de recuperação judicial será apresentado no prazo previsto no art. 53 desta Lei e **limitar-se á às seguintes condições:**

I - abrangerá todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, excetuados os decorrentes de repasse de recursos oficiais, os fiscais e os previstos nos §§ 3º e 4º do art. 49;

II - preverá parcelamento em até **36 parcelas mensais**, iguais e sucessivas, acrescidas de juros equivalentes à taxa **SELIC**, podendo conter ainda a proposta de abatimento do valor das dívidas;

III – preverá o pagamento da 1ª parcela no **prazo máximo de 180 dias**, contado da distribuição do pedido de recuperação judicial;

IV- estabelecerá a necessidade de autorização do juiz, após ouvido o administrador judicial e o Comitê de Credores, para o devedor aumentar despesas ou contratar empregados.

Parágrafo único. O pedido de recuperação judicial com base em plano especial não acarreta a suspensão do curso da prescrição nem das ações e execuções por créditos não abrangidos pelo plano.

Art. 72. Caso o devedor de que trata o art. 70 desta Lei opte pelo pedido de recuperação judicial com base no plano especial disciplinado nesta Seção, não será convocada assembléia-geral de credores para deliberar sobre o plano, e o juiz concederá a recuperação judicial se atendidas as demais exigências desta Lei.

Parágrafo único. O juiz julgará improcedente o pedido de recuperação judicial e decretará a falência do devedor se houver objeções, nos termos do art. 55, de credores titulares de mais da metade de qualquer uma das classes de créditos previstos no art. 83, computados na forma do art. 45, todos desta Lei.

8.11. Convolução em falência

A convolução da recuperação judicial em falência é possível em quatro hipóteses:

- **deliberação dos credores pelo voto da maioria simples em plenário;**
- **não apresentação do plano de recuperação judicial no prazo de 60 dias;**
- **rejeição do plano apresentado pela assembleia;**
- **descumprimento das obrigações do plano de recuperação judicial que se vencerem em até dois anos da data da concessão da recuperação.**

Convolada a recuperação judicial em falência, haverá, conforme já visto, o retorno dos créditos a suas configurações originais, descontando-se os valores porventura pagos.

Além disso, há algumas benesses concedidas em prol de quem continuou contratando com a sociedade em recuperação judicial.

Inicialmente, todos os créditos que tiverem surgido no curso da recuperação judicial serão considerados extraconcursais no processo falimentar (e serão pagos antes dos créditos concursais). Além disso, haverá outra benesse. Suponha a seguinte situação: o credor A possuía um crédito quirografário de R\$ 100 mil em novembro de 2019; em dezembro de 2019 veio a recuperação judicial; continuou contratando com a sociedade já em recuperação judicial, com um montante de R\$ 30.000,00 de serviços fornecidos.

Nesse contexto, os R\$ 30.000,00 no curso da recuperação já vimos que serão considerados extraconcursais. Além disso, pega-se o valor correspondente aos serviços ou bens fornecidos à recuperanda como forma de melhorar a situação do crédito anterior à recuperação. No caso do exemplo acima, ao invés de os R\$ 100.000,00 originais continuarem sendo integralmente quirografários, R\$ 30.000,00 passarão a ter privilégio geral e os R\$ 70.000,00 restantes continuarão quirografários (art. 67, p.u., da LFRE).

9. Falência

9.1. Introdução

A falência se destina a apurar passivo e ativo de um devedor empresário que está insolvente (insolvência econômica) para distribuir esse passivo entre seus credores e tentar pagar ao máximo os créditos que deve.

Com a Lei nº 11.101/05, a falência foi deixada cada vez mais em último plano, pois o maior objetivo é preservar a empresa, permitindo, de todas as formas possíveis, que o devedor consiga a recuperação. Mesmo assim, eventualmente a falência é decretada e o processo de falência propriamente dito se instaura.

De acordo com a doutrina, a falência possui três pressupostos:

- **pressuposto material subjetivo (devedor empresário ou sociedade empresária)**
- **pressuposto material objetivo (estado de insolvência jurídica)**
- **pressuposto formal (sentença que decreta a falência)**

Conceito: “execução concursal do devedor empresário insolvente”, ou seja, falência é um processo de execução, mas não individual, e sim concursal, porque é voltada contra um devedor que está insolvente. Contra devedor insolvente não é recomendável a execução individual, porque se cada credor for executar individualmente uns irão receber e outros não.

Ainda que na falência alguns credores eventualmente possam não receber, por ser um processo concursal, ou seja, que reúne todos os credores em um só processo, tem-se, de forma mais fácil, como respeitar a preferência ou o privilégio de cada crédito.

Conforme visto no tópico sobre a incidência subjetiva da Lei nº 11.101/2005, apenas o devedor empresário pode ter sua falência decretada. Devedores não empresários submetem-se a outro rito de execução: o da execução contra devedores insolventes ainda hoje regida pelos arts. 748 e ss. do CPC/73.

9.2. Etapas do processo falimentar

O processo falimentar compreende três etapas, cujos principais atos serão aprofundados na sequência:



- **etapa pré-falencial:** indivíduo ingressa com o pedido de falência. Aqui, ainda não há decretação da falência. Essa etapa se encerra no momento da sentença declaratória de falência;
- **etapa falencial:** inicia-se no momento da decretação da falência e se conclui com o encerramento da falência;
- **etapa de reabilitação:** há uma extinção das responsabilidades do falido, e ele volta a se tornar apto ao exercício da atividade empresarial.

9.3. Juízo da falência

A competência do processo de falência, de recuperação judicial e de recuperação extrajudicial é do juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial de empresa que tenha sede fora do Brasil.

Conforme já visto, não necessariamente o principal estabelecimento será a sede. O principal estabelecimento **é aquele em que está concentrado o maior número de negócios daquela empresa**, motivo pelo qual é o principal estabelecimento. Em outras palavras, reger-se-á pelo critério econômico a definição do juízo competente a competência do processo, ainda que a sede seja diversa.

Outra característica do juízo da falência é de que ele é **universal**. Isso quer dizer que todas as ações relativas aos bens, interesses e negócios da massa falida deverão ser julgadas no juízo em que tramita o processo de falência.

Todavia, existem cinco exceções em que **não haverá a atração da resolução da questão para o juízo falimentar**:

- **ações que não são reguladas pela lei falimentar, em que a massa falida seja autora;**
- **reclamação trabalhista, até a definição do valor do crédito;**
- **execuções tributárias e créditos não tributários se o crédito estiver inscrito em dívida ativa;**
- **ação de conhecimento em que houver a União como parte, ou como interessada, hipótese em que será tramitada perante a Justiça Federal;**
- **ação que demanda quantia ilíquida: quando a quantia se tornar líquida, haverá habilitação do crédito no juízo universal.**

9.4. Legitimados a pedir falência

O art. 97 da LFRE prevê o seguinte:

Art. 97. Podem requerer a falência do devedor: I – o próprio devedor, na forma do disposto nos arts. 105 a 107 desta Lei; II – o cônjuge sobrevivente, qualquer herdeiro do devedor ou o inventariante; III – o cotista ou o acionista do devedor na forma da lei ou do ato constitutivo da sociedade; IV – **qualquer credor**.

§ 1º O credor empresário apresentará certidão do Registro Público de Empresas que comprove a regularidade de suas atividades.

§ 2º O credor que não tiver domicílio no Brasil deverá prestar caução relativa às custas e ao pagamento da indenização de que trata o art. 101 desta Lei.

O inciso I se refere à autofalência.

O inciso III se refere ao sócio da sociedade que pode pedir falência, o que não se confunde com a autofalência.

Embora a lei use a expressão “qualquer credor” no inciso IV, o STJ tem diversos precedentes no sentido de que **a Fazenda Pública não tem legitimidade, nem interesse de agir**, para pedir a falência do devedor (REsp 164.389/MG e REsp 287.824/MG). A Corte Superior entende que, uma vez que a Fazenda Pública dispõe de instrumento específico para cobrança



do crédito tributário, a Lei nº 6.380/1980 (Lei de Execuções Fiscais), falta-lhe interesse de agir para o pedido de falência. No mesmo sentido, foi aprovado o **enunciado 56 das Jornadas de Direito Comercial do CJF**: “A Fazenda Pública não possui legitimidade ou interesse de agir para requerer a falência do devedor empresário”.

A lei estabelece alguns requisitos para determinados credores promoverem o pedido de falência:

- **credor empresário deverá comprovar a regularidade do exercício da empresa:** perceba então que a sociedade irregular poderá requerer a sua autofalência, mas não poderá pedir a falência do devedor;
- **credor estrangeiro:** deverá prestar caução, pois poderá ser responsabilizado se agiu com dolo;
- **exibição do título.**

Obs: Pelo inciso IV, o credor não precisa ser empresário para pleitear a falência do devedor, pode ser qualquer pessoa. Porém, se o credor for empresário, precisa apresentar certidão da Junta Comercial que comprove sua situação regular.

Não é necessário que o requerente da falência tenha o seu próprio título vencido, pois poderá pedir falência fundando-se em título de outro credor. Ex.: João pede a falência de Souza Cruz S.A., pois ela não pagou Pedro Comércio de Cigarros Ltda., estabelecendo que o título da credora supera 40 salários mínimos.

9.5. Fundamentos do pedido de falência (insolvência jurídica)

Para a decretação da falência do devedor, é necessário demonstrar a sua insolvência. No entanto, a legislação não exige a demonstração de uma insolvência real ou econômica (passivo maior que ativo – art. 748 do CPC/73), contentando-se com a demonstração de uma **insolvência presumida ou jurídica**: a lei descreve algumas situações que, se caracterizadas, presumem a insolvência do devedor, autorizando o pedido e a eventual decretação de sua falência (REsp 733.060 e REsp 1.433.652).

O que é insolvência econômica? Situação de patrimônio negativo.

Essa é a insolvência necessária para que seja requerida a falência de um devedor empresário? Não. A legislação falimentar não exige a demonstração de uma insolvência técnica/econômica/real, contenta-se com a demonstração de uma insolvência presumida/jurídica, decorrente de hipóteses previamente definidas em lei.

As hipóteses de insolvência jurídica para fins falimentares estão previstas no art. 94 da LFRE:

Art. 94. Será decretada a falência do devedor que:

- I – sem relevante razão de direito, não paga, no vencimento, obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos **protestados** cuja soma ultrapasse o equivalente a **40 salários-mínimos** na data do pedido de falência;
- II – executado por **qualquer quantia líquida**, não paga, não deposita e não nomeia à penhora bens suficientes dentro do prazo legal;
- III – pratica qualquer dos seguintes **atos**, exceto se fizer parte de plano de recuperação judicial: (...)

9.5.1. Impontualidade injustificada

A hipótese do inciso I do art. 94 é chamada de **impontualidade injustificada**. A maioria dos pedidos de falência incidem nesse inciso. Ressalte-se que a impontualidade **injustificada** é aquela em que não há razão relevante de direito para que o devedor não pague a dívida no vencimento.



Mesmo antes de 2001, os Tribunais já não estavam aceitando pedidos de falência com base em dívida de pequeno valor, tendo o legislador incorporado esse entendimento jurisprudencial na lei. Porém, quando havia pedido de falência embasado em uma dívida muito baixa, o juiz fundamentava que aquela dívida não era suficiente para presumir a insolvência do devedor e extingua o processo de falência liminarmente. Em outras palavras, a jurisprudência criou um requisito que não estava na lei “a dívida precisa ser de monta X que presuma a insuficiência do devedor”.

Depois do estabelecimento do patamar mínimo da dívida em 40 salários mínimos, não há mais dúvidas de que não cabe pedido de falência para créditos de pouca monta. Porém, alguns juízes mesmo com um patamar fixado, continuaram a analisar se o valor da dívida é mesmo suficiente para caracterizar a insolvência do devedor.

Então, decidiu o **STJ**:

no sistema inaugurado pela Lei n. 11.101/2005, os pedidos de falência por impontualidade de dívidas aquém do piso de 40 (quarenta) salários mínimos são legalmente considerados **abusivos**, e a própria lei encarrega-se de embaraçar o atalhamento processual, pois elevou tal requisito à condição de procedibilidade da falência (art. 94, inciso I). Porém, superando-se esse valor, a ponderação legal já foi realizada segundo a ótica e prudência do legislador. (...) Assim, tendo o pedido de falência sido aparelhado em impontualidade injustificada de títulos que superam o piso previsto na lei (art. 94, I, Lei n. 11.101/2005), por absoluta **presunção legal**, fica afastada a alegação de atalhamento do processo de execução/cobrança pela via falimentar. Não cabe ao Judiciário, nesses casos, obstar pedidos de falência que observaram os critérios estabelecidos pela lei, a partir dos quais o legislador separou as situações já de longa data conhecidas, de uso controlado e abusivo da via falimentar (REsp 1433652/RJ).

Quando se trata de **impontualidade injustificada**, a lei exige alguns requisitos para a obrigação: deve ser **obrigação líquida, representada por título ou títulos executivos devidamente protestados**. De acordo com o § 3º do art. 94, exige-se que o protesto seja um protesto especial para fins falimentares.

De acordo com o § 2º do art. 94, § 2º “ainda que líquidos, não legitimam o pedido de falência os créditos que nela não se possam reclamar”, a exemplo das obrigações a título gratuito e das despesas que os credores fizerem para tomar parte na recuperação judicial ou na falência (art. 5º, I e II, da LFRE).

Ademais, exige-se o valor do título ou dos títulos em atraso seja superior a 40 salários mínimos na data da falência. **Havendo credores com créditos menores, poderão estes se reunir em litisconsórcio, a fim de que se alcance o montante de 40 salários mínimo e promovam o protesto do título para fins de falência**, nos termos do § 1º do art. 94.

9.5.2. Execução frustrada

Também justifica a decretação da falência a execução frustrada (art. 94, II, da LFRE).

A frustração da execução se caracteriza quando o devedor, executado por qualquer quantia líquida (ou seja, independentemente do valor):

- **não paga;**
- **não deposita;**
- **nem nomeia à penhora bens suficientes dentro do prazo legal.**

Perceba-se que, no caso de execução frustrada, há uma **tríplice omissão**.

O credor, munido de uma certidão judicial trazendo a tríplice omissão, ingressa com o pedido de falência, não precisando o título estar protestado, tampouco que seu valor ultrapasse os 40 salários mínimos exigidos na hipótese da impontualidade injustificada.



9.5.3. Prática de atos de falência

São comportamentos que denotam que o devedor esteja insolvente.

Tais comportamentos estão previstos no inciso III do art. 94 da LFRE:

- a) procede à liquidação precipitada de seus ativos ou lança mão de meio ruinoso ou fraudulento para realizar pagamentos;
- b) realiza ou, por atos inequívocos, tenta realizar, com o objetivo de retardar pagamentos ou fraudar credores, negócio simulado ou alienação de parte ou da totalidade de seu ativo a terceiro, credor ou não;
- c) transfere estabelecimento a terceiro, credor ou não, sem o consentimento de todos os credores e sem ficar com bens suficientes para solver seu passivo;
- d) simula a transferência de seu principal estabelecimento com o objetivo de burlar a legislação ou a fiscalização ou para prejudicar credor;
- e) dá ou reforça garantia a credor por dívida contraída anteriormente sem ficar com bens livres e desembaraçados suficientes para saldar seu passivo;
- f) ausenta-se sem deixar representante habilitado e com recursos suficientes para pagar os credores, abandona estabelecimento ou tenta ocultar-se de seu domicílio, do local de sua sede ou de seu principal estabelecimento;
- g) deixa de cumprir, no prazo estabelecido, obrigação assumida no plano de recuperação judicial.

9.6. Defesas do Devedor

Há pequenas alterações procedimentais a depender do autor do pedido de falência. Na **autofalência**, o próprio devedor pede a sua falência, instruindo-a com **balanço patrimonial**, **relação de credores** e o seu **contrato social** (obs: o qual não precisará estar registrado, permitindo que a sociedade irregular peça autofalência).

Já quando a **falência é requerida por terceiros**, o rito vai prever a citação do empresário devedor para que ele se manifeste no **prazo de 10 dias**. Confira-se:

Art. 98. Citado, o devedor poderá apresentar contestação no **prazo** de 10 (dez) dias. Parágrafo único. Nos pedidos baseados nos incisos I e II do **caput** do art. 94 desta Lei, o devedor poderá, no prazo da contestação, **depositar o valor correspondente ao total do crédito**, acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios, hipótese em que a falência não será decretada e, caso julgado procedente o pedido de falência, o juiz ordenará o levantamento do valor pelo autor.

Observe-se, primeiramente, que se admite como estratégia de defesa que o devedor pague o crédito que embasa o pedido falimentar, quando se tratar de pleito fundamentado na impontualidade injustificada ou em execução frustrada. Fábio Ulhoa entende que **é necessário estender os casos de depósito elisivo às hipóteses de prática de atos de falência**. Isso porque, se o devedor promove um depósito em favor do credor que requer a decretação da falência, este perderá o interesse de agir.

Esse depósito do parágrafo único é chamado de depósito **elisivo**. Ao realizá-lo, comprova-se que não há insolvência, afastando a possibilidade de que a falência seja decretada, transformando-se o processo de falência em ação de cobrança. Julgado improcedente o pedido, a falência será denegada e o depósito será devolvido ao Requerido. Julgado procedente o pedido, ainda assim, em tal caso, haverá denegação da falência, porque a insolvência foi elidida, mas com levantamento do depósito pelo autor.

Também como defesa, o art. 95 estipula que “Dentro do prazo de contestação, o devedor poderá pleitear sua recuperação judicial”.



9.7. Sentença declaratória da falência

Aqui se inicia a **2ª etapa** do processo de falência. Entre os principais requisitos da sentença que decreta a falência, podem-se citar os seguintes:

Art. 99. A sentença que decretar a falência do devedor, dentre outras determinações: (...) II – fixará o **termo legal da falência**, sem poder retrotraí-lo por mais de 90 (noventa) dias contados do pedido de falência, do pedido de recuperação judicial ou do 1º (primeiro) protesto por falta de pagamento, excluindo-se, para esta finalidade, os protestos que tenham sido cancelados; (...) IV – **explicitará o prazo para as habilitações de crédito**, (...); V - ordenará a **suspensão de todas as ações ou execuções contra o falido**, (...); IX – nomeará o **administrador judicial**, (...); XI – pronunciar-se-á a respeito da **continuação provisória das atividades** do falido (...); XIII – ordenará a **intimação do Ministério Público** e a comunicação por carta às Fazendas Públicas Federal e de todos os Estados e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento, para que tomem conhecimento da falência.

Quanto ao inciso II, alguns atos praticados após o termo legal da falência são considerados fraudulentos, o que demonstra a importância da fixação do termo.

Registre-se, outrossim, que a suspensão das execuções e do prazo prescricional contra o devedor da falência se dá até o seu encerramento, diferentemente da recuperação judicial, em que a suspensão se dá por 180 dias.

Ao decretar a falência, o devedor é afastado, ficando a cargo de um administrador judicial a administração da empresa. Ressalte-se, porém, que, conforme jurisprudência do STJ (vide informativo 653), a decretação da falência não implica, por si só, na extinção da personalidade jurídica da sociedade, razão pela qual pode atuar como assistente nas ações em que a massa falida seja parte ou interessada e mesmo requerer providências conservatórias dos bens arrecadados na ação falimentar.

Não há nulidade se a falência for decretada sem a oitiva do Ministério Público, porque não há previsão legal para intimar o MP antes da sentença.

A lei fala em sentença declaratória da falência, mas apesar deste nome a sentença tem **caráter constitutivo**. O juiz, ao prolatar a sentença, submeterá os credores, bens, interesses, sujeitos ao regime jurídico específico. Por isso é que se diz que ela tem **natureza constitutiva**.

9.7. Suspensão das execuções individuais

Outra consequência da decretação da falência está prevista no art. 6º da LFRE, que dispõe o seguinte:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.

§ 2º É permitido pleitear, perante o administrador judicial, habilitação, exclusão ou modificação de créditos derivados da relação de trabalho, mas as ações de natureza trabalhista, inclusive as impugnações a que se refere o art. 8º desta Lei, serão processadas perante a justiça especializada até a apuração do respectivo crédito, que será inscrito no quadro-geral de credores pelo valor determinado em sentença. (...)

§ 7º As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica.



Já estudamos esse dispositivo quando tratamos da recuperação judicial. As principais diferenças quanto a sua aplicação na recuperação e na falência são: os créditos fiscais se sujeitam à execução concursal falimentar, mas não à recuperação judicial; ao contrário do que ocorre na recuperação judicial, não há prazo temporal predeterminado para a duração da suspensão de que trata o caput do art. 6º da LFRE em relação à falência.

Já quanto às ações de execução fiscais, importante citar o seguinte entendimento do STJ, em prol da *par conditio creditorum*:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. LIQUIDAÇÃO JUDICIAL. REMESSA DO PRODUTO ARRECADADO AO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA PARA DESTINAÇÃO CONFORME O QUADRO GERAL DE CREDORES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento de que a falência superveniente do devedor não tem o condão de paralisar o processo de execução fiscal, nem de desconstituir a penhora realizada anteriormente à quebra. Outrossim, o produto da alienação judicial dos bens penhorados deve ser repassado ao Juízo universal da falência para apuração das preferências. Agravo Regimental da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1232440/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 25/06/2015)

AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA - PENHORA REALIZADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL COM A ANUÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL - REMESSA DO VALOR AO JUIZ FALIMENTAR PRECEDENTES DO STJ. Realizado o ato de arrematação do bem penhorado pelo juízo da execução fiscal após o decreto de falência e com a anuência expressa e formalizada do juízo universal, o produto da venda judicial do imóvel tão-somente ser repassado ao juiz falimentar. Precedentes do STJ. Agravo regimental desprovido. (AgRg no CC 129.400/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/02/2015, DJe 18/02/2015)

9.8. Termo legal da falência

O **termo legal da falência** é o período anterior à decretação da falência em que se considera que determinados atos praticados pela agora massa falida são **ineficazes** perante a os credores.

O termo legal **não pode retrotrair por mais de 90 dias**, contados:

- **do primeiro protesto por falta de pagamento;**
- **da petição inicial do requerimento de falência; ou**
- **do requerimento de recuperação judicial, quando for caso de convolação.**

Se o juiz ainda não tiver os elementos necessários para determinar o termo legal, poderá fixar posteriormente à sentença declaratória de falência.

9.9. Recurso contra decisão de falência

Da sentença que declara a falência caberá **agravo de instrumento**, com base no princípio da especialidade.

9.10. Requerimento doloso ou culposo do pedido de falência

No caso de sentença denegatória da falência, é necessário saber se quem requereu o fez dolosamente ou culposamente. Caso tenha havido dolo manifesto, o juiz, na própria sentença denegatória, já irá condenar o autor a pagar indenização em favor do requerido. Por isso, a necessidade de prestação de caução de empresa localizada no estrangeiro.



Não havendo dolo manifesto, o requerido poderá demandar o requerente em ação própria a fim de buscar indenização. Confira-se:

Art. 101. Quem por dolo requerer a falência de outrem será condenado, na sentença que julgar improcedente o pedido, a indenizar o devedor, apurando-se as perdas e danos em liquidação de sentença.

§ 1º Havendo mais de 1 (um) autor do pedido de falência, serão solidariamente responsáveis aqueles que se conduziram na forma prevista no **caput** deste artigo.

§ 2º Por ação própria, o terceiro prejudicado também pode reclamar indenização dos responsáveis.

9.11. Presidente da falência

Declarada a falência, **o juiz passa a supervisionar a atuação do administrador judicial**. Os atos mais importantes necessitam de decisão judicial. Por exemplo, é o juiz que autoriza a venda antecipada de bens, que autoriza o pagamento de salário do administrador judicial, que aprova a prestação de contas do administrador judicial.

O membro do MP somente intervém na ação na condição de fiscal da lei, nos momentos processuais previstos na lei ou quando o juiz lhe conceder vista dos autos sobre determinada questão.

9.12. Órgãos da falência

São três os órgãos da falência:

- **administrador judicial;**
- **assembleia de credores;**
- **comitê de credores.**

9.12.1. Administrador judicial

O administrador judicial auxilia o juiz, atuando em nome próprio. Tem responsabilidades, devendo cumprir as funções atribuídas por lei, e não apenas pelo magistrado.

É o **representante da massa falida subjetiva**, que são os interesses dos credores. Para fins penais, é considerado funcionário público. Ademais, o administrador judicial é escolhido pelo juiz, devendo ser profissional idôneo, preferencialmente advogado, economista, administrador de empresas ou contador, mas poderá também ser uma pessoa jurídica especializada.

O administrador judicial poderá deixar suas funções em duas situações:

- **por substituição:** não há caráter sancionatório;
- **por destituição:** tem **caráter de sanção**, motivo pelo qual **não poderá mais ser escolhido para essa função pelos 5 anos seguintes**. Os casos de destituição são: inobservância do prazo legal ou a existência de interesse conflitante com o interesse da massa.

Dentre os **atos praticados pelo administrador judicial**, quatro se destacam:

- **procede à verificação dos créditos, a fim de verificar quem são os credores;**
- **relatório inicial:** o administrador judicial dirá no prazo de 40 dias, a contar da assinatura do seu termo de compromisso de administrador judicial quais foram as causas e circunstâncias que acarretaram a falência;
- **prestar contas mensais ao juiz:** que também serão analisadas pela assembleia de credores;



- **relatório final:** esse relatório é elaborado pelo administrador **no prazo de 10 dias**, a contar do término da liquidação e do julgamento de suas contas. Aqui haverá o levantamento do valor do ativo e do passivo, bem como dos pagamentos feitos, para saber, portanto, se existe algum saldo cabível a cada credor.
- Vale lembrar que o administrador judicial pratica vários outros atos.

9.12.2. Assembleia de credores na falência

A assembleia de credores possui algumas competências importantes na falência:

- **aprova a constituição do comitê de credores;**
- **aprova adoção de modalidades extraordinárias de realização do ativo** (depende de 2/3 do capital votante);
- **delibera sobre assuntos de interesse geral dos credores.**

Esse órgão é composto por todos os credores do falido.

9.12.3. Comitê de credores

O comitê de credores é eleito pela assembleia de credores.

A sua função mais importante é a de **fiscalizar a atuação do administrador judicial**.

O comitê de credores é composto por:

- um representante dos credores trabalhistas;
- um representante dos titulares de direitos reais e de privilégios especiais;
- um representante dos credores quirografários e dos empresários de pequeno porte e microempresários;

9.13. Pessoa e bens do falido

9.13.1. Restrições pessoais

Existem algumas restrições pessoais a que se submete a pessoa falida, seja **empresário individual** ou o **responsável legal da sociedade empresária**. Por exemplo:

- **o falido não pode se ausentar do lugar da falência, se não houver autorização judicial:** sendo autorizado, deverá constituir um procurador;
- **a partir da declaração da falência, as agências postais serão comunicadas para que entregue as correspondências ao administrador judicial:** caso ele verifique que a correspondência não diz respeito à atividade empresarial, o administrador encaminhará para o falido;
- **o falido fica impedido de se restabelecer como empresário, mas somente enquanto não for reabilitado:** após a reabilitação, é possível se tornar empresário.

Essas restrições alcançam o empresário individual e os representantes da sociedade falida.

Com a decretação da falência, o falido sofre uma *capitis diminutio* referente aos direitos patrimoniais envolvidos na falência, sendo afastado da administração dos seus bens. Isso significa que **o falido sofre uma restrição de sua capacidade**, ou seja, depois que é decretada a falência, a sociedade empresária falida não mais possui personalidade jurídica e não poderá postular, em nome próprio, direitos da massa falida, nem mesmo em caráter extraordinário.

Todavia, segundo o STJ, **o falido tem capacidade para propor ação rescisória para desconstituir a sentença transitada em julgado que decretou a sua falência**.



Decretada a falência, os bens do falido são arrecadados. Todavia, **não serão arrecadados:**

- **bens absolutamente impenhoráveis;**
- **bens gravados com cláusula de inalienabilidade;**
- **bens de meação do cônjuge.**

9.13.2. Continuação provisória da empresa do falido

A falência, como regra, implica a descontinuidade da atividade empresarial. No entanto, **é possível que haja a continuação provisória da empresa do falido.**

Na sentença declaratória de falência, que tem caráter constitutivo, **o juiz deverá se pronunciar sobre a continuidade das atividades do falido ou sobre a lacração** do seu estabelecimento.

Essa continuação provisória da atividade **é excepcional**, podendo se justificar pela relevância social e econômica da empresa. Ex.: empresa faliu, mas continuará funcionando até a alienação do estabelecimento.

Nesse caso, há uma responsabilidade social para que as pessoas não percam empregos, para que determinados produtos importantes para a comunidade continuem sendo fornecidos, etc.

9.14. Atos ineficazes

A arrecadação dos bens do devedor falido não deve se restringir ao ativo que ele possui no momento em que sua falência foi decretada. Afinal, é bem possível que o devedor tenha se desfeito de bens que compunham seu ativo antes da decretação da quebra com o objetivo (ou não) de evitar que tais bens fossem arrecadados no processo falimentar. Por isso, os credores podem investigar os atos que o devedor praticou antes da falência com o objetivo de identificar quais deverão ser considerados ineficazes perante a massa e, com isso, assegurar a recuperação de ativos importantes, trazendo-os para a massa falida. É por essa razão, vale lembrar, que o juiz fixa o **termo legal da falência (“período suspeito”)** na sentença que decreta a quebra (art. 99, inciso II, da LFRE).

Esses atos não são nulos e não são anuláveis. Em relação a terceiros serão plenamente válidos e produzem efeitos, mas não produzirão efeitos perante a massa. As consequências, portanto, se encontram no terceiro degrau da Escada Ponteano (plano da eficácia).

A lei emprega duas expressões diferentes para designar os **atos ineficazes em sentido amplo**:

- **atos ineficazes em sentido estrito;**
- **atos revogáveis.**

O que os diferencia são as condições exigidas para que o ato seja ineficaz em sentido estrito ou revogável, ou também o meio processual, como poderá se dar esse reconhecimento.

9.14.1. Atos ineficazes em sentido estrito

Assim dispõe o art. 129 da LFRE:

Art. 129. São **ineficazes** em relação à massa falida, tenha ou não o contratante conhecimento do estado de crise econômico-financeira do devedor, seja ou não intenção deste fraudar credores:

I – o pagamento de dívidas não vencidas realizado pelo devedor dentro do termo legal, por qualquer meio extintivo do direito de crédito, ainda que pelo desconto do próprio título;



II – o pagamento de dívidas vencidas e exigíveis realizado dentro do **termo legal**, por qualquer forma que não seja a prevista pelo contrato;

III – a constituição de direito real de garantia, inclusive a retenção, dentro do termo legal, tratando-se de dívida contraída anteriormente; se os bens dados em hipoteca forem objeto de outras posteriores, a massa falida receberá a parte que devia caber ao credor da hipoteca revogada;

IV – a prática de atos a título gratuito, desde **2 (dois) anos** antes da decretação da falência;

V – a renúncia à herança ou a legado, até 2 (dois) anos antes da decretação da falência;

VI – a venda ou transferência de estabelecimento feita sem o consentimento expresso ou o pagamento de todos os credores, a esse tempo existentes, não tendo restado ao devedor bens suficientes para solver o seu passivo, salvo se, no prazo de 30 (trinta) dias, não houver oposição dos credores, após serem devidamente notificados, judicialmente ou pelo oficial do registro de títulos e documentos;

VII – os registros de direitos reais e de transferência de propriedade entre vivos, por título oneroso ou gratuito, ou a averbação relativa a imóveis realizados após a decretação da falência, salvo se tiver havido prenotação anterior.

Parágrafo único. A ineficácia poderá ser declarada **de ofício** pelo juiz, alegada em defesa ou pleiteada mediante ação própria ou incidentalmente no curso do processo.

Cuida-se, nesse caso, de ineficácia objetiva, pois independe da demonstração de conluio ou de intuito de fraudar credores. O rol do artigo 129 é taxativo. Observe-se que as três primeiras hipóteses tomam por base o termo legal da falência, enquanto os incisos IV e V estabelecem um lapso temporal de 2 anos antes da decretação da falência e o inciso VII toma por base a decretação da falência.

Haverá somente um ato, que configura uma exceção, o qual independe da época em que ocorreu e da comprovação da fraude. Esse ato, que será considerado ineficaz, é o trespasse irregular referido no inciso VI.

Lembre-se de que a ineficácia poderá ser declarada de ofício pelo juiz, ou ser alegada em defesa ou pleiteada mediante ação própria ou incidentalmente no curso do processo.

9.14.2. Atos revogáveis

Segundo o art. 130, são revogáveis **os atos praticados com a intenção de prejudicar credores, provando-se o conluio fraudulento entre o devedor e o terceiro que com ele contratar e o efetivo prejuízo sofrido pela massa falida.**

Aqui, não há rol específico de atos nem se perquire sobre a data da prática do ato, pois o que importa é que sejam comprovados o conluio fraudulento e o prejuízo para a massa.

Atenção: caso, por exemplo, um ato do art. 129, I, II ou III, tenha sido praticado 120 dias antes da decretação da falência (fora do termo legal), se estiverem preenchidos os requisitos do art. 130, poderá ser ajuizada ação revocatória.

Os legitimados e o prazo da ação revocatória estão disciplinados nos arts. 132 da LFRE:

“Art. 132. A ação revocatória, de que trata o art. 130 desta Lei, deverá ser proposta pelo administrador judicial, por qualquer credor ou pelo Ministério Público no prazo de 3 (três) anos contado da decretação da falência”.

Os valores a serem restituídos à massa falida decorrentes da procedência de ação revocatória não podem ser compensados com eventual crédito habilitado no processo de falência pelo réu condenado.



9.14.3. Declaração judicial da ineficácia

A declaração da **ineficácia objetiva** (art. 129) poderá se dar de diversas formas:

- **por despacho do juiz, de ofício:** nesse caso, o juiz deverá determinar que se proceda a arrecadação dos bens pelo administrador judicial;
- **por sentença acolhendo tese defensiva levantada pela massa falida;**
- **por sentença, quando a massa falida é autora:** ex.: numa ação autônoma o juiz poderá reconhecer a ineficácia objetiva.

Por outro lado, a **ineficácia subjetiva** é mais difícil de ocorrer, pois é necessário comprovar a fraude. Nesse caso, há uma ação própria e específica do processo falimentar, que é a **ação revocatória**.

O **juiz competente** para apreciar a ação revocatória é o **mesmo juízo da falência**.

9.15. Regime jurídico dos contratos do falido

Com a sentença declaratória da falência, os contratos do falido passam a se submeter a um regime jurídico específico do direito falimentar.

A falência autoriza que os contratos bilaterais sejam resolvidos, encerrando os contratos. Para isso, o contrato deverá ser bilateral e **nenhuma das partes pode ter começado a cumpri-lo**. Caso uma delas já tenha cumprido o contrato, não se admite a resolução.

Ex.: Comércio de Arroz Ltda. comprou uma colheitadeira de João, mas este disse que entregaria o bem em 10 dias. No 5º dia, a sociedade veio à falência. Esse contrato será resolvido, pois João não entregou o bem, tampouco a sociedade efetuou o pagamento. Não cabem juros, multa etc. Caso já tivesse entregado a colheitadeira anteriormente, não seria possível resolver o contrato.

Sendo o **contrato unilateral**, o administrador judicial poderá resolver o contrato.

No caso de contrato bilateral, **a lei admite que seja cumprido**, caso **evite o aumento do passivo** ou **contribua com a manutenção ou a preservação do ativo**.

Sendo o caso de diminuição ou manutenção do passivo, é melhor resolver o contrato. A empresa está falida.

Caso o contratante deseje, **será possível interpor o administrador judicial**, desde o momento de investidura dele na função, **para que ele se manifeste sobre a continuidade ou não do contrato**. O **silêncio do administrador no prazo de 10 dias**, contados da sua interposição, implica **resolução do contrato**.

Em síntese, os efeitos da falência quanto aos contratos do falido são os seguintes:

- o vendedor pode obstar a entrega da coisa ao falido, quando ainda não paga ou recebida;
- na venda a prazo de coisa móvel pelo falido, o administrador poderá optar pela resolução do contrato, mas neste caso ficará obrigado a restituir ao comprador o valor das prestações que já foram pagas;
- na compra com reserva de domínio, feita com relação a bem móvel, caso o administrador resolva o contrato, o vendedor, que é quem tem o domínio, pode reivindicar o bem, visto que ele é o seu proprietário e foi resolvido o contrato;
- se o estabelecimento do falido se encontra em imóvel locado, o administrador judicial poderá rescindir o contrato, sem pagar qualquer multa;
- sendo o falido locador, o contrato continuará, visto que os valores do aluguel passarão a ser destinadas à massa falida;
- as contas correntes do falido serão encerradas no momento da declaração da falência;
- havendo cláusula de resolução por falência, o contrato será resolvido, caso um dos contratantes venha a falir. É plenamente válida e deve ser cumprida;



- havendo crédito de moeda estrangeira, será convertido em moeda nacional pelo câmbio do dia em que foi declarada a falência, ainda que se pague posteriormente;
- suspensão da prescrição das obrigações do falido, quando houver sentença que declara a falência. O prazo prescricional só volta a correr com o trânsito em julgado da decisão que encerra a falência. Tais prazos não se suspendem caso ele seja credor.

9.16. Regime jurídico dos credores do falido

A falência, em tese, compreende todos os credores, excluindo a lei alguns, tais como os credores de obrigações a título gratuito e os créditos por despesa para que o credor possa ingressar na massa falida subjetiva (gastos que o credor teve para se habilitar na falência não será recebido).

9.16.1. Direitos do credor no processo falimentar

- o credor poderá intervir como assistente, em qualquer ação em que a massa falida seja parte, ou mesmo interessada;
- fiscalização da administração judicial;
- examinar, sempre que quiser, os livros e demais documentos da massa.

9.16.2. Efeitos da falência quanto aos credores

Existem quatro principais efeitos da falência quanto aos credores:

- **formação da massa falida subjetiva:** é a comunhão de interesses dos credores;
- **suspensão das ações individuais contra o falido:** passa-se a ter um processo de execução concursal;
- **vencimento antecipado das dívidas;**
- **suspensão da fluência dos juros.**

a) Massa falida subjetiva

A massa falida subjetiva é um **sujeito de direito despersonalizado**, não tendo personalidade jurídica. A ideia é que a massa falida subjetiva atue no interesse dos credores gerais daquele empresário falido.

A massa falida objetiva é o **conjunto de bens arrecadados do falido**.

b) Suspensão das ações individuais contra o falido

Já tratamos da suspensão das ações de que trata o art. 6º acima. Aqui, deve-se complementar o tema com alguns detalhes adicionais.

Para o resguardo de seus interesses, o autor da ação individual que não se submete à suspensão poderá (e a prudência indica que deve) requerer ao juiz que faça reserva daquele valor, ainda que por estimativa (no caso de ações que demandem obrigações ainda ilíquidas).

Os arts. 6º, caput, e 99, V, da Lei nº 11.101/05 estabelecem, como regra, que, após a decretação da falência, tanto as ações quanto as execuções movidas em face do devedor devem ser suspensas. Trata-se de medida cuja finalidade é impedir que sigam em curso, concomitantemente, duas pretensões que objetivam a satisfação do mesmo crédito.

Exceto na hipótese de a decisão que decreta a falência ser reformada em grau de recurso, a suspensão das execuções terá força de definitividade (não há prazo específico para



essa suspensão, ao contrário do que ocorre na recuperação judicial), correspondendo à extinção do processo.

Quaisquer dos desfechos possíveis da ação falimentar - pagamento da integralidade dos créditos ou insuficiência de acervo patrimonial apto a suportá-lo - conduzem à conclusão de que eventual retomada das execuções individuais suspensas se traduz em medida inócua: na hipótese de satisfação dos créditos, o exequente careceria de interesse, pois sua pretensão já teria sido alcançada; no segundo caso, o exaurimento dos recursos arrecadados conduziria, inexoravelmente, ao seu insucesso.

Nesse contexto, após a formação de juízo de certeza acerca da irreversibilidade da decisão que decretou a quebra, deve-se admitir que as execuções individuais até então suspensas sejam extintas, por se tratar de pretensões desprovidas de possibilidades reais de êxito (REsp 1564021/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018).

c) Vencimento antecipado das dívidas

É o que estipula o art. 77 da LFRE:

Art. 77. A decretação da falência determina o vencimento antecipado das dívidas do devedor e dos sócios ilimitada e solidariamente responsáveis, com o abatimento proporcional dos juros, e converte todos os créditos em moeda estrangeira para a moeda do País, pelo câmbio do dia da decisão judicial, para todos os efeitos desta Lei.

d) Suspensão da fluência dos juros

A quebra implica suspensão da fluência dos juros, porém também existem exceções, como é o caso das obrigações com garantia real. Neste caso, serão pagos os juros posteriores à decretação da falência, desde que o bem dado em garantia seja suficiente para pagar inclusive os juros.

9.17. Habilitação dos créditos, divergências e impugnações

Quanto à habilitação dos créditos na falência, à apresentação de divergências ou de impugnações no procedimento falimentar, seguem o mesmo rito já explanado quando tratamos da recuperação judicial, razão pela qual ora se remete o leitor para o respectivo tópico.

9.18. Arrecadação dos bens

Com a decretação da falência, a administração dos bens do falido passa para o administrador judicial, o qual, assim que assinar o termo de compromisso, “efetuará a arrecadação dos bens e documentos e a avaliação dos bens, separadamente ou em bloco, no local em que se encontrem, requerendo ao juiz, para esses fins, as medidas necessárias” (**art. 108 da LFRE**).

Assim, é efeito específico da falência a arrecadação de todos os bens do devedor – “com exceção dos bens absolutamente impenhoráveis” (**art. 108, § 4º, LFRE**) –, que deverão ser vendidos para que o produto da venda seja utilizado para o pagamento dos credores. Os bens arrecadados constituem, pois, a chamada **massa falida objetiva**, que corresponde ao ativo do devedor submetido à execução concursal falimentar.

A maioria dos processos de falência é dirigido contra sociedades empresárias, nesses casos são arrecadados os bens apenas das pessoas jurídicas ou também dos sócios? Depende



do tipo de sociedade, se for do tipo em que a responsabilidade do sócio é ilimitada, arrecadam-se os bens dos sócios também, pois os sócios vão à falência junto com a sociedade. Se a sociedade for do tipo em que a responsabilidade do sócio é limitada, em princípio não se irá atrás dos bens dos sócios, embora a lei abra brecha para isso.

Vide, ainda, o seguinte enunciado do CJF:

Enunciado 48 das Jornadas de Direito Comercial do CJF: a apuração da responsabilidade pessoal dos sócios, controladores e administradores feita independentemente da realização do ativo e da prova da sua insuficiência para cobrir o passivo, prevista no art. 82 da Lei n. 11.101/2005, **não** se refere aos casos de desconsideração da personalidade jurídica.

9.19. Realização do ativo

De acordo com o **art. 139 da LFRE**, “logo após a arrecadação dos bens, com a juntada do respectivo auto ao processo de falência, será iniciada a realização do ativo”, a qual consiste, basicamente, na venda dos bens arrecadados, a fim de juntar dinheiro para pagamento dos credores habilitados. Registre-se, porém, que **a venda dos bens deve ser iniciada antes mesmo de formado o quadro-geral de credores** (art. 140, § 2º da LFRE), uma novidade da lei atual em relação à anterior.

Existem três formas de venda: leilão, proposta fechada, ou pregão, que não se confundem com as modalidades de venda, previstas no art. 140 da LFRE na seguinte ordem de preferência:

I – alienação da empresa, com a venda de seus estabelecimentos em bloco; II – alienação da empresa, com a venda de suas filiais ou unidades produtivas isoladamente; III – alienação em bloco dos bens que integram cada um dos estabelecimentos do devedor; IV – alienação dos bens individualmente considerados.

O art. 141 da LFRE, por sua vez, prevê que

Art. 141. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que trata este artigo: I – todos os credores, observada a ordem de preferência definida no art. 83 desta Lei, sub-rogam-se no produto da realização do ativo; **II – o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor**, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho.

O destaque está no inciso II do dispositivo transcrito, que excepciona as regras de sucessão empresarial (art. 1.146 do Código Civil), sucessão tributária (art. 133 do CTN) e sucessão trabalhista (art. 448 da CLT). Regra semelhante, vale lembrar, foi prevista no art. 60, parágrafo único, da LFRE para o processo de recuperação judicial.

Além da alienação ordinária, é também possível a realização do ativo sob forma **forma extraordinária, nas seguintes situações:**

Art. 144. Havendo motivos justificados, o juiz poderá autorizar, mediante requerimento fundamentado do administrador judicial ou do Comitê, modalidades de alienação judicial diversas das previstas no art. 142 desta Lei.

Art. 145. O juiz homologará qualquer outra modalidade de realização do ativo, desde que aprovada pela assembléia-geral de credores, inclusive com a constituição de sociedade de credores ou dos empregados do próprio devedor, com a participação, se necessária, dos atuais sócios ou de terceiros.



§ 1º Aplica-se à sociedade mencionada neste artigo o disposto no art. 141 desta Lei.

§ 2º No caso de constituição de sociedade formada por empregados do próprio devedor, estes poderão utilizar créditos derivados da legislação do trabalho para a aquisição ou arrendamento da empresa.

§ 3º Não sendo aprovada pela assembléia-geral a proposta alternativa para a realização do ativo, caberá ao juiz decidir a forma que será adotada, levando em conta a manifestação do administrador judicial e do Comitê

Em relação ao art. 145 da LFRE, a deliberação em AGC será aprovada se houver votos favoráveis de credores que representem 2/3 dos créditos presentes à assembleia (art. 46 da LFRE).

Para a alienação ordinária, a lei exige publicação prévia em jornal de ampla circulação com 15 dias de antecedência, se os bens forem móveis, e com 30 dias de antecedência, se forem bens imóveis (art. 142, § 1º, da LFRE). Tal regra se aplica à alienação extraordinária? De acordo com o STJ, não.

A realização do ativo não compreende apenas a venda dos bens, mas também a busca em obter bens em favor da massa falida, como é o caso dos devedores da massa. A cobrança dos créditos do falido deverá ser feita pelo administrador judicial, pois cabe a ele fazer a realização do ativo.

Exaurido o produto da venda, o administrador judicial apresentará a prestação de contas. Após o julgamento, apresentará o relatório final.

Após, o **juiz proferirá uma sentença**, declarando encerrado o processo de falência. Esta sentença, diferentemente da sentença declaratória de falência, poderá ser atacada por meio de **recurso de apelação**.

9.20. Pedido de restituição, embargos de terceiro e patrimônio separado

9.20.1. Pedido de restituição

Pode ser que a arrecadação atinja bens de terceiros que estão em poder do devedor na data da decretação da falência. Nesses casos, os titulares desses bens poderão formular pedidos de restituição.

De acordo com o art. 85 da LFRE, “o proprietário de bem arrecadado no processo de falência ou que se encontre em poder do devedor na data da decretação da falência poderá pedir sua restituição”. É o caso, por exemplo, de bens que estavam com o devedor em razão de contratos de alienação fiduciária em garantia ou arrendamento mercantil. Por disposição expressa do DL 911/69, em seu art. 7º, caberá o pedido de restituição da coisa alienada com garantia fiduciária. A instituição financeira, proprietária fiduciária, pode fazer o pedido de restituição do bem que estava no estabelecimento do falido a título de alienação fiduciária.

O art. 85, parágrafo único da LFRE, por sua vez, dispõe o seguinte: “também pode ser pedida a restituição de coisa vendida a crédito e entregue ao devedor nos 15 (quinze) dias anteriores ao requerimento de sua falência, se ainda não alienada”. Trata-se de bem que foi vendido a crédito ao falido, entregue a ele até quinze dias antes do pedido de falência e ainda não alienado a terceiros.

Sobre o tema, vale ressaltar também o entendimento do STJ de que os Certificados de Depósito Bancário – CDBs – que ainda não tenham sido liquidados no momento de intervenção do Banco Central sobre uma instituição financeira –, serão submetidos aos efeitos da falência da instituição. Segundo o STJ, “quando se trata de contrato de depósito bancário, ocorre a transferência da propriedade do bem para a instituição financeira, assumindo o depositante, em consequência, a posição de credor daqueles valores” (REsp 1.801.031-SP, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019).



Outra hipótese de restituição está prevista no art. 86, inciso II, da LFRE, que prevê que caberá a restituição em dinheiro

da importância entregue ao devedor, em moeda corrente nacional, decorrente de adiantamento a contrato de câmbio para exportação, na forma do art. 75, §§ 3º e 4º, da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, desde que o prazo total da operação, inclusive eventuais prorrogações, não exceda o previsto nas normas específicas da autoridade competente.

9.20.2. Embargos de terceiro

Nos casos em que **não couber pedido de restituição**, fica resguardado o direito dos credores de propor embargos de terceiros, observada a legislação processual civil.

9.20.3. Patrimônio separado

O patrimônio separado também é conhecido como **patrimônio afetado ou segregado**. Esse patrimônio não integra a massa falida.

Ex.: a incorporadora de um edifício pode se submeter ao regime de afetação. Nesse caso, pegará o terreno e as acessões e dirá que esse patrimônio está apartado do patrimônio da incorporadora. Há a afetação desse patrimônio, fazendo a averbação no registro de imóveis.

Com isso, permite-se que terceiros firmem promessa de compra e venda desses imóveis, sem que tais bens venham a responder por eventuais dívidas da sociedade.

Outro exemplo é o caso dos consórcios. Na hipótese de pagamento da mensalidade do consórcio para a administradora, essas parcelas pagas devem se destinar ao lastro dos créditos contemplados. O valor desses pagamentos mensais é patrimônio separado, não pertencendo às administradoras. Por conta disso, se houver a falência dessa entidade de consórcio, esse dinheiro não será dela, motivo pelo qual deverá ser devolvido aos consorciados.

9.21. Princípio *par conditio creditorum*

O procedimento falimentar é regido pelo princípio *par conditio creditorum*, que determina que seja dado aos credores um tratamento paritário. Por isso, **par conditio creditorum**, ou seja, a mesma condição paritária aos credores, ainda que seus créditos gozem de prioridades diferentes.

9.22. Classificação dos créditos

9.23.1. Créditos pagáveis com a disponibilidade de caixa

Antes de serem pagos os credores concursais habilitados e descritos no quadro-geral, o administrador judicial deve fazer alguns pagamentos com os recursos que tem em caixa e, em seguida, pagar os créditos extraconcursais. Exemplos daqueles são os **arts. 150 e 151 da LFRE**. De acordo com o primeiro,

Art. 150. As **despesas cujo pagamento antecipado seja indispensável à administração da falência**, inclusive na hipótese de continuação provisória das atividades previstas no inciso XI do caput do art. 99 desta Lei, serão pagas pelo administrador judicial com os recursos disponíveis em caixa.



O segundo (art. 151), por sua vez, dispõe que “os créditos trabalhistas de natureza estritamente salarial vencidos nos 3 (três) meses anteriores à decretação da falência, até o limite de 5 (cinco) salários-mínimos por trabalhador, serão pagos tão logo haja disponibilidade em caixa”. Assim, frise-se, os pagamentos previstos nos arts. 150 e 151 da LFRE devem ser realizados assim que houver disponibilidade de caixa.

9.23.2. Créditos extraconcursais

Nos termos do **art. 149 da LFRE**, o administrador judicial também deve pagar, antes dos credores concursais habilitados e descritos no quadro-geral, as restituições em dinheiro deferidas pelo juiz (art. 86 da LFRE), que não são créditos propriamente ditos, e os créditos extraconcursais. Esses **créditos extraconcursais** são descritos no **art. 84 da LFRE**, que assim dispõe:

Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com **precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei**, na ordem a seguir, os relativos a:

- I – remunerações devidas ao administrador judicial e seus auxiliares, e créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho relativos a serviços prestados após a decretação da falência;
- II – quantias fornecidas à massa pelos credores;
- III – despesas com arrecadação, administração, realização do ativo e distribuição do seu produto, bem como custas do processo de falência;
- IV – custas judiciais relativas às ações e execuções em que a massa falida tenha sido vencida;
- V – obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial, nos termos do art. 67 desta Lei, ou após a decretação da falência, e tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação da falência, respeitada a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei.

No caso do artigo 84 (créditos extraconcursais), observe-se que, em regra, são dívidas que surgiram após a decretação da falência. A exceção está na primeira parte do inciso V (“obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial”).

9.23.3. Créditos concursais

Finalmente, de acordo com o **art. 83 da LFRE**,

Art. 83. A classificação dos créditos na falência obedece à seguinte ordem:

- I – os créditos derivados da legislação do trabalho, limitados a 150 (cento e cinquenta) salários-mínimos por credor, e os decorrentes de acidentes de trabalho;
- II – créditos com garantia real até o limite do valor do bem gravado;
- III – créditos tributários, independentemente da sua natureza e tempo de constituição, excetuadas as multas tributárias;
- IV – créditos com privilégio especial, a saber: (...);
- V – créditos com privilégio geral, a saber: (...);
- VI – créditos quirografários, a saber: (...);
- VII – as multas contratuais e as penas pecuniárias por infração das leis penais ou administrativas, inclusive as multas tributárias;
- VIII – créditos subordinados, a saber: (...).

Em síntese, a ordem de pagamento dos créditos é a seguinte:

- **créditos pagáveis com disponibilidade de caixa** (ex: art. 150 e 151 da LFRE);
- **créditos extraconcursais: previstos no art. 84 da LFRE**, cujos incisos trazem uma ordem própria de pagamento;



- **crédito por acidente de trabalho e crédito trabalhista:**
- **crédito com garantia real:** só até o limite do valor do bem gravado. Ex.: o bem é de 100 mil reais, mas a dívida é de 150 mil. No caso, será pago os 100 mil do bem gravado, mas os 50 mil restantes serão gravados como crédito quirografário;
- **créditos inscritos em dívida ativa:** sejam eles tributários ou não tributários, com exceção das multas;
- **créditos com privilégio especial;**
- **créditos com privilégio geral;**
- **créditos quirografários;**
- **multas;**
- **créditos subordinados.**

a) Crédito por acidente de trabalho e crédito trabalhista

Em relação aos trabalhistas, a preferência no pagamento está sujeita a um limite de 150 salários mínimos por credor. O que, ultrapassar tal montante será considerado crédito quirografário. Esse limite não se aplica aos créditos por acidente de trabalho nem aos créditos trabalhistas extraconcursais (por serviços prestados pelos empregados após a decretação da falência).

Cuidado: alguns créditos são também **equiparados a créditos trabalhistas** para fins de classificação na falência. É o caso dos créditos devidos aos representantes comerciais autônomos a título de comissões (art. 44 da Lei nº 4.886/1965) e dos créditos referentes a honorários advocatícios (sejam sucumbenciais ou contratuais):

os créditos resultantes de honorários advocatícios, sucumbenciais ou contratuais, têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em falência, seja pela regência do Decreto-lei 7.661/1945, seja pela forma prevista na Lei 11.101/2005, observado o limite de valor previsto no art. 83, I, do referido diploma legal (REsp 1.152.218/RS).

Além disso, de um modo geral, a jurisprudência do STJ caminha no sentido de estender essa equiparação aos créditos trabalhistas para os créditos de natureza alimentar em geral, como se observa a partir dos seguintes precedentes (honorários devidos a sociedade simples de prestação de serviços contábeis; pensionamento judicial fixado em ação de indenização por acidente de trânsito):

Os créditos decorrentes da prestação de serviços contábeis e afins, mesmo que titularizados por sociedade simples, são equiparados aos créditos trabalhistas para efeitos de sujeição ao processo de recuperação judicial.” (REsp 1.851.770)

O pensionamento fixado em sentença judicial, decorrente de ação de indenização por acidente de trânsito, pode ser equiparado ao crédito derivado da legislação trabalhista para fins de inclusão no quadro geral de credores de sociedade em recuperação judicial. (REsp 1.799.041-PR, Informativo 645).

Nesse último precedente, o STJ chegou a consignar expressamente que “as diversas espécies de verbas que ostentam natureza alimentar, dada a afinidade ontológica que lhes é inerente, devem receber tratamento isonômico para os fins da Lei de Falência e Recuperação de Empresas, ainda que ausente disposição legal específica versando sobre cada uma delas”.



b) Crédito com garantia real

Com relação aos créditos com garantia real, a preferência incide apenas até o limite do valor do bem gravado. Ex.: o bem é de R\$ 100 mil, mas a dívida é de R\$ 150 mil. No caso, serão pagos os R\$ 100 mil do bem gravado, mas os R\$ 50 mil restantes serão gravados como crédito quirografário.

Mas há uma peculiaridade entre essa quebra do crédito que ocorre em relação aos trabalhistas e a que ocorre em relação aos credores com garantia real. Quanto aos trabalhistas, nas deliberações assembleares por classes, os seus titulares (credores trabalhistas) apenas votarão na classe dos credores trabalhistas, pelo valor total do seu crédito. Já os credores com garantia real cujo valor do crédito seja inferior ao do bem gravado votarão tanto na classe dos credores com garantia real (pelo valor do bem) quanto na classe que abrange os quirografários (pelo valor excedente).

c) Créditos tributários

Com relação aos **créditos tributários, há uma ordem interna para recebimento:**

- créditos da União e suas autarquias;
- créditos dos Estados e suas autarquias;
- créditos dos municípios e suas autarquias.

Ressalte-se que aqui entram os créditos tributários independentemente de sua natureza e tempo de constituição, excetuadas as multas tributárias, que ocupam local bem abaixo na ordem de prioridade de pagamento.

d) Créditos com privilégio especial

Em se tratando de **créditos com privilégio especial**, serão exemplos:

- **credor com direito de retenção sobre a coisa dada em garantia;**
- **microempresários individuais e os empresários de pequeno porte:** a ideia da lei é promover a proteção das pequenas empresas e empresas de pequeno porte;
- **Demais créditos considerados com privilégio especial em outras normas (ex: art. 964 do CC).**

De acordo com o **art. 43, III, da Lei das Incorporações Imobiliárias**, são considerados **créditos privilegiados os créditos decorrentes das importâncias pagas ao incorporador falido pela aquisição das unidades autônomas, quando não for possível prosseguir na construção das edificações.**

Já as quantias que os adquirentes tiverem que dispendar para a conclusão da obra após a quebra do incorporador serão consideradas meros créditos quirografários (Informativo 548 do STJ).

e) Créditos com privilégio geral

Os créditos com **privilégio geral** serão hipóteses:

- **Os assim definidos em lei;**
- **Os previstos no art. 965 do CC;**
- **Os previstos no p.u. do art. 67 (uma das benesses concedidas a quem continuar contratando com o devedor em recuperação judicial, já estudada em tópico próprio).**



f) Créditos quirografários

É, comumente, a grande massa das obrigações do falido. São os créditos que não têm quaisquer especialidades, como contratos em geral, por exemplo, bem como os excedentes dos créditos trabalhistas e dos credores com garantia real, conforme visto acima.

g) Multas

Após o pagamento dos créditos quirografários, caso sobre algo, aí os recursos serão destinados ao pagamento de multas contratuais e penalidades pecuniárias por infrações penais, administrativas ou tributárias.

h) Créditos subordinados

Por último, pagam-se os créditos subordinados, que serão aqueles relacionados aos sócios, administradores, sem vínculo empregatício, bem como às debêntures subordinadas.

9.23. Encerramento

De acordo com o art. 154 da LFRE, “concluída a realização de todo o ativo, e distribuído o produto entre os credores, o administrador judicial apresentará suas contas ao juiz no prazo de 30 (trinta) dias”, em autos apartados, porém apensados aos autos da falência.

Na sequência, o juiz determina a publicação de aviso de que as contas foram entregues, para que os interessados as analisem e eventualmente apresentem impugnação no prazo de 10 dias. Realizadas as diligências necessárias à apuração dos fatos, o juiz intimará o MP, que se manifestará no prazo de 5 dias, após o qual “o administrador judicial será ouvido se houver impugnação ou parecer contrário do Ministério Público” (art. 154, § 3º). Por fim, o juiz decide acerca das contas.

“A sentença que rejeitar as contas do administrador judicial fixará suas responsabilidades, poderá determinar a indisponibilidade ou o seqüestro de bens e servirá como título executivo para indenização da massa” (art. 154, § 5º).

De acordo com os arts. 155 e 156 da LFRE:

Art. 155. Julgadas as contas do administrador judicial, ele apresentará o relatório final da falência no prazo de 10 (dez) dias, indicando o valor do ativo e o do produto de sua realização, o valor do passivo e o dos pagamentos feitos aos credores, e especificará justificadamente as responsabilidades com que continuará o falido.

Art. 156. Apresentado o relatório final, o juiz encerrará a falência por sentença.

Parágrafo único. A sentença de encerramento será publicada por edital e dela caberá apelação.

9.23. Reabilitação do falido

Essa é a **3ª etapa**. Após a sentença de encerramento da falência, encerrou-se o processo falimentar. Nos termos dos arts. 158 a 160 da LFRE:

Art. 158. Extingue as obrigações do falido:

I – o pagamento de todos os créditos;

II – o pagamento, depois de realizado todo o ativo, de mais de 50% (cinquenta por cento) dos créditos quirografários, sendo facultado ao falido o depósito da quantia necessária para atingir essa porcentagem se para tanto não bastou a integral liquidação do ativo;



III – o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contado do encerramento da falência, se o falido não tiver sido condenado por prática de crime previsto nesta Lei;

IV – o decurso do prazo de 10 (dez) anos, contado do encerramento da falência, se o falido tiver sido condenado por prática de crime previsto nesta Lei.

Art. 159. Configurada qualquer das hipóteses do art. 158 desta Lei, o falido poderá requerer ao juízo da falência que suas obrigações sejam declaradas extintas por sentença.

§ 1º O requerimento será autuado em apartado com os respectivos documentos e publicado por edital no órgão oficial e em jornal de grande circulação.

§ 2º No prazo de 30 (trinta) dias contado da publicação do edital, qualquer credor pode opor-se ao pedido do falido.

§ 3º Findo o prazo, o juiz, em 5 (cinco) dias, proferirá sentença e, se o requerimento for anterior ao encerramento da falência, declarará extintas as obrigações na sentença de encerramento.

§ 4º A sentença que declarar extintas as obrigações será comunicada a todas as pessoas e entidades informadas da decretação da falência.

§ 5º Da sentença cabe apelação.

§ 6º Após o trânsito em julgado, os autos serão apensados aos da falência.

Art. 160. Verificada a prescrição ou extintas as obrigações nos termos desta Lei, o sócio de responsabilidade ilimitada também poderá requerer que seja declarada por sentença a extinção de suas obrigações na falência.

10. Recuperação extrajudicial

A Lei autoriza que o devedor que preencha os mesmos requisitos do art. 48 da LFRE proponha e negocie diretamente com os credores um plano de recuperação extrajudiciário.

10.1. Requisitos para homologação do plano de recuperação extrajudicial

Há requisitos de ordem subjetiva, que dizem respeito ao requerente, e requisitos de ordem objetiva, quanto ao plano que apresenta.

10.1.1. Requisitos subjetivos

O devedor, para requerer a recuperação extrajudicial, **deverá**:

- preencher as mesmas condições do devedor que requer a recuperação judicial (art. 48 da LFRE);
- não poderá se encontrar em tramitação nenhum pedido de recuperação judicial;
- não poderá ter sido concedido a ele, há menos de 2 anos, recuperação judicial ou extrajudicial.

10.1.2. Requisitos objetivos

São requisitos objetivos:

- plano apresentado pelo devedor não poderá prever o pagamento antecipado de qualquer das dívidas;
- não poderá prever tratamento desfavorável aos credores que a ele não estejam sujeitos (art. 161, § 2º) (em prol do princípio *par conditio creditorum*);
- plano não poderá abranger senão os créditos constituídos até a data do pedido de homologação: crédito constituído após o pedido não entrará no plano de recuperação extrajudicial.



- Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante a aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.
- Nos créditos em moeda estrangeira, a variação cambial só poderá ser afastada se o credor titular do respectivo crédito aprovar expressamente previsão diversa no plano de recuperação extrajudicial.

10.1.3. Homologação do plano

A homologação do plano poderá ser facultativa ou obrigatória:

- **homologação facultativa:** ocorre quando todos os credores alcançados pelo plano de recuperação extrajudicial concordam com suas cláusulas. Apesar de ser facultativa, a homologação traz uma certa solenidade, além de possibilitar a hasta judicial de unidades e filiais da sociedade, caso seja necessário.
- **homologação obrigatória:** neste caso, nem todos os credores concordaram com o plano de recuperação extrajudicial. Houve adesão de uma parte significativa dos credores, porém uma minoria resiste. Com a homologação judicial, o plano se estenderá a todos os credores, inclusive aos minoritários que estavam rejeitando.

Para ser homologado o plano deve ostentar a **assinatura de credores** que sejam titulares de ao menos **60% (ou 3/5) de todos os créditos de cada espécie por ele abrangidos**.

Da **sentença que homologa** o pedido de recuperação extrajudicial cabe **recurso de apelação**.

10.2. Os credores na recuperação extrajudicial

Não se submetem à recuperação extrajudicial (art. 161, § 1º, da LFRE):

- titulares de crédito de relação empregatícia;
- credor tributário;
- credor fiduciário;
- credor titular de reserva de domínio;
- instituição financeira que tenha dado crédito de adiantamento ao exportador (ACC)

11. Liquidação extrajudicial de instituições financeiras

11.1. Introdução

Se a instituição financeira não estiver sob liquidação extrajudicial ou intervenção, decretada pelo Banco Central, poderá ter sua falência decretada judicialmente, pelas mesmas razões e condições que os demais empresários.

Em outras palavras, ela não será absolutamente excluída da falência, mas eventualmente uma instituição financeira poderá falir.

A execução concursal do patrimônio da instituição financeira que é devedora será feito conforme a modalidade de execução concursal: falência ou liquidação extrajudicial.

As **instituições financeiras federais não estão sujeitas à liquidação extrajudicial, pois para elas fala-se em liquidação ordinária**.

Caso pare a atividade, a União deverá fazer liquidação ordinária, pagando todo mundo e pronto.

O **Banco Central editará a ordem da liquidação extrajudicial**. O BC é órgão da administração indireta, sendo o órgão competente para decretar a liquidação extrajudicial das instituições financeiras.



Como **causas da liquidação extrajudicial das instituições financeiras**, há duas basicamente:

- Decreta-se a liquidação extrajudicial em razão de que a **instituição financeira tem comprometida a sua situação econômico financeira**; ou
- Decreta-se a liquidação extrajudicial **como sanção administrativa**, pois aquela **instituição financeira violou gravemente normas estatutárias, do conselho monetário nacional**, etc.

A liquidação extrajudicial poderá ser decretada pelo Banco Central, inclusive a pedido da própria instituição, bem como **se o interventor nomeado pelo BC assim entender**.

A decretação da liquidação extrajudicial importa a **suspensão das ações e execuções judiciais** em face daquela instituição financeira e **importa na proibição de ajuizamento de novas ações**. Isto é, **haverá o vencimento antecipado das dívidas**.

Além disso, **interrompe-se o prazo prescricional de todas as obrigações** em que a liquidanda figura como devedor.

A liquidação extrajudicial se desenvolve **sob o comando de um liquidante**, nomeado pelo Banco Central.

Nos **60 dias seguintes à sua posse**, o liquidante apresentará ao Banco Central um **relatório**. Nesse relatório traz o exame da situação econômico-financeira da instituição, além de dizer quais os atos e omissões danosos eventualmente foram praticados nas instituições, bem como as medidas a serem adotadas de forma conveniente àquela liquidanda.

Ao receber o relatório, **o Banco Central poderá autorizar a continuidade daquela instituição financeira** ou **podará autorizar que seja requerida a falência da instituição financeira**.

Sendo **requerida a falência**, só poderá se justificar **se o ativo da instituição financeira se mostrar menor do que o passivo**, a ponto de **não ser suficiente para pagar pelo menos 50% dos credores quirografários**.

Poderá ainda requerer a falência, caso **haja indícios da ocorrência de crime falimentar**.

Caso o BC **entenda pela continuidade da liquidação extrajudicial**, o liquidante **convoca os credores a habilitarem os seus créditos**, organizando o quadro geral de credores, promovendo a realização do ativo de instituição financeira, **venda essa que se dará por meio de licitação**.

Para a liquidação extrajudicial, serão aplicadas subsidiariamente as regras da lei de falências. Deverá então ser visto o liquidante como administrador judicial e o Banco Central como se fosse o juiz.

11.2. Reorganização da instituição financeira

Perceba-se que a liquidação é uma modalidade de execução concursal, acabando a personalidade da instituição financeira.

Se for possível continuar, é preciso evitar a liquidação extrajudicial, havendo dois documentos que evitam precipuamente a reorganização da instituição financeira:

- **Intervenção;**
- **regime de administração especial temporária (RAET).**

Em ambos os casos há o mesmo objetivo: possibilitar a recuperação econômico-financeira daquela instituição, evitando a liquidação extrajudicial e continuando as suas atividades.

11.2.1. Intervenção

No tocante as causas, poderá ser decretada quando houver um prejuízo decorrente de má-administração, infrações reiteradas de infrações bancárias, etc.



11.2.2. Regime de administração especial temporária (RAET)

Já o Regime de Administração Especial Temporária (RAET) **poderá ser decretado nas hipóteses de intervenção, mas também poderá ser decretado quando se perceber que o passivo é maior do que o ativo, houve uma gestão fraudulenta, gestão temerária, desobediência das reservas bancárias que devem existir.**

Ademais, o RAET e a intervenção se diferenciam quanto aos efeitos. A intervenção implica a **suspensão da exigibilidade das obrigações vencidas**, em face da instituição devedora, e também da **fluência do prazo das obrigações vencidas**.

Ainda, os **depósitos** feitos naquela instituição financeira **serão inexigíveis durante o período de intervenção**.

O RAET não afeta o curso regular dos negócios. **Os seus efeitos irão se concentrar na perda do mandato dos administradores e do conselho fiscal.**

Em relação ao prazo de duração, **a intervenção não poderá ter prazo superior a 6 meses**, podendo ser **prorrogada uma única vez, por até 6 meses**.

Com relação ao RAET, não há prazo determinado pela lei, **devendo ser aplicado pela autoridade administrativa**, podendo este prazo ser prorrogado, desde que o período não seja superior àquele fixada da primeira vez pela autoridade.

A última diferença é que a intervenção é executada por um interventor, enquanto a **RAET é executada por um conselho diretor**, que vai assumir a administração.

Tanto a intervenção quanto o RAET **cessarão**:

- **decretação da falência ou quando há liquidação extrajudicial;**
- **alcançam seu objetivo principal que é a reorganização.**



CAPÍTULO 16 — CONTRATOS EMPRESARIAIS

1. Introdução

Contrato é uma fonte de obrigações. Os contratos que o empresário celebra poderão estar sujeitos a 5 regimes jurídicos diferentes:

- regime administrativo;
- regime trabalhista;
- regime do consumidor;
- regime civil;
- regime comercial.

O devido enquadramento de cada contrato depende de quem figura do outro polo da relação contratual, se for um empregado, o contrato se sujeitará ao regime trabalhista; se for a administração pública, ao regime administrativo; se um cliente, o regime do direito do consumidor; etc.

Todavia, mesmo o contrato entre dois empresários poderá não ser regido pelo direito empresarial. Aqui, há que se fazer uma distinção entre contratos estritamente empresariais, que são os realmente estudados sob a nomenclatura de “contratos empresariais” e os demais contratos que, ainda que firmados entre dois empresários, serão regidos por normas civis ou até mesmo do Direito do Consumidor.

Via de regra, o entendimento prevalente, em situações ordinárias, é no sentido de que “Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados entre empresários em que um dos contratantes tenha por objetivo suprir-se de insumos para sua atividade de produção, comércio ou prestação de serviços” (Enunciado 20 da I Jornada de Direito Comercial do CJF).

Todavia, nada impede que um empresário figure como destinatário final de uma mercadoria adquirida de outro empresário e que aquele esteja em uma situação de vulnerabilidade apta a atrair a regência pelo CDC. Além disso, no CDC foi adotada a teoria do finalismo mitigado. É finalista porque, via de regra, impõe que o adquirente seja o destinatário final do bem para que ela se aplique. Porém, é mitigado, porque, em alguns casos, mesmo que o adquirente seja pessoa jurídica e não seja a destinatária final do bem, poderá ser considerada a existência de uma relação de consumo, caso haja alguma vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica significativa na relação entre adquirente e fornecedor. Esse entendimento já foi inclusive cancelado pelo STJ (vide, entre outros, o RMS 27.512/BA e o AgRg no Ag 1.316.667/RO).

É certo, todavia, que a unificação, sob o regime do CC, da regência diversos contratos que podem ser tanto cíveis quanto empresariais (aqui no sentido de serem firmados entre dois empresários/sociedades empresárias) é alvo de crítica doutrinária. Confira-se:

Submeter contratos cíveis e contratos empresariais (estes entendidos como aqueles firmados entre empresários, no exercício de atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços) a uma mesma “teoria geral” é algo absolutamente equivocado e que a doutrina comercialista, praticamente de forma unânime, tem criticado severamente, a ponto de ter sido iniciado, conforme mencionamos no capítulo I, intenso movimento em defesa da edição de um novo Código Comercial, já tendo sido apresentado à Câmara dos Deputados, inclusive, projeto de lei nesse sentido (PL 1.572/2011).

No entanto, enquanto tal diploma legislativo não vem, é urgente que, pela via da interpretação, seja feita a imprescindível distinção entre os contratos cíveis e empresariais, dada a nítida diferença que há entre eles. Com efeito, os contratos empresariais se caracterizam pela simetria natural entre os contratantes, não sendo justificável aplicar a eles certas regras do Código Civil que analisaremos adiante, as



quais limitam ou relativizam a imprescindível liberdade para a celebração de contratos.

Ademais, em homenagem aos princípios da livre-iniciativa, da livre concorrência e da propriedade privada (princípios constitucionais que sustentam o direito empresarial, conforme visto no capítulo I), os empresários devem ter total liberdade para realizar negócios – desde que lícitos, obviamente –, bem como assumir os riscos de contratações malfeitas. A regra de ouro do livre mercado é a seguinte: o empresário que acerta, ganha; o empresário que erra, perde. Portanto, a intervenção estatal prévia (dirigismo contratual) ou posterior (revisão judicial) nos contratos empresariais deturpa a lógica natural do livre mercado, cria risco moral e traz insegurança jurídica para as relações interempresariais.

Nesse sentido, confira-se o Enunciado 21, da I Jornada de Direito Comercial do CJF, de nossa autoria: “Nos contratos empresariais, o dirigismo contratual deve ser mitigado, tendo em vista a simetria natural das relações interempresariais”.

Finalmente, mais uma vez corroborando nosso entendimento de que as regras do Código Civil sobre contratos não devem ser aplicadas indistintamente a contratos cíveis e empresariais, confira-se o Enunciado 28 da I Jornada de Direito Comercial do CJF: “Em razão do profissionalismo com que os empresários devem exercer sua atividade, os contratos empresariais não podem ser anulados pelo vício da lesão fundada na inexperiência”. (CRUZ, 2016).

2. Princípios dos contratos empresariais

São princípios que regem a constituição do vínculo contratual:

- **princípio da autonomia da vontade:** respeitada a função social do contrato (art. 421 do CC) e observadas demais normas de ordem pública e os bons costumes, é assegurada a liberdade de contratar (faculdade de realizar ou não um contrato) e a liberdade contratual (estipulação do conteúdo do contrato).
- **princípio da atipicidade dos contratos:** decorrente do princípio da autonomia da vontade, em sua vertente “liberdade contratual”, e expressamente previsto no art. 425 do CC, assegura que as partes criem tipos novos de contrato, sem prévio regramento legal.
- **princípio do consensualismo:** estabelece que o contrato se constitui pelo encontro de vontades. Não seria necessária qualquer outra condição. O contrato nasceria dessa comunhão de vontades. O princípio do consensualismo **tem exceções**, casos em que para celebrar o contrato não bastará a vontade. Exemplo disso são os **contratos reais**, os quais exigem a entrega da coisa (tradição). Nos **contratos solenes** também não basta esse consensualismo, sendo preciso que haja a elaboração de um instrumento contratual formal. Ex.: compra e venda de um imóvel necessita, como regra, de escritura pública;
- **princípio da relatividade:** o contrato só obriga as partes a ele vinculadas. Excepcionam essa regra os casos de seguro de vida, de estipulação em favor de terceiros, entre outros casos em que há duas pessoas contratando e uma terceira pessoa sendo atingida. Outra exceção se dá nos casos de aplicação da teoria da aparência, que será analisada adiante.
- **Princípio da força obrigatória:** caracterizado pela cláusula *pacta sunt servanda*. Há uma cláusula geral de irretratabilidade e de intangibilidade. Os direitos e deveres decorrentes do contrato são “lei” entre as partes. Excepcionam-se os casos em que se aplica a teoria da imprevisão, que será adiante estudada.
- **Princípio da boa-fé:** art. 422 do CC: “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.



3. Teoria da aparência

Questão interessante diz respeito às questões aparentes, que iludem o contratante de boa-fé. A teoria da aparência obriga a pessoa a cumprir o contrato por aquele que deixou de ser o seu representante ou que agiu fora dos limites da representação, se aquele que contratou tinha reais motivos para crer que aquela representação continuava a existir ou que os limites do mandato estavam sendo observados.

Isso é muito comum nos chamados **excessos de mandato** ou na **continuação de mandato findo**. Ex.: Fulano era representante de uma marca por mais de 10 anos. Vendia produtos aos comerciantes da região. Num dado momento, o contrato de representação comercial foi rompido, sem qualquer tipo de publicidade a respeito, e Fulano continuou a negociar com os comerciantes, que não possuíam razão para desconfiar do término da relação de representação. Em tal situação, como eles estariam de boa-fé, será possível exigir da sociedade representada os valores de volta ou os produtos, pois não tinham o conhecimento do rompimento do vínculo. Trata-se de aplicação da teoria da aparência.

Nesse caso, ficará **assegurado o direito de regresso** pelo mandante em relação ao mandatário.

4. Teoria da imprevisão (cláusula *rebus sic stantibus*) e *pacta sunt servanda*

Ao se vincularem por um contrato, as partes assumem obrigações. Uma poderá exigir da outra a prestação, visto que o contrato faz lei entre as partes, sendo denominada tal regra de ***pacta sunt servanda***.

Todavia, o ***pacta sunt servanda*** tem uma limitação em decorrência da cláusula ***rebus sic stantibus*** (“**estando as coisas como estão**”), que abre azo à **teoria da imprevisão**, com regramento nos arts. 478 a 480 do CC.

Se, após a celebração do contrato, uma das partes tiver sua **situação econômica alterada substancialmente**, em razão de **fatores imprevisíveis e independentes de sua vontade**, fazendo com que o cumprimento do contrato se torne **excessivamente oneroso**, poderá requerer a **revisão de suas condições contratuais**, caso seja possível, **ou mesmo a resolução do contrato**.

A cláusula ***rebus sic stantibus*** é implícita somente nos contratos comutativos, em que as partes já sabem o que vão prestar e o que irão receber.

Nos **contratos aleatórios**, em que o objeto essencial do contrato é o risco, **os contratantes assumem o risco de ganhar ou de perder, inexistindo equilíbrio**. E se aquele fator ocorreu mesmo não há de que se falar em ausência de cumprimento, visto que é do contrato aleatório inclusive o risco de se perder.

No âmbito empresarial, todavia, a sua incidência deve ser vista com cautela. O próprio STJ, por exemplo, embora admita a revisão de contratos de consumo atrelados ao dólar em caso de excepcional valorização da moeda, afasta tal possibilidade em relação a contratos empresariais. Também nesse sentido, os seguintes enunciados do CJF:

Enunciado 23. Em contratos empresariais, é lícito às partes contratantes estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação dos requisitos de revisão e/ou resolução do pacto contratual.

Enunciado 25. A revisão do contrato por onerosidade excessiva fundada no Código Civil deve levar em conta a natureza do objeto do contrato. Nas relações empresariais, deve-se presumir a sofisticação dos contratantes e observar a alocação de riscos por eles acordada.

Ainda sobre o tema, esclarece André Santa Cruz:



@cpiuris



www.cpiuris.com.br



contato@cpiuris.com.br



No âmbito dos contratos empresariais, é temerário admitir a rescisão ou a revisão de contratos com base na onerosidade excessiva, ainda que esta seja decorrente de situações extraordinárias e imprevisíveis. Trata-se de uma regra que não pode ser aplicada indistintamente a contratos cíveis, contratos de consumo e contratos empresariais. Nas duas primeiras espécies de contrato, pode-se até aceitar a aplicação da teoria da imprevisão, mas nos contratos empresariais ela deve ser rechaçada.

Se um empresário celebra um contrato no qual ele vislumbra a possibilidade, ainda que mínima, de alterações circunstanciais que afetem a relação contratual, deve se precaver, por exemplo, por meio de um hedge.

O hedge é uma operação muito específica, usada principalmente no mercado de valores mobiliários (mercado de capitais). Traduzidas para o português, as expressões “hedge” ou “hedging” significam “cerca”, “proteção” ou “cobertura”, e isso ajuda a entender melhor o instituto, que visa a proteger um determinado agente econômico quanto a eventuais riscos de uma operação futura sujeita a oscilações naturais do seu mercado. Assim, o hedge, na verdade, não é um contrato típico, mas apenas uma operação ínsita a determinados negócios aleatórios (que envolvem risco), como os realizados no mercado de capitais, por exemplo. (CRUZ, 2016).

5. *Exceptio non adimpleti contractus e pacta sunt servanda*

Com relação à força obrigatória do contrato, existe outra limitação denominada *exceptio non adimpleti contractus* (exceção de contrato não cumprido), prevista no art. 476 do CC.

Isto é, uma parte não poderá exigir o cumprimento do contrato pela outra, caso ela mesma esteja em mora. O art. 477 do CC complementa o disposto no art. 476, ao estipular que:

Art. 477. Se, depois de concluído o contrato, sobrevier a uma das partes contratantes diminuição em seu patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, pode a outra recusar-se à prestação que lhe incumbe, até que aquela satisfaça a que lhe compete ou dê garantia bastante de satisfazê-la.

6. Compra e venda mercantil

A compra e venda é mercantil **quando o comprador e o vendedor são empresários**. São seus elementos essenciais: o consentimento, a coisa e o preço.

A compra e venda mercantil será um **contrato consensual**, ou seja, havendo encontro de vontades, o contrato está fechado. A partir daí, o comprador assume a obrigação de pagar o preço e o vendedor assume a obrigação de transferir o domínio (entregar a coisa). Excepciona-se o contrato de compra e venda de bens imóveis, que apenas se aperfeiçoa com seu efetivo registro. Destaque-se que, incidem, como base normativa, as disposições do próprio Código Civil sobre o contrato de compra e venda (art. 481 e ss do CC).

Via de regra, as despesas da tradição cabem ao vendedor (transporte da coisa). Portanto, em princípio, é dever do vendedor entregar o bem no estabelecimento do comprador. No entanto, as partes podem estabelecer disposição diversa, o que é tão comum que a CCI – Câmara de Comércio Internacional convencionou algumas cláusulas padrões sobre o tema (INCOTERMS).

Tais INCOTERMS são classificados segundo a distribuição que as partes fazem entre elas das despesas relativas à tradição (entrega da coisa), havendo quatro tipos de contratos, sendo a regra geral que o vendedor pague pelo transporte:

- **contrato de partida:** mercadoria entregue ao comprador no estabelecimento do vendedor. Aqui, o vendedor não paga nada em relação ao transporte;



- **contrato de transporte principal não pago:** mercadoria entregue a um transportador internacional indicado pelo comprador;
- **contrato de transporte principal pago:** o vendedor contrata o transporte, sem assumir riscos por perdas ou danos às mercadorias ou custos adicionais decorrentes de eventos ocorridos após o embarque e despacho;
- **contrato de chegada:** o vendedor se responsabiliza por todos os custos e riscos para colocar a mercadoria no local de destino. Isto é, o vendedor se responsabiliza pelo transporte integral.

As normas específicas dessas INCOTERMS, que serão abaixo apresentadas, também podem ser encontradas na Resolução 21/2011 da Câmara de Comércio Exterior – CAMEX.

6.1. Contrato de partida

O contrato de partida traz a **cláusula EXW (Ex Works – local de chegada)**, a qual estabelece que se o contrato é de partida, o comprador assumirá com exclusividade os custos relativos ao recolhimento da mercadoria do estabelecimento do vendedor.

A partir da partida da mercadoria, caberá ao comprador o pagamento do transporte. Isto é, o comprador busca a mercadoria no estabelecimento do vendedor.

6.2. Contrato de transporte principal não pago

Aqui, **o transporte principal não será pago pelo vendedor**, sendo uma exceção à regra de que sobre o vendedor recaem as despesas da tradição.

Existem três cláusulas previstas:

- **cláusula FCA (free carrier – local indicado):** O vendedor completa suas obrigações e encerra sua responsabilidade quando entrega a mercadoria, desembaraçada para a exportação, ao transportador ou a outra pessoa indicada pelo comprador, no local nomeado do país de origem. A partir daquele momento, cessam todas as responsabilidades do vendedor, ficando o comprador responsável por todas as despesas e por quaisquer perdas ou danos que a mercadoria possa vir a sofrer. O comprador poderá indicar outra pessoa, que não seja o transportador, para receber a mercadoria. Nesse caso, o vendedor encerra suas obrigações quando a mercadoria é entregue àquela pessoa indicada. Esse termo pode ser utilizado em qualquer modalidade de transporte;
- **cláusula FAS (free alongside ship – porto de embarque indicado):** por este contrato, o vendedor se obriga a transportar o bem até determinado porto. Caberá ao comprador as despesas do desembarço para exportação, com o embarque da mercadoria, seguro e outras necessárias, começando ele a pagar antes mesmo do transporte. **O vendedor encerra suas obrigações no momento em que a mercadoria é colocada ao lado do navio transportador, no cais ou em embarcações utilizadas para carregamento, no porto de embarque designado.** A partir daquele momento, o comprador assume todos os riscos e custos com carregamento, pagamento de frete e seguro e demais despesas. **O vendedor é responsável pelo desembarço da mercadoria para exportação.** Esse termo pode ser utilizado **somente para transporte aquaviário** (marítimo fluvial ou lacustre);
- **cláusula FOB (free on board):** as despesas com transporte da mercadoria até um certo ponto, com o embarque das mercadorias no navio e com o desembarço da exportação correm por conta do vendedor. Os demais encargos correm por conta do comprador. Isto é, o vendedor entrega a mercadoria a bordo do navio no porto de embarque indicado, e a partir daquele momento, o comprador assume todas as responsabilidades quanto a perdas e danos. A entrega se consuma a bordo do navio



designado pelo comprador, quando todas as despesas passam a correr por conta do comprador. O vendedor é o responsável pelo desembaraço da mercadoria para exportação. Esse termo pode ser utilizado exclusivamente no transporte aquaviário (marítimo, fluvial ou lacustre).

*Obs: as informações acima foram compiladas do site:
<<https://www.rmseguros.com.br/incoterms.htm>>

6.3. Contrato de transporte principal pago

Nesse caso, o **transporte principal será a cargo do vendedor**. As variações são no sentido de que será a mercadoria levada até o porto de chegada ou não, se vai levar até uma localidade determinada, ou ainda se será responsável por eventual perda ou não. Estas são as variações.

Aqui, há quatro cláusulas possíveis:

- **cláusula CFR (*cost and freight* – custo e frete):** o vendedor só pagará o transporte principal, pois qualquer coisa que ocorra na mercadoria a partir do momento em que está sendo transportada será de risco do comprador. O **vendedor é o responsável pelo pagamento dos custos necessários para colocar a mercadoria a bordo do navio**. O vendedor é responsável pelo pagamento do frete até o porto de destino designado. O vendedor é responsável pelo desembaraço da exportação. **Os riscos de perda ou dano da mercadoria, bem como quaisquer outros custos adicionais são transferidos do vendedor para o comprador no momento em há que a mercadoria cruze a murada do navio**. Caso queira se resguardar, o comprador deve contratar e pagar o seguro da mercadoria. Essa cláusula é utilizável exclusivamente no transporte aquaviário (marítimo, fluvial ou lacustre);
- **cláusula CIF (*cost, insurance and freight* – custo, seguro e frete):** o vendedor vai assumir todas as despesas com transporte, incluindo seguro marítimo e desembaraço para exportação. A responsabilidade sobre a mercadoria é transferida do vendedor para o comprador no momento da transposição da amurada do navio no porto de embarque. O vendedor é o responsável pelo pagamento dos custos e do frete necessários para levar a mercadoria até o porto de destino indicado. O comprador deverá receber a mercadoria no porto de destino e daí para frente se responsabilizar por todas as despesas. **O vendedor é responsável pelo desembaraço das mercadorias para exportação. O vendedor deverá contratar e pagar o prêmio de seguro do transporte principal. O seguro pago pelo vendedor tem cobertura mínima, de modo que compete ao comprador avaliar a necessidade de efetuar seguro complementar**. Os riscos a partir da entrega (transposição da amurada do navio) são do comprador. Essa cláusula é utilizável exclusivamente no transporte aquaviário (marítimo, fluvial ou lacustre);
- **cláusula CPT (*carriage paid to* – transporte pago até):** o vendedor vai arcar com as despesas de transporte até uma localidade designada, salvo as despesas relativas a perdas e danos. O risco da perda é do comprador. Em outras palavras, **o vendedor contrata e paga o frete para levar as mercadorias ao local de destino designado**. A partir do momento em que as mercadorias são entregues à custódia do transportador, **os riscos por perdas e danos se transferem do vendedor para o comprador**, assim como possíveis custos adicionais que possam incorrer. O vendedor é o responsável pelo desembaraço das mercadorias para exportação. Cláusula utilizada em qualquer modalidade de transporte. Caso ele queira que o risco da perda corra pelo vendedor, então deverá contratar o CIP (*Carriage and Insurance Paid To*).



- **cláusula CIP (*carriage and insurance paid to* – transporte e seguro pago até):** o vendedor vai arcar com as despesas do transporte principal, inclusive com eventuais perdas ocorridas durante o transporte. **Nessa modalidade, as responsabilidades do vendedor são as mesmas descritas no CPT, acrescidas da contratação e pagamento do seguro até o destino.** A partir do momento em que as mercadorias são entregues à custódia do transportador, os riscos por perdas e danos se transferem do vendedor para o comprador, assim como possíveis custos adicionais que possam incorrer. O seguro pago pelo vendedor tem cobertura mínima, de modo que compete ao comprador avaliar a necessidade de efetuar seguro complementar. Cláusula utilizada em qualquer modalidade de transporte.

*Obs: as informações acima foram compiladas do site:
<<https://www.rmseguros.com.br/incoterms.htm>>

6.4. Contrato de chegada

Aqui, existem três cláusulas:

- **cláusula DAT (*delivered at terminal* – entregue no terminal no porto ou local de destino designado):** o devedor se obrigará por todas as despesas até o desembarque da mercadoria vendida no terminal. Isto é, a responsabilidade do vendedor consiste em colocar a mercadoria à disposição do comprador, não desembaraçada para importação, no terminal do porto ou local de destino designado. **O vendedor arca com os custos e riscos inerentes ao transporte até o porto de destino e com a descarga da mercadoria no cais.** A partir daí a responsabilidade é do comprador, inclusive no que diz respeito ao desembarço aduaneiro de importação. Terminal inclui qualquer local, coberto ou não, tais como um cais, um armazém, um terminal de container, um terminal aéreo ou rodoviário;
- **cláusula DAP (*delivered at place* – entregue no local de destino designado):** o vendedor é responsável pelas mercadorias até ficarem disponíveis ao comprador em um determinado lugar, diferente do terminal. Cabe ao comprador pagar o desembarque, pois, do contrário, haverá um DDP. Em outras palavras, **o vendedor deve colocar a mercadoria à disposição do comprador, no ponto de destino designado, sem estar desembaraçada para importação e sem descarregamento do veículo transportador.** O vendedor assume todas as despesas e riscos envolvidos até a entrega da mercadoria no local de destino designado, exceto quanto ao desembarço e custos dos direitos de importação. Cabe ao comprador o pagamento de direitos, impostos e outros encargos oficiais por motivo da importação. Esse termo pode ser utilizado para qualquer modalidade de transporte.
- **cláusula DDP (*delivered, duty paid* – entregue, impostos pagos):** o vendedor coloca as mercadorias à disposição do comprador no local designado, no país de exportação, respondendo em decorrência disso o vendedor pelas despesas de transporte, de seguro e de desembarço para a importação. Dito de outra forma, o vendedor entrega a mercadoria ao comprador, desembaraçada para importação no local de destino designado. É o INCOTERM que estabelece o maior grau de compromisso para o vendedor, na medida em que o mesmo assume todos os riscos e custos relativos ao transporte e entrega da mercadoria no local de destino designado. Não deve ser utilizado quando o vendedor não está apto a obter, direta ou indiretamente, os documentos necessários à importação da mercadoria. Embora esse termo possa ser utilizado para qualquer meio de transporte, deve-se observar que é necessária a utilização dos termos DES ou DEQ nos casos em que a entrega é feita no porto de destino (a bordo do navio ou no cais).



*Obs: as informações acima foram extraídas do site:
<<https://www.rmseguros.com.br/incoterms.htm>>

7. Contratos de colaboração

Os contratos de colaboração, segundo Fábio Ulhoa, são gênero.

São conceituados como sendo **obrigações assumidas por um dos contratantes (colaborador) perante outro (fornecedor)**, sendo que esta **obrigação que o colaborador assume é a de criar ou de ampliar o mercado de produtos ou serviços fabricados ou comercializados pelo fornecedor**. Por isso ele colabora.

Exemplo disso são os casos de comissão, representação comercial, concessão mercantil, distribuição, etc. Todavia, o caso mais marcante para entender o contrato de colaboração é o contrato de franquia.

Os contratos de colaboração, em razão da obrigação essencial que os caracteriza, têm em comum a denominada **subordinação empresarial**.

Atente-se que se **trata de uma subordinação de uma empresa em relação à outra empresa**. Se a subordinação for pessoal, haverá uma relação trabalhista. O colaborador deverá atender determinados padrões de exploração da atividade empresarial.

Na franquia do McDonald's, por exemplo, em qualquer lugar do Brasil espera-se um Big Mac exatamente o mesmo, com o mesmo atendimento. Isso se dá porque o franqueado deverá obedecer às normas do fornecedor.

Perceba que há uma relação de subordinação empresarial, estando relacionada à própria organização da atividade econômica.

O colaborador contratado se compromete a colocar a mercadoria comercializada ou produzida pelo fornecedor à disposição das pessoas, sempre observando as orientações gerais ou específicas estabelecidas por aquele fornecedor.

7.1. Espécies de colaboração empresarial

A colaboração empresarial poderá se enquadrar em dois grupos:

- **colaboração por aproximação:** o colaborador não adquire o produto do fornecedor para revender o produto. O colaborador simplesmente aproxima o interessado do fornecedor. Ex.: representante comercial: indústria contrata um representante comercial para vender ao atacadista; mas quem firma o contrato com o atacadista será a indústria, não o representante. Esses representantes serão remunerados por um percentual dos negócios que ajudem a viabilizar;
- **colaboração por intermediação:** o colaborador celebra com o fornecedor um contrato de compra e venda. Isto é, ele compra a mercadoria do fornecedor e, em seguida, vende a mercadoria do fornecedor para o terceiro interessado, normalmente consumidor. Ex.: concessionária de veículos, pois ela compra o carro da fábrica e vende para as pessoas comprarem os carros. Outro exemplo é o franqueado, o qual compra roupas, as quais ficam na loja até o consumidor comprá-las.

O contrato de distribuição pode ser tanto por intermediação quanto por aproximação.

7.2. Contrato de comissão mercantil

O contrato de comissão gera um vínculo em que **o empresário (comissário) se obriga a realizar negócios mercantis por conta de outro empresário (comitente)**. Todavia, o comissário se obriga em nome próprio, ao contrário do que ocorre na representação comercial.



Perante terceiros, quem assume a responsabilidade é o comissário, não o comitente. Essa é a diferença para o mandato, pois o mandatário não responde perante terceiros, já que celebra o contrato em nome do mandante.

Também se aplicam, aqui, como base normativa, as disposições do Código Civil acerca do contrato de comissão (arts. 693 e ss). De acordo com o art. 696 do CC: “no desempenho das suas incumbências o comissário é obrigado a agir com cuidado e diligência, não só para evitar qualquer prejuízo ao comitente, mas ainda para lhe proporcionar o lucro que razoavelmente se podia esperar do negócio”. Já seu parágrafo único determina que “responderá o comissário, salvo motivo de força maior, por qualquer prejuízo que, por ação ou omissão, ocasionar ao comitente”. Além disso, o comissário tem a obrigação de observar as instruções expedidas pelo comitente; e será remunerado por comissão, geralmente um percentual dos negócios que entabular.

No contrato de comissão, se houver instruções do comitente proibindo prorrogação de prazos para pagamento, ou se esta não for conforme os usos locais, poderá o comitente exigir que o comissário pague incontinenti ou responda pelas consequências da dilação concedida, procedendo-se de igual modo se o comissário não der ciência ao comitente dos prazos concedidos e de quem é seu beneficiário.

Ademais, o comissário responde pela insolvência das pessoas com quem tratar se agir com culpa.

Por fim, sinala-se que é possível a estipulação da cláusula *del credere*. Sobre o tema:

Conforme vimos, os riscos do negócio cabem ao comitente, já que o comissário, embora atue em seu próprio nome, o faz no interesse do comitente e à conta dele, seguindo, aliás, as suas instruções. Assim, se os terceiros com quem o comissário contratou não honrarem suas obrigações, o prejuízo deverá ser suportado pelo comitente, e não pelo comissário (art. 697). Todavia, havendo a previsão da cláusula *del credere*, o comissário assumirá a responsabilidade solidária juntamente com os terceiros com quem contratar. Claro que, nesse caso, como o risco de suas operações aumenta, ele será ainda mais diligente, e terá, obviamente, direito a uma comissão maior. A regra está disciplinada no art. 698 do Código: “se do contrato de comissão constar a cláusula *del credere*, responderá o comissário solidariamente com as pessoas com que houver tratado em nome do comitente, caso em que, salvo estipulação em contrário, o comissário tem direito a remuneração mais elevada, para compensar o ônus assumido”. (CRUZ, 2016)

7.3. Contrato de representação comercial

De acordo com o art. 1º da Lei de Representação Comercial (Lei nº 4.886/65), “Exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprêgo, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios.”

Em outras palavras, o contrato de representação comercial ocorre quando uma das partes (representante comercial autônomo) **se obriga a obter pedidos de compra e venda de mercadorias fabricadas ou comercializadas pela outra parte, que é o representado**.

O representante se encarrega de conseguir pessoas para compra das mercadorias do representado na região.

A representação comercial é uma atividade autônoma, **não tendo o representante, em regra, poderes para concluir a negociação em nome do representado**. Ou seja, não há propriamente um mandato entre as partes. Quem assina os negócios é o próprio representado. O representante apenas encaminha os interessados, realizando uma intermediação.



Ex.: representante comercial consegue um atacadista para comprar R\$ 50 mil da fábrica. Em tal caso, o representante fará o pedido e mandará para a fábrica. Quem irá aprovar esse pedido será a própria fábrica, ou seja, é o representado. O representante é autônomo, mas é o representado quem vai decidir.

Portanto, pela regra geral (caput do art. 1º), não se confunde com o mandato, visto que o mandatário agirá nos limites dos poderes a eles outorgados pelo mandato. No caso do representante, haverá apenas a aproximação, pois quem celebrará o contrato será o representado ficando o representante comercial de fora.

Mas há a possibilidade de expressa previsão da concessão de mandato mercantil em contratos de representação comercial, conforme autoriza o p.u. do art. 1º: “Parágrafo único. Quando a representação comercial incluir poderes atinentes ao mandato mercantil, serão aplicáveis, quanto ao exercício dêste, os preceitos próprios da legislação comercial.”

Conforme já visto pela leitura do caput do art. 1º, o representante comercial autônomo **é empresário**, podendo ser **pessoa física ou pessoa jurídica**.

Além disso, o representante comercial autônomo deverá se registrar no órgão profissional, que é o Conselho Regional dos Representantes Comerciais. Caso seja pessoa jurídica, também deverá ser registrado na Junta Comercial.

Como se trata de um contrato empresarial, não caracteriza relação de emprego (STJ) – logo, as demandas entre representante e representado correrão na justiça comum –, nem há espaço para a incidência do CDC entre ambos (STJ).

Atente-se que **é vedado** que no contrato de **representação comercial** haja a **inclusão de cláusula *del credere* (art. 43)**.

O art. 27 da Lei de Representação Comercial traz os requisitos desse contrato:

Art. 27. Do contrato de representação comercial, além dos elementos comuns e outros a juízo dos interessados, constarão obrigatoriamente: (Redação dada pela Lei nº 8.420, de 8.5.1992)

- a) condições e requisitos gerais da representação;
- b) indicação genérica ou específica dos produtos ou artigos objeto da representação;
- c) prazo certo ou indeterminado da representação;
- d) indicação da zona ou zonas em que será exercida a representação; (Redação dada pela Lei nº 8.420, de 8.5.1992)
- e) garantia ou não, parcial ou total, ou por certo prazo, da exclusividade de zona ou setor de zona;
- f) retribuição e época do pagamento, pelo exercício da representação, dependente da efetiva realização dos negócios, e recebimento, ou não, pelo representado, dos valores respectivos;
- g) os casos em que se justifique a restrição de zona concedida com exclusividade;
- h) obrigações e responsabilidades das partes contratantes;
- i) exercício exclusivo ou não da representação a favor do representado;
- j) indenização devida ao representante pela rescisão do contrato fora dos casos previstos no art. 35, cujo montante não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação. (Redação dada pela Lei nº 8.420, de 8.5.1992)

§ 1º Na hipótese de contrato a prazo certo, a indenização corresponderá à importância equivalente à média mensal da retribuição auferida até a data da rescisão, multiplicada pela metade dos meses resultantes do prazo contratual. (Redação dada pela Lei nº 8.420, de 8.5.1992)

§ 2º O contrato com prazo determinado, uma vez prorrogado o prazo inicial, tácita ou expressamente, torna-se a prazo indeterminado. (Incluído pela Lei nº 8.420, de 8.5.1992)

§ 3º Considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder, dentro de seis meses, a outro contrato, com ou sem determinação de prazo. (Incluído pela Lei nº 8.420, de 8.5.1992)



Quanto à indicação da área de abrangência da representação (zona) (alínea “d”), destaque-se que, na omissão do contrato, **o representado deverá respeitar a cláusula de exclusividade da zona que o representante atua**. Assim, caso o representado venda diretamente ou por terceiros seus produtos na zona estabelecida no contrato, todas as vendas devem ser imputadas ao representante para fins de cálculo de sua comissão (art. 31, caput). De acordo com o STJ, essa exclusividade de zona pode também ficar demonstrada em contratos verbais, mas não haverá presunção (não se considerará cláusula implícita), necessitando de prova em tal sentido (qualquer meio em direito admitido) (vide REsp 846.543/RS).

Por outro lado, o representante comercial pode trabalhar para mais de um representado, salvo expressa disposição em sentido contrário. É o que se depreende do p.u. do art. 31 e do art. 41.

A lei estabelece **indenizações pela resolução** dos contratos de representação comercial.

No caso de **contratos com prazo indeterminado firmados há mais de 6 meses**, é preciso que haja um **aviso prévio de 30 dias por parte do representante ou por parte do representado**. Caso não se observe o prazo de 30 dias, deverá haver uma **indenização**, a qual corresponderá a **1/3 das comissões dos últimos 3 meses** (art. 34).

Caso **haja culpa**, o STJ entende que **não cabe essa indenização**: não é devida a verba atinente ao aviso prévio – *um terço das comissões auferidas pelo representante comercial nos três meses anteriores à resolução do contrato* –, quando o fim do contrato de representação comercial se der por justa causa.

O representado poderá promover a resolução do contrato sem indenização ao representante quando o representante incorrer em desídia, quando praticar atos que importem em descrédito comercial ao representado, quando deixar de cumprir quaisquer obrigações inerentes ao contrato, se o representante for condenação por crime infamante ou ainda nos casos de força maior (art. 35 da Lei).

Por outro lado, **o representante também poderá resolver o contrato** quando o **representado der causa a esta resolução**, como por exemplo:

- quando houver redução de esfera de atividade do representante em desacordo com as cláusulas do contrato;
- quando o representado incorre em **inobservância de cláusula de exclusividade**;
- quando o **representado não pagar a comissão na época devida**;
- quando o **representado fixar preços abusivos em relação à zona do representante, de modo a inviabilizar sua atuação regular**;
- quando houver **força maior**.

Se não houver conduta ilícita por parte do representante (art. 35), este terá direito a uma **indenização** prevista no contrato, que **não poderá ser inferior a 1/12 do total de comissões** já auferidas pelo representante, devendo ser corrigido (alínea “j” do art. 27).

Caso o contrato seja por **prazo determinado**, a lei diz que a indenização será equivalente à **multiplicação da média mensal das comissões auferidas pela metade dos meses restantes do contrato**.

Em casos de rescisão imotivada, o STJ entendeu que, embora o art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/65 preveja que o representado deverá pagar uma indenização ao representante, cujo montante não poderá ser inferior a 1/12 do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação, o valor dessa indenização não pode ser pago **antecipadamente**, diluído no contrato de representação comercial. Nesse sentido: STJ – “É nula a cláusula que prevê o pagamento antecipado da indenização devida ao representante comercial no caso de rescisão injustificada do contrato pela representada” (STJ. 3ª Turma. REsp 1.831.947-PR, julgado em 10/12/2019).



7.4. Contrato de concessão mercantil

Na concessão mercantil, o concessionário se obriga a comercializar, com ou sem exclusividade, com ou sem cláusula de territorialidade, os produtos fabricados por outro empresário, o concedente. Via de regra, é um contrato atípico, salvo em relação à concessão comercial de veículos automotores terrestres, que é regida pela Lei Ferrari (Lei nº 6.729/79). Segundo o STJ, essa lei não se aplica a hipóteses diversas da distribuição de veículos automotores, **não podendo se aplicar às demais formas de concessão mercantil**.

É caracterizado por um grau ainda maior de subordinação empresarial, exercendo o concedente um grau maior de ingerência na organização da atividade prestada pelo concessionário.

Aqui, há a proibição de o concessionário comercializar produtos diversos dos fabricados pelo concedente. Em outras palavras, só poderá comercializar produtos de determinada marca.

A **cláusula de territorialidade** se refere à **proibição de o concedente de comercializar os seus produtos na área de atuação reservada ao concessionário**. Essa cláusula, ao contrário do que ocorre na representação comercial, é mais rara na concessão mercantil, especialmente na de veículos automotores, constando inclusive da lei diversas disposições que partem do pressuposto da ausência de exclusividade de zona (ex: art. 5º, II e § 1º, § 3º, art. 6º, art. 15).

De acordo com o STJ, perante os consumidores, concedente e concessionário são solidariamente responsáveis por vícios nos veículos comercializados, com base no art. 18 do CDC.

Pela Lei nº 6.729/79, constitui objeto da concessão:

Art. 3º Constitui objeto de concessão:

- I - a comercialização de veículos automotores, implementos e componentes fabricados ou fornecidos pelo produtor;
- II - a prestação de assistência técnica a esses produtos, inclusive quanto ao seu atendimento ou revisão;
- III - o uso gratuito de marca do concedente, como identificação.

Ademais, constitui direito do concessionário também a comercialização de:

- implementos e componentes novos produzidos ou fornecidos por terceiros;
- mercadorias de qualquer natureza que se destinem a veículo automotor, implemento ou à atividade da concessão;
- veículos automotores e implementos usados de qualquer marca.

Poderá o concessionário ainda comercializar outros bens e prestar outros serviços, **compatíveis com a concessão**.

7.5. Franquias

A franquia é um contrato por meio do qual uma empresa (franqueador) transfere a outra (franqueado) o **direito de usar a sua marca ou patente e de comercializar seus produtos ou serviços, podendo, ainda, haver a transferência de conhecimentos do franqueador para o franqueado**.

O empresário franqueador, além de licenciar o uso da sua marca a outro empresário (franqueado), prestará os serviços de organização empresarial.

A franquia consiste na conjugação de dois contratos:

- contrato de licenciamento do uso de marca;
- prestação de organização de serviços empresariais do franqueador.

Segundo a Lei nº 8.955/94, em seu art. 2º, franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semiexclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também



ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício.

O serviço de organização empresarial, que o franqueador presta ao franqueado, são decorrentes de três contratos:

- **contratos de *engineering***: o franqueador vai projetar a arquitetura, layout, do estabelecimento do franqueado;
- **contrato de *management***: o franqueador irá prestar serviços de gerência e treinamento de funcionários, além da estruturação da administração do negócio ao franqueado;
- **contrato de *marketing***: aqui o franqueador irá auxiliar nas questões de marketing ao franqueado.

Segundo o STJ, a franquia é um contrato empresarial e, em razão de sua natureza, não está sujeito às regras protetivas previstas no CDC entre franqueado e franqueador. Em outras palavras, **a relação entre o franqueador e o franqueado não é uma relação de consumo**, mas sim de fomento econômico com o objetivo de estimular as atividades empresariais do franqueado.

O franqueado não é consumidor de produtos ou serviços da franqueadora, mas sim um empresário que os comercializa para terceiros, estes sim, os destinatários finais. Dessa forma, **a franqueadora responde solidariamente com a franqueada pelos danos que esta causar ao consumidor, independentemente de haver previsão contratual** de que apenas a franqueada responde pelos danos que causar a terceiros. Com efeito, de acordo com os artigos 14 e 18 do CDC todos aqueles que participarem da cadeia de consumo responderão pelos danos causados ao consumidor. Eventual cláusula limitativa da responsabilidade vale apenas entre as partes (franqueador e franqueado, para fins de delimitação de eventual responsabilidade regressiva).

O STJ inclusive entendeu que **o contrato de franquia é um contrato de adesão**, mesmo não se tratando de contrato de consumo. Os contratos de adesão se caracterizam pela **desigualdade entre as partes contratantes**. Não existe, assim, discussão a respeito do teor do contrato e suas cláusulas, de modo que o oblato cinge-se a anuir à proposta do solicitante. Tais contratos supõem, antes de mais nada, a superioridade econômica de um dos contratantes, que fixa unilateralmente as cláusulas contratuais. O contratante economicamente mais fraco manifesta seu consentimento aceitando, pura e simplesmente, as condições gerais impostas pelo outro contratante. A proposta é, de regra, aberta a quem se interessar pela contratação, e a oferta é predeterminada, uniforme e rígida.

O franqueador deve fornecer ao franqueado uma **circular de oferta de franquia**. Essa circular deverá ser fornecida, **sob pena de anulabilidade do contrato, pelo menos 10 dias antes da assinatura do contrato**, não podendo conter qualquer informação falsa. De acordo com o art. 2º da Lei:

Art. 2º Para a implantação da franquia, o franqueador deverá fornecer ao interessado Circular de Oferta de Franquia, escrita em língua portuguesa, de forma objetiva e acessível, contendo obrigatoriamente:

- I - histórico resumido do negócio franqueado;
- II - qualificação completa do franqueador e das empresas a que esteja ligado, identificando-as com os respectivos números de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
- III - balanços e demonstrações financeiras da empresa franqueadora, relativos aos 2 (dois) últimos exercícios;
- IV - indicação das ações judiciais relativas à franquia que questionem o sistema ou que possam comprometer a operação da franquia no País, nas quais sejam parte o franqueador, as empresas controladoras, o subfranqueador e os titulares de marcas e demais direitos de propriedade intelectual;



V - descrição detalhada da franquia e descrição geral do negócio e das atividades que serão desempenhadas pelo franqueado;

VI - perfil do franqueado ideal no que se refere a experiência anterior, escolaridade e outras características que deve ter, obrigatória ou preferencialmente;

VII - requisitos quanto ao envolvimento direto do franqueado na operação e na administração do negócio;

VIII - especificações quanto ao:

a) total estimado do investimento inicial necessário à aquisição, à implantação e à entrada em operação da franquia;

b) valor da taxa inicial de filiação ou taxa de franquia;

c) valor estimado das instalações, dos equipamentos e do estoque inicial e suas condições de pagamento;

IX - informações claras quanto a taxas periódicas e outros valores a serem pagos pelo franqueado ao franqueador ou a terceiros por este indicados, detalhando as respectivas bases de cálculo e o que elas remuneram ou o fim a que se destinam, indicando, especificamente, o seguinte:

a) remuneração periódica pelo uso do sistema, da marca, de outros objetos de propriedade intelectual do franqueador ou sobre os quais este detém direitos ou, ainda, pelos serviços prestados pelo franqueador ao franqueado;

b) aluguel de equipamentos ou ponto comercial;

c) taxa de publicidade ou semelhante;

d) seguro mínimo;

X - relação completa de todos os franqueados, subfranqueados ou subfranqueadores da rede e, também, dos que se desligaram nos últimos 24 (vinte quatro) meses, com os respectivos nomes, endereços e telefones;

XI - informações relativas à política de atuação territorial, devendo ser especificado:

a) se é garantida ao franqueado a exclusividade ou a preferência sobre determinado território de atuação e, neste caso, sob quais condições;

b) se há possibilidade de o franqueado realizar vendas ou prestar serviços fora de seu território ou realizar exportações;

c) se há e quais são as regras de concorrência territorial entre unidades próprias e franqueadas;

XII - informações claras e detalhadas quanto à obrigação do franqueado de adquirir quaisquer bens, serviços ou insumos necessários à implantação, operação ou administração de sua franquia apenas de fornecedores indicados e aprovados pelo franqueador, incluindo relação completa desses fornecedores;

XIII - indicação do que é oferecido ao franqueado pelo franqueador e em quais condições, no que se refere a:

a) suporte;

b) supervisão de rede;

c) serviços;

d) incorporação de inovações tecnológicas às franquias;

e) treinamento do franqueado e de seus funcionários, especificando duração, conteúdo e custos;

f) manuais de franquia;

g) auxílio na análise e na escolha do ponto onde será instalada a franquia; e

h) leiaute e padrões arquitetônicos das instalações do franqueado, incluindo arranjo físico de equipamentos e instrumentos, memorial descritivo, composição e croqui;

XIV - informações sobre a situação da marca franqueada e outros direitos de propriedade intelectual relacionados à franquia, cujo uso será autorizado em contrato pelo franqueador, incluindo a caracterização completa, com o número do registro ou do pedido protocolizado, com a classe e subclasse, nos órgãos competentes, e, no caso de cultivares, informações sobre a situação perante o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares (SNPC);

XV - situação do franqueado, após a expiração do contrato de franquia, em relação a:

a) know-how da tecnologia de produto, de processo ou de gestão, informações confidenciais e segredos de indústria, comércio, finanças e negócios a que venha a ter acesso em função da franquia;

b) implantação de atividade concorrente à da franquia;

XVI - modelo do contrato-padrão e, se for o caso, também do pré-contrato-padrão de franquia adotado pelo franqueador, com texto completo, inclusive dos respectivos anexos, condições e prazos de validade;

XVII - indicação da existência ou não de regras de transferência ou sucessão e, caso positivo, quais são elas;

XVIII - indicação das situações em que são aplicadas penalidades, multas ou indenizações e dos respectivos valores, estabelecidos no contrato de franquia;

XIX - informações sobre a existência de cotas mínimas de compra pelo franqueado junto ao franqueador, ou a terceiros por este designados, e sobre a possibilidade e as condições para a recusa dos produtos ou serviços exigidos pelo franqueador;

XX - indicação de existência de conselho ou associação de franqueados, com as atribuições, os poderes e os mecanismos de representação perante o franqueador, e detalhamento das competências para gestão e fiscalização da aplicação dos recursos de fundos existentes;

XXI - indicação das regras de limitação à concorrência entre o franqueador e os franqueados, e entre os franqueados, durante a vigência do contrato de franquia, e detalhamento da abrangência territorial, do prazo de vigência da restrição e das penalidades em caso de descumprimento;

XXII - especificação precisa do prazo contratual e das condições de renovação, se houver;

XXIII - local, dia e hora para recebimento da documentação proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, quando se tratar de órgão ou entidade pública.

§ 1º A Circular de Oferta de Franquia deverá ser entregue ao candidato a franqueado, no mínimo, 10 (dez) dias antes da assinatura do contrato ou pré-contrato de franquia ou, ainda, do pagamento de qualquer tipo de taxa pelo franqueado ao franqueador ou a empresa ou a pessoa ligada a este, salvo no caso de licitação ou pré-qualificação promovida por órgão ou entidade pública, caso em que a Circular de Oferta de Franquia será divulgada logo no início do processo de seleção.

§ 2º Na hipótese de não cumprimento do disposto no § 1º, o franqueado poderá arguir anulabilidade ou nulidade, conforme o caso, e exigir a devolução de todas e quaisquer quantias já pagas ao franqueador, ou a terceiros por este indicados, a título de filiação ou de royalties, corrigidas monetariamente.

Em suma, essa circular de oferta de franquia traz os dados de como funcionará a franquia, os dados essenciais da operação. Deverá constar **obrigatoriamente** na circular de oferta da franquia, entre outros detalhes, os balanços e demonstrações financeiras da empresa franqueadora relativos aos dois últimos exercícios.

Segundo o STJ, **é válida a notificação por e-mail enviada ao franqueador para o exercício do direito de preferência previsto em contrato de franquia**, no caso em que, não tendo o contrato previsto forma específica para a notificação e sendo o correio eletrônico meio usual de comunicação entre franqueador e franqueado, houver ciência inequívoca do franqueador quanto à data do envio e do recebimento da mensagem, segurança quanto à legitimidade do remetente para tratar do assunto e, quanto ao conteúdo, respeito aos requisitos estabelecidos na cláusula contratual.

É possível a previsão de cláusula compromissória em contratos de franquia?

O contrato de franquia é uma espécie de contrato de adesão. Assim, só será válida cláusula compromissória em contrato de franquia **se o aderente** (franqueado):

- **tomar a iniciativa de instituir a arbitragem;** ou
- **concordar, expressamente, com a sua instituição, por escrito, em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula.**



Por fim, destaque-se o seguinte:

O art. 6.º da Lei 8.955/1994, por sua vez, estabelece que “o contrato de franquia deve ser sempre escrito e assinado na presença de 2 (duas) testemunhas e terá validade independentemente de ser levado a registro perante cartório ou órgão público”. Não obstante, o art. 211 da LPI determina que os contratos de franquia devem ser registrados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), nos seguintes termos: “o INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros”. Como conjugar, então, as duas regras? Ora, uma trata da validade do contrato, e a outra da sua eficácia perante terceiros. Assim, a ausência de registro da franquia no INPI não invalida o contrato, mas nesse caso ele só produzirá efeitos perante as partes contratantes – franqueador e franqueado –, não sendo oponível perante terceiros.

7.6. Contrato de distribuição

O contrato de distribuição poderá ser por aproximação ou por intermediação.

O contrato de distribuição comercial, classificado como pacto de colaboração e que transborda da mera intermediação, **não implica na hipossuficiência do distribuidor em relação ao fabricante.**

Todavia, nesse contrato, **que se celebra por adesão, o fornecedor realiza controle e padronização da atividade desenvolvida pelo distribuidor.**

7.6.1 Contrato de distribuição por aproximação

O contrato de distribuição por aproximação ocorre quando um dos empresários-distribuidores se obriga **em caráter não eventual**, ou seja, de forma habitual, a realizar certos negócios por conta de outro empresário, chamado de proponente.

Ele vai realizar essas negociações numa zona determinada, tendo a posse da mercadoria que será vendida naquela zona. Lembre-se que a **mercadoria não será do empresário-distribuidor.**

Caso **não tenha as mercadorias em sua posse**, esse contrato não será de distribuição, sendo denominado de **agência**.

A distribuição por aproximação sem a posse da mercadoria, que é denominado **agência**, são contratos típicos, estando sujeitos às mesmas regras.

São **cláusulas implícitas** do contrato de distribuição-aproximação:

- **exclusividade da distribuição:** o distribuidor ou agente não podem trabalhar para outro proponente na zona de atuação. O sujeito recebe a mercadoria, mas quem celebra o contrato é o proponente;
- **exclusividade de zona:** o proponente deverá se abster de realizar negócios naquela zona, a não ser que eles se deem por aproximação do distribuidor. Caso não tenha a posse, o distribuidor será denominado de agente;
- **remuneração por percentual dos negócios realizados:** o nome dessa remuneração é comissão.

Os contratos de distribuição por aproximação poderão ser celebrados **com ou sem prazo**. Sendo de **prazo determinado, após transcorrido o prazo, as obrigações cessam.**

Se o contrato for de **prazo indeterminado**, o vínculo contratual **se desfaz após 90 dias da notificação de qualquer um dos empresários** para fazer a cessação contratual.

Na resolução dos contratos por prazo indeterminado, pode acontecer de o distribuidor ou agente terem feito um **alto investimento**, e o prazo que eles exerceram suas atividades não



tenha sido suficiente para recuperar o investimento realizado. Neste caso, **o proponente será obrigado a indenizar em razão dessa cessação precoce do contrato.**

7.6.2 Contrato de distribuição por intermediação

O contrato de distribuição por intermediação **é atípico**, pois não há regulamentação legal desse contrato.

Esse contrato é celebrado entre distribuidoras de combustível e os postos de abastecimento de suas bandeiras. Também é visto nos contratos entre as fábricas de cerveja e os atacadistas de bebidas.

Nesse caso, o posto de combustível e o atacadista **compram esse produto para revender.**

Por ser atípico, as obrigações assumidas pelo distribuidor **serão reguladas por aquilo contido no respectivo contrato.**



CAPÍTULO 17 — CONTRATOS BANCÁRIOS

1. Introdução

Para que haja contrato bancário, por óbvio, deve haver um banco.

Atividade bancária pode ser conceituada como uma **atividade destinada à coleta, intermediação e aplicação de recursos financeiros, sejam eles próprios, sejam eles de terceiros.**

São operações econômicas ligada à concessão de crédito, circulação e administração dos créditos.

As instituições financeiras adotam **necessariamente a forma de sociedade anônima.**

2. Requisitos dos contratos bancários

Para que se fale em contrato bancário, tais requisitos deverão ser cumpridos:

- **uma das partes deverá ser um banco;**
- **o contrato deve se referir ao exercício da atividade bancária:** coleta, intermediação e aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros. Quando o banco compra uma sede, não se trata de contrato bancário, assim como quando contrata uma empresa de engenharia. Apesar de figurar num dos polos, não há por objeto coleta, circulação ou aplicação de recursos financeiros.

3. Atividades bancárias

As atividades bancárias poderão ser **típicas** ou **atípicas**:

- **atividades bancárias típicas:** são as atividades relacionadas ao crédito. As operações típicas se subdividem em:
 - **operações típicas passivas:** quando o banco ocupa a posição de devedor;
 - **operações típicas ativas:** banco ocupa a posição de credor;
- **atividades bancárias atípicas:** relacionada a serviços acessórios ao cliente. Ex.: no banco é feita a custódia de valores e locação de cofres, sendo contratos atípicos.

Spread bancário

Spread bancário é a diferença entre o que os bancos pagam na captação de recursos e o que eles cobram ao conceder um empréstimo para uma pessoa física ou jurídica. No valor do *spread* bancário estão embutidos também impostos como o IOF e o CPMF.

Nesse contexto, o termo inglês *spread* significa margem. Essa margem financeira cobrada pelo banco e outras instituições financeiras, é um valor que varia de banco para banco e acresce à habitual taxa de juros cobrada pelo empréstimo.

Para os bancos, **quanto maior o *spread*, maior é o lucro nas suas operações.** O *spread* bancário brasileiro é um dos mais altos do mundo, o que gera muitas críticas, uma vez que é um dinheiro que poderia estar fazendo girar a economia e não ser totalmente utilizado pelos bancos.

3.1. Operações passivas

Na operação passiva, o banco é o devedor. Terá por função a captação de recursos no mercado, os quais irão ingressar no banco, passando ele a ser o devedor.

São contratos desta natureza:

- **contrato de depósito bancário;**
- **contrato de conta corrente;**



- **contrato de aplicação financeira.**

Em todos eles o banco receberá o dinheiro do sujeito e, na obrigação principal, será o devedor.

3.1.1. Contrato de depósito bancário

O depósito bancário é **contrato real**, isto é, somente se aperfeiçoa com a entrega do dinheiro à instituição financeira depositária. É o caso em que uma pessoa busca o banco para depositar valores. O banco se obriga a restituir estes valores quando forem solicitados. A instituição financeira passará, neste momento, a titularizar a propriedade dos valores depositados. Aqui está a especificidade do contrato de depósito. Isso porque o **depositário passará a ser o titular desse valor**.

Existem três modalidades de contratos de depósito bancário:

- **depósito à vista:** o banco se obriga a restituir esse valor depositado quando o depositante exigir a devolução;
- **depósito à pré-aviso:** ordenada a restituição ao depositante, o banco providenciará essa devolução ao depositante dentro de um prazo ajustado;
- **depósito à prazo fixo:** é o contrato de depósito em que fica estipulado que o depositante não pode solicitar a restituição do recurso antes de determinada data.

São **características** do depósito bancário:

- **contrato real:** só se aperfeiçoa a partir do momento em que se entrega o dinheiro ao banco;
- **prazo indeterminado:** geralmente, é celebrado por prazo indeterminado;
- **resilição unilateral por qualquer das partes:** cada uma das partes poderá extinguir o contrato;
- **extinção por falta de movimentação pelo prazo de 30 anos:** é possível que o contrato de depósito bancário se extinga por falta de movimentação por prazo de 30 anos, conforme a Lei nº 370/37. Se ninguém mexer na conta pelo período, a conta será fechada e perderá o dinheiro em favor do Tesouro Nacional.

3.1.2. Contrato de conta corrente

Na conta corrente, o banco recebe o valor do sujeito que o entrega.

O valor entregue pelo correntista, ou por terceiro em favor do correntista, é recebido pelo banco, mas ele também procede aos pagamentos por ordem do correntista, se valendo daqueles recursos que foram depositados.

Então, percebe-se que no contrato de conta corrente há uma **função econômica mais ampla**, visto que o banco presta o serviço de **administração de caixa ao correntista**. Ex.: pagamentos, cheques, movimentações da conta, etc.

O contrato de conta corrente prevê taxas, em virtude da administração da conta.

É característica marcante do contrato de conta corrente ser um **contrato consensual**. Isto é, o contrato **se aperfeiçoa com o acordo de vontades**, antes mesmo de o correntista entregar qualquer dinheiro ao banco.

3.1.3. Contrato de aplicação financeira

Aplicação financeira é o contrato pelo qual o **depositante autoriza o banco a empregar determinado valor em um investimento**.

O banco adquire este valor e aplica em ações, debêntures, títulos da dívida pública, etc.



3.2. Operações ativas

Operações ativas são aquelas em que o banco assume a posição de credores, sendo os principais contratos:

- mútuo bancário;
- desconto bancário;
- abertura de crédito bancário;
- crédito documentário.

Com relação à taxa de juros, já está pacificado pela **súmula 541** que a previsão no contrato bancário de **taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada**. Para tanto, a **súmula 530** estabelece que, nos contratos bancários, **na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada** - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, **aplica-se a taxa média de mercado**, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, **salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor**.

Segundo a súmula 379, nos contratos bancários não regidos por legislação específica, **os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês**.

3.2.1. Contrato de mútuo bancário

O mútuo é o empréstimo. Mútuo bancário é o empréstimo feito pelo banco. Isto é, é o contrato pelo qual o banco empresta ao cliente certa quantia em dinheiro.

São características do mútuo:

- **contrato real**: o contrato se aperfeiçoa com a entrega do dinheiro pelo banco ao cliente;
- **contrato unilateral**: quando o contrato nasce, o banco já fez a sua obrigação no contrato, restando apenas a obrigação do cliente.

O mutuário após receber o dinheiro tem as seguintes **obrigações**: pagar o valor do empréstimo monetariamente corrigido, juros, encargos, eventuais comissões e taxas. Ademais, **terá a obrigação de amortizar os valores nos prazos estabelecidos contratualmente**.

O **banco mutuante não assume qualquer obrigação perante o cliente** (mutuário), visto que somente uma das partes é devedor, motivo pelo qual é contrato unilateral. Em outras palavras, o contrato nasce com a entrega do dinheiro.

Com relação à **forma do contrato** de mútuo bancário, **exige somente instrumento público se houver garantia real hipotecária**. Do contrário, não haverá instrumento público.

Fábio Ulhoa ressalta a **impossibilidade de o mutuário exigir do mutuante o recebimento da devolução do valor emprestado antes do prazo fixado**. Isso porque o interesse do mutuante é não receber antes do prazo, visto que deseja receber no prazo contratado, pois receberá juros, encargos, etc. Em outras palavras, **só é possível essa devolução antecipada com a concordância do mutante**.

Isso, do ponto de vista do direito comercial.

Se a **relação é regida pelo CDC**, então é **possível a devolução antecipada**, pois o código de defesa do consumidor consagra que se o mutuário for consumidor terá direito ao pagamento antecipado. Neste caso, terá a **redução proporcional dos juros e demais encargos**.

O que é financiamento?

Financiamento é uma espécie de mútuo bancário, em que o **banco empresta ao mutuário valor para que o empregue com determinada finalidade**.

Segundo a súmula 382 do STJ, **a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade**.

O STJ entendeu que a partir de 30 de abril de 2008 **não é mais possível tarifa de emissão de carnê pelo banco de seus clientes**.



Ademais, vale lembrar que o STJ editou a **súmula 30**, estabelecendo que **a comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis**.

3.2.2. Contrato de desconto bancário

No desconto bancário, o banco antecipa um crédito que o cliente irá receber, descontando uma parte do valor para que seja remunerado.

O contrato de desconto é aquele em que o banco (descontante) irá descontar do cliente (descontário) o valor do crédito deste contra uma terceira pessoa. Este crédito ainda não está vencido, motivo pelo qual o banco antecipa o valor ao cliente e recebe o crédito em cessão.

Portanto, há transferência da propriedade daquele crédito do cliente. O banco, ao pagar, deduzirá despesas, juros, e aqui está o lucro do banco.

O descontário cede ao banco o seu crédito. Quando se tratar de **título de crédito**, essa transferência será feita **por endosso**.

Esse contrato de desconto é um **contrato real**, se aperfeiçoando com a transferência do crédito ao banco. Não basta o acordo de vontades, é preciso a transferência do crédito ao descontador.

Por vezes, o banco descontador desconta ele próprio, com outra instituição financeira, o crédito que ele descontou do cliente. Isto é chamado de **redesconto**, porém só quem pode fazer redesconto é o Banco Central.

Veja, no caso do redesconto, o Banco Itaú desconta R\$ 100.000, pagando ao cliente R\$ 95.000. Com estes R\$ 100.000, o Itaú vai até o Banco Central e faz um redesconto. Com isso, o Banco Central paga ao Itaú R\$ 97.000 e fica com os R\$ 100.000 para receber daqui a 30 dias.

3.2.3. Contrato de abertura de crédito

O contrato de abertura de crédito ocorre quando o **banco coloca uma certa quantia em dinheiro à disposição do cliente, caso queira utilizar**. Neste caso, somente pagará juros e demais encargos se o cliente utilizar e quando utilizar.

Caso seja utilizado, o cliente entrará no cheque especial. O cheque especial é a abertura de crédito.

São características do contrato de abertura de crédito:

- **contrato bilateral;**
- **contrato consensual:** já está formalizado com o acordo de vontades, pois o sujeito poderá usar ou não, visto que o crédito está disponível. Não se trata de contrato real.

3.2.4. Contrato de crédito documentário

O crédito documentário não é muito utilizado, mas é importante para o comércio internacional.

Nesse caso, **haverá uma obrigação devida pelo banco, que será o emissor, perante o seu cliente, que é quem dá a ordem ao banco, para que ele proceda a um pagamento segundo a ordem de um cliente em favor de um terceiro**. Este terceiro é denominado de beneficiário.

O banco pagará ao terceiro beneficiário **quando ele apresentar documentos**. Tais documentos estão relacionados com o negócio que foi realizado entre o beneficiário e o cliente do banco. Ex.: importador de determinada mercadoria contrata com a instituição financeira para que ela pague em favor do exportador determinado valor (R\$ 100.000) à vista, desde que apresente o documento que comprove a entrega da mercadoria.



A vantagem é que para o comprador-importador o negócio será à vista em relação ao exportador, mas em relação ao comprador-importador, o negócio será a prazo, por meio de um financiamento. O banco será remunerado pelos juros.

Firmado o contrato com o ordenante, caberá ao banco emitir ao beneficiário essa carta de crédito. Após o beneficiário expedir as mercadorias vendidas, ele irá com a carta e com os documentos de que ele realmente entregou a mercadoria, promovendo o banco o pagamento.

Por isso o crédito é documentário.

4. Contratos bancários impróprios

A expressão contratos bancários impróprios é utilizada por Fábio Ulhoa Coelho, pois existem divergências doutrinárias se estes contratos seriam contratos bancários ou não.

São exemplos de contratos bancários impróprios:

- alienação fiduciária em garantia;
- faturização;
- arrendamento mercantil;
- cartão de crédito.

4.1. Alienação fiduciária em garantia

Na alienação fiduciária, uma das partes (fiduciante) é proprietário de um bem, alienando este bem em confiança a outra parte (fiduciário).

Este fiduciário se obriga a devolver ao fiduciante aquela propriedade (propriedade resolúvel) nas hipóteses delineadas no contrato.

A alienação fiduciária é sempre um contrato que instrumentaliza um contrato principal, uma finalidade maior. Para a validade de um contrato de alienação fiduciária em garantia é **desnecessário o registro do contrato em cartório**.

Por exemplo, alienação fiduciária em garantia é um contrato de mútuo, em que o fiduciante (mutuário-devedor) transferirá ao fiduciário (mutante-credor) a propriedade do bem. O credor fiduciário receberá a propriedade desse bem.

Caso o fiduciante não pague, irá se aperfeiçoar a propriedade em favor do fiduciário-credor. Há aqui, temporariamente, a posse indireta do bem alienado. Enquanto **o fiduciante-mutuário-devedor terá a posse direta, funcionando como depositário**.

Ao pagar a obrigação ao fiduciário (mutuante-credor), incidirá a hipótese do contrato, e portanto resolverá o domínio em favor daquele que era o devedor (mutuário-fiduciante), **passando a ter a propriedade plena do bem**.

Segundo o STJ, a **determinação para que o protesto seja feito no local indicado pelo título como praça de pagamento** está prevista no art. 28, parágrafo único, do Decreto 2.044/1908. **Também pode ser admitido que o protesto ocorra no domicílio do devedor** porque isso se mostra mais vantajoso para ele, de forma que não poderá invocar qualquer nulidade no ato.

O contrato de alienação fiduciária pode ter por objeto bem móvel (fungível ou infungível) ou bem imóvel. Segundo a súmula 28 do STJ, **o contrato de alienação fiduciária em garantia pode ter por objeto bem que já integrava o patrimônio do devedor**.

Caso **não haja o pagamento**, o credor (fiduciário) **terá a plena propriedade do bem**.

Cabe ressaltar que **a teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária em garantia de bem móvel**. Isso porque, uma vez em mora e realizada a busca e apreensão do bem, **o devedor se quiser ter o bem de volta deverá pagar a integralidade da dívida**, o que inclui as parcelas vencidas e não vencidas.

A alienação de bem móvel infungível ou de bem imóvel **não é negócio exclusivo de instituição financeira**. Esta é a razão pela qual a doutrina diverge se é contrato bancário.



Todavia, a alienação fiduciária em garantia de **bem móvel fungível** é considerado efetivamente um **contrato bancário**.

Segundo o STJ, é possível a constituição de alienação fiduciária de bem imóvel para garantia de operação de crédito **não vinculada ao Sistema Financeiro Imobiliário (SFI)**. O entendimento de que o instituto da alienação fiduciária de bens imóveis somente poderia ser utilizado em crédito destinado a aquisição, edificações ou reformas do imóvel oferecido em garantia – fundado no argumento de que a finalidade da Lei n. 9.514/1997 é proteger o sistema imobiliário e o de habitação como um todo, de modo que a constituição de garantia fiduciária sobre bem imóvel deve estar em sintonia com o objetivo da lei, consubstanciado no incentivo ao financiamento imobiliário – não se sustenta, pois esse posicionamento não encontra respaldo nos arts. 22, § 1º da Lei n. 9.514/1997 e 51 da Lei n. 10.931/2004.

Vale ressaltar que, consoante a súmula 245, **a notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito**.

4.2. Faturização (*Factoring*)

Factoring é uma empresa de faturização, sendo também chamada de fomento comercial.

É o contrato pelo qual uma sociedade (faturizadora) se obriga a cobrar os devedores de uma outra sociedade (faturizada), prestando serviços de administração do crédito do sujeito.

A faturização faz com que a faturizadora assuma algumas obrigações perante a faturizada. Por exemplo, é ela que irá gerir os créditos do faturizado, procedendo a controles dos vencimentos, protestos, aviso para pagamento, cobrança de devedores, etc.

Ademais, pelo contrato de faturização, a faturizadora assumirá os riscos do inadimplemento dos devedores do faturizado, garantindo o pagamento das faturas que foram objeto de faturização.

Cabe salientar que a **faturizadora tem direito de regresso contra a faturizada** que, por contrato de factoring vinculado a nota promissória, **tenha cedido duplicatas sem causa subjacente**.

São modalidades de factoring (faturização):

- **maturity factoring**: ocorre quando a faturizadora **só administra** das faturas do faturizado, e no dia do vencimento paga à faturizada. A faturizadora paga as faturas ao faturizado apenas no vencimento;
- **conventional factoring**: é a faturizadora que garante o pagamento das faturas, antecipando o pagamento ao faturizado. Nesse caso, cobrará juros, os quais são muito altos.

A modalidade *conventional*, que é típica, compreende três elementos:

- administração do crédito;
- seguro;
- financiamento.

No plano doutrinário, a natureza do *conventional factoring* é de caráter indiscutivelmente bancário.

No plano regulamentar, **o Banco Central não veda a atividade de faturização por não exercentes da atividade bancária**. Por conta disso, não se considera *factoring* uma espécie de contrato bancário em qualquer de suas modalidades, visto que não há vedação de que instituição não bancária exerça tal atividade. Daí vem a discussão doutrinária se seria ou não contrato bancário.

Segundo o STJ, **o sacado pode opor à faturizadora a qual pretende lhe cobrar duplicata recebida em operação de factoring exceções pessoais que seriam passíveis de contraposição ao sacador, ainda que o sacado tenha eventualmente aceitado o título de crédito**. Na operação de *factoring*, em que há envolvimento mais profundo entre faturizada e faturizadora, **não se**



opera um simples endosso, mas a negociação de um crédito cuja origem é objeto de análise pela faturizadora.

Nesse contexto, **a faturizadora não pode ser equiparada a um terceiro de boa-fé a quem o título pudesse ser transferido por endosso**. De fato, na operação de *factoring*, há verdadeira cessão de crédito, e não mero endosso, ficando autorizada a discussão da *causa debendi*, na linha do que determina o art. 294 do CC, segundo o qual: “o devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente”.

Ademais, o STJ já decidiu que **é desnecessária a notificação de emitente de cheque com cláusula “à ordem”**, para que o faturizador que tenha recebido a cártula por meio de endosso **possa cobrar o crédito decorrente de operação de *factoring***.

Ainda sobre o tema, o STJ entendeu recentemente que empresas em processo de recuperação judicial podem celebrar contratos de *factoring* sem prévia autorização judicial (REsp 1.783.068-SP, julgado em 05/02/2019, DJe 08/02/2019).

4.3. Arrendamento mercantil

Arrendar é locar. O arrendamento mercantil é a locação caracterizada pela faculdade dada ao locatário de, ao término da locação, decidir pela compra ou não do bem locado.

O arrendamento mercantil é um contrato atípico. Não havendo regulamentação legal, as partes acordarão da forma que melhor entender. No entanto, **autoriza-se ao locatário, ao final do prazo de locação, decidir se quer adquirir o bem locado, a fim de amortizar, no preço da aquisição, os valores pagos a título de aluguel**.

A lei definiu o arrendamento mercantil como um negócio realizado entre uma pessoa jurídica (arrendadora) e uma pessoa física ou pessoa jurídica (arrendatária), cujo objeto é a locação de bens adquiridos pela arrendadora, de acordo com as informações e especificações fornecidas pela arrendatária e para uso da arrendatária.

O direito tributário só considera arrendamento mercantil o contrato que atenda a esse conceito legal.

Para o direito tributário se não houver essa especificação dada pela arrendatária, não haveria um arrendamento mercantil. O que teria seria uma compra e venda a prazo, motivo pelo qual seria tributado como compra e venda.

Por isso, para fins fiscais, o denominado ***self-leasing***, em que partes coligadas ou interdependentes farão a ideia do arrendamento, haveria compra e venda a prazo.

No ***leasing***, em que o arrendador é o próprio fabricante do produto, não haveria arrendamento mercantil, visto que se trataria de uma compra e venda a prazo.

Com relação ao denominado ***leasing back***, este é **considerado arrendamento mercantil**. O *leasing back* consiste no *leasing* em que a arrendadora adquire o bem da arrendatária, arrendando este bem à arrendatária. No *leasing back*, quem especificou o bem foi a arrendatária, fazendo com que a arrendadora comprou o bem sob a especificidade da arrendatária, arrendando a ela o bem, fazendo com que ela (arrendatária) decida se ao final adquirirá o bem ou não. Nesse caso, haverá arrendamento mercantil para fins tributários.

Pode ser objeto de arrendamento mercantil tanto o **bem móvel** como **bem imóvel**.

Em contrato de arrendamento mercantil de veículo automotor, **a purgação da mora realizada nos termos do art. 401, I do CC deixou de ser possível somente a partir de 14/11/2014**, data de vigência da Lei nº 13.043/2014, que incluiu o § 15º do art. 3º do Decreto-Lei 911/1969.

A atividade de *leasing* está disciplinada pela Resolução 2309/96. O importante é que ela distingue duas modalidades de contratos:



- **leasing financeiro:** caracteriza-se pela inexistência de resíduo específico ao final do contrato. Ao final do contrato, há a soma das prestações pagas ao final da locação, suficientes para recuperar o custo e o retorno do investimento pela arrendadora;
- **leasing operacional:** a soma das prestações de locação não pode ultrapassar o limite de 75% do custo do investimento. Portanto, ao final do contrato, o resíduo que vai ser pago tende a ser um resíduo expressivo.

Segundo a resolução seria possível antecipar o pagamento desse resíduo. Não somente, caso, ao final, a arrendatária decidisse por não adquirir o bem, caberia a arrendadora restituir esse valor antecipado pela arrendatária. Esse **valor residual garantido** é considerado por parte da jurisprudência como uma distorção do leasing, pois, em verdade, haveria uma compra e venda a prazo, e não o leasing.

No caso de **reintegração de posse** em arrendamento mercantil financeiro, **quando a soma da importância antecipada a título de valor residual garantido (VRG) com o valor da venda do bem ultrapassar o total do VRG previsto contratualmente, o arrendatário terá direito de receber a respectiva diferença**, cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto de outras despesas ou encargos pactuados.

O legislador não vinculou o contrato, ou a celebração do contrato, à instituição financeira. Isso quer dizer que há aqui a discussão se seria contrato bancário ou não. Não precisa que a arrendadora seja instituição financeira.

O Conselho Monetário Nacional entendeu que as operações de arrendamento mercantil somente podem ser exploradas por sociedades anônimas, dedicadas exclusivamente a essas atividades, ou por instituições financeiras especificamente autorizadas.

Em outras palavras, para se falar em arrendamento mercantil, é necessário que seja ou instituição financeira ou sociedade anônima constituída especificamente para esse fim.

CAPÍTULO 18 — CONTRATOS INTELECTUAIS

1. Introdução

Os contratos intelectuais são contratos empresariais relacionados à propriedade industrial: cessão de patente ou de registro, licença de uso de patente ou de invenção, cessão de uso de tecnologia, etc.

São contratos empresariais relacionados à propriedade industrial ou ao direito autoral.

2. Cessão de direito industrial

A cessão de direito industrial pode ter por objeto:

- **patente:** essa patente pode ser de invenção ou de modelo de utilidade;
- **registro industrial:** poderá ser de desenho industrial ou de marca.

2.1. Cessão da patente

No primeiro caso, o titular da patente (cedente) transfere os direitos dessa ao contratante (cessionário), **podendo ser total ou parcial**. Isto é, há a transferência da titularidade.

A cessão pode dizer respeito a uma patente já concedida pelo INPI, ou que apenas tenha sido solicitada.

Sendo a **cessão total**, compreenderá **todos os direitos titularizados pelo cedente**. Sendo a **cessão parcial**, receberá o cessionário **diferentes limitações**, dentre as quais estão as seguintes limitações:

- **limitação quanto ao objeto:** transfere alguns dos direitos industriais, mas outros não;
- **limitação quanto a área de atuação do cessionário:** o cessionário terá direito a utilizar a patente neste país, mas não noutro país, por exemplo.

2.2. Cessão do registro industrial

Trata-se de um contrato pelo qual o proprietário de um desenho industrial ou de marca transfere a outro (cessionário) total ou parcialmente os direitos de exploração da marca ou desenho industrial.

Há uma transferência, visto que há cessão.

A cessão de registro industrial da marca deve compreender todos os registros concedidos ou solicitados pelo cedente de marcas iguais ou semelhantes, sob pena de se considerar cancelados os outros pedidos.

3. Licença de uso de direito industrial

Na licença, o titular de direito industrial **pode** licenciar **o uso da patente ou do registro por terceiros**.

Veja, o titular licencia o uso, mas não transfere a titularidade do direito industrial que ele tem. Esse direito continua no patrimônio do licenciador.

A licença de uso é um **contrato intuito personae**. Se Pedro licencia João, este não poderá licenciar Carlos, salvo se Pedro autorizar. Dessa característica surge a possibilidade de resolução do contrato em caso da cessão do direito industrial pelo licenciado sem autorização, ou seja, em razão de o licenciado ter feito uma sublicença da licença que recebeu.



Porém, também é **causa de resolução do contrato se o licenciador faz a cessão da patente**. Isso porque o contrato era *intuitu personae*, salvo quando do instrumento de licença conste cláusula de vigência perante o cessionário, e este instrumento esteja registrado no INPI.

O licenciamento de uso poderá ser pactuado com ou sem exclusividade. O prazo não poderá exceder o prazo do próprio direito licenciado.

A **licença para uso da patente** é o contrato pelo qual o titular autoriza a exploração econômica dessa patente pelo contratante-licenciado.

A **licença de registro industrial** é o contrato em que uma parte autoriza a exploração do desenho industrial ou da marca por outro contratante.

É comum constar desse tipo de contrato uma cláusula que permita ao concedente exercer o efetivo controle sobre as especificações, natureza, qualidade do produtos, ou dos serviços identificados, no caso de licença de uso de marca.

Segundo o STJ, **pode ser causa de resolução da licença se o licenciado da marca não adere ao novo padrão estabelecido pelo licenciador**. Ex.: licença é para a marca C e D. Samer é titular da marca. Licenciado inicia vendendo para classe C e D. Mais tarde, o licenciador resolveu se tornar vendedor para marca A e B. Neste caso, foi passada essa orientação aos licenciados. O sujeito licenciado não deixou de vender para classe C e D. Diante disso, poderá haver a resolução.

3.1. Merchandising

Há uma modalidade específica de licença de uso de registro industrial de marca, sendo denominada **merchandising**.

Aqui, o **licenciador autoriza o licenciado a usar determinada marca em produtos ou serviços que o licenciador não oferece**. Ex.: a Coca-Cola licenciou o uso da marca nas roupas de vestuário.

4. Transferência de tecnologia

Tecnologia é um domínio industrial, conhecimento, que seja utilizável na indústria, apto a produzir bens e comodidades industriais.

São diferentes as modalidades de tecnologia:

- **fornecimento de tecnologia:** ocorre quando há o fornecimento de tecnologia;
- **prestação de serviços de assistência técnica e científica**

A ideia do contrato de transferência de tecnologia é simples: é capacitar o cessionário para o emprego daquela tecnologia.

A tecnologia tem uma finalidade. Ex.: produto que o indivíduo gasta em 10 horas de trabalho para fazer em 2 horas.

5. Comercialização de software

Software é programa de computador. Trata-se de um **conjunto de instruções indispensáveis para o tratamento de informações**.

O que interessa aqui são os direitos de quem criou o programa.

Os direitos de quem titularizou o software são direitos autorais, e não propriedade industrial. A diferença são as consequências experimentadas quando se tratar de direito autoral.

O direito autoral limita a forma de tutela, visto que a tutela **não impede uma obra semelhante**, limitando-se àquilo que foi exatamente criado pelo titular do direito autoral. O que não pode é o plágio.



A segunda consequência é de que, como é direito autoral, a consequência decorre da própria apresentação da obra ao público, **sendo desnecessário o registro para proteção do direito autoral**, diferentemente da marca, que precisa do registro.

A proteção decorre da própria exibição daquele ao público.

O titular do software se limita a proibir a comercialização por terceiros de programas de computador com idêntica forma. Agora, parecidos não pode impedir.

Ressalta-se a **possibilidade de utilização doméstica e não comercial de um programa idêntico, criado por terceiro**, visto que o vedado é a pirataria. Em outras palavras, se o indivíduo criar um programa idêntico para usar dentro de casa não haverá problema, desde que não comercialize.

O registro no INPI, no caso do software, é possível, mas não tem caráter constitutivo do direito autoral, o qual nasce da apresentação ao público.

Interessante é o **prazo de direito autoral sobre programas de computador (software)**, sendo esse de **50 anos**, a contar do dia 1º de janeiro seguinte à publicação ou criação do produto.



CAPÍTULO 19 — CONTRATOS DE SEGURO

1. Conceito

Seguro é um contrato feito entre a seguradora e um contratante (segurado), a qual exige o pagamento do prêmio, a fim de garantir o interesse legítimo do contratante ou de terceiro contra riscos predeterminados.

2. Sistema Nacional de Seguros Privados

Este sistema nacional de seguros privados é integrado por:

- **Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP):** trata-se de um órgão da administração direta federal. A sua função é traçar a política geral dos seguros privados, **normatizando as operações securitárias e aplica as sanções legais em caso de descumprimento dessas normas;**
- **Superintendência de Seguros Privados (SUSEP):** é uma autarquia federal, objetivando a promoção da política definida pelo CNSP. Além disso, a SUSEP faz a fiscalização das seguradoras;
- **IRB Brasil Resseguros S.A.:** é uma sociedade anônima, mas do tipo sociedade de economia mista, da qual metade das ações são titularizadas pela União e a metade pelas seguradoras. O resseguro é contratado pela seguradora junto ao IRB-Brasil Resseguros S.A., funcionando como a empresa em que a seguradora irá contratar, garantindo seus riscos. O resseguro é o contrato por meio do qual uma seguradora garante seus riscos junto à resseguradora. Veja, o resseguro segura a seguradora;
- **Sociedades seguradoras:** as seguradoras são empresas autorizadas pelo governo federal. Apenas sociedades anônimas podem ser seguradoras, com exceção das cooperativas;
- **Corretores:** podem ser pessoas jurídicas ou pessoas físicas, tendo como atividade aproximar a seguradora ao segurado.

3. Natureza do contrato de seguro

O seguro é um contrato de **adesão, comutativo e consensual**, apesar de maiores discussões:

- **contrato de adesão:** as suas cláusulas, quase todas, são definidas pelos órgãos governamentais. Ex.: contrato de seguro não pode conter cláusula dispensando o pagamento do prêmio, nem mesmo reduzindo o prêmio, além de não conter cláusula que faculte a rescisão unilateral, etc. Isso porque está vedado. Na dúvida, interpreta-se em favor do aderente;
- **contrato comutativo:** a obrigação do segurado é pagar o prêmio. A obrigação da seguradora não é pagar, caso haja o sinistro. Isso porque **a obrigação da seguradora é garantir o interesse do segurado**. Isto é, caso aconteça algo com o segurado, ela vai pagar. Garante-se o segurado contra riscos. As empresas se desenvolvem já sabendo o quanto irão prestar na obrigação, sempre com base em pesquisas de contingências e estatísticas internas. Isto faz com que a empresa já preveja o quanto irá gastar aproximadamente, tornando o contrato comutativo;
- **contrato consensual:** a apólice ou bilhete de seguro são instrumento que provam o contrato de seguro, mas não constituem o contrato, visto que o contrato é consensual. Ele é apenas provado pela apólice e pelo bilhete.



4. Obrigação das partes

A **seguradora** tem como obrigação assegurar o interesse do segurado contra riscos indicados no contrato. Portanto, a seguradora deve se organizar empresarialmente, gerindo os recursos provenientes do pagamento de prêmio, de maneira a atender os compromissos do segurado de que ela vá garantir eventuais riscos. Ocorrido o sinistro, a seguradora deverá pagar uma quantia ao segurado ou ao beneficiário, caso não seja o segurado.

Em relação ao **segurado**, a obrigação dele é de pagar o prêmio. No entanto, também tem a obrigação de prestar informações verídicas, além de abster-se de aumentar o risco. Afora isso, é obrigação do segurado comunicar à seguradora a verificação do incidente que aumente o risco, bem como comunicar à seguradora a ocorrência tão logo ocorra o sinistro.

Entende-se que ao comunicar tão logo o sinistro, a seguradora poderá tomar alguma providência que minore o prejuízo.

5. Espécies de seguro

Basicamente, existe seguro de dano e seguro de pessoas.

5.1. Seguro de dano

Seguro de dano também é conhecido como **seguro de ramos elementares**. No seguro de dano, há por objeto interesses relacionados ao **patrimônio**.

Atente-se que os bens, valores, direitos, saúde, integridade física do segurado estão relacionados ao patrimônio.

Ex.: sujeito sofreu um acidente e não pôde trabalhar por 90 dias, receberá um seguro para que seja ressarcido daquilo que ele perdeu em razão do dano à integridade física. Veja, a lesão aqui é patrimonial.

No contrato de seguro de dano, é necessário compreender que **nesta categoria estão compreendidos todos os seguros**, com **exceção dos seguros de vida** e dos **seguros de acidente pessoais com morte**.

A **característica essencial do seguro de dano é a característica indenizatória**. A ideia é que o segurado contrate a seguradora para ser eventualmente recomposto em seu patrimônio, a fim de ter ressarcido o dano experimentado.

Portanto, **a liquidação do valor que o segurado deverá receber da seguradora não pode implicar enriquecimento do segurado**, uma vez que a ideia é apenas a **restauração do status anterior**.

Por isso, **não é lícito ao segurado contratar pelo valor integral mais de um seguro para ramo elementar**. Não há **sobresseguro**, pois é ilícito. Não há como segurar um carro por uma seguradora integralmente e por outra ao mesmo tempo.

Também **não cabe o seguro em importância superior ao bem seguro**. Ex.: casa que vale R\$ 500 mil ser segurada por R\$ 1 milhão não é lícito. Do contrário, estar-se-ia instigando a ilicitude.

5.2. Seguro de pessoas

O seguro de pessoas **não tem natureza indenizatória**.

O pagamento é devido ao beneficiário em decorrência do sinistro, mas não tem natureza indenizatória, pois **a vida não tem valor expresso em moeda**.



O devido pela seguradora, ao se verificar a morte do segurado antes de certo termo ou a sua sobrevivência após certo termo, ou acidente pessoal com morte, **não tem o objetivo de ressarcir o beneficiário daquele dano sofrido, ainda que seja o segurado.**

Por essa razão, o valor devido não é denominado de indenização e sim denominado de **capital**. Pelo mesmo motivo, **não é vedado o sobressseguro no seguro de pessoas**. Isso porque é possível fazer 10 seguros de vida, sem que haja qualquer ilicitude, pois não se trata de indenização.

Ao contratar um seguro de vida, **não significa dizer que o proponente necessariamente será o beneficiário daquela prestação**. Se o proponente não tiver dito quem seria o beneficiário e ele venha a morrer, quem receberá **o capital será metade do cônjuge**, caso não esteja separado, **e a outra metade será destinada aos herdeiros.**

O recebimento pelo beneficiário do capital devido, quando o segurado falece, **não tem natureza de sucessão:**

- **não incidirá ITCMD:** não se trata de sucessão;
- **eventual dívida do falecido não será passível de ser descontada do capital:** não se trata de sucessão.

O suicídio é causa de exclusão do recebimento do valor do capital?

Depende. Se o suicídio não é premeditado, não será excluído o capital destinado ao beneficiário (súmula 61 do STJ). **Considera-se que o suicídio cometido após 2 anos da vigência inicial do contrato de seguro não é premeditado.** Isto é, se ocorrido nos 2 primeiros anos de contrato será considerado premeditado, admitindo-se prova em contrário.

Ademais, é nula a cláusula contratual que exclui o pagamento do capital por suicídio do segurado.

5.3. Seguro-saúde

Há duas modalidades de plano privado assistência à saúde:

- **contrato de plano de assistência à saúde:** prestada diretamente ou por terceiros (médicos cadastrados)
- **contrato de seguro saúde:** a operadora neste caso não presta o serviço, mas ela é uma seguradora, oferecendo garantias contra riscos associados à saúde.

O seguro saúde só pode ser oferecido por seguradoras especializadas neste tipo de contrato. **Deve ser necessariamente uma sociedade anônima, e sujeita à ANS** (Agência Nacional de Saúde).

6. Capitalização

Capitalização é o contrato em que uma sociedade anônima, que está autorizada pelo governo federal, compromete-se, por meio de contribuições periódicas que o outro contratante manda a ela, a pagar determinada importância ao final do prazo determinado.

Normalmente, firma-se uma cláusula contratual com a previsão de prêmios, ou mesmo pela possibilidade de antecipação do capital.



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ASCARELLI, Tullio. “Origem do direito comercial”. Tradução de Fábio Konder Comparato. In: Revista de Direito Mercantil, Econômico, Industrial e Financeiro, nº 103, julho-setembro de 1996.
- ASQUINI, Alberto. “Perfis da empresa”. Tradução de Fábio Konder Comparato. In: Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, nº 104, outubro dezembro de 1996.
- BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual, 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.
- BARRETO FILHO, Oscar. “A dignidade do direito mercantil”. In: Revista de Direito Mercantil, Econômico, Industrial e Financeiro, nº 11, 1973
- COELHO, Fábio Ulhoa, **Curso de direito comercial**. V. I, 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003.
- COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003.
- CRUZ, André Santa. **Direito Empresarial**. 9ª Edição. São Paulo: Método, 2019.
- CRUZ, André Santa. **Direito Empresarial Esquematizado**. 4ª Edição. São Paulo: Método, 2014.
- FÉRES, Marcelo Andrade. “Empresa e empresário: do código civil italiano ao novo código civil brasileiro”. In: VIANA, Frederico Rodrigues (coord.). Direito de empresa no novo código civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004.
- GALGANO, Francesco. **História do direito comercial**. Tradução de João Espírito Santo. Lisboa: Editores, 1990.
- MELLO FRANCO, Vera Helena. **Manual de direito comercial**. Vol. I. 2ª ed. São Paulo: RT, 2004.
- RAMOS, André Santa Cruz. **Leis Empresariais para concursos**. Salvador: Juspodivm, 2016.
- SOUZA, Ruy de. O direito das empresas. Atualização do direito comercial. Belo Horizonte: Bernardo Álvares, 1959.

